برنامج الدراسات العليا
قسم الشريعة والقانون
تخصص القانون العام

المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي (دراسة مقارنة)

بحث مقدم لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير
في تخصص القانون العام

إعـــداد الطالب: أحمد عيسى عبدالله

إشـــراف الأستاذ المساعد الدكتور: عبد الرحمن حسن ورطيري

مقديشو – الصومال
العام الجامعي
١٤٤١هـ –٢٠١٩م

بســـــــم الله الرحـــمـــن الـــرحـــيـــم

تقرير لجنة المناقشة وتوقيعات أعضائها

استهلال

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾ ﴾

[سورة الإسراء، الآية: ٣٣].

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ ﴾

[سورة النساء، الآية: ٣٤].

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته» قال: – وحسبت أن قد قال: «والرجل راع في مال أبيه ومسئول عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته))

أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما

إهـــــــداء

- إلى والديّ اللذين أمرني الله عز وجل أن أخفض لهما جناح الذل من الرحمة وأن أقول في حقهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
- وإلى كل من علمني علما نافعا ولو حرفا.
- وإلى كل من أنار لي الطريق إلى النجاح.
- وإلى من أرشدني إلى طريق الحق.
- وإلى طلاب العلم المجتهدين، وجميع الأمة.
- إليهم جميعا أهدي ثمرة هذا البحث.

شكر وتقدير

أتقدم بالشكر والعرفان وجوبا قبل كل شيء لمولي النعم، فالحمد لله على إتمام هذا العمل والبحث، عملا بقوله تعالى: ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾سورة إبراهيم، الآية: ٧.

وكما أتقدم بالشكر بعد الله سبحانه وتعالى عملا بقول المصطفى ﷺ : (من لا يشكر الناس لا يشكر الله)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث صحيح لغيره.

إلى:

– أسرة جامعة مقديشو إدارة وذكاترة وأساتذة، هذا الموكب العلمي، والمورد العذب الزلال الذي تشرفت بالانتساب إليه على ما قدموا لنا من مهد علمي شامخ.

– عميد برنامج الدراسات العليا الأستاذ الدكتور/ علمي طحلو جعل، على ما هذبه لنا من منهج دراسي مكثف الذي درسناه.

– مشرفي وأستاذي فضيلة الأستاذ المساعد الدكتور/ **عبد الرحمن حسن ورطيرى**، على ما قدّم لي من نصائح وتوجيهات فكرية وإرشادات علمية في حال إشرافه على هذا البحث مع ما هو فيه من شغل كبير في أداء مسئولياته الأخرى، فجزاه الله عني أصالة، وعن الطلاب نيابة خير الجزاء.

– كل من كان سببا في إكمال هذا البحث وإخراجه فنيا، سواء كان ذلك بمساعدات بشتى أنواعها من إعارة بعض مراجع احتجت إليها، أو غيرها.

والله أرجو أن يكون هذا البحث خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون نافعا لي وللمسلمين أجمعين.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

والحمد لله رب العالمين.

إقـــــــرار

أقرّ بأن هذا البحث من عملي الخاص، قمت بجمعه ودراسته، والنقل، والاقتباس من المصادر، والمراجع المتعلقة بموضوع البحث.

اسم الطالب: _____

التوقيع: _____

التاريخ: _____

مستخلص

هذا البحث هو عبارة عن دراسة وصفية تحليلية بالمسئولية الجنائية، تحت عنوان: المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي، (دراسة مقارنة).

وتظهر أهمية هذا البحث في إظهار محاسن الفقه الإسلامي ودوره في حماية الإنسان وتفوقه على الأنظمة الوضعية من خلال تقرير المبادئ الإسلامي، والتي لم يعرفها العالم، ولم يهتد إليها المفكرون إلا أخيرا.

والهدف الأساسي من البحث هو: إبراز مدى تطبيق المسئولية الجنائية في الواقع الصومالي، أوعدم تطبيقه على الشكل المطلوب.

والهدف الفرعي هو تحليل القواعد والمبادئ الأساسية القانونية، والتي تحكم المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.

وأما مشكلته فتتلخص في حجم مضمون المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون، ومخالفة القانون للفقه الإسلامي في بعض النصوص، وحكم بعض المسائل المعاصرة التي ليست لها أدلة شرعية أو قانونية على حسب فهم بعض الناس.

فحدوده فتنحصر في الجوانب الآتية: الجانب الموضوعي ويكون: على المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي، (دراسة مقارنة)، وأما الجانب المكاني: ففي الصومال، والجانب الزمني: ففي الفترة بعد الاستقلال منذ ١٩٦٠ م، وحتى يومنا هذا.

ومنهجيته هي أنه سلك الباحث في هذا البحث المنهج الاستقرائي، ثم الوصفي المبني على جمع المعلومات الواردة حول هذا الموضوع من مصادرها الأصلية وتحليلها، واختيار الراجح منها.

وأما **هيكله** فهو أنه تحدث أولا: **عن مفهوم المسئولية الجنائية وتاريخها وشروطها في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.**

ووضح ثانيا: محل المسئولية الجنائية وسببها ودرجاتها في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.

وتناول ثالثا: **موانع المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.**

ورابعا: تكلم **على: أسباب الإباحة في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.**

وأخيرا توصلت الدراسة إلى أن قيام المسئولية الجنائية مبنية على الإدراك والإرادة في الفقه الإسلامي والقانون.

واقترح الباحث في الرسالة أنه لا بد أن يتصدى فقهاء الفقه الإسلامي والقانون والباحثون لبحث المسائل المتعلقة بالمسئولية الجنائية، خصوصا المسائل المعاصرة والتي تظهر حينا بعد حين؛ حلا لمشاكل الأمة الإسلامية وغيرها المستجدة بمنهج علمي.

ABSTRACT

This research is an analytical descriptive study of criminal responsibility, under the title: Criminal responsibility in islam fiqhi and Somali law, (comparative study).

The importance of this research is to show the virtues of islam fiqhi and its role in protecting human beings and their superiority over the legal systems based on manmade laws through the confirmation of Islamic principles, which the world were unaware of, Only finally the thinkers guided to.

The elementary objective of the research is to highlight the extent to which criminal responsibility is applied in the Somali reality which is not applied as required.

The sub-objective is to analyze the fundamental legal rules and principles regulating criminal responsibility in usul-alfiqhi and Somali law.

Its problem lies in the extent of criminal responsibility in usul-alfiqhi and law, the conflict with usul-alfiqhi in some provisions, and the ruling of some ccontemporary issues that have no legal or Shra'a evidence according to the understanding of some people.

Its scope in the following aspects: The subject scope is: the criminal responsibility in usul-alfiqhi and Somali law, (comparativwe study), and the geographical scope: in Somalia, and the time scope: in the period after independence since 1960 up to day.

The methodology is that the researcher in this research conducted an inductive method, and then descriptive based on the collection of the materials on this subject from its original sources and analysis considering the strongest one.

Its structure is that it first takes the concept of criminal responsibility and its conditions in usul-alfiqhi and Somali law.

Second, it illustrates the points of criminal responsibility, its causes and degrees in usul-alfiqhi and Somali law.

Third: the restrictions of criminal responsibility in usul-alfiqhi and Somali law.

Fourth, it talks about the reasons for permitting usul-alfiqhi and Somali law.

Finally, the research found that criminal responsibility is based on the understanding and will in Islamic jurisprudence and law.

The researcher suggested in the paper(research) that the scholars of usul-alfiqhi, law and researchers must deal with issues related to criminal responsibility, especially contemporary issues, which, after a while, are solved; a solution to the problems of the emerging Islamic nation and others with a scientific approach.

مـقـدمــة

الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فمنذ ظهور البشر على سطح الأرض كانوا يحاولون بجهد أن يضعوا حداً لنوازع الشرّ لدى الإنسان، ومن ثم جاءت الأديان والشرائع السماوية والقوانين الوضعية تبعا لتشريع الأحكام والعقوبات؛ لتهذيب هذه النوازع، والتي من مبادئها وأسسها أن يتحمل مرتكبو الجرائم المسئولية عن جرائمهم، بصرف النظر عن منزلة من يرتكبها، قال تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾[1]، فليس شيئ آخر سوى التقوى يفاضل بين الأفراد، كالجاه والمنصب وحيازة الأموال وغيرها، وبحسب الفقه الإسلامي لا يوجد في الدولة الإسلامية فرد غير مسئول، فكلّ فرد في المجتمع الإسلامي مسئول عن أفعاله وأقواله، وعليه أن يتحمّل الآثار المترتبة عنها، وأجمع علماء المسلمين على أن الرئيس (الخليفة) يخضع كغيره من أفراد المجتمع الإسلامي للأحكام الشرعية الجنائية، وأن هذه الأحكام تسري عليه أياً كان نوع العقوبة التي تقررها.

وكان الفقه الإسلامي هو الذي سبق القوانين الوضعية إلى تشريع الأحكام والعقوبات، ووضع أسسا للمسئولية الجنائية لتحقيق مقاصد الشريعة، من حفظ النفس وسائر الكليات الخمس، وكان هذا قبل أكثر من أربعة عشر قرنا، وقد جاء الفقه الإسلامي متضمنا بقواعد للحكم الرشيد، حيث غرس الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة نواة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وكانت تلك الدولة الفتية نقطة انطلاق الدولة الإسلامية الكبرى والتي ملأت الآفاق، واعتمد الرسول صلى الله عليه وسلم على الوحي دستوراً لتلك الدولة.

وأخبر الفقه الإسلامي والقانون الوضعي أن بداية المسئولية الجنائية – التكليف – في الإسلام إذا بلغ الإنسان.

والإنسان الذي رفع عنه القلم يعفي الفقه الإسلامي والقانون من المسئولية الجنائية عن الجرم الذي ارتكبه، ويعتبر العقل مناط التكليف، حيث لا مسئولية على غير العاقل، ما عدا الأحكام الوضعية الشرعية كالضمان في مال غير المكلف، وتكون المسئولية الجنائية حسب نية الجاني، وتختلف حسب الأفعال وتتدرج، انطلاقا من هذا فرّق الفقه الإسلامي والقانون بين الفعل المتعمد ارتكابه من قبل الشخص وغير المتعمد.

وعلى هذا يلقي الباحث الضوء تفصيلا على موضوع: (المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي دراسة مقارنة)

---

(١) سورة الحجرات، الآية: ١٣.

أساسيات البحث:

سبب اختيار الموضوع.

من الأسباب الأساسية التي دفعت الباحث لاختيار هذا الموضوع للبحث عنه ما يلي:

١) وجود رغبة جامحة لدى الباحث منذ فترة؛ ليتعرف كثيرا عن الجنايات عامة، وعن المسئولية الجنائية خاصة، وما يتعلق بها من أحكام.

٢) كون هذا الموضوع كان، ولا يزال محط أنظار الفقهاء.

٣) تعلق هذا الموضوع بالذود والصيانة عن الإنسان باعتداء بعضهم على بعض، كما أنه يتعلق باستقرار الأمن؛ لأن كل من أراد الاعتداء على شخص إذا علم أن هناك مسئوليات تترتب من فعله هذا ثم يعاقب عليه وفق المسئولية الجنائية، ولا سيما في هذا الوطن الذي كثرت فيه الفوضى، والقتل بأسباب متعددة وطرق شتى، فلا يتجرأ على ارتكاب الجريمة، و لا يعتدي على أي أحد، ومن ثم يحصل المقصود من حماية النفوس وغيرها؛ نتيجة أن كل أحد حَذِرٌ من أن يعاقب عليه؛ لأنه مسئول جنائيا عن أفعاله، وأقواله.

٤) اهتمام كثير من طلاب العلم والباحثين المسائل الفقهية المشهورة والمتعلقة بأبواب الجنايات، بينما القليل منهم اختار المسائل الفقهية الغامضة والأحكام المتعلقة بها؛ لأجل ذلك دفع الباحث أن يكون موضوع بحثه المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي (دراسة مقارنة).

٥) الحاجة إلى إعطاء تصور واضح للمفهوم القضائي للمسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي، وبيان الاستثناءات التي ترد عليها، وعقد مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الصومالي بالنسبة للمسئولية الجنائية.

أهمية البحث:

تتجلى أهمية البحث بالنظر إلى:

- ما للمسئولية الجنائية، من أهمية بالغة في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.
- أن المسئولية الجنائية تعتبر في الفقه الإسلامي والقانون العمود الفقري للنظام الإسلامي والقوانين الوضعية، وأن أهم الضروريات في الدنيا هي حياة الإنسان وكرامته، لذا أنزل الله سبحانه وتعالى الأحكام التي تحمي حياة الإنسان وتنظم له شؤونه وتحافظ له على أعضاءه.
- إظهار محاسن الفقه الإسلامي ودوره في حماية الإنسان وتفوقه على الأنظمة الوضعية من خلال تقرير المبادئ الإنسانية، والتي لم يعرفها العالم ولم يهتد إليها المفكرون إلا أخيرا.

- الحاجة الماسة في هذا العصر إلى التأصيل الشرعي لكثير مما يجري حولنا من أحداث، وما يحدث من تطورات تشريعية، تضمنتها المسئولية الجنائية، والتي تعد من أهم النوازل القضائية في عصرنا الحاضر.
- إن هذا الموضوع محط أنظار الفقهاء، ولأجل ذلك تشعبت أبحاثه وتوسعت فروعه، وأصبحت مباحثه من أبحاث الكتب المعتمدة، وتعددت فيه المذاهب، وخاصة في هذا الوطن الذي كان الحال فيه صعبا جدا، حيث انتشر القتل والهرج والفوضى في كل مكان، ومن هنا أتت أهمية هذا الموضوع.

أهداف البحث:

وأهداف البحث تتمثل فيما يلي:

١- تحليل القواعد والمبادئ الأساسية القانونية التي تحكم المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي (دراسة مقارنة).

٢- بيان تاريخ وشروط المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.

٣- توضيح محل المسئولية الجنائية وسببها ودرجاتها في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.

٤- بيان موانع المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي

٥- معرفة أسباب الإباحة في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.

٦- محاولة تمحيص ما ورد في كل مسألة من خلافات، بغية الوصول إلى أرجح الأقوال وفق الأدلة الشرعية.

٧- تجميع ما تناثر في موضوع المسئولية الجنائية في كتب الفقه، مقارنة بالقانون الصومالي.

مشكلة البحث:

إن هذا البحث يعالج مشكلة تكمن في حجم مضمون المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي، ومخالفة القانون للفقه الإسلامي في بعض النصوص، وحكم بعض المسائل المعاصرة التي ليست لها أدلة شرعية أو قانونية على حسب فهم بعض الناس، وبرزت مشكلة هذا البحث في الإجابة عن التساؤلات الآتية:

أسئلة البحث:

١- ما مفهوم المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي؟

٢- هل للمسؤولية الجنائية تطور في قانون العقوبات الصومالي؟

٣- ما مبنى المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي؟

٤- ما محل المسئولية الجنائية، وسببها ودرجاتها في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي؟

٥- ما موانع المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي؟

٦- ما أسباب الإباحة في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي؟

٧- هل جميع نصوص القانون الصومالي تخالف الفقه الإسلامي؟

هذه التساؤلات وغيرها هي ما يجيب عنها البحث.

فروض البحث.

فالفروض عبارة عن إجابة مبدئية لتساؤلات البحث من خلال التساؤلات السابقة يفترض الباحث ما يلي:

١- المسؤولية الجنائية مفهوم في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.

٢- لا يوجد للمسؤولية الجنائية تاريخ وتطور مدون في قانون العقوبات الصومالي.

٣- مبنى المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي الإدراك والإرادة.

٤- هناك محل وسبب ودرجات للمسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.

٥- المسؤولية الجنائية موانع في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.

٦- جواز ممارسة حق التأديب والدفاع الشرعي الخاص والأعمال الطبية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.

٧- مخالفة القانون للفقه الإسلامي في بعض النصوص.

حدود البحث:

١. الجانب الموضوعي: تنحصر هذه الدراسة من الناحية الموضوعية على المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي، (دراسة مقارنة)، وذلك يقتضي بيان مفهومها وتاريخها وشروطها، ومحلها وسببها وصور قصدها ودرجاتها وموانعها كأثر الرضا على الجناية، وأسباب إباحتها كاستعمال حق التأديب.

٢. الجانب المكاني: تنحصر هذه الدراسة مكانيا في الصومالي.

٣. الجانب الزمني: تنحصر هذه الدراسة في المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي، والقانون الصومالي في الفترة بعد الاستقلال منذ ١٩٦٠ م، وحتى يومنا هذا.

الدراسات السابقة:

قام الباحثون والكتّاب بكتابة عدد من البحوث والمؤلفات عن الجنايات بصفة عامة، **والمسئولية الجنائية بصفة** خاصة، غير أن المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي دراسة مقارنة، فلا توجد أيّة دراسة سابقة فيها، كبحث مستقل، حسب علم الباحث بعد البحث والتحري، ولكن هناك بحوث حول المسئولية الجنائية، ثم إن بعضها مقارن بالفقه الإسلامي والقانون، وبعضها مختص بالفقه الإسلامي أو بالقانون، وبعضها مقيد بشئ آخر، مثل المسئولية الجنائية للطبيب، ومن هذه البحوث:

١. المسئولية الجنائية في قانون الأحداث الأردني في ضوء الفقه الإسلامي، لـــ د.محمد نوح على معابدة، المجلة الأرضية في الدراسات الإسلامية، المجلة السابعة، العدد (١/أ)، ١٤٣٢ ه – ٢٠١١ م.

أوجه الاتفاق والاختلاف بين هذه الدراسة وهذا البحث:

يتفقان في النقاط التالية:

- كل منهما يعالج المسولية من حيث الجناية.
- كل منهما فيه مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون.

ويختلفان في النقاط التالية:

- إن هذه الدراسة مختصة بالمسئولية الجنائية باعتبار الأحداث (صغار السن)، بينما دراسة هذا البحث تتناول مسئولية الأحداث والكبار جنائيا.
- إن هذه الدراسة وإن كانت فيها مقارنة بالفقه الإسلامي كما تقدم، لكنها تقارن بالقانون الأردني، بينما دراسة هذا البحث كذلك فيها مقارنة، لكنها تقارن بالقانون الصومالي.
- إن هذه الدراسة هي مجلّة، بينما أن دراسة هذا البحث بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير.

٢. المسئولية الدولية الجنائية للأفراد في ضوء تطور القانون الدولي الجنائي، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، لفلاح مزيد المطيري، إشراف الأستاذ الدكتور: نزار العنبكي، (٢٠١١).

أوجه الاتفاق والاختلاف بين هذه الدراسة وهذا البحث:

يتفقان في النقاط التالية:

- كل منهما يعالج المسولية من حيث الجناية.
- كل منهما يعالج مسئولية الأفراد، بغض النظر عن كونها أحداثا أو كبارا.

ويختلفان في النقاط التالية:

- إن هذه الدراسة مختصة بالمسئولية الجنائية باعتبار العلاقة بين أفراد دول العالم على ضوء تطور القانون الدولي الجنائي، بينما دراسة هذا البحث تختص بالعلاقة بين أفراد دولة معية.
- إن هذه الدراسة ليست فيها مقارنة بالفقه الإسلامي البتة، بينما تكون دراسة هذا البحث مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الصومالي، كما هو واضح بالعنوان.
- إن هذه الدراسة تعالج موضوع المسئولية الجنائية في قانون الدولي الجنائي، بينما دراسة هذا البحث تعالج المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.

٣. المسئولية الدولية الجنائية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون والقضاء الدوليين الجنائيين، لحسين نسمة، إشراف الأستاذ الدكتور بن حليلو فيصل، السنة الجامعية ٢٠٠٦ – ٢٠٠٧ م.

أوجه الاتفاق والاختلاف بين هذه الدراسة وهذا البحث، هي شبهها في الدراسة السابقة.

٤. المسئولية الجنائية للطبيب، مذكرة مكملة من مطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، لـــ(بن فاتح عبد الرحيم)، إشراف الأستاذة: زوزو هدى، الموسم الجامعي: ٢٠١٤ – ٢٠١٥ م.

أوجه الاتفاق والاختلاف بين هذه الدراسة وهذا البحث:

يتفقان في النقاط التالية:

- كل منهما يعالج المسؤولية الجنائية.
- كل منهما يعالج المسئولية الجنائية للأفراد من غير قيد بالصغر أو الكبر.

ويختلفان في النقاط التالية:

- إن هذه الدراسة تعالج المسئولية الجنائية للطبيب، بينما تعالج دراسة هذا البحث ما هو أوسع مما في هذه الدراسة، فبينهما عموم وخصوص من وجه.
- إن هذه الدراسة ليست فيها مقارنة بالفقه الإسلامي، أما دراسة البحث فيها مقارنة بالفقه الإسلامي والقانون الصومالي، كما تقدم.
- إن هذه الدراسة تعالج المسئولية الجنائية في القانون الجنائي العام، أما دراسة هذا البحث تتناول أحكام المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي والقوانين الوضعية الأخرى في حالة ما إذلم يوجد الحكم في القانون الصومالي.

٥. المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي، القانون الجزائري نموذجيا، لأمينة زواوي، إشراف الدكتورة: ذهينة نصيرة، ١٤٢٦ ه – ١٤٢٧ ه = ٢٠٠٥ م – ٢٠٠٦ م .

أوجه الاتفاق والاختلاف بين هذه الدراسة وهذا البحث:

يتفقان في النقاط التالية:

- كل منهما يعالج المسولية من حيث كونها جنائية.
- كل منهما يعالج مسئولية الأفراد صغيرة أو كبيرة.
- كل منهما فيه مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون.

ويختلفان في النقاط التالية:

- إن هذه الدراسة تتناول المسئولية الجنائية في القانون الجزائري، بينما تعالج دراسة هذا البحث المسئولية الجنائية في القانون الصومالي.

- إن هذه الدراسة تعالج بعض ما يتناول هذا البحث، وما ليس فيه، بينما يكون هذا البحث كذلك، فبينهما عموم وخصوص من وجه.

منهجية البحث:

سلك الباحث في هذا البحث المنهج الاستقرائي، ثم الوصفي المبني على جمع المعلومات الواردة حول هذا الموضوع من مصادرها الأصلية وتحليلها، واختيار الراجح منها، وتتمثل الخطوات التي اتخذها الباحث في الآتي:

١) الرجوع إلى المصادر الأصلية، والتبعية لهذا الموضوع.
٢) الحرص على التزام الأمانة العلمية في عزو الأقوال إلى قائليها، مع بذل الجهد في نقل كل قول من مصدره.
٣) الحرص على تدعيم البحث بالأدلة الشرعية والقانونية.
٤) بيان مواضع الآيات القرآنية في المصحف الشريف، وذلك بذكر اسم السورة، ورقم الآية في الهامش.
٥) تخريج الأحاديث الواردة في الرسالة، مع مراعاة ما يلي:
– إن كان الحديث في الصحيحين يكتفي الباحث بالعزو إليهما.
– وإن كان الحديث في غيرهما يقوم الباحث بتخريجه، ثم ذكر حكمه من حيث القبول والرد.
٦) ترجمة الأعلام غير المشهورين.
٧) إتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها.
- فهرس الآيات القرآنية.
- فهرس الأحاديث النبوية، والآثار.
- فهرس الأعلام.
- فهرس المصادر والمراجع.
- فهرس الموضوعات.

مصطلحات البحث:

م: يعني المادة من قانون العقوبات الصومالي، وقانون الأحوال الشخصية الصومالي.

ف: يعني فقرة المادة.

الصعوبات:

إن سنة الحياة تعب ونصب، والبحث عمل شاق وصعب، يحتاج إلى بذل جهد، ومزيد من التثبيت والتوثيق والدقة، بالإضافة إلى أن هذا الموضوع يتعلق بأهم المسائل الجنائية، وهي: المسئولية الجنائية؛ لذا فإن أهم الصعوبات التي واجهت الباحث أثناء بحثه، هي: المقارنة بين الفقه

الإسلامي والقانون الصومالي في المسئولية الجنائية، مع قلة المصادر القانونية الصومالية، وأشد من ذلك أنه لم يحظ القانون الصـــومالي بشـــتى أنواعه أيّ شرح وتعديل عمـــوما

على حسب علم الباحث، و خاصة قانون العقوبات الصومالي، إضافة إلى أن نُسَخ القانون التي توجد حاليا ليست لغتها سليمة من العيوب، سواء كانت مكتوبة باللغة الصومالية، أو اللغة العربية، فهذا وغيره من أهمّ الصعوبات التي واجهت الباحث خلال كتابة هذا البحث.

هيكل البحث:

لقد قسّم الباحث بحثه إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة.

فالمقدمة تشمل: سبب اختيار الموضوع، وأهميته ومشكلته، وأسئلته، وفروضه، وأهدافه، وحدود البحث، والدراسات السابقة للموضوع، ومنهجية البحث، ومصطلحاته، والصعوبات؛ أما الفصول فتكون حسب ما يأتي:

الفصل الأول: مفهوم المسئولية الجنائية وتاريخها وشروطها في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.

المبحث الأول: مفهوم المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي

المطلب الأول: تعريف المسئولية الجنائية في اللغة.

الفرع الأول: تعريف المسئولية في اللغة

الفرع الثاني: تعريف الجنائية في اللغة

المطلب الثاني: تعريف المسئولية الجنائية في الاصطلاح

الفرع الأول: تعريف المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي

الفرع الثاني: تعريف المسئولية الجنائية في القانون

المبحث الثاني: تاريخ وتطور المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي

المطلب الأول: تاريخ وتطور المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني: تاريخ وتطور المسئولية الجنائية في القانون

المبحث الثالث: شروط المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.

المطلب الأول: الإدراك والتمييز في الفقه الإسلامي.

الفرع الأول: الإدراك

الفرع الثاني: التمييز

المطلب الثاني: الإدراك والتمييز في القانون
المطلب الثالث: الاختيار في الفقه الإسلامي
المطلب الرابع: الاختيار في القانون.
الفصل الثاني: محل المسئولية الجنائية وسببها، وصور قصدها ودرجاتها في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.
المبحث الأول: محل المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي
المطلب الأول: الإنسان محلّ المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي.
المطلب الثاني: الإنسان محلّ المسئولية الجنائية في القانون
المطلب الثالث: المسئولية الجنائية شخصية في الفقه الإسلامي.
المطلب الرابع: المسئولية الجنائية شخصية في القانون.
المبحث الثاني: سبب المسئولية الجنائية وصور قصدها في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.
المطلب الأول: سبب المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي .
المطلب الثاني: سبب المسئولية الجنائية في القانون.
المطلب الثالث: صور قصد المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي.
المطلب الرابع: صور قصد المسئولية الجنائية في القانون.
المبحث الثالث: درجات المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي
المطلب الأول: درجة مسئولية العمد في الفقه الإسلامي
المطلب الثاني: درجة مسئولية العمد في القانون
المطلب الثالث: درجة مسئولية شبه العمد في الفقه الإسلامي
المطلب الرابع: درجة مسئولية شبه العمد في القانون
المطلب الخامس: درجة مسئولية الخطأ في الفقه الإسلامي
المطلب السادس: درجة مسئولية الخطأ في القانون
الفصل الثالث: موانع المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي
المبحث الأول: موانع الإدراك في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.
المطلب الأول: الصغر في الفقه الإسلامي
المطلب الثاني: الصغر في القانون
المطلب الثالث: الجنون وما يلحق به في الفقه الإسلامي
المطلب الرابع: الجنون وما يلحق به في القانون

المبحث الثاني: موانع الاختيار في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي
المطلب الأول: الإكراه في الفقه الإسلامي
المطلب الثاني: الإكراه في القانون
المطلب الثالث: الضرورة في الفقه الإسلامي
المطلب الرابع الضرورة في القانون
المبحث الثالث: الرضا على المسئولية الجناية والجهل عنها في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.
المطلب الأول: رضا المجنى عليه على القتل والجرح في الفقه الإسلامي
المطلب الثاني: رضا المجنى عليه على القتل والجرح في القانون
المطلب الثالث: الجهل بتحريم الفعل والحكم وأقسامه في الفقه الإسلامي
المطلب الرابع: الجهل بتحريم الفعل والحكم وأقسامه في القانون
الفصل الرابع: أسباب الإباحة في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي
المبحث الأول: استعمال حق التأديب في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي
المطلب الأول: حق تأديب الزوجة في الفقه الإسلامي
الفرع الأول: حكم تأديب الزوجة ومشروعيته وحكمته
الفرع الثاني: مراتب تأديب الزوجة
المطلب الثاني: حق تأديب الزوجة في القانون
الفرع الأول: حكم تأديب الزوجة وحكمته
الفرع الثاني: شروط استعمال حق تأديب الزوجة
المطلب الثالث: حق تأديب الصغار في الفقه الإسلامي
الفرع الأول: مشروعية تأديب الصغار وعلته
الفرع الثاني: شروط تأديب الصغار بالضرب
المطلب الرابع: حق تأديب الصغار في القانون
الفرع الأول: حكم تأديب الصغار وعلته
الفرع الثاني: شروط تأديب الصغار
المبحث الثاني: استعمال حق الأعمال الطبية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي
المطلب الأول: ممارسة حق الأعمال الطبية في القه الإسلامي
الفرع الأول: الأعمال الطبية ومشروعية التداوي
الفرع الثاني: حكم ممارسة الأعمال الطبية

المطلب الثاني: ممارسة حق الأعمال الطبية في القانون

الفرع الأول: حكم الأعمال الطبية

الفرع الثاني: الأساس القانوني لإباحة الأعمال الطبية

المطلب الثالث: شروط ممارسة حق الأعمال الطبية في الفقه الإسلامي

المطلب الرابع: شروط ممارسة حق الأعمال الطبية في القانون

المبحث الثالث: الدفاع الشرعي الخاص (دفع الصائل) وشروطه في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي

المطلب الأول: الدفاع الشرعي الخاص (دفع الصائل) في الفقه الإسلامي.

المطلب الثاني: الدفاع الشرعي الخاص في القانون.

المطلب الثالث: شروط الدفاع الشرعي الخاص(دفع الصائل) في الفقه الإسلامي

المطلب الرابع: شروط الدفاع الشرعي الخاص في القانون

الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس، وتشمل ما يلي:

- فهرس الآيات القرآنية.
- فهرس الأحاديث.
- فهرس الأعلام.
- فهرس المصادر والمراجع.
- فهرس الموضوعات.

الفصل الأول: مفهوم المسئولية الجنائية وتاريخها وشروطها في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.

المبحث الأول: مفهوم المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي

المطلب الأول: تعريف المسئولية الجنائية في اللغة.

الفرع الأول: تعريف المسئولية في اللغة

الفرع الثاني: تعريف الجنائية في اللغة

المطلب الثاني: تعريف المسئولية الجنائية في الاصطلاح

الفرع الأول: تعريف المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي

الفرع الثاني: تعريف المسئولية الجنائية في القانون

المبحث الثاني: تاريخ وتطور المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي

المطلب الأول: تاريخ وتطور المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني: تاريخ وتطور المسئولية الجنائية في القانون

المبحث الثالث: شروط المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.

المطلب الأول: الإدراك والتمييز في الفقه الإسلامي.

الفرع الأول: الإدراك

الفرع الثاني: التمييز

المطلب الثاني: الإدراك والتمييز في القانون

المطلب الثالث: الاختيار في الفقه الإسلامي

المطلب الرابع: الاختيار في القانون.

الفصل الأول: مفهوم المسئولية الجنائية وتاريخها وشروطها في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي:

تمهيد: المسئولية الجنائية لها مفهوم لغوي، ومفهوم اصطلاحي من اعتبار الفقه الإسلامي والقانون، أما مفهوم المسئولية الجنائية في اللغة فلا بد لها من تفكيك الكلمتين، ثم تعريف كل منهما على حدة.

فأما المسئولية فأصلها اسم مفعول، ثم قلب إلى مصدر صناعي بإضافة ياء وهاء تأنيث، على حد بناء المصادر الصناعية.

وأما الجنائية فهي: الجرم والذنب، وكل ما يوجب القصاص والعقاب في الدنيا والآخرة من أفعال الناس.

وأما اصطلاحها فسيأتي في موضعه إن شاء الله.

وأما أصل وجود كلمة المسئولية، فعند فقهاء الإسلام من المتقدمين لم تستعمل هذه الكلمة بلفظها وحروفها بهذا الترتيب، ولكن تستخدم بدلها ألفاظا أخري، مثل: تحمل التبعة أو الضمان وغير ذلك.

بينما القوانين الوضعية لم تعرف مضمونها، فضلا عن استخدامها إلا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين.

وأخيرا لا بد من العلم بأن الأوامر والنواهي هي: تكاليف شرعية، فلا توجه إلا لكل عاقل فاهم للتكليف؛ لأن التكليف خطاب، ولا يخاطب إلا من له عقل وفهم يستطيع من خلاله على فهم تفاصيله.

ومن هنا لابد من توافر شروط لكي يكون الشخص مسئولا عن أفعاله، فهذه الشروط باختصار هي: الإدراك والاختيار، وسيأتي تفاصيل هذا كله في المباحث التالية إن شاء الله.

المبحث الأول: مفهوم المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي

تمهيد: مفهوم المسئولية الجنائية لغة واصطلاحا أمر ضروري، من اعتبارين، أما مفهوم المسئولية الجنائية في اللغة فلا بد لها من تفكيك الكلمتين، فأن المسئولية الجنائية تتكون من كلمتين، بمعنى أنها مركب من كلمتين، مما يستدعي تعريف كل كلمة لوحدها، هذا من حيث اللغة ثم تعريف كل منهما على حدة.

فأما المسئولية فأصلها كما سيأتي اسم مفعول، ثم قلب إلى مصدر صناعي بإضافة ياء وهاء تأنيث، على حد بناء المصادر الصناعية.

وأما الجنائية فهي: الجرم والذنب، وكل ما يوجب القصاص والعقاب في الدنيا والآخرة من أفعال الناس.

وأما معنى المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي: أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختاراً وهو مدرك لمعانيها ونتائجها.

وأما معنى المسئولية الجنائية في القوانين الوضعية الحديثة هي عبارة عن: "القدرة على الإدراك والإرادة "، وذلك على المطالب الآتية:

المطلب الأول: تعريف المسئولية الجنائية في اللغة.

أن المسئولية الجنائية تتكون من كلمتين، بمعنى أنها مركب من كلمتين، مما يستدعي تعريف كل كلمة لوحدها، هذا من حيث اللغة، وعلى ذلك ينبغي تعريف المسئولية بداية، ثم تعريف كلمة الجناية، مراعاة لترتيبها المتقدم.

الفرع الأول: تعريف المسئولية في اللغة:

إن المقصود من كلمة المسئولية لفظ مشتق من مادة سَأَلَ، يقال: سَأَلَ يَسْأَلُ سُؤَالاً، وأصلها اسم مفعول، ثم صار مصدرا صناعيا بإضافة ياء وهاء تأنيث، على حد كثير من المصادر الصناعية، استخبره عنه[١]، وفي التنزيل العزيز: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْـَٔلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [٢]، وفيه أيضا: ﴿ فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا ﴾ [٣]، وسأل المحتاج الناس: تسول؛ طلب

---

(١) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار) :دار الدعوة، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر، ج١/ص:٤١١.

(٢) سورة المائدة، الآية: ١٠١.

(٣) سورة الفرقان، الآية: ٥٩.

منهم الصدقة، وفلانا الشيء: استعطاه إياه، ويقال: سألت زيدا درهما [١]، وفي التنزيل العزيز: ﴿لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ [٢]، وردت في القرآن الكريم كلمة المسئول بصيغة اسم المفعول في مواضع، ومن تلك قوله تعالى:﴿وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا﴾[٣]، وقوله تعالى:﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا﴾[٤]، وقوله تعالى:﴿لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَٰلِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْـُٔولًا﴾[٥]، وقوله تعالى:﴿وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ﴾[٦]، أي: أنْ سؤالهم يكون سؤال توبيخ وتقرير إيجاب الحجّة عليهم؛ لأن الله جل ثناؤه عالم بأعمالهم[٧]، ووردت في القرآن أيضا كلمات مشابهة للمسئول من حيث المفهوم، ومنها: قوله تبارك وتعالى:﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾[٨]، وقوله جل ثناؤه: ﴿وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾[٩]، وقوله تعالى:﴿تَٱللَّهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ﴾[١٠]، وقوله عز وجل: ﴿وَسَوْفَ تُسْـَٔلُونَ ﴿٤٤﴾ وَسْـَٔلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ﴾[١١]، ومعناه سوف تسألون عن شكر ما خلق الله لكم من الشرف والذكر[١٢]، وقوله تعالى أيضا:﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾ [١٣]، ويقال: سأل فلان عن فلان وسأله عن الشيء سؤالاً، وتساءلوا فيما بينهم، بمعنى

---

(١) معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر، عالم الكتب، ط ١، ت: ١٤٢٩ هـ – ٢٠٠٨ م، بدون مكان النشر، ج ٢، ص: ١٠١٩.

(٢) سورة طه، الآية: ١٣٢.

(٣) سورة الإسراء، الآية:٣٤.

(٤) سورة الإسراء، الآية:٣٦.

(٥) سورة الفرقان، الآية:١٦.

(٦) الصافات، آية، ٢٤.

(٧) لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى، دار صادر، ط٣، ت: ١٤١٤ ه، بيروت، ج١١، ص: ٣١٩.

(٨) البقرة، أية:٢١٧.

(٩) النحل، آية: ٩٣.

(١٠) النحل، أية: ٥٦.

(١١) الزخرف: ٤٤ – ٤٥.

(١٢) المحكم والمحيط الأعظم، علي بن إسماعيل بن سيده أبو الحسن المرسي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢١ هـ – ٢٠٠٠ م، بيروت، ج ٨، ص: ٥٤٧.

(١٣) الحجر، آية: ٩٢ – ٩٣.

سأل بعضهم بعضا [١]، ويطلق السؤال للاستفسار، وقوله تعالى: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ﴾[٢]، كما في قوله تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَن ذَنۢبِهِۦٓ إِنسٌ وَلَا جَآنٌّ﴾[٣]؛ لأنه جل ثناؤه وتقدست أسماءه يعلم ما كان من أعمالهم فلا حاجة لسؤالهم[٤].

ويطلق السؤال في أحيان أخرى للتعريف بالمسئول عنه وتبيينه [٥]، ومن هنا ورد لفظ المسئولية، أي: مسئولية الإنسان عن أفعاله وتصرفاته، وقد ورد الحديث الشريف أن ابن عمر – رضي الله عنهما– قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته» قال: – وحسبت أن قد قال: «والرجل راع في مال أبيه ومسئول عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته))[٦].

والمسئولية هي: حالة أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته يقال أنا بريء من مسئولية هذا العمل وتطلق (أخلاقيا) على التزام الشخص بما يصدر عنه قولا أو عملا[٧].

---

(١) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي أبو العباس، الفيومي ثم الحموي، المكتبة العلمية، بدون الطبعة، والتاريخ، بيروت، ج ١، ص: ٢٩٧.

(٢) البقرة، آية: ٢١٩.

(٣) الرحمن، آية: ٣٩.

(٤) لسان العرب، مرجع سابق، ج ١١، ص: ٣١٩.

(٥) محيط المحيط قاموس عصري مطول للغة العربية، المعلم بطرس البستاني، تحقيق: محمد عثمان، دار الكتب، بدن الطبعة، والتاريخ، بيروت – لبنان، ج ٤، ص: ٣٤٤.

(٦) أخرجه محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، برقم: (٨٩٣) تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط١، ت: ١٤٢٢هـ، بدون مكان النشر، ج٢/ص:٥، واللفظ له، ومسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، في صحيحه، كتاب الإمارة برقم: (١٨٢٩) كلاهما عن ابن عمر – رضي الله عنه – ما –، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار احياء التراث العربي، بدون الطبعة، والتاريخ، بيروت، ج٣/ ص:١٤٥٩.

(٧) المعجم الوسيط، مرجع سابق، ج١/ص:٤١١.

الفرع الثاني: تعريف الجنائية في اللغة:

الجناية في الأصل: مصدر جنى عليه شر جناية، وهو عام في كل ما يقبح ويسوء وقد خص بما يحرم من الفعل[١].

وبعبارة أخرى: الجناية: الجرم والذنب، وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه القصاص والعقاب في الدنيا والآخرة [٢].

المطلب الثاني: تعريف المسئولية الجنائية في الاصطلاح

الفرع الأول: تعريف المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي

تعريف المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي يحتاج إلى تجزئتها، وبيان كل جزء منها على حدة، كما في الآتي:

أ. تعريف المسئولية في الفقه الإسلامي:

بعد البحث والفحص عن بطون كتب الفقه القديمة اتضح أنه لم يرد فيها تعريف لهذه الكلمة، وعدم ورود التعريف فيها، لعله يرجع إلى سبب أنهم استعملوا عبارات أخرى بدل المسئولية الجنائية، ولكن ورد ذلك في كتب المتأخرين والبحوث الجامعية؛ أخذا من كتب المعاصرين، ومن ذلك تعريف لبعض المعاصرين بأن المسئولية هي:

كون الفرد مكلفًا بأن يقوم ببعض الأشياء، وبأن يقدم عنها حسابًا إلى زيد من الناس(مثلا)، ولا ريب أن الكلام على المسئولية بالمعنى الحقيقي هو الذي قد يتفاوت في قوته، وقد يحدث أن يستخدم هذا الاصطلاح بتوسيع دلالته أو إضعافها [٣]، أو هي الإلتزام بتعويض الغير عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية[٤]

---

(١) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي، تحقيق: يحيى حسن مراد، دار الكتب العلمية، بدون الطبعة، ت:٢٠٠٤م-١٤٢٤ه، بدون مكان النشر، ص:١٠٨.

(٢) المطلع على ألفاظ المقنع، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل أبو عبد الله، شمس الدين، البعلي، تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، مكتبة السوادي، ط١، ت. ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م، بدون مكان النشر، ص:٤٣٣.

(٣) دستور الأخلاق في القرآن، محمد بن عبد الله دراز، مؤسسة الرسالة، ط١، ت:١٤١٨ه-١٩٩٨م، بدون مكان النشر، ص:١٣٦.

(٤) أحكام المسئولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، وهبة الزحيلي، دار الفكر، بدون الطبعة، ت١٩٩٨م، دمشق _ سورية، ص: ٢٢.

ب. تعريف الجناية في الفقه الإسلامي:

والجناية: اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس، وخص الفقهاء الغصب والسرقة بما حل بمال، والجناية بما حل بنفس وأطراف.(١)، أو هي: كل فعل عدوان على نفس أو مال(٢).

يتضح من هذا أن الفقهاء في عرفهم أن الجناية لها معنيان: معنى خاص، ومعنى عام، وأما المعنى الخاص فهو: أن الجناية هو: الفعل المؤثم الواقع على النفس والأطراف، سواء أكان قتلًا أم ضربا أم جرحًا، أم غير ذلك(٣).

فأما المعنى العام هو أن الجناية اسم لفعل مجرّم سواء أكان في مال أو نفس(٤)، لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان، وسموا الجنايات على الأموال غصبا، ونهبا، وسرقة، وخيانة، وإتلافا (٥).

ويتضح من هذا أيضا أن الجناية في الأصل نوعان: جناية على البهائم والجمادات، وجناية على الآدمي، أما الجناية على البهائم والجمادات فنوعان أيضا: غصب وإتلاف(٦)، ويذكرهما الفقهاء في كتاب الغصب.

وأما الجناية على الآدمي فهو الذي يختص بالبحث، ويرادف الجناية الجريمة، وعرفوها بأنها محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحدّ أو تعزير (٧).

---

(١) الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، محمد بن علي بن محمد الحصني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط.١، ت:١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م، بدون مكان النشر، ج٦/ ص:٥٢٧.

(٢) المغني، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة أبو محمد موفق الدين الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر، ج٨/ص:٢٥٩.

(٣) الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون، منصور محمد منصور الحفناوي، مطبعة الأمانة، ط/١، ت: ١٤٠٦ هـ- ١٩٨٦ م، بدون مكان النشر، ص:٢٦.

(٤) المغني، مرجع سابق، ج٨/ص:٢٥٩.

(٥) الشرح الكبير (المطبوع مع المقنع والإنصاف)، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة أبو الفرج شمس الدين المقدسي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو، هجر، ط ١، ت:١٤١٥ هـ - ١٩٩٥م، القاهرة - جمهورية مصر العربيةج٢٥/ص:٥.

(٦) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين، الكاساني الحنفي، دار الكتب العلمية، ط.٢، ت. ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، بدون مكان النشر، ج٧، ص: ٣٣.

(٧) الأحكام السلطانية، علي بن محمد بن محمد بن حبيب أبو الحسن البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، دار الحديث، بدون الطبعة، والتاريخ، القاهرة - مصر، ص:٣٢٢.

معنى المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي:

معنى المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختاراً وهو مدرك لمعانيها ونتائجها [١].

فمن أتى فعلاً محرماً وهو لا يريده كالمكره أو المغمى عليه لا يسأل جنائياً عن فعله، ومن أتى فعلاً محرماً وهو يريده ولكنه لا يدرك معناه كالطفل أو المجنون لا يسأل أيضاً عن فعله [٢].

الفرع الثاني: تعريف المسئولية الحنائية في القانون:

تعريف المسئولية الجنائية في القوانين الوضعية الحديثة هو نفس معنى المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي، وإن قانون العقوبات لجمهورية الصومال الديمقراطية أورد تعريف المسئولية الجنائية، ونص على أنها عبارة عن: القدرة على الإدراك والإرادة [٣].

وأما المسئول فقد عرفه بقوله: ٢– كل من كانت لديه القدرة على الإدراك والإرادة[٤].

وجاء في " النظرية العامة للقصد الجنائي " أنها التزام الإنسان بتحمل الآثار القانونية المترتبة على قيام فعل يعتبر جريمة من جهة نظر القانون ونتيجة مخالفة هذا الإلتزام[٥]

وعلى هذا فإن معنى المسئولية الجنائية في القوانين الوضعية الحديثة هي: نفس معنى المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي [٦].

---

(١) التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، دار الكاتب العربي بدون الطبعة، والتاريخ، بيروت، ج١، ص: ٣٩٢.

(٢) المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.

(٣) قانون العقوبات الصومالي، لجمهورية الصومالي الديمقراطية، مؤسسة الحلبي، الصادر: ١٩٦٢، بدون الطبعة، القاهرة – مصر، م: ٤٧، ف: (٢).

(٤) المرجع السابق، م: ٤٧، ف: (٢).

(٥) النظرية العامة للقصد الجنائي، محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية، بدون الطبعة، ت: ١٩٩٨م، القاهرة – مصر، ص: ١٣ – ١٤.

(٦) التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، مرجع سابق، ج ١، ص: ٣٩٢.

المبحث الثاني: تاريخ وتطور المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون

تمهيد: سيأتي في المطالب الآتية لهذا المبحث بيان أصل وجود هذه كلمة المسئولية الجنائية، وعلم أن فقهاء الإسلام المتقدمين لم يستعملوا هذه الكلمة بلفظها وحروفها على هذا الترتيب، ولكن استخدموا بدلها ألفاظا أخري، مثل: تحمل التبعة أو الضمان وغير ذلك كما سيأتي.

بينما أن القوانين الوضعية لم تعرف مضمونها، فضلا عن استخدامها إلا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين؛ لأن القوانين الوضعية كانت بشكل عام في العصور الوسطى وإلى ما قبل الثورة الفرنسية، تعاقب الجماد والحيوان، وسيأتي مزيد من ذلك إن شاء الله تعالى في المطالب الآتية:

المطلب الأول: تاريخ وتطور المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي

لم يخضع الفقه الإسلامي الجنائي في قواعده وأسسه إلى التطور والتغيير إلا ما كان منه في مسائل اجتهادية معروفة ترك الشارع الحكيم أمرها لأولي الأمر عبر الأزمان، وهي المسائل التي من شأنها أن تبرهن على صلاحية هذا النظام وفعاليته في مواجهة كل تغيير[١].

هذا فيما يتعلق بتغير وتطور أحكام المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي.

وأما ما يتعلق بأصل وجود هذه المسئولية، فقد تقدم أن الفقهاء لم يستعملوا هذه الكلمة بلفظها، ولكنهم كانون يستخدمون بدلها ألفاظا أخري، مثل: تحمل التبعة[٢] أو التكليف أو الضمان[٣].

ويتضح من هذا أن المسئولية الجنائية التي لم تعرفها القوانين الوضعية إلا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، فقد عرفتها الشريعة من يوم وجودها بمثل الألفاظ المتقدمة، وأنها من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الشريعة.

---

(١) المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي، القانون الجزائري نموذجا، أمينة زواوي، إشراف الدكتورة: دهينة نصـ□ة، جامعة ا□زائر، بدون الطبعة، ت: ١٩٩٦م، الخروبة- الجزائر، ص:١٤-١٥.

(٢) المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة -رضي الله عنه- محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَة ، أبو المعالي برهان الدين البخاري الحنفي، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م، بيروت - لبنان، ج ٥، ص: ٤٢٨.

(٣) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير، الجامع الصغير: محمد بن الحسن أبو عبد الله الشيباني، عالم الكتب، ط ١، ت: ١٤٠٦ هـ بيروت، ص: ٣٧٩.

فالفقه الإسلامي لا يعرف محلاً للمسئولية إلا الإنسان الحي المكلَّف، فإذا مات سقطت عنه التكاليف ولم يعد محلاً للمسئولية [١].

والفقه يعفي الأطفال إلا إذا بلغوا الحلم مما لا يعفى من الرجال[٢]؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾[٣]، ولقول عليّ لعمر –رضي الله عنهما–: ((أما علمت: أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ)) [٤].

وعن عائشة: أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبى حتى يكبر" [٥].

والشريعة لا تؤاخذ المكرَه، ولا فاقد الإدراك، لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾[٦]، وقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾[٧]، ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))[٨].

ومن القواعد الأساسية في الفقه الإسلامي: ﴿ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾[٩]، قال ابن عباس – رضي الله عنهما–: كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الرجل بذنب غيره، ويأخذون الولي

---

(١) التشريع الجنائي، عبد القادر عودة، مرجع سابق ، ج١/ص:٣٨٢.

(٢) المرجع السابق، نفس الصفحة.

(٣) سورة النور، الآية:٥٩.

(٤) أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الحدود، باب: لا يرجم المجنون والمجنونة، ج٨، ص: ١٦٥.

(٥) أخرجه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو أبو داود الأزدي السِّجِستاني، في سننه، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، برقم: (٤٣٩٨)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط – محمَّد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط ١، ت: ١٤٣٠ هـ – ٢٠٠٩ م، بدون مكان النشر ج ٦، ص: ٤٥٢، وفي الصفحة نفسها قال شعيب الأرنؤوط ، ومحمَّد كامل قره بللي: إسناده صحيح.

(٦) سورة النحل، الآية:١٠٦.

(٧) سورة البقرة، الآية:١٧٣.

(٨) أخرجه ابن ماجه محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، في سننه، أبواب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٦)، عن ابن عباس، تحقيق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد – محمَّد كامل قره بللي – عبد اللّطيف حرز الله، دار الرسالة العالمية، ط١، ت: ١٤٣٠ هـ – ٢٠٠٩م، بدون مكان النشر، ج٣، ص: ٢٠١، وفي الصفحة نفسها قال شعيب الأرنؤوط عادل مرشد – محمَّد كامل قره بللي – عبد اللّطيف حرز الله: حديث صحيح.

(٩) سورة النجم الآية: ٣٨.

بالولي في القتل والجراحة، فيقتل الرجل بأبيه وابنه وأخيه وعمه وخاله وابن عمه وقريبه وزوجته وزوجها وعبده، فبلغهم إبراهيم عليه السلام عن الله تعالى[١]: ﴿ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾[٢].

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾[٣]، يقال وزر يزر فهو وازر ووزر وزرا وزرة، ومعناه: أثم يأثم إثما، وفي تأويل هذه الآية وجهان:

أحدهما أن الإثم والمذنب، لا يؤخذ بذنبه غيره، والوجه الثاني: أنه لا ينبغي للإنسان أن يعمل بالإثم؛ لأن غيره عمله [٤]، كما قال الكفار: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴾[٥].

واعلم أن الناس تمسكوا بهذه الآية في إثبات أحكام كثيرة:

الحكم الأول:

في الآية دلالة على أنه تعالى لا يعذب الأطفال بكفر آبائهم، وإلا لكان الطفل مؤاخذا بذنب أبيه، وذلك على خلاف ظاهر هذه الآية.

الحكم الثاني:

روى ابن عمر –رضي الله عنهما– عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الميت ليعذب ببكاء أهله))[٦]

فعائشة –رضي الله عنها– طعنت في صحة هذا الخبر، واحتجت على صحة ذلك الطعن بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾[٧]، فإن تعذيب الميت بسبب بكاء أهله أخذ للإنسان بجرم غيره، وذلك خلاف هذه الآية.

الحكم الثالث:

دلت هذه الآية على أن الوزر والإثم ليس من فعل الله تعالى وبيانه من وجوه:

أحدها: أنه لو كان كذلك لامتنع أن يؤاخذ العبد به كما لا يؤاخذ بوزر غيره.

---

(١) الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد الله شمس الدين الأنصاري الخزرجي القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، ط/٢، ت:١٣٨٤هـ – ١٩٦٤ م، القاهرة، ج١٧، ص:١١٣.

(٢) سورة النجم الآية: ٣٨.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ١٥.

(٤) معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب ط١، ت: ١٤٠٨ هـ – ١٩٨٨م، بيروت، ج٣، ص: ٢٣١.

(٥) سورة الزخرف، الآية: ٢٢.

(٦) أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الجنائز، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان النوح من سنته ' برقم: (١٢٨٦)، ج ٢، ص:٧٩.

(٧) سورة الأنعام، الآية: ١٦٤.

وثانيها: أنه كان يجب ارتفاع الوزر أصلاً؛ لأن الوازر إنما يصح أن يوصف بذلك إذا كان مختارا يمكنه التحرز، ولهذا المعنى لا يوصف الصبي بهذا.

الحكم الرابع:

أن جماعة من قدماء الفقهاء امتنعوا من ضرب الدية على العاقلة، وقالوا: لأن ذلك يقتضي مؤاخذة الإنسان بسبب فعل الغير، وذلك على مضادة هذه الآية، وأجيب عنه بأن المخطئ ليس بمؤاخذ على ذلك الفعل، فكيف يصير غيره مؤاخذا بسبب ذلك الفعل، بل ذلك تكليف واقع على سبيل الابتداء من الله تعالى(١).

المطلب الثاني: تاريخ وتطور المسئولية الجنائية في القانون

كانت القوانين الوضعية بشكل عام في العصور الوسطى وإلى ما قبل الثورة الفرنسية تجعل الإنسان والحيوان بل الجماد محلاً للمسئولية الجنائية، وكان الجماد يعاقب كالحيوان على ما نسب إليه من أفعال ضارة، كما يعاقب الإنسان على ما ينسب إليه من أفعال محرمة، وكانت العقوبة تصيب الأموات كما تصيب الأحياء، ولم يكن الموت من الأسباب التي تعفي الميت من المحاكمة والعقاب، ولم يكن الإنسان مسئولاً جنائياً عن أعماله فقط، وإنما كان يسأل عن عمل غيره ولو لم يكن عالماً بعمل هذا الغير، ولو لم يكن له سلطان فعليٌ على هذا الغير؛ فكانت العقوبة تتعدى المجرم إلى أهله وأصدقائه، وتصيبهم كما تصيبه؛ وهو وحده الجاني وهم البرءاء من جنايته(٢).

وكان الإنسان يعتبر مسئولاً جنائياً عن عمله، سواء كان رجلاً أو طفلاً مميزاً أو غير مميز، وسواء كان مختاراً أو غير مختار، مدركاً أو فاقد الإدراك(٣).

أما فيما يتعلق بما في تطور المسئولية الجنائية خصوصا في قانون العقوبات الصومالي الجنائي لا يوجد له تاريخ وتطور مدون، ولعل السبب الرئيس يرجع إلى عدم إعطاء اهتمام لشرح قانون العقوبات الصومالي جنائيا أو مدنيا، بخلاف ما كان عليه قوانين أكثر دول العالم من الشرح عليها وتحليل ما تحتاج إليه.

أما تاريخ المسئولية الجنائية في القوانين الأخرى فهي قبل اليوم لم تمثل إلا مزيجا أو خليطا من المفاهيم، فقد كان الحديث عن المسئولية الجنائية في الفكر القانوني القديم حديثا عن المسئولية المدنية أيضا، كما اختلط مفهوم الجريمة بالخطيئة الدينية والعقوبة بالكـــفـــارة،

---

(١) مفاتيح الغيب، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين أبو عبد الله التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، دار إحياء التراث العربي، ط/٣، ت:١٤٢٠ هـــ، بيروت، ج٢٠/ص:٣١٢.

(٢) التشريع الجنائي، عبد القادر عودة، مرجع سابق ، ج١/ص:٣٨١.

(٣) المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.

والقصد الجنائي بالخطأ والإهمال مما جعل أحكامها مزيجا مختلطا بين الدين والقانون في أغلب صورها.

وبناء على ما سلف فقد اختلف مفهوم المسئولية الجنائية باختلاف حالة العصر التي سادت فيه نظرا لما لها من علاقة بنظم المجتمعات، وبما أن قواعد القانون تخضع في تكوّنها لمؤثرات بيئية فلاشك أن القانون الجنائي الذي ساد وقتئذ كان له طابعه الخاص بالنظر لتلك المعتقدات، لذا فإنّا نجد بصمات رجال الدين في المجال القانوني بيّنة واضحة في فترة امتزج فيها الدين بالقانون إلى حد بعيد[١].

(١) المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي، القانون الجزائري نموذجا، مرجع سابق، ص:١٤-١٥.

المبحث الثالث: شروط المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي:

تمهيد: ولما كانت الأوامر والنواهي تكاليف شرعية فإنها لا توجه إلا لكل عاقل فاهم للتكليف؛ إذ التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال كالجماد والبهيمة، ومن استطاع أن يفهم أصل الخطاب ولا يفهم تفاصيله من كونه أمراً أو نهياً أو مقتضياً للثواب والعقاب، كالمجنون والصبي الذي لا يميز، فهو في عجزه عن فهم التفاصيل كالجماد والبهيمة في العجز عن فهم أصل الخطاب.

ومن ثم يتعذر تكليفه؛ لأن المقصود من التكليف فهو يتوقف على فهم تفاصيله كما يتوقف أيضاً على فهم أصل الخطاب.

ومن هنا لابد من وجود شروط لكي يكون الشخص مسئولا عن أفعاله، فهذه الشروط باختصار هي: الإدراك والتمييز والاختيار، فإذا انتفت هذه يحصل ما يسمى بموانع المسئولية الجنائية، وعلى هذا يكون هذا المبحث في المطالب التالية:

المطلب الأول: الإدراك والتمييز في الفقه الإسلامي

الفرع الأول: الإدراك

الإدراك لغة: اللحاق، يقال: مشى حتى أدركه وعاش حتى أدرك زمانه، و أدركه ببصره أي رآه، و أدرك الغلام والثمر، أي بلغ. واستدرك ما فات و تداركه بمعنى، و تدارك القوم تلاحقوا أي لحق آخرهم أولهم[١]، ومنه: قوله تعالى:﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا ﴾[٢]، ومنه الدرك الأعلى والدرك الأسفل، يقال أدركت الثمرة إذا وصلت وبلغت حد الكمال والتصور[٣].

أما اصطلاحا فهو: وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها بلا حكم معه من إيقاع النسبة أو لا وقوعها، وهو التصور، أما وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه، فيسمى شعورا، أو بحكم، فيسمى التصديق[٤].

---

(١) مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر أبو عبد الله زين الدين الحنفي الرازي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ، المكتبة العصرية، ط٥، ت: ١٤٢٠هـ – ١٩٩٩م، بيروت، ص:١٠٤.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٣٨.

(٣) نشر البنود على مراقي السعود، عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، تحقيق: الداي ولد سيدي بابا – أحمد رمزي، مطبعة فضالة، بدون الطبعة، والتاريخ، المغرب، ج١/ص:٦٠.

(٤) غاية الوصول في شرح لب الأصول، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا أبو يحيى زين الدين السنيكي الأنصاري، دار الكتب العربية الكبرى، بدون الطبعة، والتاريخ، مصر، ج١/ص:٢٢.

وأول مراتب وصول العلم إلى النفس: الشعور، ثم الإدراك، ثم الحفظ: وهو استحكام المعقول في العقل، ثم التذكر: وهو محاولة النفس استرجاع ما زال من المعلومات، ثم الذكر: وهو رجوع الصورة المطلوبة إلى الذهن، ثم الفهم: وهو التعلق غالبا بلفظ من مخاطبك، ثم الفقه: وهو العلم بغرض المخاطب من خطابه، ثم الدراية: وهو المعرفة الحاصلة بعد تردد مقدمات، ثم اليقين: وهو أن تعلم الشيء ولا تتخيل خلافه، ثم الذهن: وهو قوة استعدادها لكسب العلوم غير الحاصلة، ثم الفكر: وهو الانتقال من المطالب إلى المبادئ ورجوعها من المبادئ إلى المطالب، ثم الحدس: وهو الذي يتميز به عمل الفكر، ثم الذكاء: وهو قوة الحدس، ثم الفطنة: وهي التنبه للشيء الذي يقصد معرفته، ثم الكيس: وهو استنباط الأنفع، ثم الرأي: وهو استحضار المقدمات وإجالة الخاطر فيها، ثم التبين: وهو علم يحصل بعد الالتباس، ثم الاستبصار: وهو العلم بعد التأمل، ثم الإحاطة: وهي العلم بالشيء من جميع وجوهه، ثم الظن: وهو أخذ طرفي الشك بصفة الرجحان، ثم العقل: وهو جوهر تدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة[١].

والمسئولية الجنائية لا يتحملها المجنون؛ لأنه غير مكلف،ومقتضى التكليف الامتثال، وهو قصد الطاعة بفعل المأمور وترك المنهي تحقيقا لامتحان المكلف، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾[٢]، ولا يتصور قصد الامتثال وقصد الطاعة في حق المجنون؛ لأن القصد إنما يكون بعد الفهم، والمجنون لا يفهم، ومن لا يفهم الخطاب لا يتصور منه قصد مقتضاه[٣]، ولأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – ذكر أنه رفع التكليف عن المجنون بقوله صلى الله عليه وسلم: ((رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق)).[٤]

---

(١) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيب بن موسى أبو البقاء الحسيني القريمي الحنفي، الكفوي، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بدون الطبعة، والتاريخ، بيروت، ص:٦٧.

(٢) سورة هود، الآية: ٧.

(٣) شرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي بن الكريم أبو الربيع نجم الدين، الطوفي الصرصري، تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط١، ت: ١٤٠٧ هـ – ١٩٨٧ م، بدون مكان النشر، ج١/ص:١٨١.

(٤) أخرجه النسائي، في سننه، كتاب الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج، برقم: (٣٤٣٢)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية ، ط ٢، ت: ١٤٠٦ ه– ١٩٨٦م، حلب – سوريا،ج ٦، ص: ١٥٦، وابن ماجه، في سننه، أبواب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم: (٢٠٤١)، كلاهما عن عائشة، ج ٣، ص: ١٩٨، وفي الصفحة نفسها قال شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد – محمَّد كامل قره بللي – عبد اللطيف حرز الله: إسناده صحيح.

الفرع الثاني: التمييز:

تعريف التمييز لغة، هو العزل والفرز والفرق بين الشيئين، ويقال فيه أيضا: التفضيل على الشيء، ومنه ميز الأخ من غيره[١].

تعريف التمييز اصطلاحا:

التمييز هو: فهم الخطاب، ومعرفة ما يضر وما ينفع [٢]. والمميز اختلف الفقهاء في تحديد معناه، لاختلاف زاوية التمييز التي ينظر إليها الكل، ويتخطى الطفل إلى مرحلة التمييز، ويكون بها مميزا، ومن هنا يمكن تعريف المميز بأنه هو: الإنسان الذي صار بحيث يأكل وحده، ويشرب وحده، ويستنجي وحده [٣]، وقيل هو الذي يعرف يمينه من شماله[٤].

وقيل هو الذي يعرف ما يضره وينفعه [٥]، وقيل هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، أو أنه هو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام، ولا ينضبط بسن مخصوص بل يختلف باختلاف الأفهام [٦].

ويتبين من هذا أن الصبي: المميز وغير المميز لا يتحمل المسئولية الجنائية؛ لأنه غير مكلف؛ لأنه لا فهم له، ولا قصد، كما تقدم بيانه في المجنون، ولأن الشارع رفع عنه التكليف بقوله – صلى الله عليه وسلم –: «وعن الصغير حتى يكبر»[٧]، وهذا يشمل المميز وغير المميز؛ لأن المميز

---

(١) معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ج٣/ص:٢١٤٤.

(٢) شرح الزُّرقاني على مختصر خليل، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري، تحريج: عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢٢ هـ – ٢٠٠٢ م، بيروت–لبنان، ج ٦/ص:٢٤٨، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل، محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله شمس الدين الطرابلسي المغربي، الرُّعيني المالكي المعروف بالحطاب، دار الفكر، ط٣، ت: ١٤١٢هـ – ١٩٩٢م، بدون مكان النشر، ج٢، ص: ٤٨٢، و إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، عثمان بن محمد شطا أبو بكر الدمياطي الشافعي (المشهور بالبكري)، دار الفكر، ط١، ت: ١٤١٨ هـ – ١٩٩٧ م، بدون مكان النشر، ج١، ص: ٣٣.

(٣) فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل، دار الفكر ، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر ، ج١/ص:٢٨٩.

(٤) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد شمس الدين بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار الفكر، بدون الطبعة، ت: ١٤٠٤ه–١٩٨٤م، بيروت، ج١، ص: ٣٩٠.

(٥) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، مرجع سابق، ج١، ص: ٣٣.

(٦) شرح الزُّرقاني على مختصر خليل، مرجع سابق، ج ٦/ص:٢٤٨، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج٢، ص: ٤٨٢.

(٧) سبق تخريجه، ص: ٢٦.

مع كونه يفهم لكن فهمه لم يكمل فيما يتعلق بالقصد إلى الامتثال قصدًا صحيحًا فجعل الشارع البلوغ علامة لظهور العقل[١].

ويتضح مما سبق أن الصبي والمجنون: غير مكلفين؛ لأن مقتضى التكليف: الطاعة والامتثال، ولا تمكن إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد العلم بالمقصود، والفهم للتكليف؛ إذ من لا يفهم كيف يقال له افهم؟، ومن لا يسمع الصوت كالجماد كيف يكلم؟ وإن سمع ولم يفهم كالبهيمة، فهو كمن لا يسمع، ومن يفهم فهما ما "لكنه لا يفهم ولا يثبت كالمجنون وغير المميز فخطابه ممكن، لكن اقتضاء الامتثال منه –مع أنه لا يصح منه قصد صحيح– غير ممكن، ووجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون ليس تكليفًا لهما؛ إذ يستحيل التكليف بفعل الغير[٢].

ومن أجل ذلك عرفوا التكليف بأنه هو: الفهم، فالغافل في حالة غفلته، والناسي في حالة نسيانه، والساهي في حالة سهوه، والنائم في حالة نومه، والمغمى عليه في حالة الإغماء لا يدركون معنى الخطاب [٣].

والإنسان في طريقه إلى البلوغ يمر بمراحل، قال تعالى: ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴾[٤]، وهذه الأطوار تكون بمجموعها في ثلاث مراحل وهذه الثلاثة كلها مأخوذة من القرآن الكريم أو من السنة النبوية الشريفة:

المرحلة الأولى: من الولادة إلى سن التميز:

وهذه المرحلة يكون الولد فيها غير مميز، ولا عقل له، فلا يصح له تصرف من التصرفات الشرعية، ولا يؤاخذ على شيء من أفعاله مؤاخذة جسدية؛ لأن البلوغ هو شرط توقيعها، ولكنه يضمن في ماله ما يتلفه [٥]، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ﴾[٦].

---

(١) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمّد بنْ حسيْن بن حَسنْ الجيزاني، دار ابن الجوزي، ط٥، ت:١٤٢٧ ه، بدون مكان النشر، ص:٣٤٦.

(٢) روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة أبو محمد موفق الدين الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، مؤسسة الريان، ط٢، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م، بدون مكان النشر. ،ج١/ص:١٥٥

(٣) المهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ المُقَارَنِ، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد، ط١، ت: ١٤٢٠ هـ – ١٩٩٩ م، الرياض– المملكة العربية السعودية، ج١/ص:٣٣٧.

(٤) سورة نوح، آية: ١٤.

(٥) منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، يحيى بن شرف أبو زكريا محيي الدين النووي، تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، ط١، ت:١٤٢٥هـ – ٢٠٠٥م، بدون مكان النشر، ص:١٢٣، و المغني، مرجع سابق، ج٩، ص:٣١١، و الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل أبو الحسن برهان الدين، الفرغاني المرغيناني، تحقيق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي، بدون الطبعة، والتاريخ، بيروت – لبنان، ج٣، ص: ٢٨١.

(٦) سورة الحج، آية:٥.

المرحلة الثانية: من التميز إلى قبيل البلوغ:

وهذه المرحلة مأخوذة من قول علي- كرم الله وجهه- لعمر -رضي الله عنه- أما علمت: ((أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ))[١].

وفي هذا الحديث دلالة على أن المميز لا تكليف عليه حتى يبلغ، وخاصة في قوله صلى الله عليه وسلم: ((وعن الصبي حتى يدرك)).

المرحلة الثالثة: العقل و البلوغ:

أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه المرحلة، حيث قال: ﴿ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ﴾[٢]، وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمْ ﴾ [٣]، وهذه هي المرحلة الوحيدة التي إن وصلها الإنسان قامت مسئوليته عن كل أفعاله، فإن قتل أقتص منه، وإن سرق قطعت يداه، وإن زنا حد، وهكذا إلى آخره.

ثم إن الفقهاء اختلفوا في تحديد السن المعتبر للبلوغ على النحو التالي:

القول الأول: أن بلوغ الذكر يكون بإتمامه ثماني عشرة سنة، وبلوغ الأنثى يكون بإتمامها سبع عشرة سنة، وهذا قول الحنفية والمالكية [٤].

والدليل على ذلك:

قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ﴾ [٥]، وأشد الصبي ثماني عشرة سنة، كذا قال ابن عباس -رضي الله عنهما- وهو أقل ما قيل في الأشد فيبنى الحكم عليه للتيقن به [٦].

القول الثاني: قول الجمهور من الشافعية والحنابلة، وهو رواية عن أبي حنيفة، ويفتى به، و به قال أبو يوسف ومحمد، وهو تحديد سن البلوغ بخمس عشرة سنة في الذكر والأنثى[٧].

---

(١) سبق تخريجه، ص: ٢١.

(٢) سورة النساء، آية: ٦.

(٣) سورة غافر، آية: ٧٦.

(٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج٧/ص:١٧٢، وشرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الخرشي المالكي ، دار الفكر، بدون الطبعة، والتاريخ، بيروت، ج٥، ص:٢٩١.

(٥) سورة الإسراء، الآية: ٣٤.

(٦) العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أبو عبد الله أكمل الدين ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، دار الفكر، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر، ج٩، ص: ٢٧٠.

(٧) الهداية في شرح بداية المبتدي، مرجع سابق، ج٣، ص: ٢٨١، ومنهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، مرجع سابق، ص:١٢٣، و المغني، مرجع سابق، ج٩، ص:٣١١.

والدليل على ذلك:

١- أن ابن عمر -رضي الله عنهما- ذكر: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني)) [١].

فاتضح أن: قول الجمهور هو الراجح من اعتبار السن الخامس عشر حدا للبلوغ ، لما يلي:

١. لحديث ابن عمر السابق.
٢. لقصر أعمار أهل زماننا.
١. لأنها العادة الغالبة على أهله، والعادة إحدى الحجج الشرعية فيما لا نص فيه[٢].

المطلب الثاني: الإدراك والتمييز في القانون

الإدراك والتمييز تقدم معناهما في المطلب السابق، وكذلك حكمهما في الفقه الإسلامي، فإن القانون لا يخالف فيهما كثيرا الفقه الإسلامي؛ فإن قانون العقوبات الصومالي نص على أنه ١- "لا يجوز معاقبة شخص على فعل مكون بجريمة إذا لم يكن مسئولا في وقت ارتكابه الفعل"[٣].

يشترط لقيام المسئولية الجنائية وجود الإرادة الحرة عند الجاني، وهي لا تكون كذلك إلا إذا توافر لديه التمييز والإدراك، ومعنى هذا أن المسئولية الجنائية تتغير بتغير عناصر الإرادة والحرية والإدراك والتمييز لدى الشخص وجودا وعدما، كمالا ونقصا، وحكم هذه الأربعة في القانون كحكمها في الفقه الإسلامي. وهذه المادة تشمل المجنون والصبي.

وبناء على ذلك فإن الإنسان باعتبار المسئولية الجنائية يمر بمراحل، وهي تكون بمجموعها في ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: من الولادة إلى أربعة عشر عاما

اعتبر قانون العقوبات الصومالي الإنسان بهذه المرحلة غير مسئول مطلقا، ولذلك نص "الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن أربعة عشر عاما:

لا مسئولية على الشخص الذي لم يبلغ وقت ارتكابه الفعل أربعة عشر عاما"[٤]، وهذه المرحلة مأخوذة من هذه المادة نصا، ويمكن أيضا أن تؤخذ استنباطا من النص الذي يقرر

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادت، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، برقم: (٢٦٦٤)، ج٣، ص: ١٧٧، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، برقم: (١٨٦٨)، ج ٣، ص: ١٤٩٠.

(٢) رد المحتار على الدر المختار، محمد بن (محمد أمين المعروف بابن عابدين) بن عمر بن عبد العزيز عابدين علاء الدين الحسيني الدمشقي، دار الفكر، ط٢، ت: ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، -بيروت، ج ٦، ص: ١٥٤.

(٣) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٤٧ ف: (١).

(٤) المرجع السابق، م: ٥٩.

أن "لا مسئولية على كل من كان وقت ارتكاب الفعل في حالة عقلية تمنع مقدرته على الإدراك والإرادة بسبب قصوره العقلي[١]، فعلى هذا تكون هذه المادة عامة، والأولى خاصة.

المرحلة الثانية: من أربعة عشر إلى ثمانية عشر عاما:

نص قانون العقوبات الصومالي على هذه المرحلة في قوله: "الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن الثمانية عشر عاما:

١- إذا كان سن الصغير وقت ارتكاب الجريمة قد جاوزت أربعة عشر سنة ولم يبلغ ثمانية عشر سنة، اعتبر مسئولا إذا توافرت لديه القدرة على الإدراك والاختيار، على أن تخفض العقوبة في هذه الحالة[٢]"؛ لأنه لما كانت المادة رقم (٥٠) عامة في كل من لا إدراك ولا إدارة له، فُهم منها أن الإنسان إذا توفر فيه هذان الشرطان يكون مسئولا جنائيا، ولكن القانون قيد هذا المفهوم بأنه لا بد من بلوغه سنا يكون فيها مسئولا، وهو ثمانية عشر عاما، وأما إذا لم يبلغ ذلك وقد جاوز أربعة عشر عاما نص قانون العقوبات الصومالي في المادة (٦٠) السالفة على أنه يكون له مسئولية مخففة كما تقدم.

المرحلة الثالثة: من الثمانية عشرة عاما وما بعدها:

وهذه المرحلة هي التي يكون الإنسان فيها إن وصلها مسئولا عن كل أفعاله، فإن ارتكب جريمة يعاقب عليها، هذا ما نص عليه قانون العقوبات الصومالي حينما نص: ٢- "كل من كانت لديه القدرة على الإدراك والإرادة يعد مسئولا " [٣].

فما مدى موافقة القانون للفقه الإسلامي ومخالفته في حد البلوغ بالسن

فقانون العقوبات الصومالي يوافق في هذه المرحلة المذهب الحنفي والمشهور عند المالكية، إلا أنهم فرقوا بين الغلام والجارية؛ لأن مدة البلوغ بالسن عندهم في الغلام ثماني عشرة سنة، وفي الجارية سبع عشرة سنة بينما القانون يشترط في بلوغهما ثماني عشرة سنة في كليهما.

---

(١) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٥٠.

(٢) المرجع السابق، م: ٦٠، ف: (١).

(٣) المرجع السابق، م: ٤٧، ف: (٢).

المطلب الثالث: الاختيار في الفقه الإسلامي

الاختيار لغة: مصدر اختار، وهو الانتقاء وتفضيل الشيء على غيره، والإتيان بالتصرف على الوجه الذي يريد،وهو ضد الإكراه، وترجيح تصرف على غيره[١].

واصطلاحا: ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديمه على غيره وهو أخص من الإرادة[٢]، وإذا لم يكن الشخص مختارا في أفعاله يكون فاقدا الأهلية التي هي صلاحية الشخص، ومحليته للحقوق المشروعة التي تثبت له أو عليه؛ فلابد من اعتبارها في التصرفات، فإذا فقد الإنسان الأهلية، أصبح بفقدها عادمًا للحرية الاختيارية؛ إما بسبب النوم الذي أفقده الاستيقاظ لأداء واجباته، أو بسبب حداثة السن والصغر الذي هو معها فاقد للأهلية، أو بسبب الجنون الذي اضطربت معه وظائفه العقلية ففقد التمييز والتصور الصحيحين، فانتفت عنه الأهلية بسبب من هذه الأسباب الثلاثة؛ فإن الله تبارك وتعالى بعدله، وحلمه، وكرمه، قد رفع عنه المؤاخذة، بما يصدر عنه من تعدٍّ، أو تقصير طالما أنه يكون فاقدا للحرية الاختيارية [٣].

فيمتنع تكليف الملجأ، وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل مع حضور عقله، كمن يلقى من شاهق، فهو لا بد له من الوقوع، ولا اختيار له فيه، ولا هو بفاعل له، وإنما هو آلة محضة كالسكين في يد القاطع، وحركة كحركة المرتعش ومثله المضطر.[٤].

المطلب الرابع: الاختيار في القانون.

الاختيار معناه لغة واصطلاحا فقد تقدم في المطلب السالف ذكره، وأما حكمه في القانون فليس بعيدا عن حكمه في الفقه الإسلامي، فالإرادة تغاير حرية الاختيار، فالأول هو: ترجيح أحد الأمرين أو الأمور على الآخر[٥]، فالإرادة تتعلق بالسلوك والقصد، والثاني يتعلق بالفعل وعدم الفعل" ولا ينبغي الخلط بين تجرد الشخص من حرية الاختيار وبين انعدام إرادتـــه؛ لأن

---

(١) معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبي، دار النفائس، ط٢، ت:١٤٠٨ه-١٩٨٨م، بدون مكان النشر، ص:٥٠.

(٢) التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية، ط١، ت:١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، بدون مكان النشر، ص:٢٠.

(٣) توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم أبو عبد الرحمن البسام التميمي، مكتبة الأسدي، ط ٥، ت ١٤٢٣ هـ-٢٠٠٣م، مكّة المكرّمة - المملكة العربية السعودية، ج٥، ص:٥١٩.

(٤) البحر المحيط في أصول الفقه، محمد بن عبد الله بن بهادر أبو عبد الله بدر الدين الزركشي، دار الكتبي، ط١، ت: ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م، بدون مكان النشر، ج ٢/ص:٧٣.

(٥) دستور العلماء، عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، دار الكتب العلمية، ط١، ت: ١٤٢١ه - ٢٠٠٠م، بيروت - لبنان، ج١/ص:٤٤.

التلازم بين الأمرين غير مطرد، فقد يتجرد الشخص من تلك الحرية ومع ذلك لا تنعدم إرادته، وهذه التفرقة لازمة؛ لأن حرية الاختيار شرط لقيام المسئولية أما الإرادة فلازمة لقيام الحرية، والحقيقة أن حرية الاختيار بهذا المعنى هي الاستطاعة والقدرة يتمكن بها الإنسان من الفعل والترك، أما الإرادة فهي: صفة توجب للحي حالًا يقع منه الفعل على وجهٍ دون وجه [١].

فالاختيار شرط في القانون كما هو مشروط في الفقه الإسلامي، وقد نص قانون العقوبات الصومالي على أن:

٢- كل من كانت لديه القدرة على الإدراك والإرادة يعد مسئولا [٢].

تبين هذه المادة من قانون العقوبات الصومالي أنه يشترط لتوفير المسئولية الجزائية توفر عنصرين معاً وهما الوعي والاختيار.

١. الوعي: ويقصد به التمييز أي المقدرة على فهم ماهية الفعل وطبيعته وتوقع الآثار التي تنشأ عنه، ولا يعني الوعي العلم بالتكييف القانوني حيث أن العلم بالقانون مفترض، ولا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون [٣].

٢. الاختيار: وتعني حرية الاختيار أي مقدرة المجرم على تحديد الوجهة التي تتخذها إرادته أي مقدرته على توجيه إرادته إلى وجهة معينة [٤].

وسيأتي معنى الاكراه إن شاء الله بمعنى أنه عدم هذا الاختيار أو هو الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان، طبعًا أو شرعًا[٥]، يبدو أن الإنسان إذا لم يكن متصفا بالاختيار يكون متصفا بالإكراه، فتنعدم المسئولية الجنائية بسبب ذلك.

ثم إن هناك أسبابا أخرى غير الإكراه قد تنعدم الإرادة والاختيار بسببها، كالجنون أو العاهات العقلية الأخرى أو السكر والمخدرات، فهذه الأسباب ستأتي كلها إن شاء الله تعالى عند الكلام على موانع المسئولية الجنائية في الفصل الثالث الذي يتضمن موانع المسئولية الجنائية مطلقا، أي: سواء في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.

---

(١) التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، دار الكتب العلمية، ط١، ت:١٤٠٣ه - ١٩٨٣م، بيروت – لبنان، ص:١٦.

(٢) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٤٧، ف (٢).

(٣) نظرية الغلط في قانون العقوبات المقارن، محمد خصر السبعاوي، الركز القومي للإصدرات القانونية،ط ١، ت: ٢٠١٣م، بدون مكان النشر، ص: ٤٠٣

(٤) أساسيات علم النفس الجنائي ونظرياته، صالح حسن أحمد الداهري، درا الحامد، ط ١، ت: ٢٠١١، عمان – الأردن، ص: ٣١٣.

(٥) التعريفات، مرجع سابق، ص: ٣٣.

فعلى أية حالة فإن توافر الاختيار في الجاني حال فعل الجريمة فإنه تقوم المسئولية الجنائية، وبالتالي يكون المجرم مسئولا مسئولية جنائية، كما نص عليه قانون العقوبات الصومالي، من أن:٢- "كل من كانت لديه القدرة على الإدراك والإرادة يعد مسئولا" (١).

أي: إذا كان الشخص قادرا على الإدراك والإرادة فإن المسئولية الجنائية قائمة، وبالتالي فهو مسئول مسئولية جنائية.

فما مدى موافقة القانون للفقه الإسلامي ومخالفته في اشتراط الاختيار في قيام المسئولية الجنائية

ليس هناك خلاف بين الفقه الإسلامي والقانون حول اشتراط الاختيار في قيام المسئولية الجنائية، فإذا وجد الاختيار في مرتكب الجريمة يكون مسئولا جنائيا في الفقه الإسلامي والقانون.

الخلاصة:

يستخلص مما سبق أن معنى المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي هو: أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختاراً وهو مدرك لمعانيها ونتائجها، فمن أتى فعلاً محرماً وهو لا يريده كالمكره أو المغمى عليه لا يسأل جنائياً عن فعله، ومن أتى فعلاً محرماً وهو يريده ولكنه لا يدرك معناه كالطفل أو المجنون لا يسأل أيضاً عن فعله، وفي القانون إنها: القدرة على الإدراك والإرادة.

وأن الفقهاء من المتقدمين لم يستعملوا هذه الكلمة بلفظها، بل بمرادفها، مثل: الضمان، وأنه لم يخضع الفقه الإسلامي الجنائي في قواعده وأسسه إلى التطور والتغيير إلا ما كان منه في مسائل اجتهادية معروفة ترك الشارع الحكيم أمره لأولي الأمر عبر الأزمان، وهي المسائل التي من شأنها أن تبرهن على صلاحية هذا النظام وفعاليته في مواجهة كل تغيير

أما فيما يتعلق بما في تطور المسئولية الجنائية في قانون العقوبات الصومال الجنائي لم يجد الباحث له تاريخا وتطورا مدونا، ولعل السبب الرئيس يرجع إلى عدم إعطاء اهتمام لشرح قانون العقوبات الصومالي جنائيا أو مدنيا، وأما في القوانين الأخرى فهي قبل اليوم لم تمثل إلا مزيجا أو خليطا من المفاهيم، فإذا أطلقت المسئولية الجنائية في الفكر القانوني القديم تنصرف إلى المسئولية المدنية.

وأما شروط المسئولية الجنائية فهي تنحصر في اثنين: الإدراك، والاختيار، فأن المسئولية الجنائية تتغير بتغير عنصري الإدراك والاختيار لدى الشخص وجودا وعدما، كمالا ونقصاء فإذا لم يكن الشخص مدركا ولا مختارا في أفعاله فلا تكون عليه مسئولية جنائية.

---

(١) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م:٤٧، فـ(٢).

الفصل الثاني: محل المسئولية الجنائية وسببها وصور قصدها ودرجاتها في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.

المبحث الأول: محل المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي

المطلب الأول: الإنسان محلّ المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي.

المطلب الثاني: الإنسان محلّ المسئولية الجنائية في القانون

المطلب الثالث: المسئولية الجنائية شخصية في الفقه الإسلامي.

المطلب الرابع: المسئولية الجنائية شخصية في القانون.

المبحث الثاني: سبب المسئولية الجنائية وصور قصدها في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.

المطلب الأول: سبب المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي .

المطلب الثاني: سبب المسئولية الجنائية في القانون.

المطلب الثالث: صور قصد المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي.

المطلب الرابع: صور قصد المسئولية الجنائية في القانون.

المبحث الثالث: درجات المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي

المطلب الأول: درجة مسئولية العمد في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني: درجة مسئولية العمد في القانون

المطلب الثالث: درجة مسئولية شبه العمد في الفقه الإسلامي

المطلب الرابع: درجة مسئولية شبه العمد (الضرب المفضي إلى الموت) في القانون

المطلب الخامس: درجة مسئولية الخطأ في الفقه الإسلامي

المطلب السادس: درجة مسئولية الخطأ في القانون

الفصل الثاني: محل المسئولية الجنائية وسببها وصور قصدها ودرجاتها في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي

تمهيد: يادئ كل ذي بدء فمحل المسئولية الجنائية مطلقا، –أي: سواء كانت في الفقه الإسلامي أو في قانون العقوبات الصومالي أو في القوانين الوضعية الأخرى بشكل عام– ينتج من شروط المسئولية الجنائية التي تقدمت في الفصل الأول، وهي بصفة عامة: الإدراك والتمييز والاختيار، ومن المعلوم أن الحيوان غير الإنسان الذي لا يعقل لا يعتبر مكلفا، وبالتالي لا يسأل جنائيا، كما سيأتي بيانه، وأن الإنسان الذي يسأل هو الذي ارتكب الجريمة فقط، لا غيره إلا العاقلة فإنهم يتحملون فعل غيرهم مع خلاف بين الفقهاء في شبه العمد، وأن كل عقوبة – سواء كانت في الفقه الإسلامي أو في قانون العقوبات الصومالي أو القوانين الوضعية الأخرى – لا يمكن توقيعها إلا بسبب شرعي، فسبب المسئولية الجنائية هو السلوك الضار بالمجتمع باعتبار ما يمثله من خطورة كما سيأتي بيانه، وأن الشخص يكون مخالفا للفقه الإسلامي والقانون الوضعي إذا ارتكب فعلا يحظره الفقه الإسلامي والقانون ويمنعانه، فالجريمة هي فعل أو امتناع عن فعل، ولا يمكن توقيعها أيضا على كل شخص مجرم، وإنما لا بد من أن يكون له قصد جنائي، ويعني أنه لا بد من أن ينظر إلى نية الجاني من حيث إنه هل حصلت الجريمة منه عن طريق درجة العمد أو شبه العمد أو الخطأ؟

وعلى هذا تكون خطة هذا الفصل في ثلاثة مباحث، وهي كالتالي:

المبحث الأول: محل المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي

والكلام على محل المسئولية الجنائية ينبني على شروط المسئولية الجنائية التي تقدمت، وهي: الإدراك والتمييز والاختيار كما مر، ومن هنا يتضح أن هذا المبحث يتضمن أولا البيان على أن الإنسان هو المسئول جنائيا وحده، ولا يتحمل غيره المسئولية الجنائية مثل الجمادات والحيوات غير الإنسان، في الفقه الإسلامي، وثانيا فالإنسان هو المسئول وحده جنائيا في القوانين الوضعية، وأنه لا يتحمل أحد غير الجريمة التي ارتكبها، وهذا مبدأ شخصية المسئولية، ويأتي ذلك على المطالب الآتية:

المطلب الأول: الإنسان محلّ المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي.

المطلب الثاني :الإنسان محلّ المسئولية الجنائية في القانون.

المطلب الثالث :المسئولية الجنائية شخصية في الفقه الإسلامي.

المطلب الرابع :المسئولية الجنائية شخصية في القانون.

المطلب الأول: الإنسان محلّ المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي.

اشترط الفقه الإسلامي في المسائل الجناية العقل والاختيار؛ لأن معنى التكليف هو البلوغ والعقل، فالحيوان غير الإنسان لا يعقل؛ ولا بد لحمل المسئولية الجنائية من الإرادة، والإرادة لا تكون إلا للإنسان، وقد نُقِل أنه لا خلاف عند العلماء في أن الحيوانات كلها لها أفهام وعقول، ولهذا قال الشافعي: الحمام أعقل الطير[١]، وأن النمل حيوان فطن قوي شمام جدا يدخر القرى ويشق الحب بقطعتين؛ لئلا ينبت، ويشق الكزبرة [٢] بأربع قطع؛ لأنها تنبت إذا قسمت شقين ويأكل في عامه نصف ما جمع، ويستبقي سائره عدة [٣].

---

(١) أحكام القرآن، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي، تعليق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط ٢، ت: ١٤٢٤ هـ -٢٠٠٣ م، بيروت – لبنان، ج٣/ص: ٤٧٢.

(٢) وتسمى النُّقْدَة، والكزبرة لغة في الكسبرة: نبات الجلجلان إذا كان رطبا. ينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، ط١، ت: ١٤١٨ ه ١٩٩٨ م، بيروت، ج١، ص: ٢٢٧، وكتاب العين، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم أبو عبد الرحمن الفراهيدي البصري، تحقيق: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر، ج ٥/ ص: ٤٢٨.

(٣) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية أبو محمد الأندلسي المحاربي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، ط ١، ت: ١٤٢٢ هـ، بيروت، ج ٤/ ص: ٢٥٣.

وقال الأستاذ أبو المظفر شَاهْفُورِ الإسفراييني [*]: ولا يبعد أن تدرك البهائم حدوث العالم، وخلق المخلوقات، ووحدانية الله، ولكنا لا نفهم عنهم، ولا تفهم عنا، أما أنا نطلبها وهي تفر منا فبحكم الجنسية [١].

فعلى هذا هل يلزم مما تقدم القول بأن البهائم فما دام لها العقل الذي هو مناط التكليف تقع عليها مسئولية؟ وإذا قيل: لا، فلما ذا؟ فما الجواب عن قول الإسفراييني؟

فالجواب عن السؤال الأول أن نقول إن مثل هذا الوصف للحيوان بالعقل لا يقصد به على الإطلاق: العقل الإنساني الذي هو ملكة حاصلة بالتجارب، يستنبط بها المصالح والأغراض، ويحصل به الوقوف على العواقب، والتمييز بين الأمور الحسنة، والقبيحة [٢]، فالبهائم ليست مكلفة؛ لأن هذا هو ما وهبه الله سبحانه من إدراكه طرق تدبير معيشته، والخضوع لخالقه، سماه القرآن الكريم هداية، وقال تعالى: ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعۡطَىٰ كُلَّ شَىۡءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ [٣].

وإنما الذي يراد بها هو ما سبق ذكره، من أن البهائم لها إدراك تدبير شؤون معاشها بالغريزة والحيلة، وإدراك ما ألهمها الله سبحانه، وركبه في طبيعة خلقها من أمور تهتدي بها إلى مصالحها، وقوام عيشها، هكذا ينبغي أن نفهم النصوص التي تتحدث عن " هداية الحيوان "، سواء في القرآن الكريم أم في السنة النبوية، ولهذا لم يكن الحيوان مكلفا أبدا؛ لأنه لا يملك العقل الذي ينمو ويدرك عواقب الأمور، ويصبح هو المحرك للفعل الحيواني.

وأما الجواب عن قول الإسفراييني فهو: ربما ذهب الإسفرايينى إلى ذلك أخذا من قوله سبحانه وتعالى: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبۡعُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّۚ وَإِن مِّن شَىۡءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡدِهِۦ وَلَٰكِن لَّا تَفۡقَهُونَ تَسۡبِيحَهُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [٤]، ونحو ذلك مما جاء في القرآن في هذا المعنى.

(*) العلامة المفتي، طاهر بن محمد أبو المظفر، الإسفراييني، ثم الطوسي الشافعي صاحب "التفسير الكبير". كان أحد الأعلام، حدث عن: ابن محمش، وأصحاب الأصم، روى عنه: زاهر الشحامي، وغيره، صاهر الأستاذ أبا منصور البغدادي، توفي بطوس في سنة إحدى وسبعين وأربع مائة، ينظر: سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز أبو عبد الله شمس الدين الذهبي، دار الحديث، بدون الطبعة، ت: ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م، – القاهرة، ج١٣/ص: ٤٨٧.

(١) الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج ١٣/ ص: ١٧٦.

(٢) شرح التلويح على التوضيح، مسعود بن عمر سعد الدين التفتازاني، مكتبة صبيح، بدون الطبعة، والتاريخ، مصر، ج/٢، ص: ٣١٢-٣١٣.

(٣) سورة طه، الآية: ٥٠.

(٤) سورة الإسراء، الآية: ٤٤.

والحاصل أن القاعدة العامة أنه لا يسال جنائيا غير الإنسان؛ لأنه لا شك في أن التكليف إنما هو فرع عن العقل والعلم والقدرة والاختيار، فغير الإنسان لا يعقل؛ لأن العقل إنما هو قوة للنفس الإنسانية بها يتمكن من إدراك الحقائق، وهذا معنى الأثر الفائض عليها من العقل.(١)

وأن العقل الذي هو مناط التكليف من خصائص الإنسان التي تميزه عن سائر الحيوان، وأن ما نشهده من سلوك الحيوانات تجاه إصلاح معاشها والتصرف بمحيطها إنما هو كما تقدم (هداية) غريزية، أودعها الله الحيوان، من غير تعقل قادر على تقبل العلوم وتطوير المهارات.

المطلب الثاني: الإنسان محلّ المسئولية الجنائية في القانون

وفي هذا المطلب يكون الكلام على أن الإنسان محلّ المسئولية الجنائية باعتبار القوانين الوضعية بشكل عام، ثم قانون العقوبات الصومالي باعتبار خاص، وذلك على النحو التالي:

أولا: القوانين الوضعية:

فالقوانين الوضعية كانت إلى عهد غير بعيد تجعل الإنسان والحيوان والجماد محلاً للمسئولية الجنائية، ولم تكن تفرق بين الإنسان الحي والميت ولا بين المميز وغير المميز ولابين المختار والمكره؛ لأنها كانت تنظر إلى الجريمة بغض النظر عن فاعلها، ومن ثم كان العاقل البالغ والصبيغيرالمميز والمجنون والمعتوه يعاقبون على جرائمهم دون النظر إلى حالاتهم وعقلياتهم، بل كان الحيوان وكذلك الجماد يعاقب على ما يمكن أن ينسب إليه من أفعال جنائية، أما اليوم بعد أن تغيرت الأسس التي كانت تقوم عليه القوانين الوضعية فإن هذه القوانين لا تعرف محلاً للمسئولية الجنائية غير الإنسان الحي، كما أنها تفرق في حكمها بين المدرك المختار وبين فاقد الإدراك والاختيار، وبهذا أصبحت في هذه النقطة المطابقة للشريعة الإسلامية(٢).

فالجريمة تفترض القيام بسلوك على أوامر المشرع أو نواهيه، وبداهة لا يكون جانيا في الجريمة ولا يسأل عنها جنائيا إلا الإنسان؛ لأنه وحده المزود بالعقل الذي يمكنه من فهم أوامر المشرع أو نواهيه، كما أنه يتمتع بالإرادة التي تتيح له ضبط تصرفاته على مقتضاها، وهذه القاعدة البديهية لم تكن كذلك قبل الثورة الفرنسية، فقد كانت قوانين العصور الوسطى تجيز محاكمة الحيوان والجماد وجثث الموتى، وكان الاعتقاد أن توقيع العقوبة عليها يطهرها من الأرواح الشريرة التي تقمصتها(٣).

---

(١) شرح التلويح على التوضيح، مرجع سابق، ج/٢، ص: ٣١٢.

(٢) التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، مرجع سابق، ج١/ص: ٣٩٤.

(٣) أي لبستها، ينظر: المحكم والمحيط الأعظم، مرجع سابق، ج ٦، ص: ٢٢٠.

ثم تطور هذا الغرض، وأصبح يقصد به ردع الكافة وإرهابهم بإظهار عدم تسامح السلطات الحاكمة إزاء أي انتهاك لأوامرها [١].

ثانيا: قانون العقوبات الصومالي:

أما قانون العقوبات الصومالي فقد تقدم أنه لا يعتبر غير الإنسان الحي مسئولا جنائيا، حيث إنه اشترط القدرة على الإدراك والإرادة، كما نصت المادة من قانون العقوبات الصومالي على النص التالي:

٢- (كل من كانت لديه القدرة على الإدراك والإرادة يعد مسئولا) [٢].

وعلى هذا كان من الطبيعي أن يكون الإنسان محل المسئولية الجنائية وحده، أما الحيوان أو الجماد فلا يمكن أن يكون محلاً للمسئولية الجنائية لانعدام الإدراك والاختيار، وإن توفر هذين الشرطين يستوجب أن يكون الإنسان المسئول عاقلاً بالغاً مختاراً، فإن لم يكن كذلك فلا مسئولية عليه؛ لأن غير العاقل لا يكون مدركاً ولا مختاراً، كما نص عليه قانون العقوبات الصومالي في مادة القصور العقلي الكلي[٣]، وكذلك من لم يبلغ سناً معيناً لا يمكن أن يقال إنه تام الإدراك والاختيار، كما نص عليه قانون العقوبات الصومالي في المادتين السالفتين[٤]، وعلى هذا فلا مسئولية على طفل ولا على مجنون أو معتوه وكل من كان فاقد الإدراك بأي سبب من الأسباب، وهكذا إلى آخره، وكل هذا فقد تقدم ذكره في الفصل الأول.

فما مدى موافقة القانون للفقه الإسلامي من حيث محلّ المسئولية الجنائية:

يبدو مما سبق أن قانون العقوبات الصومالي ذهب إلى ما ذهب إليه الفقه الإسلامي، من أن محل المسئولية الجنائية هو الإنسان الحي لا غير، فلا مخالفة بينهما.

المطلب الثالث :المسئولية الجنائية شخصية في الفقه الإسلامي

فالمسئولية الجنائية شخصية، بمعنى أنه لا يسأل عن الجرم إلا فاعله، ولا يؤخذ امرؤ بجريرة غيره مهما كانت درجة القرابة أو الصداقة بينهما، وقد قرر القرآن الكريم هذا المبدأ العادل في كثير من آياته، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾[٥]،

---

(١) شرح قانون العقوبات، القسم العام، أحمد عبد العزيز الألفي، بدون الناشر، والطبعة، ت: ١٩٨٥م، وبدون مكان النشر، ص:٣٨٣.

(٢) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٤٧، ف: (٢).

(٣) المرجع السابق، م: ٥٠.

(٤) المرجع السابق، م: ٥٩-٦٠، ف: (١).

(٥) سورة الأنعام، الآية: ١٦٤.

ومن هذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾[١]، ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ﴾ [٢]، فلا يجوز أن يؤاخذ أحد بذنب غيره؛ للآيات التي تقدمت.

ووجه دلالة هذه الآيات أنه: لا تجترح نفس إثما إلا عليها، فلا يؤخذ بما أتت من معصية الله تبارك وتعالى، وركبت من الخطيئة، سواها، بل كل ذي إثم فهو المعاقب بإثمه والمأخوذ بذنبه[٣].

وفي ذلك أحاديث تؤكد مبدأ شخصية المسئولية الجنائية، ومنها: رواية أبي رمثة، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي، فقال لرجل – أو لأبيه – «من هذا؟» قال: ابني، قال: (لا تجني عليه) [٤]، وفي رواية: (ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه) [٥].

ووجه الدلالة هو:

١– أن الإنسان لا يؤاخذ بجناية غيره، إنما يؤاخذ بجناية نفسه [٦].

قال الشافعي معلقا على حديث (لا تجني عليه): إنه أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أعلم الله عز وجل من أن جناية كل امرئ عليه، كما عمله له، لا لغيره، ولا عليه [٧]، وقال الشافعي –رحمه الله تعالى–: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم[٨]، فقال عز وجل:﴿ وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ ﴾[٩]﴿ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾[١٠]

---

(١) سورة النجم، الآية: ٣٩.

(٢) سورة فصلت، الآية: ٤٦.

(٣) جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الآملي، الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط ١، ت: ١٤٢٠ هـ – ٢٠٠٠ م، بدون مكان النشر، ج ١٢، ص: ٢٨٦.

(٤) أخرجه أبو داود، في سننه، كتاب النزجل، باب في الخصاب، برقم: (٤٢٠٨)، ج ٦، ص: ٢٧٠، وفي الصفحة نفسها قال شعيب الأرنؤوط و محمد كامل قره بللي: إسناده صحيح.

(٥) أخرجه أحمد بن شعيب بن علي أبو عبد الرحمن الخراساني، النسائي، في سننه الصغرى، كتاب تحريم الدم، باب تحريم القتل، برقم: (٤١٢٧)، عن عبد الله بن مسعود ج ٧، ص: ١٢٧، وقال الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الربّاعي الصنعاني: ورجاله رجال الصحيح، ينظر: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، تحقيق : مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران، دار عالم الفوائد، ط ١، ت: ١٤٢٧ هـ، بدون مكان النشر، ج٣، ص: ١٦٣٦.

(٦) جامع الأصول في أحاديث الرسول، المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم أبو السعادات مجد الدين الشيباني الجزري ابن الأثير، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط – التتمة، تحقيق: بشير عيون، مكتبة الحلواني، ط١، بدون التاريخ، ومكان النشر، ج١٠، ص: ٢٥٠.

(٧) أخرجه أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر الخُسْرَوْجِردي الخراساني، البيهقي، في السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط ٣، ت: ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٣ م، بيروت – لبنات، ج٤، ص: ١٢٢.

(٨) تفسير الإمام الشافعي، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف أبو عبد الله المطلبي القرشي المكي، تحقيق: أحمد بن مصطفى الفرّان، دار التدمرية، ط١، ت: ١٤٢٧ هـ– ٢٠٠٦م، المملكة العربية السعودية، ج ٣/ص: ١٢٩٤.

(٩) سورة النجم، الآية:٣٧.

(١٠) سورة النجم، الآية: ٣٨.

فكل امرئ بما كسب من الخير والشر رهين مرهون فيؤخذ بذنبه ولا يؤخذ بذنب غيره[١].

الاستثناء من هذا المبدأ العام:

يستثنى من هذا المبدأ العام مسألة أن العاقلة تتحمل الدية في بعض الحالات، والأصل في ذلك ما روى المغيرة بن شعبة –رضي الله عنه– قال: سأل عمر بن الخطاب –رضي الله عنه– عن إملاص المرأة، هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت: أنا، فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((فيه غرة، عبد أو أمة)) [٢]، وفي رواية: ((فقضى على العاقلة الدية)) [٣]، وفي رواية أخرى: أخرى: ((عن جابر بن عبد الله –رضي الله عنه–: أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، قال: فجعل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "لا، ميراثها لزوجها وولدها)) [٤].

وهذا الحديث في مختلف رواياته دال على هذا الاستثناء، حيث جعل الشرع دية المقتول على عاقلة القاتل.

المطلب الرابع :المسئولية الجنائية شخصية في القانون.

يعني هذا المبدأ عدم مسئولية أي شخص إلا من ارتكب الجريمة أو شارك في ارتكابها، وإن كان هذا المبدأ –كما تقدم– يعتبر من أولويات الفقه الإسلامي، إلا أن القوانين الوضعية لم تعرفه إلا منذ وقت قريب، فقد كان الإنسان في نظرها مسئولا عن فعله وفعل غيره حتى وإن لم يكن عالما بها، وقد ظهر هذا المبدأ في القوانين الوضعية نتيجة لمبدأ المسئولية الأخلاقية، أي: أن كل شخص يعتبر مسئولا عن خطئه كما يعتبر نتيجة لازمة لمبدأ الحرية الفردية،

---

(١) الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق، الثعلبي، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، ط ١، ت: ١٤٢٢، هـ –٢٠٠٢ م، بيروت – لبنان، ج٩/ص: ١٢٩.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى، برقم: (٧٣١٧)، ج ٩/ ص: ١٠٢، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات برقم: (١٦٨٢) ج٣/ ص: ١٣١٠.

(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب دية الجنين، برقم: (٤٥٧٤)، عن ابن عباس –رضي الله عنه–، ج٦، ص: ٦٣١، وفي الصفحة نفسها قال شعيب الأرنؤوط و محمّد كامل قره بللي هذا إسناد ضعيف، لكن روي الحديث بإسناد صحيح سلف عند المصنف، وله شاهد.

(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب دية الجنين، برقم: (٤٥٧٥)، ج٦، ص: ٦٣١، وفي الصفحة ٦٣١– ٦٣٢ قال شعيب الأرنؤوط وآخر: صحح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لكن له شواهد.

ويشترط القانون لمعاقبة شخص على جريمة أن يثبت أن هذه الجريمة قد تمت بفعله، ويقع إثبات ذلك على سلطة الاتهام[١].

وتأخذ القوانين الوضعية الحديثة اليوم بما فيها قانون العقوبات الصومالي بمبدأ شخصية المسئولية الجنائية، فلا يؤخذ بالجرائم غير الذي ارتكبها، ولا تنفذ العقوبة إلا على الجاني دون غيره، ولكن القوانين لم تطبق هذا المبدأ بدقة تامة، ولاسيما قانون العقوبات الصومالي المخالف للفقه الإسلامي في بعض أحكامه المتعلقة بأهم العقوبات المقررة شرعا نصا أو غيره، والمتتبع لنصوصها يجد فيه خلافا واضحا على الفقه الإسلامي في بعض الحالات، مثل: عدم تحمل دية الخطأ على العاقلة.

ومما يدل على أن قانون العقوبات الصومالي طبق هذا المبدأ أنه ذكر أن من اشترك في ارتكاب جريمة قل أو كثر يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة، حيث نص:

(إذا اشترك أكثر من شخص في ارتكاب جريمة عوقب كل منهم بالعقوبة المقررة للجريمة، إلا ما استثني في المواد التالية: ...) [٢].

ومن المستثنى: حمل شخص غير مسئول قانونا أو قام به مانع من موانع العقاب على ارتكاب جريمة، كما نص عليه قانون العقوبات الصومالي:

(كل من حمل شخصا غير مسئول قانونا أو قام به مانع من موانع العقاب بسبب نقص أو حالة شخصية على ارتكاب جريمة كان مسئولا عن الجريمة التي ارتكبها ذلك الشخص مع تشديد العقوبة)[٣].

ولم تكن القوانين الوضعية تطبق مبدأ شخصية المسئولية قبل الثورة الفرنسية كما تطبقه اليوم، وإنما كانت تعتبر المرء مسئولاً عن عمله وعن عمل غيره ولو لم يكن عالماً بعمل هذا الغير ولو لم يكن له سلطان عليه، وكانت العقوبة تتعدى المجرم إلى أهله وأصدقائه، وتصيبهم كما تصيبه، وهو وحده الجاني، وهم البرآء من جنايته [٤].

---

(١) المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، أحمد الأشهب، دار الكتب الوطنية، ط/١، ت:١٤٠٤هـ، بنغازي- ليبيا، ص: ٢٩-٣٠.

(٢) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٧١.

(٣) المرجع السابق، م: ٧٢.

(٤) التشريع الجنائي، عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص: ٣٩٦-٣٩٧.

ويمكن أن نطرح سؤالا بعد هذه المقدمة، ونقول من يسأل جنائيا؟

فمن المعلوم أن هناك شخصا طبيعيا وشخصا اعتباريا، ولا جدال في أن الشخص الطبيعي هو الإنسان، فهذا لا خلاف في أنه يسأل عموما، و أما الشخص الاعتباري مثل: الشركات والمؤسسات فمن المسلم به أن هذا الشخص الاعتباري يتمتع بكافة الحقوق، ويسأل مسئولية مدنية سواء كانت تعاقدية أو تقصيرية، ويلتزم بدفع تعويضات وغرامات من ذمته المالية، وقد يرتكب ممثلوه أفعالاً إجرامية باسمه، كما لو قاموا باستيراد مواد مخدرة أو باعوا بضائع منتهية الصلاحية، فلا جدال في أن ممثل الشخص المعنوي يسأل جنائيًا عن ذلك، والقاعدة العامة هو أن كل من يكون أهلا لاكتساب الحقوق يصح أن يسأل مسائلة جنائية [١].

فما مدى موافقة القانون للفقه الإسلامي من حيث شخصية المسئولية الجنائية:

تبين مما تقدم أن ما ذهب إليه القانون مقتبس من الفقه الإسلامي؛ لأن له فضل السبق إليه، وبالتالي لا يكون القانون بعيدا في مضمونه من حيث شخصية المسئولية الجنائية عن الفقه الإسلامي.

---

(١) المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية، والقوانين الوضعية، مرجع سابق، ص: ٢٧.

المبحث الثاني: سبب المسئولية الجنائية وصور قصدها في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي:

والسبب هو كما سيأتي: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، فعلم أن كل عقوبة –سواء كانت في الفقه الإسلامي أو في قانون العقوبات الصومالي وكذلك القوانين الوضعية الأخرى – لا يمكن توقيعها إلا بسبب، فسبب المسئولية الجنائية هو السلوك الضار بالمجتمع باعتبار ما يمثله من خطورة كما سيأتي، فإذا وجد هذا السبب يوقع على موجد ذلك السبب العقوبة المناسبة الآتية نتيجة لتحمله المسئولية الجنائية إذا توفرت لديه شروط تحمل المسئولية الجنائية المتقدمة، ثم إنه لا يكون توقيعها أيضا على كل شخص مجرم، وإنما لا بد من أن يكون له قصد جنائي، وهذا القصد الجنائي له صور ستأتي، وعلى هذا تكون خطة هذا المبحث في أربعة مطالب، وهي كالتالي:

المطلب الأول: سبب المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي

تعريف السبب:

السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته[١]، فقوله: يلزم من وجوده الوجود: احتراز من الشرط؛ لأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط [٢]، وقوله: من عدمه العدم احتراز من المانع، فإن عدم المانع لا يلزم منه شيء، كما تقول الدين مانع من الزكاة، فإذا لم يكن عليه دين لا يلزم أن تجب عليه الزكاة، لاحتمال فقره مع عدم الدين، ولا أن لا تجب الزكاة لاحتمال أن يكون عنده نصاب حال عليه الحول، وقوله: لذاته احتراز من مقارنته فقدان الشرط أو وجود المانع، فلا يلزم من وجوده الوجود أو إخلافه بسبب آخر، فلا يلزم من عدمه العدم [٣].

فسبب المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي هو مخالفة حكم الله تعالى[٤]، ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومصداق ذلك قوله تعالى: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ﴾[٥]، وقوله تعالى:

---

(١) الإبهاج في شرح المنهاج، علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي أبو الحسن تقي الدين السبكي وولده عبد الوهاب أبو نصر تاج الدين، دار الكتب العلمية بدون الطبعة، ت: ١٤١٦هـ – ١٩٩٥ م– بيروت، ج١، ص: ٢٠٦.

(٢) روضة الناظر وجنة المناظر، مرجع سابق، ج١، ص: ٨٤.

(٣) شرح تنقيح الفصول، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين المالكي الشهير بالقرافي، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط١، ت: ١٣٩٣ هـ –١٩٧٣م، بدون مكان النشر، ص: ٨١.

(٤) الفصول في الأصول، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، وزارة الأوقاف الكويتية، ط ٢، ت:١٤١٤هـ –١٩٩٤م، بدون مكان النشر ج ٤/ ص: ٣١١.

(٥) سورة النساء، الآية: ٨٠.

﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [١] فالإتيان بالسيئة هي عدم الطاعة التي هي المخالفة لأحكام الله، وهي التي تترتب عليها العقوبة، والعقوبة قد تكون في الآخرة، وهي أن يعذب فيها، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [٢]، وقد تكون في الدنيا، وهي أن يعذب فيها، والذي يهم هنا هي العقوبة في الدنيا، والتي تعبر عن تحمل المسئولية الجنائية، كالقصاص وحد الزنا والسرقة وغيرها من الحدود أو التعازير، وفي هذا قال تعالى: ﴿مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ ﴾[٣]، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته))[٤].

المطلب الثاني: سبب المسئولية الجنائية في القانون

فالقانون يتفق مع الفقه الإسلامي فيما تقدم من سبب المسئولية الجنائية من حيث المخالفة، ويختلفان من حيث تفصيل المخالفة، فالفقه الإسلامي يرى أن السبب هو مخالفة حكم الله تعالى، ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأما القانون فيرى أن سبب المسئولية الجنائية هو ارتكاب الجرائم، ولذلك لا مسئولية ما لم يكن الجاني مخطئاً؛ أي عاصياً[٥]، وهذا أيضا ما نص عليه قانون العقوبات الصومالي من أنه:

(تعتبر الجريمة قد تمت بسبب الفعل أو الامتناع عنه الذي ارتكبه الجاني في إحداث النتيجة الضارة أو الخطرة المنصوص عليها في قانون العقوبات). [٦]

ومعنى هذا النص أن الشخص يكون مخالفا للقانون إذا ارتكب فعلا يحظره القانون ويمنعه، فالجريمة هي فعل أو امتناع عن فعل، فالفعل مثل: القتل والسرقة، فالقتل أيضا فعل يمنعه القانون، ويعاقب عليه؛ لأن قانون العقوبات الصومالي نص على أن (كل من ارتكب جريمة القتل يعاقب بالإعدام)،[٧] والسرقة فعل يمنعه القانون، ويعاقب عليه؛ لأن قانون العقوبات الصومالي نص على أن: ١- (كل من استولى على منقولات مملوكة للغير بحرمانه من حيازتها قاصدا الحصول على كسب غير

---

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٦٠.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٤.

(٣) سورة النساء، الآية: ١٢٣.

(٤) سبق تخريجه، في صفحة الاستهلال.

(٥) المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مرجع سابق، ص: ٧٨.

(٦) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ١٦.

(٧) المرجع السابق، م: ٤٣٤.

مشروع لنفسه أو لغيره يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة شلن، ولا تتجاوز خمسة آلاف شلنا صومالي) [١]، فالامتناع يكون جريمة أيضا، وله صور كثيرة:

منها: امتناع الموظف العمومي عن أداء الأعمال الرسمية، فقد نص قانون العقوبات الصومالي على أن: ١- (كل موظف عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة يرفض أو يمتنع أو يؤخر أداء عمل يتعلق بوظيفته أو خدمته على خلاف أحكام القانون، يعاقب بالسجن مدة أقصاها سنة أو بغرامة أقصاها عشرة آلاف من الشلنات الصومالية). [٢]

ومنها: الامتناع عن تقديم العون للملهوف، فهذا ما نص عليه قانون العقوبات الصومالي من أن: ١- (كل من لم يبلغ السلطات المخصصة فور عثوره على طفل مهجور أو مفقود لم يبلغ العاشرة من عمره أو أي شخص آخر غير قادر على رعاية نفسه بسبب عجز عقلي أو بدني أو بسبب الشيخوخة أو لأي سبب آخر يعاقب بالسجن مدة أقصاها ثلاثة شهور أو بغرامة أقصاها ثلاثة آلاف شلن صومالي). [٣]

فما مدى موافقة القانون للفقه الإسلامي من حيث سبب المسئولية

يستخلص مما تقدم أن السبب هو: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، إذا فسبب المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي هو مخالفة حكم الله تعالى، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت أدلة ذلك في موضعها.

وعلى هذا فإن سبب المسئولية الجنائية في القانون هو مخالفة القانون سواء كانت تلك المخالفة فعلا أو امتناعا عن فعل، **وكل ذلك يتفق مع الفقه الإسلامي**؛ لأن الجريمة لا تكون فيه إلا فعلا أو امتناعا عنه، وقد تقدمت الأمثلة في ذلك.

وكذلك أن القانون يعتبر الشخص مخالفا للقانون إذا ارتكب فعلا يحظره القانون ويمنعه، ومن ثم فإن سبب المسئولية الجنائية في القانون هو ارتكاب فعل يحظره القانون أو امتناع عن أداء عمل يوجبه القانون، فيكون الشخص مجرما، ويتحمل المسئولية الجنائية.

---

(١) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٤٨٠، ف: (١).

(٢) المرجع السابق، م: ٢٥٥، ف: (١).

(٣) المرجع السابق، م: ٤٥٠، ف: (١).

المطلب الثالث: صور قصد المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي

فالبحث عن القصد الجنائي يعتبر من أصعب الأبحاث، وأدقها على وجه الإطلاق، وأن فقهاء الفقه الإسلامي **لم يتعرضوا لموضوع القصد بشكل مباشر**، وإنما تكلموا عنه بطريقة غير مباشرة، وعدوه ركناً من أركان القتل العمد، ويستدلون عليه من الآلة المستخدمة في القتل التي تعد دليلاً مادياً على القصد، وقرينة واضحة لا يمكن للجاني إنكارها كما سيأتي إن شاء الله.

القصد الجنائي يكون له صور متعددة باعتبارات كثيرة:

الصورة الأولى: القصد العام والقصد الخاص، **أما القصد العام** فهو أن يقصد فعلا محرما مع العلم بأن هذا الفعل حرام، كالقتل، فإن لم يقصد الفعل بالشخص، كأن زلق فوقع على غيره فمات به أو تولد الموت من اضطراب يد المرتعش أو قصد الفعل لكن قصد به شخصا من آدمي أو غيره فأصاب غيره من الآدميين، فهذا هو القصد العام، ويسمى الخطأ [١]، وفي هذه الحالة تجب عليه الدية والكفارة.

وأما القصد الخاص فهو أن يقصد الجاني الفعل والشخص معا؛ لأنه لا يكفي فيه القصد العام، وإنما لا بد لتحقق الجريمة من قصد خاص، فجريمة القتل السابقة مثلا قد تكون عمدا أو غير عمد، فإن الجاني إن قصد الفعل والشخص معا، فهذا قد يكون عمدا محضا، وقد يكون شبه عمد، وإذا وجد القصدان وعلمنا حصول الموت بفعله، فهو عمد محض، سواء قصد الإهلاك، أم لا، وسواء كان الفعل مهلكا غالبا، أم نادرا، كقطع الأنملة، وإن شككنا في حصول الموت به، فهو شبه عمد [٢].

والقسم الأخير الذي هو شبه عمد هو ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية[٣] والشافعية[٤] والحنابلة [٥]، وغير المشهور عند المالكية، كما ذهب إليه ابن وهب[*][من المالكية [١]،

---

(١) أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا أبو يحيى زين الدين الأنصاري، السنيكي، دار الكتاب الإسلامي، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر، ج٤، ص:٣.

(٢) روضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن شرف أبو زكريا محيي الدين النووي، تحقيق: زهير الشاوي، المكتب الإسلامي، ط ٣، ت:١٤١٢هـ – ١٩٩١م، بيروت، ج٩، ص: ١٢٣.

(٣) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، المطبعة الكبرى الأميرية بولاق، ، ط١، ت: ١٣١٣ هـ، القاهرة، ج٦/ص: ٩٨.

(٤) منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، مرجع سابق، ص: ٢٦٩.

(٥) المغني، مرجع سابق، ج٨، ص: ٢٧١.

(*) وهو: عبد الله بن وهب بن مسلم الإمام، شيخ الإسلام، أبو محمد الفهري الفهري المصري، الحافظ، مولده: سنة خمس وعشرين ومائة، طلب العلم وله سبع عشرة سنة، مع أنه طلب العلم في الحداثة، نعم، وحدث عنه خلق كثير، وانتشر علمه، ومات في شعبان، سنة سبع وتسعين ومائة، ينظر: سير أعلام النبلاء، مرجع سابق،ج ٨، ص: ١٣.

(١) الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، دارالسلاسل، ط٢ بدون التاريخ، الكويت، ج ٣٢، ص: ٣٣٤.

وخالف المالكية الجمهور عليه، فالمشهور عندهم لا يكون ما يسمى بشبه العمد، ولأجل ذلك لا يوجد عندهم قصد خاص؛ لأن القتل عندهم نوعان: قتل عمد، وقتل خطأ، وفي هذا المجال قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: شبه العمد باطل، وإنما هو عمد أو خطأ ولا أعرف شبه العمد(١).

الصورة الثانية: القصد المعين والقصد غير المعين:

معنى القصد المعين هو: قصد الجاني حصول الفعل الضار والنتيجة معا، وبعبارة أخرى هو: قصد الفعل وعين الشخص (٢).

وأما معنى القصد غير المعين فهو: أن يقصد إنسانا من جماعة أي واحدا منهم لا واحدا بعينه ولا أي واحد لا منهم (٣).

وحكم ذلك أنه يعتبر شبه عمد عند الجمهور، وشبه العمد حكمه سيأتي في المبحث الثالث خصوصا في المطلب الثالث والرابع منه إن شاء الله.

الصورة الثالثة: القصد المباشر والقصد غير المباشر أو القصد الاحتمالي:

معنى القصد المباشر هو: توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً إلى نتيجة الجريمة التي وقعت أو أية نتيجة جرمية أخرى، ويعني ذلك: أنه يشترط أن يقصد القاتل الضرب أي يقصد إيقاعه في القتل مثلا الموجب للقصاص. (٤)

وأما معنى القصد غير المباشر (القصد الاحتمالي) فهو: أن لا يقصد نتائج ما فعله، كالقتل بما لا يقتل غالبا، بمعنى: أن يقصد الجاني الجناية بما لا يقتل غالبًا، كالقتل بالحجر الصغير، (٥) يعني: أنه قصد الضرب، ولم يقصد القتل (٦).

وتوضيح ذلك أنه لابد لتوافر القصد الاحتمالي (القصد غير المباشر) من أن يكون لدى الجاني قصد مباشر إلى إحداث نتيجة معينة يعاقب عليها، فتحدث نتيجة أخرى متوقعة تتجاوز ما أراده، فإذا لم يكن لدى الجاني قصد مباشر، فلا يسأل إلا عن جريمة غير عمدية.

---

(١) المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، دار الكتب العلمية، ط١، ت: ١٤١٥هـ – ١٩٩٤ م، بدون مكان النشر، ج ٤ / ص: ٥٥٨.

(٢) تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ، المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمد، بدون الطبعة، ت: ١٣٥٧ هـ ١٩٨٣– م، مصر، ج ٨/ص: ٣٧٦.

(٣) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.

(٤) شرح مختصر خليل للخرشي، مرجع سابق، ج ٨/ ص:٧.

(٥) توضيحُ الأحكامِ من بُلوغ المرام، مرجع سابق، ص: ١٠٣.

(٦) القوانين الفقهية، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي أبو القاسم، الكلبي الغرناطي، بدون الناشر، والطبعة، والتاريخ، ومكان النشر، ص: ٢٢٦.

المطلب الرابع: صور قصد المسئولية الجنائية في القانون

القصد الجنائي هو: اتجاه النية الكاملة إلى إحداث النتيجة للفعل الإجرامي عملاً واتجاه الإرادة إليه بعد العلم به، ويؤخذ هذا المعنى من نص المادة التالية:

٢-كل من كانت لديه القدرة على الإدراك والإرادة يعد مسئولا [١].

يعني: أنه لابد من توافر القصد والعمد عند ارتكاب الجريمة قصد متّجه نحو الفعل والنتيجة المترتبة على ذلك الفعل، وتحقق الإرادة بالعلم التام بفحوى المخالفة القانونية، وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية إلمام المواطن بالأحكام الشرعية للأفعال المحرمة والنتائج المترتبة عليها وفق أحكام قانون العقوبات الصومالي، إذ من المفترض أنه يجب على كل شخص أن يدرك تماماً أحكام هذا القانون؛ لأنه لا يقبل من أحد الدفع بعدم العلم أو الجهل بالقانون، فالجهل بالقانون ليس ذريعة مقبولة لارتكاب الجريمة، وفي هذا نصت المادة من قانون العقوبات الصومالي: (لا يقبل الادعاء بالجهل بقانون العقوبات) [٢].

يتخذ القصد الجنائي في قانون العقوبات عدة صور، وهذه الصور يستند بعضها إلى نصوص قانونية محددة في التشريع الجنائي، وبعضها الآخر يستند إلى اجتهادات الشراح واستنباطاتهم:

أولا: القصد العام والقصد الخاص

يكون القصد **عاما** إذا تم واكتمل بتمام العلم وتمام الإرادة المنصرفين إلى الفعل والنتيجة، أي: إذا كان يكفي لتمامه كونه محيطا بماديات الجريمة، ولم يكن محتاجا لسواها، ويكون القصد **خاصا** إذا كان لا يكفي لتمامه ما يكفي لتمام القصد العام، وإنما يكون محتاجا فوق ذلك إلى الإحاطة بعنصر آخر غير الفعل والنتيجة وهو تطلبه إلى توافر نية خاصة [٣].

وتفصيل ذلك: أن القصد الخاص هو انصراف نية الجاني إلى تحقيق غاية معينة أو باعث خاص بالإضافة إلى توافر القصد العام، كاشتراط نية التملك لقيام جريمة السرقة بالإضافة إلى القصد العام فيها وهو العمد.

ثانيا: القصد المحدد والقصد غير المحدد:

يتوافر القصد **المحدد** عند ما تكون إرادة الجاني متجهة نحو: تحقيق نتيجة معينة بالذات، كما لو أراد شخص قتل زيد من الناس، فأطلق عليه الرصاص وأرداه قتيلا، أما القصد **غير المحدد**، فإنه

---

(١) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٤٧، ف (٢).

(٢) المرجع السابق، م: ٥.

(٣) شرح قانون الجرائم والعقوبات، القسم العام، على حسن الشرفي، دار الثقافة، بدون الطبعة، والتاريخ، عمان، ج١/ص: ٤١٣ – ٤١٤.

يوجد عند ما تنصرف إرادة الجاني إلى تحقيق نتائج جرمية لا على التعيين والتحديد، [١] كمن يحفر بئرا في الطريق بقصد أن يقع فيها من يمر بهذا الطريق[٢] ، ومثل ذلك يكون الحكم في جريمة السرقة، وجريمة السب وغيرها؛ إذ يكون القصد محددا إذا قصد مالا مملوكا لفلان من الناس، وغير محدد إذا لم يحدد الشخص المجنى عليه، ولم يبال على أي مجنى عليه وقعت الجريمة. [٣]

ثالثا: القصد المباشر والقصد غير المباشر (القصد الاحتمالي):

يعتبر القصد مباشراً كلما ارتكب الجاني الفعل وهو يعلم نتائجه ويقصدها، بغض النظر عما إذا كان يقصد شخصاً معيناً أو لا يقصد شخصاً معيناً، ويعتبر القصد غير مباشر إذا قصد الجاني فعلاً معيناً فترتب على فعله نتائج لم يقصدها أصلاً أو لم يقدر وقوعها، ويسمى القصد غير المباشر بالقصد المحتمل أو القصد الاحتمالي [٤].

فما مدى موافقة القانون للفقه الإسلامي من حيث صور قصد المسئولية

اتفق قانون العقوبات الصومالي مع الفقه الإسلامي على صور قصد المسئولية الجنائية، على علم مما تقدم، فاتضح أن لا مخالفة بينهما في هذه الصور.

---

(١) شرح قانون العقوبات، القسم العام، الألفي، مرجع سابق، ص:٤٦٤.

(٢) المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مرجع سابق، ص: ٩٤.

(٣) شرح قانون الجرائم والعقوبات، القسم العام، مرجع سابق ، ج١/ص: ٤٢٣.

(٤) التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، مرجع سابق، ج١/ص: ٤١٨.

المبحث الثالث: درجات المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي:

فدرجات المسئولية الجنائية حسب ما سيأتي في مطالب هذا المبحث إما يكون في درجة عمد أو شبه عمد أو خطأ، وتفصيل ذلك على النحو التالي:

درجة مسئولية العمد في الفقه الإسلامي، من حيث تعريف العمد تعريفا مقارنا للمذاهب الأربعة، ثم ما يترتب على درجة مسئولية العمد، من القصاص، والإثم.

ودرجة مسئولية العمد في القانون، من خلال العرض على تعريف القتل العمد في القانون، ثم عناصره الاثنين: العلم والإرادة، ثم ما يترتب على درجة مسئولية العمد، من عقوبة هي الإعدام.

ودرجة مسئولية شبه العمد في الفقه الإسلامي، من حيث التعريف، وما يترتب على درجة مسئولية شبه العمد في الفقه الإسلامي من أنه هل هو قصاص أو دية مغلظة على خلاف بين الفقهاء.

والقانون عبر درجة مسئولية شبه العمد (الضرب المفضي إلى الموت) بدل شبه العمد، وسيأتي أن لشبه العمد ركنين: أحدهما: مادي، وثانيهما معنوي، وهو يقوم على أمرين: أحدهما إيجابي، والآخر سلبي، ثم يتطرق القانون إلى المسئولية الجنائية لشبه العمد في القانون.

ودرجة مسئولية الخطأ في الفقه الإسلامي، فبيّن معنى الخطأ في اللغة، ثم في الاصطلاح، وبين ما يترتب على درجة مسئولية الخطأ في الفقه الإسلامي من الدية والكفارة إجماعا.

ودرجة مسئولية الخطأ في القانون، فتناول معنى القتل الخطأ في القانون، مع بيان أن للخطأ عنصرين: الأول: هو الإخلال بواجبات الحيطة والحذر، الثاني: هو العلاقة الذهنية والنفسية بين مرتكبي الفعل والنتيجة الجرمية، وعلى هذا الترتيب يأتي هذا المبحث على المطالب الآتية فيما يلي:

المطلب الأول: درجة مسئولية العمد في الفقه الإسلامي.

قبل الخوض على درجة مسئولية العمد ينبغي الإشارة إلى أن هذا المطلب يحتوي على أمرين هما التعريف، وما يترتب على درجة مسئولية العمد:

أولا: تعريف العمد:

أ. معنى العمد في اللغة:

العين والميم والدال أصل كبير، فروعه كثيرة ترجع إلى معنى، وهو الاستقامة في الشيء، منتصبا أو ممتدا، وكذلك في الرأي وإرادة الشيء، من ذلك عمدت فلانا وأنا أعمده عمدا، إذا قصدت إليه. والعمد: نقيض الخطأ في القتل وغيره، وإنما سمي ذلك عمدا لاستواء إرادتك إياه[١].

ب. معنى العمد في الاصطلاح:

يمكن استعراض بعض ما يُعرّف الفقه الإسلامي المقارن بين المذاهب الأربعة العمد على ما يلي:

تعريف الحنفية: يكون القتل عمدا إذا ما تعمد ضربه بالسلاح [٢].

تعريف المالكية: عرفوه أيضا بأنه هو: القصد إلى ما يقتل مثله من مباشرة أو تسبب فالمباشرة، كقتله –بمحدد، أو مثقل، أو عصر الأنثيين، وتغريق وتحريق، ومنعه من الطعام والشراب[٣].

أما التسبب هو: أن يفعل فعلا يكون سببا للإتلاف، والمعنى أن من حفر بئرا في موضع لا يجوز له حفرها فيه كطريق المسلمين أو حفرها في موضع يجوز له حفرها فيه كبيته وقصد بذلك الضرر كهلاك شخص معين وهلك فيها ذلك المعين فإنه يقتل به فإن هلك فيها غير المعين فعليه ديته إن كان حرا أو قيمته إن كان عبدا، أما إن حفر البئر في بيته لضرورة اقتضت ذلك فهلك فيها إنسان أو غيره فإنه لا ضمان عليه فيه، بل هو هدر[٤].

تعريف الشافعية: عرفوا العمد بأن يقصد الجناية بما يقتل غالبا، سواء كان مثقلا أو محددا[٥].

---

(١) معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين، القزويني الرازي، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بدون الطبعة، ت: ١٣٩٩هـ –١٩٧٩م، بدون مكان النشر، ج٤ص: ١٣٧.

(٢) الأصل المعروف بالمبسوط، محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، بدون الطبعة، والتاريخ، كراتشي–باكستان، ج٤، ص: ٤٣٧.

(٣) جامع الأمهات، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي، تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، اليمامة للطباعة، ط٢، ت: ١٤٢١هـ –٢٠٠٠م، بدون مكان النشر، ص: ٤٨٨.

(٤) شرح مختصر خليل للخرشي، مرجع سابق، ج٨/ص:٧.

(٥) منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، مرجع سابق، ص: ٢٦٩، وعمدة السالك وعدة الناسك، أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله أبو العباس، شهاب الدين الرومي، ابن النقيب الشافعي، الشؤون الدينية، ط١، ت: ١٩٨٢ م، قطر، ص: ٢٢٧.

تعريف الحنابلة: عرفوا العمد أيضا بأن يقصد الجاني القتل بمحدد، أو ما يقتل غالبًا، فيقتله[١].

ومؤدى التعاريف واحد، وهو القصد بما يقتل غالبا.

ثانيا: ما يترتب على درجة مسئولية العمد في الفقه الإسلامي:

يترتب على درجة مسئولية العمد في الفقه الإسلامي أحكام، ومن أهمها:

١. القصاص، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فمنه قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَى ﴾ [٢]، وقد نص الله تبارك وتعالى على أنه مكتوب علينا، فقال تعالى: ﴿ وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ ﴾ [٣]، وما أخبر الله تعالى أنه كتبه على من قبلنا فهو مكتوب علينا ما لم يرد دليل على عدم التكليف به[٤]، ثم بين وجه الحكمة فيه بقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ ﴾ [٥]، وأما السنة: فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة)) [٦].

أما الإجماع فقد أجمع الفقهاء وأرباب المذاهب الأربعة وغيرهم على أن القتل عمدا يوجب القصاص[٧].

٢. المأثم، فالقتل بغير حق حرام، وهو من الكبائر العظام إذا كان عمدًا [٨]، وذلك منصوص عليه في القرآن والسنة النبوية، وثابت أيضا بالإجماع، ومن القرآن: قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا ﴾ [٩].

---

(١) الكافي في فقه الإمام أحمد، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة أبو محمد موفق الدين الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، دار الكتب العلمية، بدون الطبعة، ت: ١٤١٤ هـ -١٩٩٤ م، وبدون مكان النشر، ص: ٢٥١.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.

(٣) سورة المائدة، الآية: ٤٥.

(٤) نشر البنود على مراقي السعود، مرجع سابق، ج ٢، ص: ٢٣.

(٥) سورة البقرة، الآية: ١٧٩.

(٦) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: {أن النفس بالنفس ..} إلخ، رقم الحديث: (٦٨٧٨)، عن عبد الله بن مسعود، ج٩/ص:٥.

(٧) تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية، ط٢، ت: ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م، بيروت – لبنان، ج٣/ص: ٩٩، والمدونة، مرجع سابق، ج٣/ص: ٣٨٣، ومنهاج الطالبين مرجع سابق، ص: ٢٦٩، والكافي في فقه الإمام أحمد، مرجع سابق، ج٣، ٢٥١.

(٨) الهداية في شرح بداية المبتدي، مرجع سابق، ج٤، ص: ٤٤٢، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي، دار الفكر، بدون الطبعة، ت: ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م، وبدون مكان النشر، ج٢/ص:٢٨١، والمهذب في فقه الإمام الشافعي، إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الشيرازي، دار الكتب العلمية، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر، ج٣، ص: ١٧٠، والكافي في فقه الإمام أحمد، مرجع سابق، ج٣، ص: ٢٥١.

(٩) سورة النساء، الآية: ٩٣.

ومن السنة النبوية:

أ. قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار))[١].

ب. قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل)) [٢]، يعني بقوله ((كفل)): إثما؛ لأنه أول من سن القتل، فاستن به القاتلون بعده[٣].

وأما الإجماع فإنه لا خلاف بين المسلمين في تحريم القتل العمد العدوان بغير حق، وأن صاحبه يستحق القتل في الدنيا حدًا، ما لم يكن مستحلًا لذلك فيكون كفرًا، ويستحق العقاب بالنار – والعياذ بالله – في الآخرة [٤]، وقد حكاه غير واحد من العلماء، وهو مما عُلم من الدين بالضرورة[٥].

٣. **الكفارة**، اتفق الفقهاء على أن الكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين[٦]، قال تعالى: ﴿وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ

---

(١) أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الإيمان،باب ﴿ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا ﴾[سورة الحجرات، الآية: ٩]، برقم، (٣١)، ج١، ص: ١٥، ومسلم، في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، برقم: (١٦٨٠)، كلاهما عن أبي بكرة، ج٣، ص: ١٣٠٨.

(٢) أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الجنائز، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته ، برقم، (٣٣٣٥)، ج٤، ص: ١٣٣، ومسلم، في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، برقم: (١٦٧٧)، كلاهما عن عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه–، ج٣، ص: ١٣٠٣.

(٣) شرح صحيح البخاري، علي بن خلف بن عبد الملك المعروف بابن بطال أبو الحسن، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، ط٢، ت: ١٤٢٣هـ – ٢٠٠٣م، الرياض – السعودية، ج٢، ص: ٤٩٧.

(٤) صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال بن السيد سالم، أبو مالك ، تحقيق: ناصر الدين الألباني، وعبد العزيز بن باز، محمد بن صالح العثيمين، المكتبة التوفيقية، بدون الطبعة، ت: ٢٠٠٣ م، القاهرة – مصر، ج٤، ص: ١٩٤.

(٥) توضيحُ الأحكام من بلوغ المرام، مرجع سابق، ج٦، ص: ٧٣.

(٦) شرح مختصر الطحاوي، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، تحقيق: عصمت الله عنايت الله محمد، سائد بكداش، محمد عبيد الله خان، زينب محمد حسن فلاتة، دار البشائر الإسلامية، ط١، ت: ١٤٣١ هـ – ٢٠١٠ م، بدون مكان النشر، ج ٥، ص: ٤١٢، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار أبو محمد جلال الدين الجذامي السعدي المالكي، تحقيق: حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، ط١، ت:١٤٢٣ هـ – ٢٠٠٣م، بيروت – لبنان، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، مرجع سابق، ج ٤، ص: ٩٥، و الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان أبو الحسن علاء الدين المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، دار إحياء التراث العربي، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر، ج ٢٣، ص: ٢٨٣.

ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [١]، فالكفارة **هي مما** يترتب على قتل العمد وشبهه عند من يقول به، ولكن اختلف الفقهاء في وجوب تلك الكفارة في القتل العمد على قولين:

القول الأول: أن لا تجب الكفارة في القتل العمد، وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور عندهم [٢].

واستدلوا بما يلي:

١. قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا ﴾ [٣]، فلهذا يقتضي أن يكون المذكور في الآية جميع أجزائه، ولو أوجبنا عليه الكفارة لكان المذكور بعض جزئه فيكون فسخا لهذا الحكم، ولا وجه لحمل الآية على المستحل؛ لأن المذكور في الآية جزاء قتل العمد وإذا حمل على المستحل كان المذكور جزاء لرده [٤].

٢. مفهوم قوله تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [٥]، ثم ذكر قتل العمد، فلم يوجب فيه كفارة، وجعل جزاءه جهنم، فمفهومه أنه لا كفارة فيه [٦].

القول الثاني: أنه تجب الكفارة في القتل العمد، وهذا مذهب الشافعية، وهو رواية عن أحمد [٧].

واستدلوا بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [٨]، فنص على وجوب الكفارة في قتل الخطأ؛ لينبه بذلك على وجوبها في العمد المحض وعمد الخطأ؛ لأن الخطأ أخف

---

(١) سورة النساء، الآية: ٩٢.

(٢) البناية شرح الهداية، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين أبو محمد بدر الدين الغيتابى الحنفى العينى، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م، - بيروت، لبنان، ج ١٣، ص: ٦٨، و الذخيرة، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين المالكي الشهير بالقرافي، تحقيق: محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، ط ١، ت: ١٩٩٤ م، - بيروت ج ١٢، ص: ٤١٩، و المغني، مرجع سابق، ج ٨، ص: ٥١٥.

(٣) سورة النساء، الآية: ٩٣.

(٤) المبسوط، مرجع سابق، ج ٢٧، ص: ٨٥.

(٥) سورة النساء، الآية: ٩٢

(٦) التجريد، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري، تحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد، دار السلام، ط٢، ت: ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦م، القاهرة، ج ١١، ص: ٥٨٠٧، المغني، مرجع سابق، ج ٨، ص: ٥١٦.

(٧) منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، مرجع سابق، ص: ٢٨٧، و المغني، مرجع سابق، ج ٨، ص: ٥١٥.

(٨) سورة النساء، الآية: ٩٢.

حالا من قتل العمد؛ لأنه لا قود فيه ولا إثم، والدية فيه مخففة، فإذا وجبت فيه الكفارة.. فلأن تجب في قتل العمد المحض وعمد الخطأ أولى[١].

٢- ما رواه واثلة بن الأسقع قال: أتينا رسول الله صلي الله عليه وسلم في صاحب لنا استوجب النار بقتل، فقال: ((أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار)) [٢]، وهو لا يستوجب النار إلا في العمد [٣].

الترجيح:

يترجح لدى الباحث القول بوجوب الكفارة في القتل العمد؛ لأن القتل العمد أو لى بالتشديد من القتل الخطأ، فإذا وجبت الكفارة في القتل الخطأ فلأن تجب في العمد أولى.

المطلب الثاني: درجة مسئولية العمد في القانون

أولا: معنى القتل العمد في القانون:

وهذا يسمى عند القانونيين بالقصد الإجرامي الذي هو توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الأمر المكوّن للجريمة عالما بأركانها القانونية [٤]، وهناك تعريف آخر للقتل العمد، وهو أنه: تصور الشخص في ذهنه فعل القتل والتصميم عليه قبل إيقاعه [٥].

وهذا ما ذكره قانون العقوبات الصومالي، حيث نص على أنه:

١-"تعتبر الجريمة بقصد جنائي حين يكون ضرر الواقعة أو خطرها الذي هو نتيجة الفعل أو الامتناع عنه قد يتوقعه الجاني أو يرغب فيه نتيجة لفعله أو الامتناع عنه، وحيث يجعل القانون الجريمة مترتبة على وقوع هذا الحادث" [٦].

فاتضح من أن القتل العمد هو: اعتداء على سلامة حياة الفرد عدوانا وبغير حق.

فالجريمة العمدية تتطلب القصد الجنائي، وهو يتمثل في عنصرين:

---

(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي، يحيى بن أبي الخير بن سالم أبو الحسين العمراني اليمني الشافعي، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، ط ١، ت: ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م، جدة، ج ١١، ص: ٦٢٢.

(٢) أخرجه أبو داود، كتاب العتاق، باب في ثواب العتق، برقم: (٣٩٦٤)، ج ٦، ص: ٩٤، وفي الصفحة نفسها قال شعيب الأرنؤوط وآخر: حديث صحيح.

(٣) بحر المذهب، مرجع سابق، ج ١٤، ص: ٢٤٥.

(٤) قانون العقوبات، القسم العام، عبود السراج، دار المستقبل، بدون الطبعة، ت: ١٤٠١-١٤٠٣هـ، ١٩٩١-١٩٨٢م، بدون مكان النشر، ص:٢٠٠.

(٥) شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جاك يوسف الحكيم، بدون الناشر والطبعة، والتاريخ، ومكان النشر، ج٢/ص: ١٠٠.

(٦) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٢٤، ف: (١/أ).

أ) العلم بثلاثة أمور: بطبيعة الفعل من كونه قاتلا أولا، وبطبيعة النتيجة من حيث كونها مرتبة على فعله ومتوقعا على حدوثها ثانيا، والثالث هو: أن يكون عالما بالظروف التي تدخل في تكوين الجريمة(١).

ب) إرادة الفعل والنتيجة التي تتجه إلى فعل الاعتداء على الحياة وإلى تحقيق النتيجة المترتبة عليه إزهاق روح المجنى عليه (٢).

وعلى هذا نصت المادة من قانون العقوبات الصومالي:

١- "لا يجوز معاقبة شخص على فعل مكون بجريمة إذا لم يكن مسئولا في وقت ارتكابه الفعل.

٢- كل من كانت لديه القدرة على الإرادة والإدراك يعد مسئولا" (٣).

ثانيا: ما يترتب على درجة مسئولية العمد:

عاقب قانون العقوبات الصومالي على من قتل نفسا بغير حق بالإعدام، أي: بالقصاص في نص المادة على أن: "كل من ارتكب جريمة القتل يعاقب بالإعدام (٤).

ومعنى ذلك أنه يعاقب بالإعدام على القتل قصدا إذا ارتكب مع سبق الإصرار والترصد، ويقال له: (القتل العمد) (٥).

فما مدى موافقة القانون للفقه الإسلامي من حيث حكم العمد على الجاني:

فقانون العقوبات الصومالي لا يخالف جملةً الفقه الإسلامي في حكم القتل العمد، من كونه إعداما، أي: قصاصا، وأما تفصيلا فيوجدفيهاختلاف في القيود والشروط؛ لأن في الفقه الإسلامي أحكاما، خاصة إذا كان بين القاتل والمقتول اختلاف دين ومكافأة مثلا، والقانون لا يفرق بين ذلك.

المطلب الثالث: درجة مسئولية شبه العمد في الفقه الإسلامي

درجة مسئولية شبه العمد تستدعي تعريفها ثم الكلام على ما يترتب عليها، وذلك على النحو التالي:

أولا: معنى شبه العمد في الفقه الإسلامي:

---

(١) قانون العقوبات، القسم العام، عبود السراج، مرجع سابق، ص:٢٠٠-٢٠٢.

(٢) شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، القسم الثاني، فتوح عبد الله الشاذلي، دار المطبوعات الجامعية، بدون الطبعة، ت:١٩٩٤م، وبدون مكان النشر، ص:٤٩٣، وقانون العقوبات، القسم العام، عبود السراج، مرجع سابق، ص:٢٠٠-٢٠٥.

(٣) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٤٧.

(٤) المرجع السابق، م: ٤٣٤.

(٥) شرح قانون العقوبات الأردني، الجرائم الواقعة على الإنسان، كامل السعيد، مكتبة دار الثقافة، ط٢، ت:١٩٩١، عمان – الأردن، ص: ١٠٣.

ذهب الفقهاء إلى أن شبه العمد هو: أن يقصد الجاني إنساناً معصوم الدم، فيقتله بجناية، لا تقتل غالباً، ولم يجرحه بها، فيموت بها المجنى عليه [١].

بناء على ذلك يمكن استعراض بعض تعريفات شبه العمد عندهم فيما يلي:

تعريف الحنفية: عرقوا القتل إذا كان شبه عمد بأنه هو: ما تعمدت ضربه بالعصا أو السوط أو الحجر أو البندقة [٢].

تعريف بعض المالكية كأبي القاسم الغرناطي[*] عرقوا شبه العمد بأنه هو: أن يقصد الضرب ولا يقصد القتل[٣].

تعريف الشافعية: عرفوا شبه العمد بأن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت[٤].

تعريف الحنابلة: عرقوه بأن: يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا؛ إما لقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب له، فيسرف فيه، كالضرب بالسوط، والعصا، والحجر الصغير، والوكز واليد، وسائر ما لا يقتل غالبا إذا قتل، فهو شبه عمد؛ لأنه قصد الضرب دون القتل، ويسمى عمد الخطأ وخطأ العمد؛ لاجتماع العمد والخطأ فيه، فإنه عمد الفعل، وأخطأ في القتل [٥].

ثانيا: ما يترتب على درجة مسئولية شبه العمد في الفقه الإسلامي:

يترتب على درجة مسئولية شبه العمد في الفقه الإسلامي أحكام، ومن أهمها: عقوبة شبه العمد، وقد تقدم أن أرباب المذاهب الأربعة اتفقوا على معنى شبه العمد، ولكنهم اختلفوا هنا في عقوبة جناية شبه العمد في الفقه الإسلامي، من أنها الدية والكفارة أو القصاص؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يرى وجوب الدية المغلظة على العاقلة، أما وجوب الدية فلأن القصاص امتنع وجوبه مع وجود القتل العمد؛ للشبهة فتجب الدية، وأما الوجوب على العاقلة فلأن العاقلة إنما تعقل الخطأ تخفيفا على القاتل؛ نظرا له لوقوعه فيه لا عن قصد، وفي هذا القتل شبهة عدم القصد

---

(١) موسوعة الفقه الإسلامي، محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، بيت الأفكار الدولية، ط ١، ت: ١٤٣٠ هـ – ٢٠٠٩ م، بدون مكان النشر، ج ٥، ص: ٥٠.

(٢) المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة، بدون الطبعة، ت: ١٤١٤هـ – ١٩٩٣م، بيروت، ج٢٦، ص:٦٤.

(*) محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى ابن عبد الرحمن بن يوسف بن جزيّ الكلبيالغرناطي الأندلسي، المتوفى شهيداً سنة ٧٤١، وله من التصانيف في السنة وعلومها: وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم، ينظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، محمد عبّد الحيّ بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي، المعروف بعبد الحي الكتاني، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، ط ١، ت: ١٩٨٢م – بيروت، ج ١، ص: ٣٠٦

(٣) القوانين الفقهية، مرجع سابق، ص: ٢٢٦، وشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج٨/ص: ٧.

(٤) منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، مرجع سابق، ص: ٢٦٩.

(٥) المغني، مرجع سابق، ج٨، ص: ٢٧١.

لحصوله بآلة لا يقصد بها القتل عادة، فكان مستحقا لهذا النوع من التخفيف، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة [١].

ويعنى ذلك أنه لا قصاص فيه؛ لتمكن الشبهة والخطأ من حيث انعدام القصد إلى القتل، والقصاص عقوبة تدرئ بالشبهات، وهي تعمد المساواة، ولا مساواة بين قتل مقصود وقتل غير مقصود، ثم إن هذا القتل لما اجتمع فيه معنيان: أحدهما يوجب القصاص، والآخر يمنع، ترجح المانع على الموجب؛ لأن السعي في إبقاء النفس واجب ما أمكن، فإن الإبقاء حياة حقيقة، وفي القصاص حياة حكما فلهذا لا يوجب القود في شبه العمد[٢].

القول الثاني: للمالكية: يرى هذا القول أن شبه العمد هو أن يقصد الضرب ولا يقصد القتل، والمشهور أنه كالعمد، وقيل كالخطأ، وقيل تغلظ فيه الدية[٣]، وقال الإمام مالك –رحمه الله: شبه العمد باطل لا أعرفه، وإنما هو عمد أو خطأ [٤].

وأما صفة تغليظ الدية في شبه العمد على قول من يراه قسما برأسه فاختلفوا في مقدار المأئة على قولين:

القول الأول: **أنها أرباع**، وهي: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وهذا قول الحنفية[٥]، ورواية عن احمد [٦]"

والدليل: قوله تبارك وتعالى ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾ [٧] أطلق سبحانه وتعالى القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل فدل أن الواجب في الكل على قدر واحد [٨].

القول الثاني أنها **أثلاث** ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وإلى هذا ذهب الشافعية[٩] وهو رواية عن أحمد [١٠].

---

(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج٧، ص:٢٥١، ومنهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، مرجع سابق، ص: ٢٧٩، والمغني، مرجع سابق، ج٨/ص: ٢٧١.

(٢) المبسوط، مرجع سابق، ج ٢٦، ص: ٦٥، الأصل المعروف بالمبسوط، مرجع سابق، ج٤/ ٤٣٧.

(٣) القوانين الفقهية، مرجع سابق، ص: ٢٢٦.

(٤) المدونة، مرجع سابق، ج٤/٥٥٨.

(٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج ٧، ص: ٢٥٤ – ٢٥٥.

(٦) الشرح الكبير على متن المقنع، مرجع سابق، ج ٩، ص: ٥١٠.

(٧) سورة النساء، الآية: ٩٢

(٨) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج ٧، ص: ٢٥٤ – ٢٥٥.

(٩) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، علي بن محمد بن محمد بن حبيب أبو الحسن البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، تحقيق: علي محمد معوض – عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط ١، ت: ١٤١٩ هـ –١٩٩٩ م، بيروت – لبنان، ج ١٢، ص: ٢١٣.

(١٠) الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين البلباني الحنبلي، عبد العزيز بن عدنان العيدان، وأنس بن عادل اليتامى، دار الركائز، ط ١، ت: ١٤٣٩ هـ – ٢٠١٨ م، الكويت، ج ٣، ص: ٣٤٤، والشرح الكبير على متن المقنع، مرجع سابق، ج ٩، ص: ٥١٠.

والدليل: ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه، فهو لهم، وذلك تشديد العقل"[١].

وما رواه عمرو أيضا عن أبيه عن جده، أن النبيَّ –صلَّى الله عليه وسلم– قال: "عَقْلُ شبه العمدِ مُغلَّظٌ مثلُ عقلِ العمدِ، ولا يُقتل صاحبُه" "وذلك أن يَنْزُوَ الشيطانُ بين الناس، فتكونَ دماءٌ في عِمِّيَّا، في غيرِ ضَغِينَةٍ ولا حملِ سلاحٍ"[٢].

فاتضح من هذا أنهم اختلفوا في شيئين: في تغليظ دية شبه العمد بالسن على قولين، وفي شبه العمد هل هو باطل، لا اعتبار به –وهو المذهب عند مالك وأكثر أصحابه؛ لأن القتل عند الإمام مالك إما عمد أو خطأ، لا غير– أم يعتبر به فيكون صحيحا، كما قيل به في بعض الرواية عن مالك [٣]، وإليه ذهبت المذاهب الثلاثة، كما تقدم.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المالكية يذكرون شبه العمد في كتبهم ويجعلون له أقساما، ويقولون: إن شبه العمد أربعة أقسام:

أحدها: أن يكون القتل بغير آلة القتل وبما لا يقصد إلى إتلاف النفس بمثله كالسوط والعصا والبندقة واللطمة واللكزة، وفيه ورد الحديث: ((ألا إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط، والعصا، مائة من الإبل: منها أربعون في بطونها أولادها)) [٤]، إلا أن يقوم دليل العمد؛ لقوة الضربة من الرجل الشديد لمريض أو ضعيف.

والثاني: أن يكون بآلة القتل ممن لا يتهم أن يكون أراد القتل، وهو ما يكون من الأب والأم لولدهما يحذفه بسيف أو برمح.

والثالث: أن يكون ممن أبيح له فعل مثل ذلك كمعلم الثقافة والطبيب والختان.

---

(١) أخرجه الإمام أحمد، في مسنده، برقم ٦٧١٨، ج ١١، ص: ٣٢٦ – ٣٢٧، وفي الصفحة: ٣٢٧ قال شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون: إسناده حسن.

(٢) أخرجه أبو داود، في سننه، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء، برقم: (٤٥٦٥)، ج ٦، ص: ٦٢٣، وفي الصفحة نفسها قال شعيب الأرنؤوط – محمَّد كامل قره بللي: حديث صحيح. وهذا إسناد حسن.

(٣) شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك، أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي، دار الفكر، ط٢، بدون التاريخ، بيروت – لبنان، ج٣/ص: ١٢٨.

(٤) أخرجه أحمد، في مسنده: مسند عبد الله بن عمرو، برقم: (٦٥٣٣)، ج ٦، ص: ١٠١، و أبو داود، في سننه، واللفظ له، كتاب الديات، باب الدية، كم هي؟ برقم: (٤٥٤٧)، ج ٦، ص: ٦٠٧، والنسائي، في سننه الصغرى، كتاب القسامة، باب كم دية شبه العمد، وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه برقم: (٤٧٩١) ج ٨، ص: ٤٠، وابن ماجه، في سننه، أبواب الديات، باب دية شبه العمد مغلظة، برقم: (٢٦٢٧)، كلهم عن عبد الله بن عمرو ، ج ٣، ص: ٦٤٧، وفي هامش سنن أبي داود، ج ٦، ص: ٦٠٧ قال شعيب الأرنؤوط – محمَّد كامل قره بللي: إسناده صحيح.

والرابع: أن يكون على صفة يراد بها القتل ويتقدمه بساط[١] يعلم أنه لم يكن المراد القتل كالمتصارعين والمتلاعبين[٢].

ويتضح مما سبق أن قولهم: القتل نوعان عمد وخطأ مردود؛ لأن شبه العمد ورد في الشرع على ما رواه عبد الله بن عمرو –رضي الله عنهما– أن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال: ((ألا إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط، والعصا، مائة من الإبل: منها أربعون في بطونها أولادها)) [٣]، والصحابة اتفقوا على شبه العمد حيث أوجبوا الدية فيه مغلظة مع اختلافهم في صفة التغليظ، وقال علي –رضي الله عنه– –شبه العمد الضربة بالعصا والعزقة[٤] بالحجر العظيم[٥].

وأجابوا بأن وجه النفي أن الله تعالى ذكر أنواع القتل، فذكر العمد المحض والخطأ المحض، ولم يذكر في كتابه العزيز زائدًا عليهما، ولو كان ثالث لذكره؛ لقوله تعالى: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَٰبِ مِن شَىْءٍ﴾[٦]، ولأن العمد معنى، وهو قصد الفاعل إلى الفعل، والخطأ معنى معقول، وهو ما يكون من غير قصد، وذلك ممتنع من الفعل الواحد؛ لأنهما صفتان متعاندتان [٧].

---

(١) البساطة في الطبع: السذاجة. استعمال شائع عند العامة، وهي من البسيط يعني أن طبعه لا يشوبه مكر ولا دهاء، ينظر: معجم متن اللغة، أحمد رضا، دار مكتبة الحياة، بدون الطبعة، ١٣٧٧ هـ – ١٩٥٨ م، بيروت، ج ١، ص: ٢٩٤.

(٢) الشامل في فقه الإمام مالك، بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، أبو البقاء، تاج الدين السلمي الدَّمِيريّ الدَّمْيَاطيّ المالكي، تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط١، ت: ١٤٢٩ ه – ٢٠٠٨ م، بدون مكان النشر، ج٢، ص: ٨٨١، والتبصرة، علي بن محمد أبو الحسن، الربعي، المعروف باللخمي، تحقيق: أحمد عبد الكريم نجيب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط١، ت: ١٤٣٢ هـ –٢٠١١ م، قطر، ج١٣/ص: ٦٣٥٩.

(٣) سبق تخريجه، ص: ٦١

(٤) هذه الكلمة ليس فيها كلام أصيل، وهي مأخوذة من عزق، بمعنى شق، ويقال: أرض معزوقة، إذا شققتها بفأس أو غيرها، وعزق به، كفرح: لصق، وكنصر: أسرع في العدو، ينظر: معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج٤، ص: ٣٠٦، والقاموس المحيط، محمد بن يعقوب أبو طاهر مجد الدين الفيروزآبادى، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة، ط ٨، ت: ١٤٢٦ هـ – ٢٠٠٥ م، بيروت – لبنان ج١، ص: ٩٠٩، وتاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق أبو الفيض، الحسيني، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر، ج٢، ص: ١٥٢.

(٥) المبسوط، مرجع سابق، ج٢٦/ص: ٦٥.

(٦) سورة الأنعام، الآية: ٣٨.

(٧) الإشراف على نكت مسائل الخلاف، عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد البغدادي المالكي، تحقيق: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، ط١، ت: ١٤٢٠هـ –١٩٩٩م، بدون مكان النشر، ج٢، ص:٨٢٤.

ورد بأن السنة هي المبينة، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾[١]، وقد ورد ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألا إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط، والعصا، مائة من الإبل)) [٢]، فأثبت شبه العمد، ولأن وصفه بذلك يفيد أنّه أخذ شبهاً من العمد، وشبهاً عن الخطأ، فلم يكن له حكم أحدهما على التجريد، وشبهه بالعمد قصد القاتل إلى الضرب بما لا يقتل مثله غالباً، وشبهه بالخطأ أنه لم يقصد القتل، فوجب أن يثبت له حكم منفرد عن حكم يخصهما[٣].

تسمية هذا النوع من أنواع الفعل بهذا المصطلح المركب (شبه العمد أو عمد الخطأ أو خطأ العمد):

هذا النوع يأخذ من العمد شبها ومن الخطأ شبها، فهو أن يكون عامدا في الفعل غير قاصد للقتل وذلك بأن يعمد ضربه بما لا يقتل في الغالب وإن جاز أن يقتل كالسوط والعصا وما توسط من المثقل الذي يجوز أن يقتل ويجوز ألا يقتل، فيأخذ شبها من العمد لعمده للفعل ويأخذ شبها من الخطأ لعدم قصده للقتل فسمي عمد الخطأ لوجود صفة العمد في الفعل وصفة الخطأ في عدم القصد [٤].

المطلب الرابع: درجة مسئولية شبه العمد (الضرب المفضي إلى الموت) في القانون.

من خلال تتبع الباحث تبين أن القوانين الوضعية – ومن ضمنها قانون العقوبات الصومالي– عبرت عن شبه العمد (الضرب المفضي إلى الموت) بدل اصطلاح الفقه الإسلامي بشبه العمد، وهذا ما اعتاد عليه شراح القانون، مع أنه لا يمكن أن يقع شبه العمد بالضرب فقط، وإنما يقع بأفعال أخرى، كالجرح وإعطاء الجواهر السامة وغير ذلك، لهذا ينبغي الانتباه إلى أن التسمية قد شاعت بسبب ما تضمنته من اختصار[٥]، ولذلك ينبغي تقسيم مضمون هذا المطلب إلى الاتي:

أولا: معنى شبه العمد في القانون:

يعرف شبه العمد بأنه الجريمة التي يختلط فيها العمد والخطأ، فلا هي عمد محض، ولا هي خطأ محض، وإنما هي مزيج من العمد والخطأ، كأن يقصد الضرب بآلة لا تقتل عادة [١].

---

(١) سورة النحل، الآية: ٤٤.

(٢) سبق تخريجه، ص: ٦١.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف، مرجع سابق، ج ٢/ص: ٨٢٣.

(٤) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، مرجع سابق، ج١٢/ ص: ٢١١.

(٥) شرح قانون العقوبات الأردني، مرجع سابق، ص: ٢٠٧.

(١) الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، حسن علي الشاذلي، دار الكتاب الجامعي، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر، ص: ٣٥٠.

وتقسم الجنايات إلى نوعين: الأول: هو جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة التي تفضي إلى موت المجنى عليه، والثاني: إذا ترتب على فعل الاعتداء إحداث عاهة مستديمة في جسم المجنى عليه [١].

وأما قانون العقوبات الصومالي لم يعرف تعريفا خاصا للضرب المفضي إلى الموت (شبه العمد)، ولكنه **بين حكمه**، وهو ما سيأتي فيما يترتب على مسئولية شبه العمد في القانون.

عناصر شبه العمد اثنان:

أحدهما: مادي، وهو يقوم على ثلاثة عناصر:

١. فعل الضرب.

٢. وفاة المجنى عليه.

٣. وجود علاقة سببية بين الفعل والنتيجة التي هي الموت.

وثانيهما: معنوي، وهو يقوم على أمرين: أحدهما إيجابي، والآخر سلبي:

أما الأول: فهو أن يكون لدى الجاني قصد ارتكاب الضرب.

وأما الثاني: فهو ألا يكون الجاني قد قصد ارتكاب القتل[٢].

ثانيا: ما يترتب على مسئولية شبه العمد في القانون:

يعاقب القانون على مرتكب الضرب المفضي إلى الموت بالحبس مدة تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة، وعلى هذا نص قانون العقوبات الصومالي على أنه:

"كل من تسبب في وفاة آخر بارتكابه فعلا من الأفعال المشار إليها في المادتين ٤٣٩ و٤٤٠ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تتجاوز عن خمسة عشرة سنة" [٣].

فعقوبة هذا النوع من أنواع القتل هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تتجاوز عن خمسة عشرة سنة.

نص في المادة الأولى: ١- "كل من تعدى على آخر بالضرب ولم ينجم عن هذا التعدي مرض جسمانية أو عقلية يعاقب -بناء على شكوى المجنى عليه-بالسجن مدة أقصاها ستة شهور أو بغرامة أقصاها ثلاثة آلاف شلن صومالي[١].

ونص أيضا في المادة الثانية: ١- كل من أصاب آخر إصابة نسأت عنها مرض جسماني أو عقلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور، ولا تتجاوز ثلاث سنوات [٢].

---

(١) شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ماهر عبد شويش الدرة، المكتبة القانونية، ط ٢، بدون التاريخ، بغداد-العراق، ص:١٩٥.

(٢) الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، مرجع سابق، ص: ٣٦٩.

(٣) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٤٤١.

(١) المرجع سابق ، م: ٤٣٩، ف: (١).

(٢) المرجع السابق، م: ٤٤٠، ف: (١).

وكل هذا ينصب على ما يسمى بـــــ(الضرب المفضي إلى الموت).

وتنص بعض القوانين على أن "من ضرب أو جرح أحدا بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو إعطاء مواد ضارة، ولم يقصد من ذلك قتلا قط، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرا مما وقع عليه، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات" (١).

أما عقوبة الجرح أو الضرب المفضي إلى الموت فقد بينها القانون فيما يلي:

"من اعتدى عمدا على آخر بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو بإعطائه مادة ضارة أو ارتكاب أي فعل آخر مخالفا للقانون، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكنه أفضى إلى موته، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة" (٢).

فما مدى موافقة القانون أو مخالفته للفقه الإسلامي من حيث ما يترتب على شبه العمد:

فمن المعلوم أن هذا النوع هو مما اختلف فيه فقهاء المذاهب الأربعة، وقد تقدم هذا في المطلب السابق آنفا، وذلك على قولين:

قول الجمهور: يرون أن الواجب على مرتكب القتل شبه العمد أو عمد الخطأ الدية مغلظة والكفارة.

وقول المالكية: يرون أنه يجب عليه القود؛ لأن القتل عندهم نوعان: عمد وخطأ، فأما شبه العمد يرون أنه باطل، وقد تقدم الكلام عليه بالتفصيل.

ورغم هذا الاختلاف بين الفقهاء، فإن القانون لم يشم رائحة الموافقة للفقه الإسلامي ولو في وجه من الوجوه، فضلا عن أن يكون موافقا له، بحيث أنه يعاقب القانون الجاني بالاشغال الشاقة في السجن مدة لا تنقص عن عشر سنوات، ولا تتجاوز عن خمسة عشرة سنة، وحكم هذا النوع مما يمكن أن يقال فيه: إنه مما هو معلوم من الدين بالضرورة.

---

(١) شرح قانون العقوبات الأردني، مرجع سابق، ص:٢٠١.

(٢) شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ماهر عبد شويش الدرة، مرجع سابق، ص:١٩٥.

المطلب الخامس: درجة مسئولية الخطأ في الفقه الإسلامي

درجة مسئولية الخطأ في الفقه الإسلامي يستدعي إلى التعريف ثم ما يترتب عليها، وذلك كالتالي:

أولا تعريف القتل الخطأ:

أ- معنى الخطأ في اللغة:

الخطأ في اللغة هو: من خطئ يخطأ خطأ وخِطْئًا، فهو خاطئ وخطئ، فهو مصدر ثلاثي الفعل، فهو من باب أثم[١] ، ويأتي هذا الفعل بمعنى: حاد عن الصواب، غلط، ضد أصاب يقال: خطئ في رأيه، وهو بَشَرٌ يخطأ ويصيب"، وبمعنى: أذنب، تعمد الذنب [٢]، وينبغي هنا الإشارة إلى أنه يفرق في اللغة بين الخطأ بفتحتين، وبين الخطء بكسرة فسكون، فالخطأ هو: ما لم يتعمد، والخطء: ما تعمد، مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴾ [٣]، ويقال: فلان سلك سبيل الخطأ عمدا لا سهوا[٤]، وقوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَٰٓأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَٰطِـِٔينَ ﴾ [٥].

ب. معنى الخطأ في الاصطلاح:

فقد عرف الفقهاء القتل الخطأ: بأن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كأن يرمي صيداً، أو يقصد غرضاً، فيصيب إنساناً معصوم الدم فيقتله، أو كأن يحفر بئراً بشروطه[٦]، فيتردى فيها إنسان ويموت.

وأجمع أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئاً فيصيب غيره، ولا أعلمهم يختلفون فيه [٧]، وفيما يلي تفصيل المذاهب الأربعة:

تعريف الحنفية: الخطأ أن يرمي شخصا يظنه صيدا، أو حربيا فإذا هو مسلم، أو يرمي غرضا فيصيب آدميا[٨].

---

(١) التلخيص في معرفة أسماء الأشياء، الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران أبو هلال العسكري، تحقيق: عزة حسن، دار طلاس، ط٣، ت:١٩٩٦ م، دمشق، ص: ٤١٧.

(٢) معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ج١/ص: ٦٥٨.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ٣١.

(٤) معجم متن اللغة، مرجع سابق، ج٢/ص: ٢٩٥.

(٥) سورة يوسف، الآية: ٩٧.

(٦) بحر المذهب، عبد الواحد بن إسماعيل أبو المحاسن الروياني، تحقيق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، ط ١، ت: ٢٠٠٩ م، بدون مكان النشر، ج ١٢، ص: ٣٤٣.

(٧) الإشراف على مذاهب العلماء، محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري، تحقيق: صغير أحمد أبو حماد الأنصاري، مكتبة مكة الثقافية، ط١، ت:١٤٢٥هـ -٢٠٠٤ م، رأس الخيمة -الإمارات العربية المتحدة، ج٧/ص: ٣٦٠.

(٨) الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود أبو الفضل مجد الدين الموصلي البلدحي، الحنفي، تحقيق: محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي، بدون الطبعة، ت:١٣٥٦ هـ -١٩٣٧ م، القاهرة، ج٥/ص:٢٥.

تعريف المالكية: الخطأ: ما لا قصد فيه إلى الفعل، كما لو سقط على غيره فقتله، أو ما لا قصد فيه إلى الشخص، كما لو رمى إلى صيد فأصاب إنساناً[١].

تعريف الشافعية: الخطأ هو ألا يقصد الجاني عين من وقعت عليه الجناية كأن زلق فوقع على غيره أو لا قصد له إلى الفعل [٢].

تعريف الحنابلة: الخطأ هو: ألا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله [٣]، وجملته: أن الخطأ أن يفعل فعلا لا يريد به إصابة المقتول، فيصيبه ويقتله، مثل أن يرمي صيدا أو هدفا، فيصيب إنسانا فيقتله [٤].

ثانيا: ما يترتب على درجة مسئولية الخطأ في الفقه الإسلامي:

يترتب على درجة مسئولية الخطأ في الفقه الإسلامي أحكام، ومن أهمها عقوبة الخطأ، وهي: وجوب الدية، إذا لم يعفوا عنه والكفارة: وهما بالكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فمنه قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟﴾[٥].

وأما السنة فمنها ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل)) [٦].

وأما الإجماع فهو أن المذاهب المعتبرة الأربعة وغيرهم أجمعوا على أنه تجب على من قتل خطأ الدية والكفارة [٧].

ودية الخطأ مخففة من ثلاثة أوجه: كونها مخمسة: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون ذكر، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، فهذه مذاهب جميع الفقهاء، إلا أن أبا حنيفة جعل مكان ابن لبون ابن مخاض، وذهب جماعة من السلف منهم علي بن أبي طالب

---

(١) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، مرجع سابق، ج٣/ص:١٠٩٠.

(٢) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا أبو يحيى زين الدين الأنصاري، السنيكي، دار الفكر، بدون الطبعة، ت:١٤١٤هـ/١٩٩٤م، وبدون مكان النشر، ج ٢، ص: ١٥٤.

(٣) الكافي في فقه الإمام أحمد، مرجع سابق، ص: ٢٥١.

(٤) المغني، مرجع سابق، ج٨/ص: ٢٧٢.

(٥) سورة النساء، الآية: ٩٢.

(٦) أخرجه الإمام أحمد، في مسنده، مسند عبد الله بن عمرو، برقم: (٢٤٤)، ج ١١، ص: ٢٤٤، وفي الصفحة نفسها شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون: إسناده حسن.

(٧) الجوهرة النيرة، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيديّ اليمني الحنفي، المطبعة الخيرية، ط١، ١٣٢٢هـ، بدون مكان النشر، ج٢/ص: ١٢٨، والكافي في فقه أهل المدينة، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم أبو عمر النمري القرطبي، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، ط٢، ت: ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م، الرياض، المملكة العربية السعودية، ، ج٢/ص: ١١٠٨، و المهذب في فقه الإمام الشافعي، مرجع سابق، ج٣/ص: ٢٠٣، و الكافي في فقه الإمام أحمد، مرجع سابق، ج٤/ص: ٥٢.

إلى أن دية الخطأ مربعة، واختلفوا في أسنانها اختلافا كثيرا ليس هذا موضع إيراده، إذ لم أقصد إلى ذكر الاختلاف وإنما قصدت إلى تلخيص المذاهب، وكونها مؤجلة بثلاث سنوات، وكونها على العاقلة.[١]

المطلب السادس: درجة مسئولية الخطأ في القانون.

سيأتي في هذا المطلب تعريف للقتل الخطأ أولا، ثم ما يترتب على درجة مسئولية الخطأ ثانيا، وذلك على النحو التالي:

أولا: تعريف القتل الخطأ:

معنى القتل الخطأ في القانون:

القتل الخطأ هو النشاط الإرادي –إيجابيا كان أو سلبيا–لا يتفق مع واجبات الحيطة والحذر يؤدي إلى وفاة المجنى عليه، مع استطاعة المتهم أن يحول دون تحققها [٢].

وعلى هذا نص قانون العقوبات الصومالي من أنه:

١- تعتبر الجريمة:

ج- خطأ أو بغير عمد حين لا يقصد الجاني إتيان الفعل حتى ولو تكهن به وحدث نتيجة إهماله أو رعونته أو افتقاره إلى المهارة أو عدم مراعاة للقوانين واللوائح والأوامر والتعليمات [٣].

فاتضح أن القتل الخطأ هو: عدم اتجاه إرادة الجاني إلى إيجاد الفعل.

وفي هذا التعريف نقص من حيث إنه لم يذكر القانون فيه عدم إرادة إحداث النتيجة، فإنه يعتبر أيضا خطأ.

ثم إن للخطأ عنصرين:

الأول: هو الإخلال بواجبات الحيطة والحذر. والثاني: هو العلاقة الذهنية والنفسية بين مرتكبي الفعل والنتيجة الجرمية [٤].

---

(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي، ط ٢، بدون التاريخ، ومكان النشر، ج ٧، ص: ٣٧٣، و المقدمات الممهدات، محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد القرطبي، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ط ١، ت: ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م، ج ٣، بيروت – لبنان، ص: ٢٩١، والعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، تحقيق: علي محمد عوض – عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط ١، ت: ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م، بيروت – لبنان، ج ١٠، ص: ٣١٣، والدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، مرجع سابق، ج ٣، ص: ٣٤٥.

(٢) شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، القسم الثاني، فتوح عبد الله الشاذلي، مرجع سابق، ص:٥٥٥.

(٣) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٢٤، ف (١/ج).

(٤) قانون العقوبات، القسم العام، عبود السراج، مرجع سابق، ص:٢٠٠-٢٠٥.

ثانيا: ما يترتب على درجة مسئولية الخطأ في القانون:

ذكر قانون العقوبات الصومالي أن حكم القتل الخطأ الحبس، حيث نص في الفقرة الأولى من المادة على أن:

١. "كل من تسبب في موت آخر بإهماله الناشئ عن خطئه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور، ولا تتجاوز خمس سنوات" (١).

أنواع القتل الخطأ، يتنوع القتل الخطأ إلى ثلاثة أنواع:

١. الخطأ غير الواعي والخطأ الواعي، فالخطأ غير الواعي هو: الذي لم يتوقع في الجاني النتيجة الجرمية، وكانت إرادته منصرفة إلى نتيجة مشروعة، كمن يطلق النار على طير، فيصيب إنسانا فقتله، والخطأ الواعي هو: على عكس الخطأ غير الواعي، يتوقع الجاني في النتيجة الجرمية.

٢. الخطأ الجزائي والخطأ المدني، فالخطأ الجزائي هو: سلوك غير مقصود أدى إلى نتيجة ضارة يعاقب عليه القانون بعقوبة جزائية. والخطأ المدني هو: سلوك مقصود أو غير مقصود يسبب ضررا للغير، ويلزم من يرتكبه بالتعويض.

٣. الخطأ العادي والخطأ الفني: فالخطأ العادي هو: الخطأ العام الذي يرجع إلى مخالفة واجب الحيطة والحذر في الأمور المتعلقة بجميع الناس، والخطأ الفني هو: الذي يرتكبه أهل الفن ممن يزاولون مهنة من المهن، كالأطبّاء(٢).

فما مدى موافقة القانون للفقه الإسلامي من حيث حكم الخطأ على الجاني:

فقانون العقوبات الصومالي مخالف هنا للفقه الإسلامي على الإطلاق؛ لأن حكم الخطأ في الفقه الإسلامي هو الدية على العاقلة والكفارة، فجعل القانون حكم الخطأ الحبس.

فاتضح أن بينهما مخالفة واضحة كوضوح الشمس، فينبغي لمجلس التشريع اجتناب ما هو فيه مخالفة لكتاب الله تعالى، كما هنا؛ لأن الله سبحانه تعالى كما تقدم قرر للقتل الخطأ عقوبة من: تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلا أن يعفو أولياء المجنى عليه، فلا عليه شيء، إلا أنه يجوز للسلطة المختصة التعزير.

---

(١) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٤٤٥، ف (١).

(٢) قانون العقوبات، القسم العام، عبود السراج، مرجع سابق، ص:٢٠٠-٢٠٢.

الخلاصة

يشترط في المسائل الجنائية الإدراك والإرادة؛ لأن معنى التكليف هو البلوغ والعقل، وبناء على ذلك فإن محل المسئولية الجنائية لا يكون إلا في الإنسان فحسب، فالحيوان غير الإنسان لا مسئولية عليه؛ لأنه لا يعقل، وكذلك أن المسئولية الجنائية شخصية، بمعنى: أنه لا يسأل عن الجرم إلا فاعله، ولا يؤخذ أمرؤ بجريرة غيره مهما كانت درجة القرابة أو الصداقة بينهما إلا أن الفقه الإسلامي استثنى من هذه القاعدة أن العاقلة تتحمل دية شبه العمد والخطأ بشكل عام، ولكن القوانين لم تطبق هذا المبدأ بدقة تامة.

فالقانون يتفق مع الفقه الإسلامي فيما تقدم من سبب المسئولية الجنائية من حيث المخالفة، ويختلفان من حيث تفصيل المخالفة، فالفقه الإسلامي يرى أن السبب هو مخالفة حكم الله تعالى، ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأما القانون فيرى أن سبب المسئولية الجنائية هو ارتكاب الجرائم، ولذلك لا مسئولية ما لم يكن الجاني مخطئاً؛ أي عاصياً.

وأما صور القصد الجنائي في الفقه الإسلامي والقانون فمتة باعتبارات ثلاثة:

١. باعتبار عموم القصد وغيره يكون له صورتان: القصد العام والقصد الخاص.
٢. باعتبار التعيين وعدمه ينقسم إلى القصد المعين وغير المعين.
٣. باعتبار المباشرة وعدمها ينقسم إلى القصد المباشر والقصد الاحتمالي.

وأما درجات المسئولية الجنائية إما أن يكون في درجة عمد أو شبه عمد أو خطأ.

ودرجة العمد فحكمها القصاص وهو الإعدام، ولا مخالفة بين قانون العقوبات الصومالي والفقه الإسلامي جملةً من حيث حكم القتل العمد، من كونه إعداما، أي: قصاصا، وأما حكمه تفصيلا فيوجد فيه اختلاف في القيود والشروط؛ لأن في الفقه الإسلامي أحكاما خاصة إذا كان بين القاتل والمقتول اختلاف دين ومكافأة مثلا، والقانون لا يفرق بين ذلك.

ومن أهم ما يترتب على درجة مسئولية شبه العمد في الفقه الإسلامي عقوبة شبه العمد، فهي إما وجوب دية، وإما أن شبه العمد باطل، ويدخل في العمد، وإنما هو عمد أو خطأ، وأما حكمه في القانون فهو أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تتجاوز عن خمسة عشرة سنة.

وأيضا مما سبق أن قانون العقوبات الصومالي خرج عن قواعد الشريعة الإسلامية، خروجا واضحا، بحيث أن الفقه الإسلامي يحكم على مرتكب هذا النوع من القتل الدية على العاقلة مغلظة عند الجمهور، والقتل عند المالكية، بخلاف القانون، فإنه يجعل عقوبة هذا الجاني بالسجن بدلا عن الدية في الفقه الإسلامي.

ومن أهم ما يترتب على درجة مسئولية الخطأ في الفقه الإسلامي: وجوب الدية بالنص، بينما ذكر قانون العقوبات الصومالي أن حكم القتل الخطأ الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور، ولا تتجاوز خمس سنوات بالنص، وهذه مخالفة فاحشة، فلا ينبغي أن يكون هذا النص موجودا في قانون دولة يقال: إنها مسلمة مائة بالمائة، فنسأل الله أن يوافقنا بالتدارك في أمر ديننا، ويحولنا إلى الصواب.

الفصل الثالث: موانع المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي

المبحث الأول: موانع الإدراك في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي

المطلب الأول: الصغر في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني: الصغر في القانون

المطلب الثالث: الجنون وما يلحق به في الفقه الإسلامي

المطلب الرابع: الجنون وما يلحق به في القانون

المبحث الثاني: موانع الاختيار في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي

المطلب الأول: الإكراه في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني: الإكراه في القانون

المطلب الثالث: الضرورة في الفقه الإسلامي

المطلب الرابع الضرورة في القانون

المبحث الثالث: الرضا على المسئولية الجنائية والجهل عنها في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.

المطلب الأول: رضا المجنى عليه على القتل والجرح في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني: رضا المجنى عليه على القتل والجرح في القانون

المطلب الثالث: الجهل بتحريم الفعل والحكم وأقسامه في الفقه الإسلامي

المطلب الرابع: الجهل بتحريم الفعل والحكم وأقسامه في القانون

الفصل الثالث: موانع المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي:

تمهيد: فموانع المسئولية الجنائية: هي الأسباب الشخصية التي تعترض الفاعل بالذات فتصيب إرادته وتعيبها كالإكراه، أو تعدمها كالجنون، أو تنقصها كالصغر.

أو هي تلك الأسباب التي تفقد الشخص قدرته على التميز والاختيار فتجعله غير أهل لتحمل المسئولية الجنائية.

وعلى هذا يمكن حصر موانع المسئولية الجنائية في أمور وذلك في ثلاثة مباحث.

١. موانع الإدراك، وهي اثنان: الأول: الصغر، وهو يعتبر من موانع المسئولية الجنائية، فكل من لم يبلغ الاحتلام لا يعتبر مكلفا في الفقه الإسلامي، ولا مسئولا جنايا في قانون العقوبات الصومالي، والثاني: الجنون، وهو زوال العقل أو اختلاله بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا، فكل مجنون غير متعد لا يعتبر أيضا مكلفا في الفقه الإسلامي، ولا مسئولا جنائيا في قانون العقوبات الصومالي.

٢. موانع الاختيار، وهو اثنان أيضا: الأول: الإكراه، وهو حمل الإنسان على أمر لا يريده طبعا أو شرعا، وهو في الجملة يعتبر مانعا من موانع المسئولية الجنائية، والثاني: الضرورة، وهي: بلوغ الشخص حدا إن لم يفعل الممنوع هلك أو قارب، كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعا أو عاريا لمات أو تلف منه عضو، فهي أيضا مانع من موانع المسئولية الجنائية بشروط ستأتي.

٣. الرضا والجهل، وكل منهما من موانع المسئولية الجنائية، أما الرضا فنوعان، الأول: الرضا على القتل مع اختلاف الفقهاء في أثره على القتل، والثاني: الرضا على الجرح، فهو مجمع على كونه مانعا من موانع المسئولية الجنائية في الفقه والقانون، وأما الجهل، فهو انتفاء العلم بالمقصود، وهو أيضا مانع من موانع المسئولية الجنائية، مع تفصيل سيأتي فيما بعد.

المبحث الأول: موانع الإدراك في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي

تمهيد: تقدم في الفصل الأول تفصيل ما يتعلق بمعنى الإدراك لغة واصطلاحا، فأما الإدراك في اللغة: اللحاق، وفي الاصطلاح: وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها بلا حكم معه.

وفائدته هي: أن الإدراك يعتبر أساسا لكل نشاط متعلق بالذهن، فهو يؤثر في حياة الطفل حيث يبدأ بالتعرف على المحيط البيئي الذي يعيش فيه وبالتفاعل مع المدركات الحسية التي تواجهه.

وهنا يتكلم الباحث على موانع الإدراك: **الصغر**، وهو: يعتبر نقصا وسببا من أسباب التخفيف، وهو بمعنى القلة ضد العظمة، ويقال: صغر الشخص أو الشيء: قل حجمه أو سنه، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله، **والجنون**، الذي هو: زوال العقل أو اختلاله، بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا، فإنه يكون أيضا مانعا من موانع المسئولية الجنائية.

فموانع الإدراك سواء كانت في الفقه الإسلامي أو في قانون العقوبات الصومالي أو القوانين الوضعية الأخرى يتكون من اثنين: الأول منهما: الصغر، والثاني: الجنون وما يلحق به، فعلى هذا فالصغر باعتبار حكمه في الفقه الإسلامي، وباعتباره في قانون العقوبات الصومالي والقوانين الأخرى يكون مانعا من موانع المسئولية الجنائية، ويكون له مطلبان، وأما الجنون فكذلك أيضا، ويكون له مطلبان، وسيأتي هذا في ما يلي:

المطلب الأول: الصغر في الفقه الإسلامي.

الصغر على وزان عنب وجمعه صغار، والصغيرة صفة جمعها صغار أيضا، ولا تجمع على صغائر [١].

وهو بمعنى القلة ضد العظمة، ويقال: صغر الشخص أو الشيء: قل حجمه أو سنه [٢].

ويعتبر الصغر في الفقه الإسلامي أنه مانع من موانع المسئولية ورافع للتكليف، فكل من لم يبلغ الاحتلام فلا يعتبر مسئولا جنائيا ومكلفا في الفقه الإسلامي؛ لأنه لا فهم ولا قصد له، وأيضا يعتبر الصغر نقصا، وهو سبب من أسباب التخفيف، والنقص هو نوع من المشقة؛ إذ النفوس مجبولة على حب الكمال، فناسبه التخفيف في التكليفات [١].

---

(١) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مرجع سابق، ج١، ص: ٣٤٠.

(٢) معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ج٢، ص: ١٢٩٧.

(١) الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، ط١، ت: ١٤١١هـ-١٩٩٠م، بدون مكان النشر، ص: ٨٠.

فمسألة تكليف الصبي فيها خلاف بين العلماء، وتفصيل ذلك هو أن الصبي إما أن يكون مميزا أو غير مميز.

أما المميز ففي تكليفه قولان:

القول الأول: قول الإثبات؛ أي: تكليف الصبي المميز، وهو رواية مرجوحة عن أحمد[١]؛ لأنه يفهم الخطاب، ولذلك سمي مميزا؛ لأنه يميز الأقوال والأفعال بعضها من بعض، خيرا وشرا، وجيدا ورديئا، والتمييز: التخليص والتفصيل، ويقال: ميزت هذا من هذا، أي: أفرزته عنه، وفصلته منه، فإذا فهم المميز الخطاب، كان مكلفا، كالبالغ[٢].

القول الثاني هو: قول النفي، أي: عدم تكليف الصبي المميز، وهو قول المحققين [٣] ؛ لأن أول وقت يفهم فيه الخطاب، غير موقوف على حقيقته، فنصب له علم ظاهر يكلف عنده، وهو البلوغ، ولأن العقل قوة غريزية، يدرك بها الكليات وغيرها، وهو يوجد بوجود الإنسان، ثم يتزايد بتزايد البدن تزايدا تدريجيا خفيا عن الحس، كتزايد الأجسام النباتية والحيوانية في النماء، وضوء الصبح، وظل الشمس، ونحوها من المتزايدات الخفية، فلا يمكن الوقوف على أول وقت يفهم فيه الخطاب، فجعل الشرع بلوغه علما ظاهرا على أهليته للتكليف، وضابطا له[٤].

ولكن ذهب الإمام مالك وأصحابه إلى تكليف الصبي المميز بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب والحرام [١].

---

(١) الشرح الكبير على متن المقنع، مرجع سابق، ج١/ص: ٣٨٠.

(٢) شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، ج١، ص: ١٨٦.

(٣) التقرير والتحبير، محمد بن محمد بن محمد أبو عبد الله، شمس الدين المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي، دار الكتب العلمية، ط ٢، ت: ١٤٠٣هـ – ١٩٨٣م، بدون مكان النشر، ج ٢، ص: ١٦٤، و كتاب التلخيص في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد أبو المعالي، ركن الدين، الجويني، الملقب بإمام الحرمين، تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية، بدون الطبعة، والتاريخ، بيروت، ج ١، ص: ١٤٤، وتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، يحيى بن موسى أبو زكريا الرهوني، تحقيق، الهادي بن الحسين شبيلي، يوسف الأخضر القيم، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ط ١، ت: ١٤٢٢ هـ – ٢٠٠٢ م، دبي – الإمارات، ج ٢، ص: ١٢٤، وشرح مختصر أصول الفقه، تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي، تحقيق: عبد العزيز محمد عيسى محمد مزاحم القايدي، عبد الرحمن بن علي الحطاب، ومحمد بن عوض بن خالد رواس، أصل الكتاب: رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية، الشامية – ط ١، ت: ١٤٣٣ هـ – ٢٠١٢ م، الكويت،ج ١، ص: ٤٨٤.

(٤) شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، ج١، ص: ١٨٦.

(١) مذكرة في أصول الفقه، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، مكتبة العلوم والحكم، ط٥، ت: ٢٠٠١ م، المدينة المنورة – المملكة العربية السعودية، ص: ٣٦.

واستدلوا على مذهبهم بالإجماع على أنه لا إثم عليه بترك واجب ولا بارتكاب حرام لرفع القلم عنه، وأما المكروه والمندوب[١]، فاستدلوا لتكليفه بهما بما روى ابن عباس –رضي الله عنهما– من أن النبي صلى الله عليه وسلم، لقي ركبا بالروحاء، فقال: «من القوم؟» قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله صلى الله عليه وسلم»، فرفعت إليه امرأة صبيا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر)) [٢].

والراجح هو القول الثاني، الذي مضمونه: أن الصبي غير مكلف؛ لقوة دليله، مما سبق من أن مقتضى التكليف هو الطاعة والامتثال، ولا تمكن إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد العلم بالمقصود، والفهم للتكليف؛ إذ من لا يفهم كيف يقال له: افهم؟، ومن لا يسمع الصوت كالجماد كيف يكلم؟ وأما وجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي ليس تكليفًا له؛ إذ يستحيل التكليف بفعل الغير [٣].

وأما تكليف الصبي غير المميز: ففي تكليفه أيضا قولان:

القول الأول: أن الصبي إذا لم يبلغ حد التمييز، فإنه غير مكلف؛ لأنه إذا لم يكلف الصبي المميز، لم يكلف الصبي غير المميز، بل عدم تكليف الصبي غير المميز أقوى من عدم تكليف الصبي المميز، وهذا مذهب جمهور العلماء، ومضمونه: أن الصبي غير المميز ليس مكلَّفا، وهو الحق الذي لا يجوز غيره؛ وذلك لأن الذي لا يفهم الخطاب الوارد من الشارع لا يتصور منه قصد مقتضاه، والصبي غير المميز لا يفهم شيئاً من الخطابات، فلذلك سقطت عنه المطالبة بمقتضى ذلك الخطاب[٤].

القول الثاني: أن الصبي غير المميز مكلف، وذهب إلى ذلك بعض الناس [٥]؛ لأن الصبي قد وجه إليه الخطاب بدفع الزكاة من ماله إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، ودفع أروش

---

(١) الشرح الكبير على متن المقنع، مرجع سابق، ج١/ص: ٣٨٠.

(٢) أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب الحج، برقم: (١٣٣٦)، ج ٢، ص: ٩٧٤.

(٣) روضة الناظر وجنة المناظر ، مرجع سابق، ج ١/ص: ١٥٥.

(٤) تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول «المختصر»، محمد بن محمد بن عبد الرحمن كمال الدين المعروف بـــ «ابن إمام الكاملية» ، تحقيق: عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، دار الفاروق الحديثة، ط١، ت: ١٤٢٣ هـــ – ٢٠٠٢ م– القاهرة– مصر، ج٤، ص: ٣١٤.

(٥) كما نقل ذلك ابن تيمية في المسودة، آل تيمية [بدأ بتصنيفها الجد: مجد الدين عبد السلام بن تيمية (ت: ٦٥٢هـــ) ، وأضاف إليها الأب، : عبد الحليم بن تيمية (ت: ٦٨٢هـــ) ، ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (٧٢٨هـــ)]، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر، بقوله: واختار قوم تكليفهما – أي: الصبي والمجنون، ص: ٣٥.

الجنايات، وقيم المتلفات، وهذا تكليف من جهة الشرع، فلو كان غير مكلّف لما لزمه دفع تلك الواجبات من ماله، فلما لزم ذلك دلّ على تكليفه[١].

الترجيح:

يترجح لدى الباحث القول الأول، وهو عدم تكليف الصبي غير المميز؛ لقوة دليله، مما سبق من أن مقتضى التكليف هو الطاعة والامتثال، ولا تمكن إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد العلم بالمقصود، والفهم للتكليف؛ إذ من لا يفهم كيف يقال له: افهم؟، ومن لا يسمع الصوت كالجماد كيف يكلم؟ كما تقدم.

ولحديث "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر" [٢].

المطلب الثاني: الصغر في القانون

صغير السن في القوانين الوضعية هو الذي قل سنه بعدم بلوغه سنا معينا يحدده القانون، ومع ذلك فإن القانون ذكر ثلاث مراحل باعتبار وجود المسئولية الجنائية وعدمها، كما تقدم بيانه عند الكلام على التمييز في الفصل الأول.

وعلى أية حال فإن صغر السن يعتبر أحد أسباب امتناع المسئولية الجنائية في قانون العقوبات الصومالي، وغيره من القوانين الأخرى، كالقانون اليمني، وعلة ذلك: أن الشخص في هذه المرحلة من العمر لا يكتمل إدراكه ونموه العقلي، الأمر الذي لا يسمح له بتفهم ماهية أفعاله والنتائج المترتبة عليها، كما لا يسمح له بالتمييز بين البواعث المختلفة لسلوكه [٣].

وبناء على ذلك فإن القانون ينظم أحكام المسئولية الجنائية للإنسان منذ ولاته حتى تكتمل له المسئولية الجنائية التامة في المراحل الثلاث:

١. حالة عدم المسئولية الجنائية:

وهذه الحالة تبدأ من ولادته إلى الرابعة عشر من عمره، فالقانون يعتبر الشخص في هذه الحالة غير مسئول جنائيا، وهذا ما نص عليه قانون العقوبات الصومالي في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن أربعة عشر عاما، حيث نص على أنه: "لا مسئولية على الشخص الذي لم يبلغ وقت ارتكاب الفعل أربعة عشر عاما "[١].

---

(١) المهذب في علم أصول الفقه المقارن، مرجع سابق، ج١، ص: ٣٢٧.

(٢) سبق تخريجه، ص:٢١.

(٣) شرح قانون العقوبات اليمني، القسم العام، حسني الجنيدي، بدون الناشر والطبعة، ت١٤١١هـ-١٩٩٠م، وبدون مكان النشر، ص:٤١٣.

(١) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٥٩.

٢. حالة المسئولية الناقصة:

تبدأ من الرابعة عشر إلى الثامنة عشر، وهذا منصوص عليه في قانون العقوبات الصومالي في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشر عاما، حيث نص على أنه: ١. "إذا كانت سن الصغير وقت ارتكاب الجريمة قد جاوزت أربعة عشر سنة ولم يبلغ ثمانية عشر سنة، اعتبر مسئولا إذا توافرت لديه القدرة على الإدراك والاختيار، على أن تخفض العقوبة في هذه الحالة" (١).

٣. حالة المسئولية الجنائية الكاملة:

وهذه الحالة تبدأ من الثامنة عشر سنة إلى الوفاة، ما دامت الشروط المطلوبة متوفرة فيها، وهي مفهومة من مجموع النصين السابقين؛ لأنه إذا كان فيما قبل السنة الرابعة عشر غير مسئول جنائيا البتة، وما بينها وبين الثامنة عشر كان مسئولا جنائيا مسئولية مخففة، ولم ينص القانون فيما إذا كان اكتمل له ثمانية عشر وما بعده، ويفهم من ذلك أنه في هذه الحالة غير المنصوصة عليها هو المسئول جنائيا مسئولية كاملة، ولأنه هو الذي يطبق عليه أحكام قانون العقوبات (٢).

فما مدى موافقة القانون للفقه الإسلامي من حيث تكليف الصبي المميز وغير المميز وعدمه؟

ليس هناك خلاف جوهري يمكن القول لأجله: إن القانون مخالف للفقه الإسلامي من تكليف الصبي مطلقا، فهو موافق له إجمالا، كما يبدو للباحث.

المطلب الثالث: الجنون وما يلحق به في الفقه الإسلامي

الجنون هو: زوال العقل أو اختلاله، بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا (٣)، **وبمعنى آخر:** هو ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف وشرط توجه الخطاب للمخاطب، وأما الشخص المجنون فهو الذي: ذهب عنه العقل أو فسد عنه، ويجمع على مجانين(٤).

ولا يختلف العلماء في أن الجنون يمنع التكليف في الجملة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم: «المجنون حتى يفيق»(٥).

---

(١) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٦٠، ف: (١).

(٢) شرح قانون الجرائم والعقوبات، مرجع سابق، ص: ٣٥٢.

(٣) دستور العلماء، مرجع سابق، ج١/ص: ٢٨٢.

(٤) المعجم الوسيط، مرجع سابق، ج١، ص: ١٤١.

(٥) أخرجه محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم أبو عبد الله الحاكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع، في المستدرك على الصحيحين، كتاب الطهارة، أما حديث عبد الرحمن بن مهدي، برقم: ٩٤٩، عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط١، ت:١٤١١هـ – ١٩٩٠م، بيروت، ج١،ص: ٣٨٩، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

وأما الأحكام التي تثبت للمجنون فهي تختلف باختلاف متعلقها على النحو التالي:

أ. أحكام أقواله.

ب. أحكام أفعاله.

ج. أحكام تركه.

فأما أحكام أقواله فهي لغو لا يؤاخذ عليها ولا يترتب عليها حكم شرعي لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلو قذف أو باع أو اشترى فلا أثر لشيء من ذلك، وهو محل وفاق [١].

وأما **أحكام** أفعاله وتصرفاته التي قام بها وتتعلق بالعبادات، فهي لغو لا أثر لها، بشرط أن لا تمس في شيء لا دخل للغير فيها، وإن كان فيها ضرر بالغير فهو لا يؤاخذ عليها في الآخرة، فلا تعتبر الأفعال الصادرة من المجنون، وأنها لا حكم لها في الشرع بأن يقال فيها: جائز، أو ممنوع، أو واجب، أو غير ذلك؛ كما لا اعتبار بها من البهائم [٢].

وأما في الدنيا فعليه ضمانها إن ترتب عليها ضمان، فلو أتلف مالا أو قتل قتيلا فلا إثم عليه ولا قصاص ولكن الضمان يثبت في ماله أو على عاقلته؛ لأن الضمان ليس مشروطا بالتكليف[٣].

وأما أحكام تركه فإنه لا يؤاخذ عليه فيما يتعلق بحقوق الله، ولكن اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: ذهب إلى أنه لو أفاق المجنون بعد فوات واجبات من عبادة بفوات وقت النية لم يجب عليه القضاء مطلقا، وهو مذهب الحنفية والشافعية [٤].

واستدلوا أيضا بأنه بلغ بعد فوات الوقت الموضوع للعبادة، فلم يلزمه فعلها، كما لو بلغ بعد غروب الشمس، ولأنها عبادة مؤقتة بلغ بعد خروج وقتها الموضوع لها، فلم يلزمه، فصار كمن بلغ بعد مضي رمضان، ولأنه وقت للجمع بين الصلاة فلم تجب بإدراكه، قياسا على وقت الظهر [٥].

---

(١) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، بدون الطبعة والتاريخ، ومكان النشر، ج ٤، ص: ٢٧٠، وأصول الفقه الذي لا يَسَعُ الفقيهِ جَهلُهُ، عياض بن نامي بن عوض السلمي، دار التدمرية، ط١، ت: ١٤٢٦ هـ -٢٠٠٥م، الرياض -المملكة العربية السعودية، ص: ٨١.

(٢) الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: مشهور بن حسن أبو عبيدة آل سلمان، دار ابن عفان، ط١، ت: ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م، بدون مكان النشر، ج١، ص: ٢٣٥.

(٣) أصُولُ الفقهِ الذي لا يَسَعُ الفَقيهِ جَهلُهُ، مرجع سابق، ص:٨٢.

(٤) رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق، ج ٢، ص: ٣٧٣، و منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين أبو محمد الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى، تحقيق: أحمد عبد الرزاق الكبيسي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط ١، ت: ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م، قطر، ص: ٩٢، و تحفة المحتاج في شرح المنهاج، مرجع سابق، ج ٣، ص: ٤١٥.

(٥) التجريد للقدوري، مرجع سابق، ج ١، ص: ٣٩٩.

القول الثاني: ذهب إلى أنه لا يطلب منه القضاء لو أفاق من جنونه إلا إذا كانت العبادة لم يذهب وقتها، **وهذا مذهب المالكية والحنابلة** [١].

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((وعن المجنون حتى يعقل)) [٢] ، ووجه الدلالة هو أن رفع القلم هو في حالة الجنون، وينتهي بإفاقة المجنون، فإذا أفاق يجب عليه القضاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ﴾ [٣] ، وأن الجنون مرض، والمرض لا يمنع القضاء [٤] ؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [٥] .

الترجيح:

والراجح عند الباحث هنا هو القول بعدم تكليف المجنون؛ لأن الجنون يخالف المرض في كثير من الأحكام؛ لأن العلة التي ترفع التكليف عن المجنون – وهو عدم العقل– غير العلة التي ترفع التكليف عن المريض –وهو عدم القدرة– فلا تتناوله الآية.

ويلحق بالجنون أمور، منها:

١– المعتَه بمنزلة الصبا، (كالجنون) بعدما عقل الصبي، فالمعتوه هو الذي اختلف كلامه، فصار بعضه ككلام العاقل، وبعضه ككلام المجنون، فكان ذلك الاختلاط لنقصان عقله، كما يكون في الصبي فيكون حكمه حكم الصبي، إلا في حق العبادات، فلا يسقط به الوجوب؛ احتياطياً في وقت الخطاب، وهو البلوغ، بخلاف الصبا؛ لأنه وقت سقوط الخطاب.

٢ السفه بعد البلوغ، فهو لا يوجب الحجر؛ لأن ظهاره وطلاقه وما لا يبطله الهزل ينفذ منه؛ لأن السفه ليس بعبارة عن نقصان العقل، بل عن مكابرة العقل بغلبة الهوى، وقد نهانا الشرع عن اتباع الهوى، فلا يصير اتباعه الهوى بخلاف موجب العقل عذراً له يوجب الحجر نظراً له، وبالإجماع لم يوجب سقوط الخطاب نظراً، ولم يجعل السفيه وإن كان مغلوب هواه كالمكره

---

(١) أصُولُ الفقهِ الذي لا يَسَعُ الفَقِيهَ جَهلُهُ، مرجع سابق، ص:٨١–٨٢، وشفاء الغليل في حل مقفل خليل، محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي أبو عبد الله العثماني المكناسي، تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات، ط ١، ت: ١٤٢٩ هـ – ٢٠٠٨ م، القاهرة – جمهورية مصر العربية، ج ١، ص: ٢٩٥، والمغني لابن قدامة، مرجع سابق، ج ٣، ص: ١٤٦.

(٢) سبق تخريجه، ص:٢٦.

(٣) سورة طه، الآية: ١٤.

(٤) بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، مرجع سابق، ج ١، ص: ٢٤٧.

(٥) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.

الذي هو مغلوب بغيره لأن ذلك عذر عند الله تعالى، وهذا لم يجعل عذراً عند الله تعالى لقدرته لا محالة على الدفع لو لم يساعد نفسه، وإنما يصير مغلوباً بالمساعدة مختاراً [١].

٣- السكر، وهو من أقسام العوارض للأهلية، ولكن مع هذا فإن جميع أنواع السكر ليس مانعا للمسئولية الجنائية، وتفصيل ذلك أن السكر نوعان: سكر بشيء مباح، وسكر بمحرم:

أما السكر بمباح، مثل الإكراه على شرب الخمر بالقتل والاضطرار إلى المحرم، فهذا النوع هو الذي يعتبر كمانع من موانع المسئولية الجنائية.

أما السكر بمحرم، فلا ينافي الخطاب، قال الله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ ﴾ [٢]، وإن كان هذا خطابا في حال السكر فلا شبهة فيه، وإن كان في حال الصحو فكذلك ألا ترى أنه لا يقال للعاقل إذا جننت فلا تفعل كذا، وإذا ثبت أنه مخاطب ثبت أن السكر لا يبطل شيئا من الأهلية، فيلزمه أحكام الشرع كلها، ويصح عباراته كلها [٣].

المطلب الرابع: الجنون وما يلحق به في القانون.

فما دام أن الحكم على الشيء فرع عن معرفته فإن تعريف الجنون في اللغة تقدم بيانه في المطلب السابق، وهنا يأتي الدور على معنى الجنون عند فقهاء القانون، وهم يعرفون الجنون بأنه: ظاهرة من ظواهر الاعتلال العقلي في الإنسان يترتب عليه فقدان الوعي أو الإدراك، ويعنى ذلك: فقدان القدرة على التكييف مع المؤثرات الخارجية المحيطة به أو القائمة فيه من فيزيائية أو كيميائية أو نفسية أو اجتماعية، فيجعل تصرفه غير مألوف مع السلوك الواجب والمتفق مع القواعد الاجتماعية[٤].

وبمعنى آخر هو: عدم قدرة الشخص على التوفيق بين أفكاره وشعوره وما يحيط به الإنسان عقلية [٥]، وبعد ذلك فإن الجنون مانع من موانع المسئولية الجنائية، ومن ثم فإن المجنون لو ارتكب أي فعل محرم فإنه لا يسأل مسئولية جنائية عما ترتب على ذلك الفعل، وهذا ما نص عليه قانون العقوبات الصومالي حيث نص على القصور العقلي الكلي:

"لا مسئولية على كل من كان وقت ارتكاب الفعل في حالة عقلية تمنع مقدرته على الإدراك والاختيار بسب قصوره العقلي" [٦].

---

(١) تقويم الأدلة في أصول الفقه، عبد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدَبوسيّ الحنفي، تحقيق: خليل محيي الدين الميس، دار الكتب العلمية، ط١، ت: ١٤٢١هـ -٢٠٠١م، بدون مكان النشر، ص: ٤٣٣.

(٢) سورة النساء، الآية: ٤٣.

(٣) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، مرجع سابق، ج٤، ص:٣٥١- ٣٥٣.

(٤) شرح قانون العقوبات اليمني، القسم العام، مرجع سابق، ص: ٤٢٣.

(٥) شرح قانون الجرائم والعقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص:٣٤٥

(٦) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٥٠.

ومعنى المادة: أن كل شخص ليست له قدرة على التوفيق بين شعوره وأفكاره وما يحيط به بسبب فقدان القدرة على الإرادة والإدراك، وقد ارتكب وهو على هذه الحال فعلا مجرما، فإنه لا يكون مسئولا جنائيا.

واتضح من هذا النص أن هذا الفقدان عن الإرادة والإدراك الذي يمنع المسئولية الجنائية يشترط له شروط:

الأول: أن يكون وقت ارتكاب الجريمة فاقدا للقدرة، فإذا كان وقت ارتكاب الفعل المجرم واعيا وقادرا على الإدراك والإرادة فإنه يكون مسئولا جنائيا، وهذا يفهم من عبارة نص المادة السابقة: "وقت ارتكاب الفعل".

الثاني: أن تكون الحالة مانعة كاملة للشخص عن تلك القدرة، أما إذا كانت الحالة غير كاملة، بل كانت تقلل إلى حد –وهو ما يعبر عنه القانون بالقصور الجزئي–فإنه يعد مسئولا جنائيا مسئولية مخففة، ولذلك يعاقب عليه عقوبة مخففة، وهذا ما نص عليه قانون العقوبات الصومالي من القصور الجزئي، من أنه:

يعد مسئولا عن الجريمة كل من كان وقت ارتكاب الفعل بسبب قصوره العقلي في حالة عقلية تقلل إلى حد كبير دون أن تمنع مقدرته على الإدراك والإرادة على أن تخفض العقوبة [١].

الثالث: أن يكون الفقدان طبيعيا، بمعنى أن لا يكون له يد في عدم تلك القدرة على الإدراك والإرادة، فإن كان له يد في فقدان القدرة عليهما، فإنه يعد مسئولا جنائيا كما نصت المادة من قانون العقوبات الصومالي من أنه: "لا يترتب على حالة السكر غير الناشئة عن حادث أو قوة قاهرة رفع المسئولية أو تخفيفها" [٢].

ويستثنى من هذا الشرط السكر إذا قام بالقوة القاهرة، فإذا كان الشخص قد فقد قدرته على الإدراك والإرادة بفعل آخر كحادثة، فإنه كذلك غير مسئول جنائيا، وهذا أيضا ما نص عليه قانون العقوبات الصومالي: السكر الناشئ عن حادث أو قوة قاهرة:

١. لا مسئولية على كل من ارتكب فعلا وكان وقت ارتكابه فاقد الإدراك والإرادة بسبب حالة سكر كاملة ناشئة عن حادث أو قوة قاهرة [٣].

ويلحق بالجنون أمور منها:

١. عاهة العقل، وهو وصف لكل خلل يصيب العقل فيكون هذا العامل واسع التأثير فيدخل تحته كل خلل ينقص القوى الذهنية أو النفسية فيجعلها أقل من المعدل المعتاد كضعف العقل المتمثل في وقف الملكات الذهنية في نموها دون المعدل الطبيعي كما تدخل في الأمراض العصبية التي

---

(١) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٥١.

(٢) المرجع السابق، م: ٥٤.

(٣) المرجع السابق، م: ٥٣، ف (١).

تؤدي إلى انحراف النشاط العقلي عن الوضع الطبيعي [١]، فإنه في الحكم بمنزلة الجنون، فهو يعتبر مانعا من موانع المسئولية الجنائية.

٢. السكر، فهو يعتبر مانعا من موانع المسئولية الجنائية أيضا، ولكنه لا يكون مانعا في جميع الأحوال، ومن ثم فإن السكر نوعان: أولهما بغير اختيار، وثانيهما باختيار:

فالسكر غير الاختياري تناولته المادة رقم: (٥٣) السابقة من قانون العقوبات الصومالي.

وأما السكر الاختياري فإنه لا يعتبر مانعا قطعا، ومن ثم نص قانون العقوبات الصومالي على أنه: لا يترتب على حالة السكر غير الناتجة عن حادثة أو قوة قاهرة رفع المسئولية أو تخفيضها [٢].

اعتياد السكر:

١. تزاد العقوبة إذا ارتكب الجريمة أحد معتادي تناول المسكرات، وهو في حالة سكر.

٢. في تطبيق قانون العقوبات الصومالي يعد سكيرا معتادا كل مدمن على تعاطي المشروبات الروحية، وكان في كثير من الأحيان في حالة سكر[٣].

الغيبوبة الناشئة عن تعاطي المواد المخدرة:

تسري أيضا أحكام المواد السابقة إذا ارتكب الفعل بتأثير تعاطي المواد المخدرة[٤].

الغيبوبة المزمنة بسب الكحول أو العقاقير المخدرة:

تسري أحكام المادتين: (٥٠ و ٥١) على الأفعال التي ارتكبها الشخص وهو في حالة غيبوبة مزمنة ناشئة عن تعاطي الكحول أو العقاقير المخدرة [٥].

فما مدى موافقة القانون للفقه الإسلامي من حيث تكليف المجنون ومن يلحق به وعدمه؟

ليس هناك خلاف جوهري يمكن القول لأجله: إن القانون مخالف للفقه الإسلامي من حيث تكليف المجنون، فهو موافق له إجمالا، وقد يختلف عليه في بعض الأماكن تفصيلا كما يبدو للباحث.

---

(١) شرح قانون الجرائم والعقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص:٣٤٥-٣٤٦.

(٢) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٥٤.

(٣) المرجع السابق، م: ٥٥، ف (١-٢).

(٤) المرجع السابق، م: ٥٦.

(٥) المرجع السابق، م: ٥٧.

المبحث الثاني: موانع الاختيار في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي:

تمهيد: موانع الاختيار هي عبارة عن فقد الإرادة، بحيث يكون ما يفعله بغير اختياره، ويكون ذلك بالإكراه، وهو أيضا بمعنى حمل إنسان على أمر لا يريده طبعا أو شرعا، ويكون أيضا بالضرورة، وهي: بلوغ الشخص حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضو، ويعتبر كل من الإكراه والضرورة مانعا من موانع المسئولية الجنائية، وخاصة مما يمنع الاختيار سواء كان ذلك بالإكراه أو بالضرورة إلا ما استثني منهما كالزنى والقتل، بشروط ستأتي.

وعلى ذلك يتكون المبحث عن أربعة مطالب، بحيث يأتي الإكراه في الفقه الإسلامي في مطلب، وكذلك يأتي الإكراه في قانون العقوبات في مطلب ثان، وأما حالة الضرورة فيبحث في المطلب الثالث باعتباره في الفقه الإسلامي، وفي المطلب الرابع ستأتي الضرورة في قانون العقوبات.

المطلب الأول: الإكراه في الفقه الإسلامي

الإكراه في اللغة: حمل إنسان على أمر لا يريده طبعا أو شرعا[١]، أو هو حمل غيره على فعل لا يفعله لو خلي ونفسه [٢].

والإكراه شرعا هو: اسم لفعل يفعله المرء بغيره، فينتفي به رضاه، أو يفسد به اختياره [٣]، أو هو: عبارة عن تهديد القادر على ما هدد غيره بمكروه على أمر، بحيث ينتفي به الرضا [٤].

والإكراه نوعان ملجئ وغير ملجئ: فالملجئ هو الكامل، وهو عند الحنفية أن يكرهه بما يخاف على نفسه أو على تلف عضو من أعضائه، **فإنه يعدم الرضا**، ويوجب الإلجاء، ويفسد الاختيار[٥]، وعند الجمهور: هو الذي لا يكون للمكره فيه قدرة على الامتناع، ويكون كالآلة في يد المكره، فيضاف فعله إلى المكره، ومثلوه بما لو ألقاه من مكان مرتفع على صبي فمات، أو ربطه وأدخله في دار حلّف ألا يدخلها [٦].

---

(١) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، مرجع سابق، ص: ١٦٣.

(٢) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، مرجع سابق، ص: ٨٧.

(٣) المبسوط مرجع سابق، ج٣٤، ص: ٣٨، و نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد أبو المعالي ركن الدين ، الجويني، ، الملقب بإمام الحرمين، تحقيق: عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج، ط١، ت: ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م، بدون مكان النشر، ج١٤، ص: ١٦٥.

(٤) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، مرجع سابق، ص: ١٦٣.

(٥) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، ج٥، ص: ١٨١.

(٦) قواطع الأدلة في الأصول، مرجع سابق، ج ١، ص: ١١٨، والتمهيد، محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف أبو المنذر المنياوي، المكتبة الشاملة، ط١، ت: ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م، مصر، ص: ٤٠، والإبهاج في شرح المنهاج، علي بن عبد الكافي السبكي شيخ الإسلام، وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، تحقيق: أحمد جمال الزمزمي - نور الدين عبد الجبار صغيري، أصل الكتاب: رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى بمكة المكرمة، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ط ١، ت: ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م، بدون مكان النشر، ج ٢، ص: ٤١٥.

وغير الملجئ قاصر، وهو أن يكرهه بما لا يخاف على نفسه ولا على تلف عضو من أعضائه، كالإكراه بالضرب الشديد أو القيد أو الحبس فإنه يعدم الرضا، ولا يوجب الإلجاء، ولا يفسد الاختيار، ولا يؤثر إلا في تصرف يحتاج فيه إلى الرضا كالبيع والإجارة والإقرار، ألا ترى أن الهزل يؤثر فيه لعدم الرضا حتى لا ينفذ معه، فكذا مع هذا الإكراه؛ لأنه ينعدم به الرضا [١].

والحاصل أن الإكراه نوعان: تام وناقص:

الأول: الإكراه التام، اختلف الفقهاء في حكمه، من حيث اعتباره مانعا من موانع المسئولية الجنائية وعدمه، وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: هو أن الإكراه التام معتبر من حيث كون المسئولية الجنائية على المكرِه، وعلى ذلك يكون الضمان على المكرِه، وهذا قول الحنفية[٢]، وبعض الشافعية[٣]، والحنابلة في الأرجح عندهم [٤].

الدليل على ذلك:

أن المكرَه مسلوب الإرادة، وما هو إلا آلة للمكره، ولا ضمان على الآلة [٥].

القول الثاني: أن الإكراه لا يرفع المسئولية، إلا أن الضمان على المسكره، لا على المكرِه، وبه قال المالكية[٦] وبعض الشافعية [٧].

---

(١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، ج٥، ص: ١٨١.

(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج ٧، ص: ١٨١.

(٣) تحفة المحتاج في شرح المنهاج، مرجع سابق، ج ٧، ص: ٤.

(٤) أصول الفقه، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي، تحقيق: فهد بن محمد السدحان، مكتبة العبيكان، ط ١، ت:١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، بدون مكان النشر، ج ١، ص: ٢٨٩م، والقواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية، علي بن محمد بن عباس المعروف بابن اللحام، أبو الحسن علاء الدين البعلي الدمشقي الحنبلي، تحقيق: عبد الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية، بدون الطبعة، ت: ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، وبدون مكان النشر، ص: ٦٨.

(٥) المطلع على دقائق زاد المستقنع، عبد الكريم بن محمد اللاحم، دار كنوز إشبيليا، ط ١، ت: ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م، الرياض - المملكة العربية السعودية، ج ١، ص: ١٥٦.

(٦) التوضيح في شرح المختصر الفرعي، خليل بن إسحاق بن موسى، المعروف بابن الحاجب، ضياء الدين الجندي المالكي المصري، تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط ١، ت: ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م، بدون مكان النشر، ج ٥، ص: ١٩٥.

(٧) نهاية السول شرح منهاج الوصول، عبد الرحيم بن الحسن بن علي أبو محمد، جمال الدين، الإسنوي الشافعيّ، دار الكتب العلمية، ط ١، ت: ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م، بيروت-لبنان، ص: ٦٦، والقواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية، مرجع سابق، ص: ٦٨.

الدليل على ذلك:

أن المستكره يكون في هذه الحالة كالمضطر إلى أكل طعام الغير، بجامع الإباحة في كل منهما، وكما يجب ضمان المضطر يجب ضمان المستكره [١].

القول الثالث: الضمان على المكره والمستكره، وبه قال الشافعية في الأرجح عندهم [٢]، وهو وجه عند الحنابلة [٣].

الدليل هو: أن الفعل الضار صادر من المستكره حقيقة، ومن المكره بالتسبب، والتسبب في الفعل والمباشرة سواء، لكن يستقر الضمان في النهاية على المكره [٤].

وإن كان الإكراه ناقصاً: فاتفق الفقهاء على أن الضمان على المستكره [٥].

واستدلوا على ذلك ما يلي:

أن الإكراه الناقص لا يسلب الاختيار أصلاً، فلم يكن المستكره مجرد آلة للمكره، فكان الإتلاف من المستكره، فوجب الضمان عليه [٦].

فاتضح أن هذا الإكراه هو بمنزلة الخطأ أو دونه؛ لأن المكرَه مختار لما فعله قاصدا إياه؛ لأنه عرف الشرّين فاختار أهونهما عليه عن علم وقصد، إلا أنه قصد فاسد؛ لأنه قصد راضياً به ومريداً إياه، بل لدفع الشر عن نفسه فلحق بحكم الفساد بعدم القصد فلا يقع هدراً، وإنما يبطل به ما يتعلق لزومه بالرضا، كالبيع، والإجارة، وما لا يلزم مع استثناء الخيار أو مع الهزل [٧]، ولأن المكره مبتلى، والابتلاء يقرر الخطاب، ولا شك أنه مخاطب في غير ما أكره عليه [٨].

---

(١) منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي، دار الفكر، بدون الطبعة، ت: ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م، وبدون مكان النشر، ج ٢، ص: ١٤٢.

(٢) أسنى المطالب في شرح روض الطالب، مرجع سابق، ج ٤، ص: ٩.

(٣) تقرير القواعد وتحرير الفوائد، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب زين الدين الحنبلي، تحقيق: مشهور بن حسن أبو عبيدة آل سلمان، دار ابن عفان، ط ١، ت: ١٤١٩ هـ المملكة العربية السعودية، ج ٢، ص: ٦٠٣.

(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي، مرجع سابق، ج ٤، ص: ٢٤٨.

(٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج ٧، ص: ١٧٩، و التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، مرجع سابق، ج ٥، ص: ١٩٥، ونهاية السول شرح منهاج الوصول، مرجع سابق، ص: ٦٦، والقواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية، مرجع سابق، ص: ٦٨.

(٦) المرجع السابق، ج ٧، ص: ١٧٩.

(٧) تقويم الأدلة في أصول الفقه، مرجع سابق، ص: ٤٣٥.

(٨) المبسوط مرجع سابق، ج٢٤، ص: ٣٨– ٣٩.

شروط الإكراه:

يشترط للإكراه شروط:

١. قدرة المكره بكسر الراء على تحقيق ما هدد به [١].

٢. عجز المكره بفتح الراء عن دفعه بهرب وغيره وظنه أنه إن امتنع حقق ما هدده به[٢].

٣. أن يغلب على ظن المكره أن يوقع به ذلك إن لم يفعل [٣].

المطلب الثاني: الإكراه في القانون

يعتبر الإكراه مانعا من موانع المسئولية الجنائية على تفصيل سيأتي، ولكن قبل ذلك لا بد من بيان معناه في القانون، وذلك فيما يلي:

معنى الإكراه:

الإكراه في القانون هو الإلزام الشديد الواقع؛ خلافا للرغبة والإرادة، الناتجة عن إرهاب وإخافة تبلغ حدا من الشدة يكون معها غير قادر على أن يختار فعله، أي: غير قادر على أن يفعل أو يترك كما يشاء ويختار[٤].

أنواع الإكراه:

ينقسم الإكراه على نوعين:

١. **الإكراه المادي:**

ويراد بالإكراه المادي الحالة التي يتعرض فيها الشخص لقوة مادية من آخر تعجزه عن المقاومة، وتجعل جسده مجرد أداة لتحقيق الجريمة، كأن يدفع زيد بكرا على صبي، فيصاب الصبي بنحو: جروح [٥]، أو هي عبارة عن: قوة تستحيل مقاومتها، تسيطر على أعضاء جسمه، وتسخرها في عمي أو امتناع يعاقب عليه القانون، ويعرف أيضا بأنه: سلب إرادة الشخص في موقف معين، ودفعه إلى إتيان أمر يعده القانون جريمة، إلى غير ذلك [٦].

---

(١) درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا – أو مذلا أو المولى – خسرو، دار إحياء الكتب العربية، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر، ج ٢، ص: ٢٧٠.

(٢) كنز الدقائق، عبد الله بن أحمد بن محمود أبو البركات حافظ الدين النسفي، تحقيق: ساند بكداش، دار البشائر الإسلامية، ط١، ت: ١٤٣٢هـ – ٢٠١١م، بدون مكان النشر، ص: ٥٦٩

(٣) روضة الطالبين وعمدة المفتين، مرجع سابق، ج٨، ص: ٥٨.

(٤) شرح قانون الجرائم والعقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص:٣٦١.

(٥) شرح قانون العقوبات، القسم العام، الألفي، مرجع سابق، ص:٤٣٩.

(٦) شرح قانون العقوبات اليمني، القسم العام، مرجع سابق، ص:٣٦٥-٣٦٦.

٢. الإكراه المعنوي:

ويعرف فقهاء القانون الإكراه المعنوي بأنه:

ضغط وتهديد ووعيد بما يخاف منه ويؤثر على إرادة الشخص، ويجبره على إقدام الفعل المجرم بنفسه [١].

حكم الإكراه:

بين المشرع الصومالي حكم الإكراه البدني في قانون العقوبات الصومالي: حيث نص على أنه:

١- لا يعاقب كل من ارتكب فعلا مجبرا على ذلك من آخرين بوسائل من القوة والعنف البدني، لا يستطيع لهما دفعا أو مقاومة، أو لم يستطع أن يتخلص منهما بأية وسيلة [٢].

الأصل أن الإكراه مطلقا هو أحد موانع المسئولية الجنائية؛ لكونه يؤثر في الإرادة فيجعلها معيبة، ويجعل صاحبها معذورا من الناحية الجنائية ... إلا أن الإكراه إذا كان ماديا فإنه لا يمنع المسئولية الجنائية فحسب، وإنما يمنع قيام الجريمة أصلا؛ لكون الشخص الذي تعرض لهذا الإكراه لم يفعل شيئا على الإطلاق [٣].

٢- يعتبر الشخص المستعمل لوسائل القوة والعنف مسئولا عن الفعل الذي ارتكبه الشخص المجبر عليه [٤].

فاتضح أن النظم العقابية وشراح القانون تميز بين النوعين هما: الإكراه المادي والإكراه المعنوي، ويجعلون الثاني مانعا من موانع المسئولية الجنائية فقط؛ لكونه يؤثر في الإرادة التي هي قوام الأهلية التي تتبني عليها المسئولية الجنائية، بينما الإكراه المادي لا يمنع المسئولية الجنائية فحسب، وإنما يمنع المسئولية المدنية أيضا، أي: أنه يمنع قيام الجريمة أصلا في حق المكرَه [٥].

ويستثنى -في الإكراه المادي- من ذلك القتل والزنا، فلا ترتفع المسئولية الجنائية فيهما عن المكره، ومن أكرهه [٦]، ومن ثم إذا ارتكب المكره محظورا مما هو قتل أو إيذاء جسم للغير، فإنه لا بد أن يسأل مسئولية جنائية ومدنية، بمعنى: أنه لا يمكن إعفاء الفاعل من أية مسئولية؛ لأنه يتحمل المسئولية الجنائية، والمدنية كذلك إن كان لها محل [٧].

---

(١) شرح قانون الجرائم والعقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص:٣٤٥

(٢) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٢٧، ف: (١).

(٣) شرح قانون الجرائم والعقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص:٣٦٤.

(٤) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٢٧، ف: (٢).

(٥) شرح قانون الجرائم والعقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص:٣٦٤.

(٦) شرح قانون العقوبات اليمني، القسم العام، مرجع سابق، ص:٤٦٨، وشرح قانون الجرائم والعقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص:٣٧٣.

(٧) شرح قانون الجرائم والعقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص: ٣٧٢-٣٧٣.

شروط الإكراه المادي:

يشترط له شروط منها:

١- أن تكون هذه القوة غير متوقعة، فإذا توقع -فعلا- تعرضه للقوة التي سيطرت عليه أو كان توقع تعرضه لها في استطاعته، فينبغي ذلك أنه كان في وسعه تفادى النتيجة، مثال ذلك: المرأة المتزوجة التي تتوقع أن من يراودها عن نفسها يتربص لها في مكان معين، وتذهب إلى ذلك المكان بمفردها، وتعرضت لقوة تمنعها عن الدفاع عن نفسها حتى تمكن المراود عن نفسها، فلا يمكن أن تقول بأنها أكرهت على الزنى [١].

٢- وجود قوة مادية: لكي يتوافر الإكراه المادي ينبغي أن توجد قوة مادية من شأنها أن تعدم إرادة الإنسان، فيصبح لا مفر من ارتكاب الجريمة، فلا يكفي وجود قوة معنوية، أي: تهديد بالخطر[٢].

٣- أن تكون تلك القوة يستحيل دفعها أو مقاومتها، فإذا كان تجنب القوة التي ينشأ عنها السلوك الذي يؤدي إلى النتيجة المجرمة أمرا عسيرا، فلا يجوز للشخص أن يدفع بالإكراه [٣].

شروط الإكراه المعنوي:

يشترط لامتناع المسئولية الجنائية في الإكراه المعنوي شروط أربعة:

١. أن يدفع هذا التهديد المكره إلى ارتكاب جريمة مما يعاقب عليها القانون[٤].

٢. وقوع المكره تحت تهديد في حياة أو سلامة جسد أو عرض أو حرية أو سمعة.

٣. أن يتوقع ضمن دائرة المعقول أن امتناعه عن ارتكاب الجريمة المكره على ارتكابها يؤدي إلى موته عاجلا أو تعرضه للضرر البليغ في أحد أعضاء جسمه.

٤. أن لا يكون المكره هو الذي عرض نفسه لهذا الإكراه بمحض إرادته أو لم يستطع إلى دفعه سبيلا [٥].

فما مدى موافقة القانون للفقه الإسلامي من حيث تكليف المكره وعدمه؟

ليس هناك خلاف جوهري يمكن القول لأجله: إن القانون مخالف للفقه الإسلامي من حيث تكليف المكره، فهو موافق له، كما يبدو للباحث.

---

(١) شرح قانون العقوبات، القسم العام، الألفي، مرجع سابق، ص:٤٤٠.

(٢) شرح قانون العقوبات اليمني، القسم العام، مرجع سابق، ص:٤٢٣.

(٣) شرح قانون العقوبات، القسم العام، الألفي، مرجع سابق، ص:٤٤١.

(٤) شرح قانون العقوبات اليمني، القسم العام، مرجع سابق، ص: ٤٦٠.

(٥) شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجنبدي، مرجع سابق، ص:٤٦٠.

المطلب الثالث: الضرورة في الفقه الإسلامي.

كما هي العادة لا بد من بيان الشيء بتعريفه من حيث اللغة والاصطلاح، ومن ثم فالضرورة لها معنى في اللغة، ومعنى في الاصطلاح، وتفصيل ذلك:

أولا: معنى الضرورة لغة:

الضرورة لغة: اسم لمصدر الاضطرار، تقول: بناؤه: افتعل فجعلت التاء طاء؛ لان التاء لم يحسن لفظها مع الضاد [١]، حملتني الضرورة على كذا، وقد اضطر فلان الى كذا وكذا [٢].

ثانيا: معنى الضرورة اصطلاحا:

عرّف فقهاء الإسلام الضرورة، ويكون هناك عدة تعريفات تختلف في الألفاظ، وتتحد في المضمون، ومن تلك التعريفات:

١. الضرورة هي: بلوغ الشخص حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضو[٣].

٢. الضرورة هي: التي يحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو العجز عن الواجبات[٤]، فالضرورة هي الحالة التي تلجئ الشخص إلى ما لا بدَّ منه، إذا فالضرورة أشدُّ مراتب حاجة للإنسان.

والضرورة تمنع المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي، ومن ثم اهتم فقهاء الفقه الإسلامي بالضرورة التي تبيح المحظور، وتمنع المسئولية الجنائية، حتى قعدوا لها قواعد تنظم الضرورة الشرعية، ومن تلك:

١. الضرورات تبيح المحظورات.
٢. المشقة تجلب التيسير [٥].

وأكبر ما يدخل تحت حالة الضرورة أنها أبيحت كلمة الكفر للمكره، وكذلك إتلاف المال، وكذلك أخذ مال الممتنع من الدين بغير إذنه إذا كان من جنسه ولو كان بكسر بابه [٦].

---

(١) كتاب العين، مرجع سابق، ج٧، ص:٧.

(٢) مختار الصحاح، مرجع سابق، ص: ١٨٣.

(٣) الأشباه والنظائر، السيوطي، مرجع سابق، ج٢، ص: ٣١٩.

(٤) مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية أبو العباس تقي الدين الحراني، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد، بدون الطبعة، ت:١٤١٦هـ/١٩٩٥م المدينة النبوية-المملكة العربية السعودية، ج٣١، ص: ٢٢٦.

(٥) الأشباه والنظائر، عبد الوهاب تاج الدين بن تقي الدين السبكي، دار الكتب العلمية، ط١، ت:١٤١١هـ-١٩٩١م، بدون مكان النشر، ج١، ص: ٤٩.

(٦) المنثور في القواعد الفقهية، محمد بن عبد الله بن بهادر أبو عبد الله بدر الدين الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، ط٢، ت: ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م، الكويت، ج٢، ص: ٣١٧.

وعلى هذا فإنه إذا صار الشخص مكلفا، يجب عليه الامتثال بأوامر الله والانزجار عن المحرمات والنواهي، ومن اضطر إلى ارتكاب محرم بحيث إن ضرورته لا تندفع إلا به، فلا حرج عليه في أن يرتكبها، كأن يأكل الميتة فيما ليس فيه ما يصلح للأكل شرعا، ولو لم يكلها لخاف منه تلف نفسه وليس بوسعه ما يغنيه عن الحرام، وكذلك شرب الخمر للغصة.

فعلى أية حال فإن الضرورة التي تسلب المسئولية الجنائية ليست على الإطلاق، بل فإنها تبيح المسئولية التي بينه وبين الله، أما المحرم المتعلق بحق بني آدم فلا ترتفع مسئوليته بالضرورة؛ لأن حق الله –تعالى–مبني على المسامحة والمساهلة؛ لأنه لا يتضرر بفوات حقوقه ولا ينتفع بحصولها، وحق الآدمي مبني على الشح والمضايقة؛ لأنه ينتفع بحصوله ويتضرر بفواته [١].

وإنه من مقررات الإسلام أنه لا يهدر دم في الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا﴾ [٢]، أي: تسلطا على القاتل، يتتبعه حتى يقتضي الحاكم منه [٣].

شروط حالة الضرورة في الفقه الإسلامي

ويشترط للضرورة أمور، منها:

١. أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، وتظهر هذه القاعدة في الفروع الفقهية المبنية [٤].
٢. يجب على المضطر مراعاة قدر الضرورة؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها [٥].
٣. ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى إلا مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية[٦].
٤. يجب على المضطر أن يراعي عند دفع الضرورة مبدأ درء الأفسد فالأفسد، والأرذل فالأرذل[٧].
٥. إذا زال المانع عاد الممنوع [٨].

---

(١) الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أبي علي بن محمد بن سالم أبو الحسن سف الدين الثعلبي الآمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بدون الطبعة، والتاريخ، بيروت– لبنان، ج ٢، ص: ٢٧١.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٣٣.

(٣) زهرة التفاسير، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة، دار الفكر العربي، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر، ج٨، ص: ٤٣٧٧.

(٤) مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بدون الطبعة، ت: ١٤٢٥ هـ – ٢٠٠٤ م، قطر، ج ٢، ص: ٥٦٢.

(٥) شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، تحقيق: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، ط ٢، ت: ١٤٠٩هـ – ١٩٨٩م، دمشق – سوريا، ص: ١٨٧.

(٦) مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ج ٢، ص: ٥٦٢.

(٧) الأشباه والنظائر للسيوطي، مرجع سابق، ص: ٨٧.

(٨) شرح القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص: ١٩١.

المطلب الرابع: الضرورة في القانون

تقدم تعريف الضرورة لغة في المطلب السابق، وأما اصطلاحا فهي: الحالة التي يجد فيها الشخص أن خطرا جسيما يوشك أن يقع على نفسه أو غيره، ولا تكون أمامه من وسيلة لدفع الخطر إلا بارتكاب جريمة(١).

وبعبارة أخرى هي: مجموعة من الظروف التي تهدد الإنسان بخطر حال يترتب عليه ضرر جسيم، بحيث لا يجد سبيلا إلى تلافيه إلا بارتكاب جريمة (٢).

وعالج قانون العقوبات الصومالي حالة الضرورة حيث نص على أنه:

١. "لا عقوبة على أي شخص ارتكب فعلا ألجأته إليه ضرورة إنقاذ نفسه أو غيره من خطر محقق ينشأ عنه ضرر بدني جسيم، بشرط ألا يكون قد تسبب بإرادته في هذا الخطر، وألا يكون من الممكن تفادي هذا الخطر بوسيلة أخرى، وذلك مادام الفعل متناسبا مع الخطر، وبشرط ألا يكون مرتكبه غير ملزم قانونا بتعريض حياته لمثل هذا الخطر.

٢. تسري أحكام الفقرة الأولى إذا نشأت حالة الضرورة بسبب تهديدات الآخرين، ومع ذلك – في هذه الحالة – فإن الشخص الذي أجبر الآخر على ارتكاب الفعل يعاقب على الفعل بالعقوبة المقررة لذلك الفعل الذي ارتكبه الشخص الآخر" (٣).

وعلى ذلك فإنه من الواضح فيما وقف عليه الباحث من قوانين الدول الإسلامية أن حالة الضرورة تعتبر كأحد أسباب امتناع المسئولية الجنائية، فتشتمل في نطاقها الواسع على الخطر الواقع على الشخص أو غيره، والخطر الواقع على النفس أو المال (٤)، ولكن لو أمعن شخص نظره إلى نص المادة (٣٦) السابقة لوجد أن قانون العقوبات الصومالي يقتصر على الخطر الذي وقع على النفس فقط، بدليل عبارة النص: "من خطر محقق ينشأ عنه ضرر بدني جسيم" (٥).

يعني: أن الخطر الذي أنشأ عن الضرورة هو الخطر البدني، أما غير البدني يخرج بقيد "البدني"، ولذلك فالذي يريد نقد قانون العقوبات الصومالي يمكن له ذلك بقوله:

إن قانون العقوبات الصومالي مخالف للفقه الإسلامي بحصر الخطر الناشئ عن الضرورة الخطر الواقع على النفس، أما ما يقع على بقية ما يسمى في الفقه الإسلامي بالضروريات الخمس فإنه غير داخل في أحكام هذا النص.

---

(١) شرح قانون العقوبات، الألفي، مرجع سابق، ص: ٤٢٩.

(٢) المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مرجع سابق ، ص: ١٦١.

(٣) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٣٦، ف: (١)، و (٢).

(٤) شرح قانون العقوبات اليمني، القسم العام، مرجع سابق ، ص: ٤٦٢.

(٥) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٣٦، ف: (١).

وكذلك تجب الإشارة إلى أن الضرورة لا تنفي المسئولية الجنائية عن جميع الجرائم مطلقا، بل منها ما لا ينفي المسئولية الجنائية، كجرائم القتل والزنا، ومنها ما ينفي المسئولية الجنائية، كالمضطرّ في شرب الخمر للغصة والعطش الشديد وجريمة السرقة، إلا أن في جريمة السرقة عليه الضمان.

علة امتناع المسئولية الجنائية:

هناك مبررات عديدة لامتناع المسئولية الجنائية في حالة الضرورة، ومن أهمها:

١. عدم جدوى العقاب فيها، فإن التهديد بالعقاب لن يترتب عليه أي تأثير في ردع المتهم ما دام أن التلويح به لن يبعده عن ارتكاب الجريمة في حالة الضرورة، ومن ثم فإن العقاب ممتنع؛ لأن المجتمع ليس له مصلحة في العقاب عليها.

٢. تجرد الإرادة من حرية الاختيار، فإنه في هذه الحالة ليس له اختيار حتى يبتعد عن ارتكاب الجريمة[١].

شروط حالة الضرورة:

ويشترط للضرورة شروط يمكن تصنيفها إلى ما يلي:

١. شروط تتعلق بالخطر الذي يراد دفعه.

٢. شروط تتعلق بالفعل اللازم لدفع الخطر [٢].

٣. شروط تتعلق بالشخص المستفيد [٣].

وهذا التصنيف يمكن أخذه أيضا مما نص عليه قانون العقوبات الصومالي بقوله:

١. "لا عقوبة على أي شخص ارتكب فعلا ألجأته إليه ضرورة إنقاذ نفسه أو غيره من خطر محقق ينشأ عنه ضرر بدني جسيم، بشرط ألا يكون قد تسبب بإرادته في هذا الخطر، وألا يكون من الممكن تفادي هذا الخطر بوسيلة أخرى، وذلك مادام الفعل متناسبا مع الخطر، وبشرط ألا يكون مرتكبه غير ملزم قانونا بتعريض حياته لمثل هذا الخطر" [٤].

الشروط المتعلقة بالخطر الذي يراد دفعه:

ويشترط في الخطر المنشئ لحالة الضرورة أن تتوافر فيه أمران:

الأول: أن يكون الخطر جسيما [٥]، بحيث يكون الخطر منذرا بضرر بليغ، لا يمكن إصلاحه، أو أن إصلاحه يعتبر أمرا عسيرا جدا [١].

---

(١) شرح قانون العقوبات اليمني، القسم العام، مرجع سابق، ص: ٤٦٢-٤٦٣.

(٢) شرح قانون العقوبات، القسم العام، الألفي مرجع سابق ، ص: ٤٣١، وشرح قانون العقوبات اليمني، القسم العام، مرجع سابق ، ص: ٤٦٦.

(٣) شرح قانون العقوبات اليمني، القسم العام، مرجع سابق، ص: ٤٦٦.

(٤) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٣٦، ف: (١).

(٥) المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مرجع سابق ، ص: ١٦٦.

(١) شرح قانون الجرائم والعقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص:٣٦٨.

الثاني: حلول الخطر [١]، ويعني ذلك أن الخطر المعتبر ليس إلا الخطر الواقع فعلا، وهو الخطر الحالي، لا الخطر وشيك الوقوع، والخطر الحال هو الذي يهدد بوقوع الضرر، ولو لم يقع ذلك فعلا [٢].

الشروط المتعلقة بالفعل اللازم لدفع الخطر:

ويشترط في الفعل الذي يقترف تحت تأثير الاضطرار أن يتوافر لديه أمران، وهما: التناسب، واللزوم [٣].

الشرط الأول: أن يكون الفعل متناسبا مع الخطر

ومقتضى هذا الشرط أنه لا بد من أن لا يكون فعل الجاني أشد جسامة مما يلزم لدفع الخطر [٤]، يعني: يشترط أن يكون ذلك الفعل أقل جسامة من الفعل الذي يمكن أن يندفع به الخطر، بحسب ظروف الجاني وحالة الخطر [٥].

الشرط الثاني: أن يكون الفعل لازما

يشترط القانون لامتناع المسئولية الجنائية عن المضطر واستبعاد العقاب أن لا يكون في قدرته منع الخطر بطريقة أخرى غير الجريمة التي ارتكبها، فإذا أمكن له درؤه بمباح لا يجوز له الدرء بالجريمة، وإذا أمكن له درؤه بجريمة أخف فلا يجوز له درؤها بأشد منها [٦].

الشروط المتعلقة بالشخص المستفيد:

يشترط في الشخص الذي يستفيد من الدفع بحالة الضرورة أن يتوافر فيه شرطان:

الشرط الأول: ألا يكون ملزما بمواجهة الخطر:

فمضمون هذا الشرط هو ألا يكون القانون قد كلف ذلك الشخص بمواجهة الخطر ومكافحته والتصدي له؛ إذ لو كان مكلفا بذلك لما جاز له الالتجاء منه إلى أفعال مخالفة للشرع[٧].

الشرط الثاني: أن لا يكون لإرادة الشخص دخل في حلول الخطر

يعني ذلك: أن لا يكون فعل الشخص هو السبب في ظهور الخطر المنشئ لحالة الضرورة، ولو كان لإرادته دخل في نشوء الخطر لكان معنى ذلك أن الخطر غير مفاجئ له[٨].

---

(١) المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مرجع سابق ، ص: ١٦٧.

(٢) شرح قانون العقوبات اليمني، القسم العام، مرجع سابق ، ص: ٤٦٦.

(٣) شرح قانون الجرائم والعقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص:٣٦٨.

(٤) المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مرجع سابق ، ص: ١٦٩.

(٥) شرح قانون الجرائم والعقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص:٣٦٨.

(٦) شرح قانون العقوبات اليمني، القسم العام، مرجع سابق ، ص: ٤٧٥.

(٧) شرح قانون الجرائم والعقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص: ٣٦٦.

(٨) شرح قانون العقوبات، القسم العام، الألفي، مرجع سابق ، ص: ٤٢٥.

أثر حالة الضرورة:

يترتب على وجود حالة الضرورة بالشروط السابقة امتناع المسئولية الجنائية عن المضطر، ومن ثم يعتبر غير مسئول جنائيا، وعلى هذا يستفيد من امتناع المسئولية الجنائية كل شخص آخر ساهم على هذا الفعل (حالة الضرورة)، وعلة هذا الحكم أن شروط الضرورة يغلب توافرها بالنسبة لكل من يساهم في الفعل [١]؛ لكونه أقدم على الفعل دون أن يملك القدرة التامة على الاختيار، ولكن هذا الأثر ليس عاما، فهو لا يعفى عن المسئولية المدنية إن كان لها محل، كما تقدم في الإكراه المادي [٢].

فما مدى موافقة القانون للفقه الإسلامي من حيث تكليف المضطر وعدمه؟

ليس هناك خلاف جوهري يمكن القول لأجله: إن القانون مخالف للفقه الإسلامي، فهو موافق له إجمالا، كما يبدو للباحث.

---

(١) شرح قانون العقوبات اليمني، القسم العام، مرجع سابق ، ص: ٨٠٤.

(٢) شرح قانون الجرائم والعقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص: ٣٦٧.

المبحث الثالث: الرضا على المسئولية الجناية والجهل عنها في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي:

تمهيد: الرضا يعني: ضد السخط، ويُراد به أيضا: قبول ما يقضي به الله عز وجل من غير تردد, ولا معارضة، وهو مانع أيضا للمسئولية الجنائية، على اختلاف بين فقهاء الفقه الإسلامي فيما إذا سرت الجنائية إلى القتل، إلا مسألة قتل الرحيم، فلا يعتبر مانعا من موانع المسئولية الجنائية، مما سيأتي بيانه، أما إذا اقتصرت الجنائية على جرح، وتوقفت عليه دون الموت فهو لا شيء على الجاني اتفاقا، ومثل الرضا في كونه مانعا من موانع المسئولية الجنائية الجهل.

والجهل هو: اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، ولذلك يقوم الباحث بدراسة رضا المجنى عليه على الجناية من جانبيها الفقهي والقانوني، وبدراسة الجهل من جانبيه الفقهي والقانوني، وكل منهما مانع من موانع المسئولية الجنائية على تفصيل في كل منهما، وذلك على المطالب الآتية إن شاء الله.

المطلب الأول: رضا المجنى عليه على القتل والجرح في الفقه الإسلامي

قبل الخوض في بيان حكم رضا المجنى عليه على القتل والجرح ينبغي أن بيان معنى الرضا، وبعد ذلك يأتي حكمه في القتل مع بيان حكم مسألة القتل الرحيم، وفي الجرح، وذلك على ما يلي:

أولا: معنى الرضا:

ومعنى الرضا هو: ضد السخط [١]، ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم: في الدعاء: ((اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)) [٢].

ثانيا: اختلاف الفقهاء في اعتباره مانعا من موانع المسئولية الجنائية:

اختلف الفقهاء في أثر الرضاء على جناية القتل وما يترتب عليه من أحكام على أقوال:

القول الأول هو: أنه لو أذن المجنى عليه للجاني في قتله، فقتله، فلا يترتب عليه شيء غير الدية، وهذا ظاهر مذهب الحنفية[٣]، وهو أظهر الأقوال في المذهب المالكي [٤] وهو أيضا وجه عند الشافعية [٥].

---

(١) لسان العرب، مرجع سابق،ج١٤، ص: ٣٢٣.

(٢) أخرجه مسلم بن الحجاج، في صحيحه، كتاب الصلاة، برقم: (٤٨٦)، عن أبي هريرة، عن عائشة، ج ١، ص: ٣٥٢.

(٣) لسان الحكام في معرفة الأحكام، أحمد بن محمد بن محمد، أبو الوليد، لسان الدين ابن الشحنة الثقفي الحلبي، البابي الحلبي، ط٢، ت: ١٣٩٣ه – ١٩٧٣م، القاهرة-مصر، ص: ٢٨٥.

(٤) التوضيح في شرح المختصر الفرعي، مرجع سابق، ج٨، ص: ١٢٤.

(٥) روضة الطالبين وعمدة المفتين، مرجع سابق، ج ٩، ص: ١٣٧.

وعليه فالمسئولية الجنائية لا ترتفع تماما، بل تقوم المسئولية الجنائية مخففة من القصاص إلى الدية، ولكن الحنفية فقط قيدوا هنا في القتل بسيف، فقالوا: ولو قال اقتلني فقتله بسيف فلا قصاص وتجب الدية في ماله في الصحيح [١].

فقوله: "بسيف" قيد به لقوله "وتجب الدية في ماله"، فلو قتله بمثقل فالدية على العاقلة [٢]، وعلى هذا القيد فإن المسئولية الجنائية تتحملها العاقلة مع الجاني عند الحنفية.

واستدلوا على ذلك بأدلة من أهمها:

١) أن الإباحة لا تجري في النفس، وسقط القود؛ لشبهة الإذن [٣].

٢) أن الآمر بالقتل لم يقدح في العصمة، لأن عصمة النفس مما لا تحتمل الإباحة بحال، ألا ترى أنه يأثم بالقول؟ فكان الأمر ملحقا بالعدم بخلاف الأمر بالقطع، لأن عصمة الطرف تحتمل الإباحة في الجملة فجاز أن يؤثر الأمر فيها، والدليل على ذلك أنه تمكنت في هذه العصمة شبهة العدم، لأن الأمر، وإن لم يصح حقيقة فصيغته تورث شبهة، والشبهة في هذا الباب لها حكم الحقيقة [٤].

٣) الاستحسان [٥].

القول الثاني هو: أن الرضا في القتل لا يؤثر في ارتفاع المسئولية الجنائية، فإذا حصل رضاء من المجنى عليه بقتله، فلا يترتب على هذا الرضاء شيء، فيقتل القاتل وهذا هو **مذهب المالكية** [٦].

واستدلوا على ذلك بما يلي:

- أن المقتول عفا عن شيء لم يجب له، وإنما يجب لأوليائه [٧].

---

(١) تحفة الفقهاء، مرجع سابق، ج٣، ص: ١٠٢.

(٢) رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق، ج٦، ص٥٤٧.

(٣) الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، مرجع سابق، ص: ٧٠٣.

(٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق ، ج٧، ص: ٢٣٦.

(٥) أن عليه الدية استحساناً. شرح مختصر الطحاوي، مرجع سابق، ج٨، ص: ٩٥.

(٦) التوضيح في شرح المختصر الفرعي، مرجع سابق، ج٨، ص: ١٢٤.

(٧) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد القرطبي، تحقيق: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، ط٢، ت: ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م، بيروت – لبنان، ج١٧، ص:٥٧.

القول الثالث: يعتبر هذا الرضا مانعا من موانع المسئولية الجنائية، ومن ثم لو قال المجنى عليه للجاني: اقتلني، فقتله، فلا شيء عليه، وهذا هو المعتمد عند الشافعية [١]، والحنابلة [٢].

وعلى هذا فإن المسئولية الجنائية تنعدم، ومن ثم فإن الرضا على القتل يعد عندهم مانعا من موانع المسئولية الجنائية.

واستدلوا على ذلك بالإذن، وبأن الدية تثبت للمورث ابتداء أي؛ لأنها بدل عن القود البدل عن نفسه [٣].

والراجح الذي يظهر عند الباحث هو القول بعدم قيام المسئولية الجنائية على القاتل المأذون له في القتل، وذلك لما يلي:

١) لأن الإذن معتبر من الشبهات التي تدرء الحدود بها، ودرء الحدود بالشبهات أولى.

٢) لأن المقتول يثبت له حقه في الدية ابتداء في آخر جزء من حياته، ثم يتلقاها الوارث، وعلى ذلك تبين أنه صح إذنه في قتله، ومن ثم لم يجب عليه شيء، لا قصاص ولا دية.

مسألة القتل الرحيم في الفقه الإسلامي:

أولا: مفهوم القتل الرحيم:

لم يجد الباحث تعريفا في كتب الفقه الإسلامي، إلا ما في البحوث العلمية الجديدة، من أن القتل الرحيم هو: "القتل الذي يحدث من خلال لجوء المريض أو غيره إلى وسيلة ما للتعجيل بموته للتخلص من آلامه المبرحة لمرضه المصاحبة الميئوس من شفائه [٤].

وعلى كل حال فإن القتل الرحيم بكل تسمياته يمكن تعريفه بأنه عبارة عن إزهاق روح مريض أو كبير سن لا يُرجَى شفاؤه أو غيرهما ممن كره الحياة لأجل ما يشعر به من الآلام مطلقا.

ثانيا: حكمه في الفقه الإسلامي:

فمعلوم أن القتل الرحيم غير مشروع، وأن قتل نفس بغير حق كقتل الناس جميعا، كما قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه، ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ

---

(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي، مرجع سابق، ج١١، ص: ٣٥٦.

(٢) كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط١، ت: ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م، بدون مكان النشر، ج٩، ص: ٣٦٤.

(٣) تحفة المحتاج في شرح المنهاج، مرجع سابق، ج ٨، ص: ٤٤٨.

(٤) القتل الرحيم بين الإباحة والتجريم، مجلة المفكر، العدد السادس، عتيقة بلجبل، بدون الطبعة، والتاريخ، الجزائر، ص: ٢٥٤.

ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [١]، فهو بدعة مذمومة، ومخالفة لدين الإسلام، وهو من الكبائر، فهو محرم؛ قياسا على تحريم قتل الأولاد خشية إملاق؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴾ [٢]، فهو قتل بغير حق إذا كان من الطبيب، ويعتبر انتحارا محرما إذا صدر من المريض نفسه.

وقد توافقت آراء المفتين المعاصرين على ما ذكر، من أن هذا النوع من القتل محرم قطعا بالأدلة التي ستأتي، فالمريض أيّا كان مرضه وكيف كانت حالة مرضه لا يجوز قتله؛ لليأس من شفائه أو لمنع انتقال مرضه إلى غيره، ففي حالة اليأس من الشفاء يحرم على المريض أن يقتل نفسه، ويحرم على غيره حتى ولو أذن له في قتله، فالأول انتحار، والثاني: عدوان على الغير بالقتل، وإذنه لا يحلل الحرام، فهو لا يملك روحه حتى يأذن لغيره حتى يقضي عليها [٣].

ولكن حكم القتل بدافع الرحمة بالنظر إلى ضمان القاتل وعدمه يبدو لي أنه لا بد لذلك من التفصيل؛ لأنه إن كان برضا من مريض إذنه معتبر فلا شيء على القاتل عند الشافعية والحنابلة؛ لأنه داخل في رضا المجنى عليه وإذنه، وهو من موانع المسئولية الجنائية[٤].

وأما إذا لم يكن من مريض أهل للإذن فالحكم أن هذا القتل عمد وبغير حق فعلي القاتل القصاص.

<u>الأدلة في عدم مشروعيته:</u>

ويمكن الاستدلال على تحريم القتل الرحيم بشكل عام بما يلي:

١) قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴾[٥].

٢) قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ [٦].

٣) وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾[٧]

---

(١) سورة المائدة، الآية: ٣٢.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٣١.

(٣) القتل بدافع الشفقة، بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، تخصص القانون الخاص الشامل، الطلبة: سبايعي علي، وصايت فريد، جامعة عبد الرحمن ميرة، وبدون الطبعة، السنة الجامعية: ٢٠١٢ – ٢٠١٣م، بجاية – الجزائر، ص: ٢٩.

(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي، مرجع سابق، ج١١، ص: ٣٥٦، وكتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع، مرجع سابق، ج٩، ص: ٣٦٤.

(٥) سورة الإسراء: الآية: ٣٣.

(٦) سورة الفرقان، الآية: ٦٨.

(٧) سورة الأنعام، الآية: ١٥١.

٤) قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي[١]".

٥) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات))[٢].

الملجأ المشروع عند المرضى الذين لا يرجى برؤهم، وكبار السن أيضا:

لقد كان الفقه الإسلامي كاملا وتاما في جميع النواحي؛ لقوله تعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى ﴾[٣].

فالملجأ المشروع عند المرضى الذين لا يرجى برؤهم، وكبار السن هو الدعاء والتضرع إلى الله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي[٤]".

فهذا هو الملجأ المشروع عند كل من أصابه ضر، وليس الخنق والانتحار.

رضا المجنى عليه على جناية الجرح في الفقه الإسلامي:

يخالف الرضا في جناية القطع ما تقدم من الرضا في القتل، فإن الفقهاء مجمعون على أنه لا شيء على الجاني في جناية ما دون النفس [٥].

وبناء على ذلك فإن رضا المجنى عليه على جناية الجرح يعتبر كمانع من موانع المسئولية الجنائية، فلا يترتب عليه أي عقوبة.

---

(١) أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت، برقم: (٥٦٧١)، عن أنس بن مالك رضي الله ج٧، ص: ١٢١.

(٢) أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات، برقم: (٦٨٥٧)، عن أبي هريرة – رضي الله عنه–، ج٨، ص: ١٧٥.

(٣) سورة المائدة، الآية: ٣.

(٤) سبق تخريجه، في هذه الصفحة.

(٥) عُيُون الْمَسَائِل، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث السمرقندي، تحقيق: صلاح الدين الناهي، مطبعة أسعد، بدون الطبعة، ت: ١٣٨٦م، بَغْدَاد، ص: ٢٦٩، و البيان والتحصيل، مرجع سابق، ج١٧، ص: ٥٧، و البيان في مذهب الإمام الشافعي، مرجع سابق، ج ١١، ص: ٣٥٦، والمبدع في شرح المقنع، مرجع سابق، ج ٧، ص: ٢٠٦.

المطلب الثاني: رضا المجنى عليه على القتل والجرح في القانون.

بيّن قانون العقوبات الصومالي أحكام رضا المجنى عليه، كمانع من موانع المسئولية الجنائية، حيث ذكرها بعنوان: رضا المجنى عليه، ونص على أنه:

"لا عقوبة على كل من أحدث ضررا أو عرض للخطر حقا برضاء من الشخص الذي من حقه قانونا التنازل عنه" (١).

وهذا واضح في انتفاء المسئولية الجنائية في حال الرضا على كل الأضرار اللاحقة على الشخص.

ويستثنى من هذا الضرر أنه إذا أفضى إلى الموت، فإنه لا ترتفع المسئولية الجنائية تماما، بل يجب الحبس، وعلى هذا نص قانون العقوبات الصومالي، وهو أنه:

١. " كل من تسبب في وفاة شخص برضاه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة (٢).

شروط الرضا الذي يحول دون قيام الجريمة:

يشترط في الرضا الذي يحول دون قيام المسئولية الجنائية ما يلي:

١. أن يكون المجنى عليه أهلا للرضا، أما إذا لم يكن أهلا له، بأن انتفت عنه القدرة على الإدراك أو الاختيار، كما لو كان مجنونا أو صغيرا أو تحت تأثير سكر، فلا يعتد برضائه(٣).

ويمكن أخذ هذا الشرط مما نص عليه قانون العقوبات الصومالي، من أنه:

٢- توقع نفس العقوبة على الشخص الذي يواقع أنثى ليست أهلا للرضا أو يواقع أنثى مدعيا أنه شخص آخر (٤).

فقوله هنا: أهلا للرضا صريح في اشتراط الأهلية.

٢. أن لا يكون الرضا مشوبا بالغش والخيانة أو الغلط، فالمرأة إذا هتك عرضها بموافقة مع شخص اعتقدت أنه طبيب، فلا تعتبر راضية بما وقع من المتهم من الأفعال التي أتاها تحت هذا الاعتقاد الذي بان خلافه (٥).

وبناء على هذا الشرط فإن هذا الرضا بسبب جهل المجنى عليه عن الجاني لا يعتبر كمانع من موانع المسئولية الجنائية، ويمكن أخذه مما نص عليه قانون العقوبات الصومالي بقوله:

"... فإن الشخص الذي حمل المخدوع على ارتكاب الفعل يعاقب بنفس العقوبة" (٦).

---

(١) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٣٢.

(٢) المرجع السابق، م: ٤٣٦، ف:(١).

(٣) شرح قانون العقوبات، القسم العام، الألفي، مرجع سابق ، ص: ٢٤٥.

(٤) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٣٩٨، ف: (٢).

(٥) شرح قانون العقوبات، القسم العام، الألفي، مرجع سابق ، ص: ٢٤٥-٢٤٦.

(٦) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٢٩.

٣. أن يكون الرضا مصاحبا للفعل، فلا يمنع الرضا اللاحق وقوع الجريمة [١].

القتل الرحيم في القانون:

وردت تسميات هذا النوع من القتل، ومنها: القتل الرحيم، القتل بدافع الرحمة، والقتل بدافع الشفقة، وورد العديد من التعريفات ومن أهمها ما يلي:

١- استعجال حصول الموت لتفادي ما يزامن المرض العضال من آلام أو لاختزال تلك الآلام لدى المريض[٢].

ظهرت جماعات في كل من أوربا وأستراليا وكندا وأمريكا تروّج إباحة القتل الرحيم، وترى فيه سبيلا سهلا وآمنا لتخلص المرضا بأمراض مستعصية، من آلامهم المبرحة، بل تمارس مزيدا من الضغط على حكومات دولها لسرعة التدخل بسن القوانين التي تسمح بممارسة القتل الرحيم، ولاسيما أنه انتشر اللجوء إليه كثيرا في هذه الدول بصورة مستترة، وبأشكال مختلفة، دون أن تتمكن السلطات القانونية من محاسبة مرتكبيه، وبنوا فكرتهم على الآتي:

١. أن للإنسان حق في الموت كحقه في الحياة.
٢. قيمة الإنسان مرهونة بقدر إسهامه في الحياة.
٣. القتل الرحيم يخلص المريض من آلامه ويريح الأهل والمجتمع من مؤنة المريض الميئوس من شفائه [٣].

وأما قانون العقوبات الصومالي فإن الباحث لم يجد فيه نصا في مسألة القتل بدافع الرحمة، إلا ما في بعض المواد العامة التي كان من المحتمل أن تدخل فيه، ومنه ما نص عليه قانون العقوبات الصومالي، من أن:

"كل من حاول إزهاق روحه بارتكاب فعل كاف لإحداث الوفاة يعاقب بالسجن مدة أقصاها خمس سنوات أو بغرامة أقصاها عشرة آلاف شلن صومالي [٤].

وهذا النص عام في تحريم كل من يحاول إزهاق روحه، مطلقا، أي: بنفسه أو بغيره، وأما من ساعده من طبيب وغيره، فقد يدخل تحق ما نص عليه قانون العقوبات الصومالي من أن:

---

(١) شرح قانون العقوبات، القسم العام، الألفي، مرجع سابق ، ص: ٢٤٦.

(٢) القتل بدافع الشفقة، بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص: ٨.

(٣) المرجع السابق، ص:٢٥٩ – ٢٦١.

(٤) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٤٣٧.

١. كل من حرّض شخصا أو ساعده على الانتحار أو سهل له وسيلة ارتكاب هذه الجريمة يعاقب في حالة وقوع الانتحار بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، و لا تزيد على عشرة سنوات، فإذا لم تتم جريمة الانتحار فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن السنة ولا تتجاوز الخمس سنوات بشرط أن يترتب على المحاولة إصابة جسيمة أو شديدة الجسامة[١].

خلاصة القول في القتل الرحيم هي:

أن المريض إذا أذن بإزهاق روحه، وكان إذنه معتبرا، فلا شيء على القاتل، وإن لم يكن إذنه معتبرا، فعليه العقوبة بحسب ملابسات هذه الجريمة، وهذه الخلاصة مفهومة مما نص عليه قانون العقوبات الصومالي، من أنه: "لا عقوبة على كل من أحدث ضررا أو عرض للخطر حقا برضاء من الشخص الذي من حقه قانونا التنازل عنه" [٢].

وعليه فقانون العقوبات الصومالي لا يخالق الفقه الإسلامي في مسألة القتل الرحيم.

رضا المجنى عليه على جناية الجرح في القانون:

إن الرضا على جناية الجرح يعتبر كمانع من موانع المسئولية الجنائية، وقد تقدم في مطلب الرضا على جناية القتل أن قانون العقوبات الصومالي بيّن أحكام رضا المجنى عليه، كمانع من موانع المسئولية الجنائية، حيث ذكرها بعنوان: رضا المجنى عليه، ونص على أنه:

"لا عقوبة على كل من أحدث ضررا أو عرض للخطر حقا برضاء من الشخص الذي من حقه قانونا التنازل عنه" [٣]، وهذا واضح في انتفاء المسئولية الجنائية في حال الرضا على كل الأضرار جرحا كان أو وفاة، وعلى هذا فإن القانون موافق للفقه الإسلامي في القول الثالث: (الشافعية والحنابلة) في جناية القتل، كما يوفق فيه في اعتبار الرضا كمانع من موانع المسئولية الجنائية في جناية الجرح.

المطلب الثالث: الجهل بتحريم الفعل والحكم وأقسامه في الفقه الإسلامي.

الجهل في اللغة: خلاف العلم [٤]، يعني: انعدام العلم عمن يتصور منه العلم[٥].

وأما الجهل اصطلاحا فقد عرّفه العلماء بعدة تعريفات، ومن أهمها ما يلي:

١. "اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه"[٦].

---

(١) قانون العقوبات الصومالي مرجع سابق، م: ٤٣٨، ف: (١).

(٢) المرجع السابق، م: ٣٢.

(٣) المرجع السابق، م: ٣٢.

(٤) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد أبو نصر الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، ط ٤، ت: ١٤٠٧ هـ -١٩٨٧ م، بيروت-لبنان، ج٤، ص: ١٦٦٣.

(٥) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، مرجع سابق، ص: ٨٣.

(٦) التعريفات، مرجع سابق، ص: ٨٠.

٢. "تبين المعلوم على خلاف ما هو به "[١].

٣. "انتفاء العلم بالمقصود" [٢].

وأما الجهل بتحريم الفعل، فسيأتي في البند الرابع من أقسام الجهل باعتبار كونه رافعا للتكليف وعدم كونه ذلك.

وأما الحكم: فإن وقع الجهل في ترك مأمور لم يسقط، بل يجب تداركه، ولا يحصل الثواب المترتب عليه لعدم الائتمار، أو فعل منهي، ليس من باب الإتلاف، فلا شيء فيه، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان، فإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها[٣]، فعلى أي حال فإن الجهل مسقط للإثم مطلقا[٤].

أقسام الجهل.

يقسم الجهل باعتبارين:

أولا: من حيث كونه عذرا رافعا للتكليف وعدمه ينقسم على أنواع أربعة:

أ. **الجهل بالله جل وعلا** وإنكار وجوده أو قدرته ونحوهما من صفاته الثابتة بالنصوص القطعية، وما يجب له من العبادة، فهذا لا يعذر به الإنسان بعد علمه بإرسال الرسل إلى الخلق، وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [٥]، فمعرفة الله سبحانه وتعالى واجبة [٦]؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [٧]، فلا يعذر أحد بالجهل بأصول الدين.

ب. الجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة، كالجهل بوجوب الصلاة والزكاة، والجهل بحرمة الزنى والربا والظلم، ونحو ذلك. فهذا لا يعذر به أحد ممن عاش بين المسلمين؛ لأنه إما ناشئ عن تقصير وتفريط، وإما أنه دعوى كاذبة، فيدعي الجهل وهو يعلم [٨].

---

(١) التمهيد في أصول الفقه، محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكَلْوَذَاني الحنبلي، تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، ط١، ت: ١٤٠٦ هـ -١٩٨٥ م، بدون مكان النشر، ج١، ص: ٥٧.

(٢) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي، دار الكتب العلمية، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر، ج ١، ص: ٢١١.

(٣) الأشباه والنظائر، السيوطي، مرجع سابق، ص: ١٨٨.

(٤) المنثور في القواعد الفقهية، مرجع سابق، ج٢، ص: ١٩.

(٥) سورة الإسراء، الآية: ١٥.

(٦) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، محمد بن إبراهيم بن علي، (المعروف بابن الوزير)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط٢، ت: ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م، بيروت، ج٤، ص: ٤٠

(٧) سورة محمد، الآية: ١٩.

(٨) قواعد معرفة البدع، محمد بن حسين بن حسن الجيزاني، دار ابن الجوزي، ط١، ت: ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م، المملكة العربية السعودية، ص: ١٦٦

ج. الجهل في موضع الاجتهاد أو الاشتباه، كالجهل بحرمة بعض أنواع البيوع، وبعض الأحوال العارضة للإنسان في صلاته أو في حجه، ونحو ذلك مما يصعب على عامة الناس الإحاطة به، فهذا النوع يسقط عن الجاهل اللوم والذم، ولكنه يلزم باستدراك ما فعله على غير الصفة الصحيحة إذا أمكن ذلك من غير مشقة خارجة عن المعتاد(١).

د. الجهل بتحريم الفعل إذا كان من حديث عهد بالإسلام، أو ممن عاش حياته في البلاد الكافرة، ويجهل بما يعرفه عامة المسلمين في البلاد الإسلامية كتحريم الزنا، فهذا يعد عذرا مسقطا للمؤاخذة الأخروية، ولكن يلزم الجاهل باستدراك ما فاته إذا أمكن استدراكه، وذلك كالجاهل بوجوب الغسل من الجنابة وتحريم الأخت من الرضاعة ونحو ذلك مما هو معلوم للمسلمين الذين يعيشون في البلاد الإسلامية ولكن قد يجهله من عاش في البلاد الأخرى (٢)، وهذا داخل تحت القاعدة الترك للمطلوب؛ خوفا من مفسدة أعظم من مصلحة(٣)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت، فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا، وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم »(٤).

ثانيا: الجهل باعتبار كونه مركبا أو غيره ينقسم إلى قسمين:

١. الجهل البسيط: هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالمًا.

٢. الجهل المركب: هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع (٥).

بناء على هذا إن الجهل هو: انتفاء العلم بالمقصود في الأصح، بأن لم يدرك، يسمى الجهل البسيط، أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع، ويسمى الجهل المركب لتركبه من جهلين: جهل المدرك بما في الواقع، وجهله بأنه جاهل به كاعتقاد الفلسفي أن العالم قديم (٦).

---

(١) التقرير والتحبير، مرجع سابق، ج ٣، ص: ٣٢٥.

(٢) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، مرجع سابق، ص: ٨٣.

(٣) دراسات أصولية في القرآن الكريم، محمد إبراهيم الحفناوي، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، بدون الطبعة، ت: ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م، القاهرة-مصر، ص: ٢٦٠.

(٤) أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، رقم الحديث: (١٥٨٦)، عن عائشة - رضي الله عنها-، ج ٢، ص: ١٤٧.

(٥) التعريفات، مرجع سابق، ص: ٨٠.

(٦) غاية الوصول في شرح لب الأصول، مرجع سابق، ص: ٢٤.

المطلب الرابع: الجهل بتحريم الفعل والحكم وأقسامه في القانون

معنى الجهل في القانون:

فمعنى الجهل في اللغة تقدم في المطلب السابق في الفقه الإسلامي، وأما معنى الجهل اصطلاحا فإنه يقصد بالجهل بالشيء عدم توافر العلم به، أو هو حالة ذهنية سلبية تحمل على تخلف العلم التام بهذا الشيء ومقوماته [١]، فالجهل بالشيء يعني: عدم العلم به [٢].

وتطرق قانون العقوبات الصومالي إلى بيان أحكام الجهل في الوقائع والأحكام حيث نص على أنه:

١- لا يعتبر جريمة ما يقع من شخص بسبب جهله بالحقيقة فيما يتعلق بالفعل الذي يكوّن الجريمة، ومع ذلك لا إعفاء من العقاب إذا كان الجهل المرتكب يرجع إلى خطأ، وأن الواقعة تكون جريمة ارتكبت خطأ.

٢- الجهل بالحقيقة فيما يتعلق بالفعل الذي يكوّن جريمة معينة لا يعفى من التعرض للعقوبة حين يكون الفعل جريمة مختلفة.

٣- الجهل بالقانون – ماعدا قانون العقوبات- يعفى عن توقيع العقوبة حين يكون الجهل بالقانون الذي ترتب على جهل بالحقيقة فيما يتعلق بالفعل المكوّن للجريمة [٣].

أقسام الجهل من حيث المسئولية الجنائية في القانون.

ينقسم الجهل من حيث ارتفاع المسئولية الجنائية إلى قسمين:

١. الجهل في الفعل المكوّن للجريمة.

٢. الجهل في القانون.

أما القسم الأول الذي هو الجهل في الوقائع، فقد بين قانون العقوبات الصومالي في المادة رقم: (٢٨)، حيث نص فيها أن لا يعفى من التعرض للعقوبة، ومن ثم لا يعتبر القانون هذا النوع من الجهل مانعا.

وأما القسم الثاني الذي هو الجهل بالقانون، فهذا النوع من الجهل يفصّل القانون فيه بين ما إذا كان الجهل في قانون العقوبات أو كان في غير أحكام هذا القانون كالقانون المدني أو التجاري، فإن كان الجهل فيما عدا قانون العقوبات فإنه تنتفي بسببه المسئولية الجنائية [٤].

أما إذا كان الجهل بقانون العقوبات فلا يقبل الاعتذار فيه، ولا ينتفي بالجهل المسئولية الجنائية، وهذا داخل في القاعدة العامة التي تقول: الجهل بالقانون ليس عذرا، وهذا ما نص عليه قانون العقوبات الصومالي، من أنه لا يقبل الادعاء بالجهل بقانون العقوبات [٥].

---

(١) شرح قانون العقوبات اليمني، مرجع سابق، ص:٤٨٣.

(٢) شرح قانون الجرائم والعقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ج١، ص:٣٨١.

(٣) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٢٨، ف (١) و(٢) و (٣).

(٤) المرجع السابق، م: ٥.

(٥) المرجع السابق، م: ٥.

القاعدة العامة للجهل بالقانون

لا يعذر أحد لجهله بالقانون؛ إذ أن العلم بالقانون مفترض، فلا يقبل الدفع بالجهل به، وهذا العلم بقانون العقوبات مفترض لدى كل شخص، وقرينة لا تقبل الدليل العكسي على توافره بحيث لا تكلف سلطة الاتهام بإثباته، ولا يقبل من المتهم إقامة الدليل على انتفائه [١].

وهذا القانون إنما يفترض في كل شخص متمتع بإمكانية فهم أحكام القانون أن يكون قد وصل إليه كل حكم منها، وأحاط به علما، واستوعبه فهما، فإن لم يصل إليه أو وصل مع أنه غير فاهم فهما صحيحا فإنه يعامل كما لو فهم فهما صحيحا وتمكن من فهمه، ولا يقبل منه الدفع بالجهل[٢].

فما مدى موافقة القانون للفقه الإسلامي في حكم الجهل

يبدو أنه لا مخالفة بينهما في حكم الجهل، من حيث المسئولية وعدمها جملة، إلا ما كان لهما من تفاصيل، فكل له قواعده الخاصة التي يبني عليها أحكام مسألة الجهل، ككونه ما نعا من موانع المسئولية الجنائية.

الخلاصة:

يستخلص مما سبق: أن الصبي بقسميه – المميز وغير المميز – فالراجح أنه غير مكلف، وأما الجنون هو: عدم قدرة الشخص على التوفيق بين أفكاره وشعوره وما يحيط به الإنسان عقلية، وأنه يعتبر مانعا من موانع المسئولية الجنائية، وأن تكليف المجنون يختلف باختلاف متعلقه، فإن كان قولا مطلقا، أو فعلا يتعلق بحقوق الله فلغو، وأما إذا كان فعلا يتعلق بغير حقوق الله فعليه الضمان، **وأنه يلحق بالجنون أمور منها:** عاهة العقل، والسكر، فإنهما يعتبران مانعا أيضا، ولكن لا يكون السكر مانعا مطلقا، ومن ثم فإن السكر نوعان: أولهما بغير اختيار، وثانيهما باختيار: **فالسكر غير الاختياري** فهو الذي يعتبر مانعا من موانع المسئولية الجنائية، بخلاف **السكر الاختياري** فإنه لا يعتبر مانعا قطعا.

وقد سبق أيضا أن الإكراه يعتبر كمانع من موانع المسئولية الجنائية، سواء في ذلك الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الصومالي والقوانين الأخرى، وأن الضرورة تمنع المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي، وأكبر شاهد في ذلك هو: أنها أبيحت كلمة الكفر للمكره، بنص القرآن، وأما قانون العقوبات الصومالي والقوانين الأخرى تعتبر الضرورة كأحد أسباب امتناع المسئولية الجنائية، مع أن قانون العقوبات الصومالي يقتصر على الخطر الذي وقع على النفس فقط، وأهمل الباقي، ومن ثم فإن فيه قصور من هذه الناحية.

وعلى ما تقدم ينبغي الانتباه إلى أن الضرورة لا تنفي المسئولية الجنائية عن جميع الجرائم مطلقا، بل منها ما لا ينفي المسئولية الجنائية، كجرائم القتل والزنا، ومنها ما ينفي المسئولية

---

(١) شرح قانون العقوبات اليمني، مرجع سابق، ص:٥٠١.

(٢) شرح قانون الجرائم والعقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص:٣٧٧.

الجنائية، كالمضطرّ في شرب الخمر للغصة والعطش الشديد وجريمة السرقة إلا أن في جريمة السرقة عليه الضمان.

فيشترط للضرورة ككونها مانعا من موانع المسئولية الجنائية شروط يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف: الصنف الأول: شروط للخطر الذي يراد دفعه، فهي اثنان: الأول: أن يكون الخطر جسيما، الثاني: حلول الخطر. والصنف الثاني: شروط تتعلق بالفعل اللازم لدفع الخطر، فهي اثنان أيضا: وهما: التناسب، واللزوم. والصنف الثالث: شروط تتعلق بالشخص المستفيد، فيشترط فيه أن يتوافر فيه شرطان: الشرط الأول: ألا يكون ملزما بمواجهة الخطر، والشرط الثاني: أن لا يكون لإرادة الشخص دخل في حلول الخطر.

ومما سبق أيضا أن الرضا هو مما اختلف عليه الفقهاء في حكمه إذا كان بالقتل، ولكن الراجح عند الشافعية والحنابلة هو أنه يعتبر مانعا من موانع المسئولية الجنائية، بخلاف ما إذا كان الرضا بالجرح، فإنه يعتبر أيضا مانعا من موانع المسئولية الجنائية اتفاقا، وأن حكم القتل الرحيم في الفقه الإسلامي والقانون يكون مخظورا وحراما، وغير مشروع، وتفصيل هذا النوع من القتل إن كان من مريض إذنه معتبر، فلا شيء على القاتل، وإن لم يكن فالحكم أن هذا القتل عمد وبغير حق فعليه القصاص، وأما الجهل فهو يعتبر أيضا مانعا من موانع المسئولية الجنائية سواء كان في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي والقوانين الأخرى إلا إذا كان الجهل متعلقا بقانون العقوبات، لا يعتبر الجهل به مانعا من موانع المسئولية الجنائية.

الفصل الرابع: أسباب الإباحة في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي

المبحث الأول: استعمال حق التأديب في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي

المطلب الأول: حق تأديب الزوجة في الفقه الإسلامي

الفرع الأول: حكم تأديب الزوجة ومشروعيته وحكمته

الفرع الثاني: مراتب تأديب الزوجة

المطلب الثاني: حق تأديب الزوجة في القانون

الفرع الأول: حكم تأديب الزوجة وحكمته

الفرع الثاني: شروط استعمال حق تأديب الزوجة

المطلب الثالث: حق تأديب الصغار في الفقه الإسلامي

الفرع الأول: مشروعية تأديب الصغار وعلته

الفرع الثاني: شروط تأديب الصغار بالضرب

المطلب الرابع: حق تأديب الصغار في القانون

الفرع الأول: حكم تأديب الصغار وعلته

الفرع الثاني: شروط تأديب الصغار

المبحث الثاني: استعمال حق الأعمال الطبية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي

المطلب الأول: ممارسة حق الأعمال الطبية في القه الإسلامي

الفرع الأول: الأعمال الطبية ومشروعية التداوي

الفرع الثاني: حكم ممارسة الأعمال الطبية

المطلب الثاني: ممارسة حق الأعمال الطبية في القانون

الفرع الأول: حكم الأعمال الطبية

الفرع الثاني: الأساس القانوني لإباحة الأعمال الطبية

المطلب الثالث: شروط ممارسة حق الأعمال الطبية في الفقه الإسلامي

المطلب الرابع: شروط ممارسة حق الأعمال الطبية في القانون

المبحث الثالث: الدفاع الشرعي الخاص (دفع الصائل) وشروطه في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي

المطلب الأول: الدفاع الشرعي الخاص (دفع الصائل) في الفقه الإسلامي.

المطلب الثاني: الدفاع الشرعي الخاص في القانون.

المطلب الثالث: شروط الدفاع الشرعي الخاص(دفع الصائل) في الفقه الإسلامي

المطلب الرابع: شروط الدفاع الشرعي الخاص في القانون

الفصل الرابع: الأسباب الإباحة في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي

تمهيد: والمراد بأسباب الإباحة أنها: مجموعة من أمور موضوعية، تخرج عن ماهية الشخص؛ فلا تتعلق بجوهره، ولكنها تتعلق بذات الفعل، فتنفي عنه الصفة الإجرامية، وتقلبه إلى عمل مشروع مباح، وتمنع العقوبة عن كل من قام بالفعل أو شارك أو تدخل فيه.

وتتنوع أسباب الإباحة باعتبار ما تتعلق به إلى:

ما يتعلق بحق تأديب الزوج لزوجته، وهو حق من الحقوق المقررة للزوج على زوجته، حفظا للأسرة من الهدم أو ما يقاربه في حالات معينة يأتي بيانها إن شاء الله.

وما يتعلق بحق تأديب الصغار، فيعتبر أنه حق واجب للصغار على الأولياء، وذلك بشروط.

وما يتعلق بأداء الواجب، كما في حالة الطبيب عند معالجته المريض أو إجراء عملية له، والجلاد، ونحو ذلك.

وما يتعلق باستعمال حق الدفاع الشرعي (دفع الصائل)، كمن ضرب أو قتل شخصاً اعتدى عليه أو اعتدى غيره أو أراد قتله أو غيره، وهو حق مشروع في الكتاب والسنة.

وعلى هذا الترتيب سيأتي الكلام على هذه الأمور في المباحث الآتية إن شاء الله:

المبحث الأول: استعمال حق التأديب في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي

تمهيد: شرع الله الزواج لمصالح دينية ودنيوية، ورتب عليه حقوقاً لكلا الزوجين تجاه صاحبه، ومن ثم أوجب على الزوجين أن يتبعا المنهج الذي شرعه الله، فلا يحيدا عنه، وإلا حصل الشقاق والخلاف والتفكك بينهما.

و من الحقوق التي قررها الشارع الحكيم للزوج على زوجته وجوب طاعته في غير معصية الله، وعدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج، وكذا حق استعمال التأديب ونحو ذلك.

وكذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب للأولاد الصغار التربية والحضانة، فمن ثم لا يمكن القيام من قبل الأولياء إلا بالتأديب عند الحاجة إليه.

وعلى هذا النظام الذي في الفقه الإسلامي سلك قانون العقوبات الصومالي، وقانون الأحوال الشخصية الصومالي، فنظّم كل منهما أحكام الأسرة من حيث التأديب وغيره، وكذلك ما يتعلق بتأديب الصغار وتربيتهم، كما نظمها الفقه الإسلامي، وبناء على ذلك يتكون هذا المبحث من المطالب الآتية:

المطلب الأول: حق تأديب الزوجة في الفقه الإسلامي

الفرع الأول:حكم تأديب الزوجة ومشروعيته وحكمته

تأديب الزوجة حق من الحقوق التي يقررها الفقه الإسلامي للزوج؛ حفظا لبيت الأسرة من الزعزعة، وكتمانا للأسرار التي بينهما، وعلى كل الأحوال فإنه اتفق الفقهاء على أن تأديب الزوجة حق للزوج، إذا لم تطعه، وعليه تنتفي المسئولية الجنائية الحاصلة من هذا التأديب [١] بشروط ستأتي.

فهذا التأديب وإن كان حقا للزوج تجاه زوجته ليس استعماله واجبا، بل الزوج مخير، بين التأديب والعفو عن استعماله، ولكن الأولى له العفو عنها، وخبر: ((إن لي امرأة، وإن في لسانها شيئا –يعني البذاء– قال: "فطلقها إذا" قال: قلت: يا رسول الله، إن لها صحبة ولي منها ولد، قال:

---

(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج٢، ص: ٣٣٤، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج٤، ص: ١٥، و منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، مرجع سابق، ص: ٢٢٤، والمغني، مرجع سابق، ج٧، ص: ٣١٨.

"فمرها –يقول: عظها– فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظعينتك كضربك أمينتك)) [١] ، فيه نهي عن ضرب المرأة [٢] .

وحمل النهي عن ضرب النساء على ما تقدم أو على الضرب بغير سبب يقتضيه لا على النسخ؛ إذ لا يصار إليه إلا إذ تعذر الجمع وعلم التاريخ [٣].

وتأديب الزوجة مشروع بالكتاب والسنة، ويستدل على ذلك مايلي:

أولا: الكتاب، ومن ذلك:

١. قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًا ﴾[٤].

ووجه الاستدلال هو: أن الضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب [٥]، وإذا تجاوز الحد وأفضى إلى التلف، فإنه يضمن [٦].

٢. قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ ﴾[٧].

ووجه الدلالة هو: أن الله عز وجل أمر المؤمنين بوقاية أهلهم من النار، ووقاية الأهل بأن يؤمروا بالطاعة، وينهوا عن المعصية"[٨]، ويصلح –الرجل– أهله إصلاح الراعي للرعية [٩].

---

(١) أخرجه أبو داود، في سننه، كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، برقم: (١٤٢)، عن لقيط بن صبرة، ج ١، ص: ٩٩، وقال شعيب الأرنؤوط وآخر: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، ص: ج ١، ص: ١٠٠.

(٢) مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، عبد الرحمن أبو الفضل جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد شايب شريف

دار ابن حزم، ط ١، ت: ١٤٣٣ هـ – ٢٠١٢ م، بيروت – لبنان، ج ١، ص: ١٢٣.

(٣) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية، ط١، ت: ١٤١٥هـ – ١٩٩٤م، بدون مكان النشر، ج٤، ص: ٤٢٧.

(٤) سورة النساء، الآية: ٣٤.

(٥) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج٤، ص: ١٥.

(٦) الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، مرجع سابق، ص: ٧٠٨، و النجم الوهاج في شرح المنهاج، محمد بن موسى بن عيسى بن علي أبو البقاء كمال الدين، الدّميري الشافعي، تحقيق: لجنة علمية، دار المنهاج، ط ١، ت: ١٤٢٥ ه – ٢٠٠٤ م، جدة، ج ، ص: ٤١٩.

(٧) سورة التحريم، الآية: ٦.

(٨) زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج جمال الدين الجوزي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، ط ١، ت: ١٤٢٢هـ بيروت–لبنان، ج٤، ص: ٣١٠.

(٩) الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج١٨، ص: ١٩٥.

ضرب الزوج زوجته على ترك العبادات:

اختلف الفقهاء على حكم ضرب الزوجة على ترك الفرائض من العبادات، على قولين:

القول الأول: أنه يجوز للزوج أن يضرب زوجته على ترك فرائض الله تعالى، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، فهو الأظهر عند الحنفية [١]، وهو مذهب المالكية [٢]، وهو أيضا وجه عند الشافعية [٣]، ورواية عن أحمد[٤].

استدل الجمهور على هذا القول بما يلي:

١) قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا ﴾ [٥].

٢) ما روى ابن عباس، – رضي الله عنهما – من ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق السوط في البيت)) [٦]، ووجه دلالة الحديث هو: أن أمره – صلى الله عليه وسلم – بتعليق السوط في البيت فيه دلالة على جواز تأديب الزوج لزوجته؛ لأنه لا معنى لهذا التعليق إلا باعتباره أنه للتأديب، والتارك على عبادة الله يستحق العذاب، والضرب على ترك عبادة الله أولى بالوقاية من النار.

٣) لأنه من باب إنكار المنكر والزوج من جملة من يكلف بالإنكار باليد أو اللسان أو الجنان[٧].

---

(١) الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، مرجع سابق،، ص: ٦٦٩.

(٢) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، مرجع سابق، ج ٥، ص: ٢٥٦، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، دار الفكر، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر، ج ٤، ص: ٣٥٤.

(٣) أسنى المطالب في شرح روض الطالب، مرجع سابق، ج ١، ص: ١٢١.

(٤) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم أبو النجا شرف الدين، الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بدون الطبعة، والتاريخ، بيروت – لبنان، ج ٣، ص: ٢٥١.

(٥) سورة التحريم، الآية: ٦.

(٦) أخرجه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الله، البخاري، في الأدب المفرد بالتعليقات، باب تعليق السوط في البيت، برقم (١٢٢٩)، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المعارف، ط ١، ت: ١٤١٩ هـ – ١٩٩٨ م، الرياض – المملكة العربية السعودية، ص: ٦٩٩، وسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير أبو القاسم اللخمي الشامي، الطبراني، في المعجم الكبير، باب العين، علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه، برقم: (١٠٦٧٢)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، ط ٢، بدون التاريخ، القاهرة، ج ١٠، ص: ٢٨٥، وفي تعليق الأدب المفرد في الصفحة: ٦٩٩، قال سمير بن أمين الزهيري: صحيح.

(٧) سبل السلام، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد أبو إبراهيم، عز الدين، الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، المعروف كأسلافه بالأمير، دار الحديث، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر، ج ٢، ص: ٤٥٥.

القول الثاني: هو: أنه لا يجوز للزوج تأديب زوجته على ترك فرائض الله تعالى؛ وهذا مذهب الشافعية[١]، وقول لأبي حنيفة [٢]، ورواية لأحمد أيضا [٣].

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١- ﴿ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ﴾ [٤].

وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى شرع التأديب للزوج، وجعله حقا من حقوقه؛ لأجل الخوف من النشوز، ونشوز المرأة: تعاليها على زوجها وإساءتها معاملته [٥]، لا ترك عبادة الله وفرائضه، ومن ثم لا يجوز له التأديب إلا في الحنود التي حددها الله للتأديب، وفرائض الله لا تدخل في ضمن النشوز.

٢- أن محل جواز ضربه لها في حق نفسه لا في حقوق الله تعالى[٦].

ويظهر للباحث أن الراجح من هذين القولين القول الأول الذي يكون مضمونه جواز ضرب الزوجة على ترك فرائض الله، والسبب في ذلك:

١) أن الحديث في جواز ضرب الزوجة وإن كان ضعيفا، لكنه يعضده عموم قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾[٧]، **ووجه ذلك** أن الزوجة من أهل الزوج، فكل ما يوجب النار يجب على المؤمنين وقاية أنفسهم منه، وأهليهم، ومن أبرز وأعظم ما يوجب النار ترك الفرائض، فإذا لم تمكن الوقاية بشيء من المراتب التأديبية إلا بالضرب فيجب؛ امتثالا، فإن الأمر بالشيء أمر بلازمه أيضا، والوقاية من النار تستلزم التأديب بترك الفرائض، وهو موجب للنار، فالضرب لفرائض الله وسيلة، واللازم حكمه حكم الملزوم، كما أن الوسائل لها حكم المقاصد.

---

(١) تحفة المحتاج في شرح المنهاج، مرجع سابق، ج ١، ص: ٤٥٢.

(٢) رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق، ج ٦، ص: ٤٢٧.

(٣) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، مرجع سابق، ج ٨، ص: ٣٧٨.

(٤) سورة النساء، الآية: ٣٤.

(٥) الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، مرجع سابق، ج ١، ص: ٢٥٨، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج ٢، ص: ٣٤٣، و بداية المحتاج في شرح المنهاج، محمد بن أبي بكر أبو الفضل بدر الدين الأسدي الشافعي ابن قاضي شهبة، تحقيق: أنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني، دار المنهاج، ط ١، ت: ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م، ج ٣، ص: ١٧٩.جدة - المملكة العربية السعودية، والمغني، مرجع سابق، ج ٧، ص: ٣١٨.

(٦) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مرجع سابق، (ج١/ ص: ٣٩٣).

(٧) سورة التحريم، الآية: ٦.

٢) القياس على الأولاد بجامع الأهلية، فكما أن الأولاد من أهل الزوج فالزوجة من أهله، فتشمل الآية وقاية الجميع من النار.

ثانيا: السنة النبوية، ومنها:

قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته)) [١].

ووجه الدلالة: أن أهل المرء ونفسه من جملة رعيته وهو مسئول عنهم؛ لأنه أمر أن يحرص على وقايتهم من النار وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه[٢].

ومن المعلوم أن أهل المرء –كزوجته– من جملة رعيته، وهو مسئول عنهم؛ لأن الله تعالى جعله راعياً عليهم، والرعاية تستلزم الحفظ والنظر والائتمان، وذلك يقتضي تربية الأهل بحملهم على امتثال أوامر الله واجتناب منهياته بالوعظ والإرشاد، وتأديبهم على ذلك عند وجود الحاجة بنحو توبيخ أو ضرب [٣].

الفرع الثاني: مراتب تأديب الزوجة

فالتأديب ليس ضربا فقط، كما يفهمه البعض مباشرة، فمراتب التأديب للزوجة مبينة في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ﴾[٤]، **ووجه الدلالة** أن الله سبحانه وتعالى بين مراتب تأديب الزوجة، وينبغي التدرج كما بينه الله عز وجل[٥] على الترتيب الآتي:

المرتبة الأولى: الموعظة:

وكيفية الموعظة: بأن يقول لها كوني من الصالحات القانتات الحافظات للغيب ولا تكوني من كذا وكذا، فلعل تقبل الموعظة، فتترك النشوز[٦]. أو أن يقول الزوج للزوجة مثلا: اتقي الله في الحق الواجب لي عليك، واعلمي أن النشوز مسقط للنفقة والقسم [٧].

---

(١) سبق تخريجه، ص:١٦

(٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة، بدون الطبعة، ت: ١٣٧٩هـ، بيروت ، ج٩، ص: ٢٥٤.

(٣) المرجع السابق، نفس الصفحة.

(٤) سورة النساء، الآية: ٣٤ – ٣٥.

(٥) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، عبد الله بن عمر بن محمد أبو سعيد ناصر الدين الشيرازي البيضاوي، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، ط ١، ت: ١٤١٨ هـ، بيروت، ج ٢، ص: ٧٣.

(٦) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج ٢، ص: ٣٣٤.

(٧) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، ج ٤، ص: ٤٢٥.

المرتبة الثانية: الهجرة في المضاجع؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ﴾[١]

اختلف الفقهاء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ﴾[٢]، وذلك على ما يلي:

القول الأول: هو أن الهجران أن يهجرها، في الفراش، لا في غير البيت، ولا الكلام فوق ثلاثة أيام، وهذا قول جمهور العلماء، من: الحنفية [٣]، والمالكية [٤]، والشافعية[٥]، والحنابلة[٦]، وغيرهم[٧].

استدل الجمهور على ذلك ما يلي:

- قوله عز وجل: ﴿وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ﴾ [٨]

كيفيتها: أن يكون الرجل وامرأته في فراش واحد ولا يجامعها [٩].

القول الثاني: هجرها في غير البيت، ويضاجع أخرى في حقها وقسمها إن كانت [١٠]، فيهجرها بلسانه ويغلظ لها بالقول، ولا يدع جماعها [١١].

استدل أصحاب هذا القول على ذلك بما يلي:

١) ما روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما– أنه قال في قوله عز وجل: ﴿وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ﴾ [١٢].

---

(١) سورة النساء، الآية: ٣٤ – ٣٥.

(٢) سورة النساء، الآية: ٣٤ – ٣٥.

(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج ٢، ص: ٣٣٤.

(٤) منح الجليل شرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج ٣، ص: ٥٤٥.

(٥) المهذب في فقة الإمام الشافعي، مرجع سابق، ج ٢، ص: ٤٨٧.

(٦) شرح الزركشي على مختصر الخرقي، محمد بن عبد الله شمس الدين الزركشي المصري الحنبلي، دار العبيكان، ط١، ت: ١٤١٣ هـ – ١٩٩٣ م، بدون مكان النشر، ج ٥، ص: ٣٥٠.

(٧) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج ٢، ص: ٣٣٤.

(٨) سورة النساء، الآية: ٣٤.

(٩) التوضيح لشرح الجامع الصحيح، عمر بن علي بن أحمد أبو حفص سراج الدين الشافعي المصري، المعروف بـ(ابن الملقن)، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النوادر، ط ١، ت: ١٤٢٩ هـ – ٢٠٠٨ م، دمشق – سوريا، ج ٢٥، ص: ٣٧.

(١٠) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج ٢، ص: ٣٣٤.

(١١) جامع البيان في تأويل القرآن، مرجع سابق، ج ٨، ص: ٣٠٦.

(١٢) سورة النساء، الآية: ٣٤.

قال ابن عباس– رضي الله عنهما–: لا تضاجعها في فراشك [١]،وأما الهجران بالكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام)) [٢]، وله هجرها في الكلام، لكن فيما دون ثلاثة أيام [٣].

٢) لأن ذلك حق مشترك بينهما، فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليها، فلا يؤدبها بما يضر بنفسه، ويبطل حقه [٤].

القول الثالث: أن يهجرها، بأن لا يكلمها في حال مضاجعته إياها لا أن يترك جماعها ومضاجعتها؛ لما يلي:

١– لأن ذلك حق مشترك بينهما، فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليها، فلا يؤدبها بما يضر بنفسه، ويبطل حقه[٥].

المرتبة الثالثة: الضرب، ويجب أن تتوافر فيه ستة شروط:

١– يشترط أن لا يكون الضرب مبرحًا ولا مدميًا [٦]؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم– في خطبته في حجة الوداع: ((فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)) [٧].

---

(١) تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر أبو محمد ابن أبي حاتم التميمي، الحنظلي، الرازي، دراسة وتحقيق، وتخريج: حكمت بن بشير بن ياسين، دار ابن الجوزي، ط١، ت: ١٤٣٩ ه، الدمام – المملكة العربية السعودية، ج ٤، ص: ٢١٤ – ٢١٥، وفي الصفحة نفسها قال: حكمت بن بشير بن ياسين، في إسناد: سماك، ورايته عن عكرمة فيها اضطراب، وشريك: صدوق اختلط؛ فالإسناد ضعيف.

(٢) أخرجه الإمام محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، برقم: (٦٠٦٥)، عن أبي هريرة –رضي الله عنه–، ج ٨، ص: ١٩، والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، في صحيحه، كتاب البر والصلة والأداب، برقم: (٢٥٥٨)، عن أنس بن مالك –رضي الله عنه–، ج ٤، ص: ١٩٨٣

(٣) شرح الزركشي، مرجع سابق، ج ٥، ص: ٣٥٠.

(٤) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج ٢، ص: ٣٣٤.

(٦) معالم السنن (شرح سنن أبي داود)، حمد بن محمد بن إبراهيم أبو سليمان المعروف بالخطابي، المطبعة العلمية، ط١، ت: ١٣٥١ هـ – ١٩٣٢ م، حلب، ج ٢، ص: ١٣٦.

(٧) أخرجه مسلم بن الحجاج النيسابوري، في صحيحه، كتاب الحج، ، برقم: (١٢١٨)، عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه–،ج ٢، ص: ٨٨٦.

٢- أن لا يقع على الوجه والمهالك، والأماكن الخطيرة [٢]؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا يضرب الوجه))[٣].

٣- أن تكون آلة الضرب خفيفة مما يتحمله الإنسان، كالمنديل أو باليد، لا بسوط ولا عصا [٣]، أي: أن تكون الآلة دون الآلة الشرعية التي تقام بها الحدود [٤].

٤- أن يغلب على ظنه أنها تطيعه إن ضربها، فيجوز الضرب إن أفاد ضربها في ظنه، وإلا فلا يضربها [٥].

٥- أن لا تظهر عداوته لها، وإلا تعين رفعها للقاضي [٦].

٦- يشترط أن يكون محدودا، فلا يزيد على ثلاثة أسواط شيئا بذلك مضت عادة السلف -رضي الله عنهم - فإن اضطر إلى زيادة على ذلك فله فيما بين الثلاثة إلى العشرة سعة[٧].

ما يترتب على فقدان هذه الشروط

فمعلوم أن إباحة الضرب في هذه الحالات الست ولاية من الشرع للزوج لأخذ حقه وهو أيضا تأديب للزجة [٨].

ويترتب على عدم توافر هذه الشروط: أنه ما أدى الضرب إليه في هذه الحالة وجب ضمانه؛ لأن ظاهره ليس بإصلاح [٩].

المرتبة الرابعة، وهي الأخيرة: رفع الأمر إلى القاضي، ليوجه إليهما حكمين حكما من أهله، وحكما من أهلها[١٠]، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ﴾ [١].

---

(١) روضة الطالبين وعمدة المفتين، مرجع سابق، ج ٧، ص: ٣٦٨.

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب النكاح، أما حديث سالم، برقم (٢٧٦٤) عن معاوية القشيري، ج ٢، ص: ٢٠٤، وفي الصفحة نفسها قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد.

(٣) النجم الوهاج في شرح المنهاج، مرجع سابق، ج ٧، ص: ٤١٩.

(٤) المدخل، محمد بن محمد بن محمد أبو عبد الله المالكي الشهير بابن الحاج، دار التراث، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر، ج ٢، ص: ٣١٧.

(٥) حاشية البجيرمي على الخطيب، سليمان بن محمد بن عمر البُجيرمي المصري الشافعي، دار الفكر، بدون الطبعة، ت: ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م، وبدون مكان النشر، ج ٣، ص: ٤٧٦.

(٦) تحفة المحتاج في شرح المنهاج، مرجع سابق، ج٧، ص: ٤٥٥.

(٧) المدخل، مرجع سابق، ج ٢، ص: ٣١٧.

(٨) النجم الوهاج في شرح المنهاج، مرجع سابق، ج٧، ص: ٤١٩.

(٩) روضة الطالبين وعمدة المفتين، مرجع سابق، ج ٧، ص: ٣٦٨، والمحلى بالآثار، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الأندلسي القرطبي الظاهري، دار الفكر، بدون الطبعة، والتاريخ، بيروت، ج ٩، ص: ١٧٦.

(١٠) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج ٢، ص: ٣٣٤.

(١) سورة النساء: ٣٥.

الحكمة من تخويل الزوج هذا الحق

الحكمة في إعطاء الزوج هذا الحق هي المصلحة التي يجتنيها الزوج أن يصلح زوجته لنفسه(١).

المطلب الثاني: حق تأديب الزوجة في القانون

الفرع الأول: حكم تأديب الزوجة وحكمته

معروف أن الضرب من أحد معظم الأسباب التي تكون أساسا في فرقة الأزواج ودمار تمسك الأسرة, بل تضع الكثير من العقبات أمام الزوج و الزوجه في إصلاح و إرجاع ما كان بينهم من احترام, ومع ذلك فإن حصل تأديب كانت الزوجة أكثر خوفا من حالة عدم وجود التأديب، ولذا يرى أكثر الناس أن الزوجات الخائفات من أزواجهم هن أكثر طاعة من غيرهن.

فاتضح أن استعمال حق تأديب الزوجة له جانبان: جانب سلبي، وجانب إيجابي، وأما قانون العقوبات الصومالي بيّن جواز استعمال حق تأديب الزوجة مراعاة لجانبه الإيجابي، حيث نص قانون العقوبات الصومالي على أنه:

١- " لا تعد جريمة كل ما حصل أثناء مباشرة حق من الحقوق أو أثناء أداء واجب من الواجبات التي يفرضها القانون، أو يفرضها أمر مشروع صادر عن موظف عمومي" (٢).

ومن هذا النص يفهم أن تأديب الزوجة حق للزوج، وهو داخل في هذا النص العام؛ لأنه جزء من الحقوق المذكورة في النص، وعلى هذا فإن القانون يخول الزوج حق تأديب زوجته إن خرجت عن طاعته.

هذا، ولم يجد الباحث نصا خاصا، يعالج حق تأديب الزوج زوجته كسبب من أسباب الإباحة، فهذه المسألة هي مما لا ينبغي الغفلة عنها، فكان من الواجب وضع مواد تنظم أحكام الأسرة؛ لأنها مما لا يستغنى عنه كل يوم.

الحكمة من تخويل الزوج هذا الحق:

ومن المعلوم أن إعطاء الزوج هذا الحق وجعله نائبا عن السلطة المختصة إنما هو نوع من الستر؛ حفظا لأسرار الأسرة، حتى لا يطلع عليها أحد، فإذا عصت المرأة فإنه يجوز له أن يشكوها إلى السلطات المختصة إن أراد ذلك (٣).

---

(١) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، ج ٤، ص: ٤٢٧.

(٢) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٣٣، ف: (١).

(٣) شرح قانون الجرائم والعقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص:١٨٣-١٨٤.

ولعل المشرع الصومالي قد ترك أحكام تأديب الزوجة للفقه الإسلامي كما هو المعروف عند حل المنازعات الأسرية في المحاكم الشرعية التي تعتمد على الأعراف الدينية والتقاليد الاجتماعية التي توافق الفقه الإسلامي.

وبناء على ذلك فإن القانون منح الزوج وفقا لأحكام الفقه الإسلامي حق تأديب زوجته عند كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر [١]، فهو حق من الحقوق المعترف بها شرعا وقانونا، وعلى ذلك فإن حق التأديب يستند إلى نصوص القانون، أو العرف [٢].

الفرع الثاني: شروط استعمال حق تأديب الزوجة

مادام أن الغرض الأساسي من وضع قانون العقوبات الصومالي هو حماية الحياة الإنسانية منذ بدايتها ولحين نهايتها يحرم على كل فرد الاعتداء على الغير بعدم مساس بحق الإنسان في الحياة، أو في السلامة البدنية والنفسية، أو في كرامته.

وقد تقدم[٣]: أن القانون نظم العلاقة بين الزوجين في شكل حقوق وواجبات ووضع لها أسسا ثابتة تحميها من المشكلات والخلافات التي قد تنتهي أحيانا بالطلاق.

وحتى تستقيم العلاقة بين الزوجين منح القانون الزوج حق التأديب الذي يمارسه في حالة النشوز، فإذا خرجت الزوجة عن طاعة زوجها فإن الزوج حينئذ من حقه تأديبها، ولكن هذا ليس على الإطلاق، فإن أغلب القواعد لا بد لها من استثناء، وكذلك إن جواز تأديب الزوجة للزوج استثناء من عدم مساس بحق الإنسان في سلامة جسمه، ولكن مع ذلك لا بد له من قيود حتى لا يحصل اعتداء، فإن القانون لم يجعل هذا الحق مطلقا، وإنما أحاطه بشروط متعددة؛ حماية من التساهل في حقوق المرأة، وعلى هذا يشترط شراح القانون لتخويل الزوج حق التأديب شروطا عدة، منها:

١- اتباع أسلوب التدرج في وسائل التأديب، وفي هذا القيد يوافق القانون الفقه الإسلامي.

٢- إذا لزم الضرب، فلا بد من التقييد بقيود، (يكون الضرب غير مبرح)، بمعنى: أنه شترط أن يكون خفيفا لا يكسر عظما، ولا يدمي، ولا يترك للجسم شينا إلى آخره مما لا يؤلم ولا يشوه[٤].

٣- أن لا تكون بينهما عداوة، بأن يكون للانتقام [٥].

---

(١) شرح قانون العقوبات، الألفي، مرجع سابق، ص:١٨٤.

(٢) شرح قانون العقوبات اليمني، مرجع سابق، ص: ٢٢٤.

(٣) استنباطا من المادة السابق م: (٣٣) آنفا: " لا تعد جريمة كل ما حصل أثناء مباشرة حق من الحقوق أو أثناء أداء واجب من الواجبات التي يفرضها القانون، أو يفرضها أمر مشروع صادر عن موظف عمومي".

(٤) قانون الجرائم والعقوبات، ص:١٨٤

(٥) شرح قانون العقوبات، الألفي، مرجع سابق، ص: ١٨٤.

فما مدى موافقة القانون ومخالفته للفقه الإسلامي في استعمال حق تأديب الزوجة

يبدو أنه لا مخالفة بينهما، سواء في كان حكم تأديب الزوجة، والمراتب التأديبية، والشروط التي ينبغي مراعاتها في سبيل التأديب.

المطلب الثالث: حق تأديب الصغار في الفقه الإسلامي.

الفرع الأول: مشروعية تأديب الصغار وعلته

تأديب الصغار مسئولية مقررة على الأولياء، وقاية للصغار من الهلاك، فالولد عند ظهوره لأول مرة في العالم الخارجي يظهر منه عدم القدرة، فيتربى تدريجيا، حتى يصير إنسانا متكاملا، فبما رحمة من الله أوجب سبحانه وتعالى على الأولياء تربية أولادهم حتى يكونوا في نهايتهم ذوي أخلاق سمية.

بناء على ذلك فإن الله عز وجل شرع لأولياء الصغار حق التأديب، فهو حق من الحقوق الثابتة لهم بالأدلة الآتية:

١) قول الله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ ﴾ (١).

وجه الدلالة: أنه سبحانه وتعالى لما قال: ﴿ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ ﴾ دخل فيه الأولاد؛ لأن الولد بعض منه.

٢) قوله تعالى: ﴿ وَأۡمُرۡ أَهۡلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَا ﴾ (٢).

٣) قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَأَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِينَ ﴾ (٣)، ذلك حق عليه في نفسه وولده وأهله وعبيده وإمائه، ويفهم من الآية أنه يجب على كل مسلم أن يعلم أولاده وأهله الدين والخير، وما لا يستغنى عنه من الأدب (٤).

٤) قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها)) (٥).

٥) لأن في تعليمهم ذلك قبل بلوغهم إلفا لها واعتيادا لفعلها، وفي إهمالهم وترك تعليمهم ما لا يخفى ضرره من التكاسل عنها عند وجوبها، والاستيحاش من فعلها وقت لزومها، فأما تعليمهم ذلك قبل بلوغهم سبع سنين، فلا يجب عليهم في الغالب؛ لأنهم لا يضبطون تعليم ما يعلمون، ولا

---

(١) سورة التحريم، الآية: ٦.

(٢) سورة طه، الآية: ١٣٢.

(٣) سورة الشعراء، الآية: ٢١٤.

(٤) الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج ١٧-١٨، ص: ١٩٦.

(٥) أخرجه أبو داود، في سننه، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم الحديث: (٤٩٤)، ج ١، ص: ٣٦٦، عن سَبْرَة، قال ابن الملقن: صحيح، صححه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي وزادا على شرط مسلم، ينظر: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، عمر بن علي بن أحمد أبو حفص سراج الدين الشافعي المصري المعروف بابن الملقن، تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني، دار حراء ط ١، ت: ١٤٠٦هـ، مكة المكرمة، ج ١، ص: ٢٦٠.

يقدرون على فعل ما يؤمرون، فإذا بلغوا سبعا ميزوا وضبطوا ما علموا، وتوجه فرض التعليم على أبائهم، لكن لا يجب ضربهم على تركها، وإذا بلغوا عشرا وجب ضربهم على الترك[١].

تقدم عند الكلام على استعمال حق تأديب الزوج أن الأولى للرجال العفو عن الزوجة والصبر على ما يصدر منها من أمور لا يرضى الزوج إذا خالفت أمره، أما تأديب الصغير فهو مخالف لتأديب الزوجة من حيث العفو، فإن الأولى لولي الصغير عدم العفو؛ لأن ضربه للتأديب مصلحة للصبي، وضرب الزوج زوجته ليس فيه مصلحة لها بل لمصلحة الزوج[٢].

وعلة إباحة هذا الحق: أن المقصود من إباحة هذا الحق هو الوقاية للصغار من الهلاك والصلاح فقط لا غير [٣].فالصغير محتاج إلى التأديب؛ لدفع الفساد كالحدود، [٤] ؛ لأن العقوبات لدرء المفاسد لا للمخالفات، بدليل تأديب الصبيان والبهائم استصلاحا لها من غير عصيان [٥] .

الفرع الثاني: شروط تأديب الصغار بالضرب:

يشترط الفقه الإسلامي في تأديب الصغار عدة شروط، وبيانها كالآتي:

١. يشترط طلب الولي من الصبي اجتناب ما هو ممنوع شرعا، فقبل ذلك فلا يجوز الضرب، وعلى الأولياء نهي الأولاد عن جميع المحرمات وتعليمهم الواجبات وسائر الشعائر كالسواك وحضور الجماعات [٦]، ومن ثم يطلب من الولي معاشرة الولد باللطف والتأديب والتعليم، وإذا احتيج إلى ضربه ضرب، ويحمل الولد على أحسن الأخلاق ويجنب سيئها [٧].

٢. يشترط في إباحة التأديب سلامة العاقبة، فلا يكون الضرب مبرحًا ولا مدميًا [٨]، فهو الذي لا يكسر عظما، ولا يشين جارحة كاللكزة، ونحوها [٩].

ومعنى ذلك أن لا يقع على الوجه والمهالك التي لا يؤمن عليهم التلف من ضربها [١٠].

---

(١) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ، مرجع سابق، ج ٢، ص: ٣١٤.

(٢) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، ج ٤، ص: ٤٢٧.

(٣) الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج ٥، ص: ١٧٢.

(٤) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، ج ٣، ص: ٢٠٧.

(٥) الذخيرة، مرجع سابق، ج ١٢، ص: ٢٠٢.

(٦) حاشية البجيرمي على شرح المنهج، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَميّ المصري الشافعي، مطبعة الحلبي، بدون الطبعة، ت: ١٣٦٩ هـ - ١٩٥٠ م، وبدون مكان النشر، ج ١، ص: ١٦٣.

(٧) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ج٤، ص: ١٥٥.

(٨) بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد بن محمد أبو العباس الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، دار المعارف، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر، ج ١، ص: ٢٦٤.

(٩) الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج ٥، ص: ١٧٢.

(١٠) أسنى المطالب في شرح روض الطالب، مرجع سابق، ج٣، ص: ٢٣٩، والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ، مرجع سابق، ج ٢، ص: ٣١٤.

٣. يشترط أن تكون آلة الضرب خفيفة، أي: أن تكون الآلة دون الآلة الشرعية التي تقام بها الحدود، [١]، بأن يضربها بنحو منديل ملفوف؛ لما روى زيد بن أسلم أن «رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فدعا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بسوط فأتي بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال دون هذا فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فجلد» [٢].

٤. يشترط في جواز التأديب بالضرب أن يظن المؤدب إفادته، فإن لم يظن فيكون ضربه حراما [٣]، فإن لم يترتب عليه إلا هربه وضياعه، تركه[٤].

٥. يشترط أن يكون محدودا، فلا يزيد على ثلاثة أسواط شيئا بذلك مضت عادة السلف – رضي الله عنهم – فإن اضطر إلى زيادة على ذلك فله فيما بين الثلاثة إلى العشرة سعة[٥].

المطلب الرابع: حق تأديب الصغار في القانون

الفرع الأول: حكم تأديب الصغار في القانون، وعلته

الكلام في هذا الفرع يكون من جانبين: **الجانب الأول:** هو الكلام على أن حكم هذا التأديب حق واجب، **والجانب الثاني** هو الكلام على علة هذا الحكم، وذلك كالتالي:

أولا: حكم تأديب الصغار:

يقصد بتأديب الصغار حضانتهم، والحضانة هي: عبارة قانون الأحوال الشخصية الصومالي[٦]، إذا تأديب الصغار هو حضانة الأولاد، يعني: تربيتهم بشكل عام، فيقصد بهذا الحق

---

(١) المدخل، مرجع سابق، ج ٢، ص: ٣١٧.

(٢) أخرجه الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، في الموطأ، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا، برقم: (١٢)، دار إحياء التراث العربي، بدون الطبعة، ت: ١٤٠٦ هـ – ١٩٨٥ م، بيروت – لبنان، ج ٢، ص: ٨٢٥، وقال الشافعي: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة، ينظر الأم: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف أبو عبد الله الشافعي المطلبي القرشي المكي، دار المعرفة بدون الطبعة، ت: ١٤١٠ هـ ١٩٩٠ م، بيروت، ج ٦، ص: ١٥٧.

(٣) فقه العبادات على المذهب المالكي، الحاجة كوكب عبيد، مطبعة الإنشاء، ط ١، ت: ١٤٠٦ هـ – ١٩٨٦ م، دمشق – سوريا، ص: ١٣١.

(٤) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مرجع سابق، ج ١، ص: ٣٩١.

(٥) المدخل، مرجع سابق، ج ٢، ص: ٣١٧.

(٦) قانون الأحوال الشخصية الصومالي، لجمهورية الصومال الديمقراطية، بدون الناشر، والطبعة، الصادر في ١١ يناير ١٩٧٥، م، وبدون مكان النشر، م:٦٣.

أن يكون لولي أمر الصغير أو متولي الرقابة عليه حق تقويمه وتأديبه إذا ما ارتكب ذنبا يستحق العقاب عليه، وينصرف هذا التأديب في الأصل إلى الأبناء والبنات [١].

وقد عبر قانون الأحوال الشخصية الصومالي عن التأديب بكلمة الحضانة، وتربية الأولاد وتأديبهم وحضانتهم حق واجب على الأولياء، حيث نص على أنه: "يقصد بحضانة الولد تربيته تربية حسنة، وتعليمه، والعناية بشأنه الخلقية بما لا يعارض مع الحقوق الخاصة بوليه"[٢].

فحكم تأديب الصغار يكون واجبا على الأولياء، فإن الصغير محتاج إلى التأديب إذا كان ذلك هو السبيل الأمثل للتعليم والتهذيب، ومعلوم أن الأب قد لا يستطيع القيام بواجبه هذا إلا بالضرب، ونحوه، فيكون واجبا [٣].

ثانيا: علة إباحة هذا الحق:

أباح معظم القوانين هذا الحق نتيجة طبيعية لانتظام المجتمع الإنساني في شكل أسر، وهو ينطوي على فكرتي: السلطة والمسئولية في ذات الوقت، فهو لم يشرع لمصلحة من يستعمله، ولكن لمصلحة الخاضع له؛ لأنه ضروري لممارسة الرقابة على الصغير، فالصغار إن صحت تربيتهم وتقويمهم أصبحوا مواطنين صالحين لمجتمعاتهم [٤].

الفرع الثاني: شروط تأديب الصغار:

لم ينص قانون الأحوال الشخصية الصومالي شروط تأديب الصغار رغم بيانه حكم هذا التأديب، ولكن يمكن أن تؤخذ هذه الشروط، مما نص عليه قانون الأحوال الشخصية الصومالي من أنه: "يقصد بحضانة الولد تربيته تربية حسنة، وتعليمه، والعناية بشأنه الخلقية بما لا يعارض مع الحقوق الخاصة بوليه" [٥].

يتضح من هذه المادة أن هذا التأديب مشروط بعدة شروط، فيباح حق تأديب الصغار للولي بشروط:

١. أن يكون المؤدب أبا ثم لولي النفس مطلقا [٦].

---

(١) شرح قانون العقوبات اليمني، مرجع سابق، ص: ٢٣٩.

(٢) قانون الأحوال الشخصية الصومالي، مرجع سابق، م:٦٣.

(٣) قانون الجرائم والعقوبات، مرجع سابق، ص: ١٨٦

(٤) شرح قانون العقوبات اليمني، مرجع سابق، ص: ٢٣٩.

(٥) قانون الأحوال الشخصية الصومالي، مرجع سابق، م:٦٣.

(٦) شرح قانون العقوبات اليمني، مرجع سابق، ص: ٢٣٩.

٢. أن يكون ذلك للتأديب أو التعليم، فإن ابتغيت به غاية أخرى كالإهانة مثلا فلا مجال للإباحة [١].

٣. أن تكون الوسيلة التي تستخدم لاستعمال ذلك الحق مناسبا ومقدورا بالنسبة للصغير، بأن لا يكون فيه كسر عظم أو إراقة دم أو تغيير لون [٢].

فعلى أية حال إن قانون الأحوال الشخصية الصومالي ذكر أن تأديب الصغار وتربيتهم حق لهم على الأولياء، ولكنه لم ينص شروطا لهذا الحق، ومن ثم يجب ردها إلى المذهب الشافعي، وإلى المبادئ العامة في الفقه الإسلامي، والعدالة الاجتماعية؛ لأن قانون الأحوال الشخصية الصومالي نص على أنه: "وفي حالة عدم وجود نص معين تطبق الآراء الراجحة في مذهب الإمام الشافعي، ثم المبادئ العامة للشريعة الإسلامية، والعدالة الاجتماعية" [٣].

فعلى ذلك فإن جميع ما يتعلق بأحكام تأديب الصغير وكذا الزوجة مما لم يرد فيه نص يخصه يجب الرجوع إلى المذهب الشافعي، وإلى غير ذلك مما تقدم في هذا النص.

فما مدى موافقة القانون ومخالفته للفقه الإسلامي في استعمال حق تأديب الصغار

تبين مما سبق أنه لا مخالفة بين القانون والفقه الإسلامي، سواء في كان حكم تأديب الصغار، وعلته، والشروط التي ينبغي مراعاتها في سبيل التأديب.

---

(١) شرح قانون العقوبات، الألفي، مرجع سابق، ص: ١٨٥.

(٢) شرح قانون العقوبات اليمني، مرجع سابق، ص: ٢٣٩.

(٣) قانون الأحوال الشخصية الصومالي، مرجع سابق، م: ١.

المبحث الثاني: استعمال حق الأعمال الطبية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي

تمهيد: الكلام على استعمال حق الأعمال الطبية يستوجب أولا بيان ما هي الأعمال الطبية؛ لأنه لا يمكن تفصيل أحكام الشيء إلا بعد التعرف على ماهيته، ثم الحكم عليه، وبعد ذلك يأتي الكلام على الشروط وما يتعلق به من أحكام.

وبناء على ذلك فإن الأعمال الطبية هي: مجموعة من نشاط يتفق في كيفيته وأصول مباشرته مع القواعد المقررة في علم الطب، ويهدف إلى شفاء المريض.

وقد أباح الشارع ممارسة الأعمال الطبية، وجعل سببا من أسباب الإباحة للجريمة، ولا تكون على الطبيب مسئولية جنائية، فضلا من أن تكون عليه مسئولية مدنية، فلا يسأل الطبيب عن الأفعال التي يأتيها أثناء ممارسته لمهنة التطبيب، طالما توافرت في فعله الشروط التي يقررها الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الصومالي والقوانين الأخرى.

وعلى ذلك سيأتي الكلام على حكم ممارسة الأعمال الطبية في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون العقوبات الصومالي في مطلبين، ثم الكلام على شروط تلك الممارسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الصومالي في مطلبين آخرين.

المطلب الأول: ممارسة حق الأعمال الطبية في الفقه الإسلامي.

الفرع الأول: الأعمال الطبية ومشروعية التداوي

ممارسة الأعمال الطبية حق من الحقوق المقررة للطبيب، فهو من المواضع المهمة لهذا البحث، وبالتالي يكون ترتيبه كالآتي:

أولا: الأعمال الطبية:

فالأعمال الطبية هي: مجموعة من نشاط يتفق في كيفيته وأصول مباشرته مع القواعد المقررة في علم الطب ويهدف إلى شفاء المريض, والأصل في العمل الطبي أن يكون علاجيا أي يهدف إلى تخليص الشخص من مرضه أو تخفيف حدته أو تخفيف آلامه , ولكن الفقه يميل إلى اعتبار الممارسات التي ترمي إلى الكشف عن أسباب المرض أو الوقاية منه وكل نشاط أو وسيلة تتصل بالعمل الطبي كاستخدام الكهرباء والأشعة من الأعمال الطبية [١].

فاتضح أن ممارسة الأعمال الطبية هي مزاولتها وفقا للأصول والقواعد المقررة في علم الطب.

---

(١) أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، مكتبة الصحابة، ط ٢، ت: ١٤١٥ هـ – ١٩٩٤ م، جدة – المملكة العربية السعودية، ص: ٢١١.

ثم إن علم الطب فن مشهور في الفقه الإسلامي، فإنه من فروض الكفاية، وهو المحتاج إليه لمعالجة الأبدان[١]، وهو الذي يسمى بعلم الأبدان، فهو واجب على كل شخص، فلا يسقط عنه إلا إذا قام به غيره، فالقيام بالتطبيب يعتبر واجبا على الطبيب ما لم يوجد أحد يقوم بذلك بدلا عنه، ويترتب على هذا أن الأعمال الطبية من أسباب الإباحة [٢].

ثانيا: مشروعية التداوي، وفيه قولان:

القول الأول: للجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو أن التداوي مشروع، فيجوز إذا لم يقدر على الصبر [٣]، والدليل على ذلك:

١. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً)) [٤]، فلما أنزل الله سبحانه وتعالى المرض والداء، بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه عز وجل أنزل طبا ودواء، وهذا يدل على جواز التداوي.

٢. قوله صلى الله عليه وسلم: ((لكل داء دواءٌ، فإذا أُصيبَ دواءُ الداء، برأ بإذن الله))[٥].

٣. حديث أسامة بن شريك –رضي الله عنه–، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه عنده كأنما على رءوسهم الطير، قال: فسلمت عليه، وقعدت، قال: فجاءت الأعراب، فسألوه فقالوا: يا رسول الله، نتداوى؟ قال: ((نعم، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم)) [٦].

---

(١) تحفة المحتاج في شرح المنهاج، مرجع سابق، ج٩، ص: ٢١٤.

(٢) المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مرجع سابق، ص:١٩٧.

(٣) الهداية في شرح بداية المبتدي، مرجع سابق، ج ٤، ص: ٣٨١، وتحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي، بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز تاج الدين الدميري، تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب، وحافظ بن عبد الرحمن خير، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط ١، ت: ١٤٣٤ هـ – ٢٠١٣ م، بدون مكان النشر، ج ١، ص: ٣٢٧، والمبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين، دار الكتب العلمية، ط ١، ت: ١٤١٨ هـ – ١٩٩٧ م، بيروت – لبنان، ج ٢، ص: ٢١٧.

(٤) أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، ورقم الحديث: (٥٦٧٨)، عن أبي هريرة –رضي الله عنه–، ج٧، ص: ١٢٢.

(٥) أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب السلام، ورقم الحديث: (٢٢٠٤)، عن جابر، ج ٤، ص: ١٧٢٩.

(٦) أخرجه الإمام أحمد، في مسنده، مسند الكوفيين، حديث أسامة بن شريك، ورقم الحديث: (١٨٤٥٣)، ج ٣٠، ص: ٣٩٥، وفي الصفحة نفسها قال شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأما إذا كان المريض قادرا على الصبر فالتفويض أفضل له؛ لما يلي:

١. أن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس –رضي الله عنهما– ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى، قال: هذه المرأة السوداء، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع، وإني أتكشف، فادع الله لي، قال: ((إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك)) فقالت: أصبر، فقالت: إني أتكشف، فادع الله لي أن لا أتكشف، فدعا لها. (١).

٢. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب، هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون))(٢).

وجه دلالة الحديثن هو: أن الصبر على قضاء الله والتوكل عليه في كل حالات الشخص أفضل، ومنها: ترك التداوي توكلا على الله، فهذا مما يورث دخول الجنة بغير حساب في يوم الآخرة.

القول الثاني: للشافعية (٣)، وهو أنه مستحب، لحمل الأحاديث المارة الدالة على الندب.

الفرع الثاني: حكم ممارسة الأعمال الطبية:

ممارسة الأعمال الطبية تعتبر مشروعا ومباحا، وسببا من أسباب الإباحة للجريمة، ولذلك لا يسأل الطبيب مسئولية جنائية فضلا عن مسئولية مدنية عن الأفعال التي يأتي بها الطبيب أثناء ممارسته لمهنة التطبيب، طالما توافرت في فعله الشروط الآتية التي يقررها الفقه الإسلامي.

فالطب علم نظري وعملي أباح الفقه الإسلامي تعلمه؛ لما فيه من حفظ الصحة ودفع العلل والأمراض عن هذه البنية الشريفة (٤).

---

(١) أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب المرضى، باب فضل من يصرع من الريح، رقم الحديث: (٥٦٥٢) ، ج٧، ص: ١١٦.

(٢) أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب اللباس، باب البرود والحبرة والشملة، رقم الحديث: (٥٨١١)، ج ٧، ص: ١٤٦، و مسلم، في صحيحه، كتاب الإيمان، رقم الحديث: (٢١٨)، كلاهما عن أبي هريرة –رضي الله عنه–، ج ١، ص: ١٩٨.

(٣) منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، مرجع سابق، ص: ٦١.

(٤) معالم القربة في طلب الحسبة، محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخوة، ضياء الدين، القرشي، دار الفنون «كمبردج»، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر، ص: ١٦٥.

فعلى كل حال إن الأدلة الشرعية من الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل دلّت على جواز ممارسة الأعمال الطبية، وأنه لا حرج على المسلم في سعيه لدفع ضرر الأمراض البدنية [١]، ومن تلك الأدلة:

١. قوله تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [٢].

وجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى امتدح من سعى في إحياء النفس وإنقاذها من الهلاك، ومعلوم أن الجراحة الطبية تنتظم في كثير من صورها إنقاذ النفس المحرمة من الهلاك المحقق[٣].

٢. حديث جابر بن عبد الله –رضي الله عنهما– قال: ((بعث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى أبي بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه عليه)) [٤].

وجه الدلالة أن النبي –صلى الله عليه وسلم– أقر الطبيب على قطعه للعرق وكيّه، وقطع العروق ضرب من العلاج الجراحي، وهو مستخدم في الجراحة الطبية الحديثة، حيث يتم قطع مواضع من العروق في حال انسدادها أو وجود آفة تستدعي قطع جزء منها[٥].

المطلب الثاني: ممارسة حق الأعمال الطبية في القانون

الفرع الأول: حكم ممارسة الأعمال الطبية

ممارسة الأعمال الطبية تعني: التعرض لجسم المريض بعمليات جراحية، كما تستلزم إحراز مواد مخدرة لاستخدامها في العلاج أو في تسكين الآلام، فكل من هذه الأفعال تدخل ضمن الجرائم الجراحية وإحراز مواد مخدرة[٦].

وهذه الممارسة الطبية يعتبرها قانون العقوبات سببا من أسباب الإباحة، ولا يكون الطبيب مسئولا جنائيا، ولكن لا يوجد مبرر لما يصدر عن الطبيب من أعمال غير داخلة في هذه الأعمال، كأن يضرب المريض أو يوجه إليه عبارات السب والقذف، بل يعتبر فعله جريمة، يسأل عنها.

---

(١) الأحكام الجراحة، مرجع سابق، ص: ٨٤.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٣٢.

(٣) أحكام الجراحة الطبية، مرجع سابق، ص: ٨٥.

(٤) أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب السلام، رقم الحديث: (٢٢٠٧)، ج ٤، ص: ١٧٣٠.

(٥) الأحكام الجراحة الطبية، مرجع سابق، ص: ٨٨.

(٦) شرح قانون العقوبات، الألفي، مرجع سابق، ص: ١٨٩.

ولم يجد الباحث نصا صريحا في بيان حكم ممارسة الأعمال الطبية في قانون العقوبات الصومالي، ولكنه يتضمنه باعتباره صورة من صور استعمال الحق، وإذا كان كذلك فقد يستنبط حكم ممارسة الأعمال الطبية من النصوص العامة في قانون العقوبات الصومالي، حيث نص على أن:

١. كل من تسبب في موت آخر بإهماله الناشئ عن خطئه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور، ولا تتجاوز خمس سنوات [١].

ونص أيضا على أن: ١. "كل من تسبب في إصابة آخر نتيجة إهمال ناشئ عن خطئه يعاقب بالحبس مدة أقصاها ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف من الشلنات الصومالية [٢].

فالإهمال الناشئ عن الخطأ شامل في كل الأخطاء بما فيه الأخطاء الطبية، وعلى هذا فإن الطبيب لو نسي الآلات الجراحية مثلا في داخل المريض، فخاطه فيه فإنه يسأل عن كل ما يترتب على هذا.

الفرع الثاني: الأساس القانوني لإباحة الأعمال الطبية:

تحديد الأساس القانوني لإباحة الأعمال الطبية يمكن إرجاعها إلى أحد أسس لا تخرج عنها، وهي ثلاثة:

الأول: أن أساس الإباحة مبني على رضا المريض بالعمل الطبي، فالعمل الطبي يفرض أولا رضا المريض بتدخل الطبيب بالعلاج.

الثاني: أن أساس الإباحة مبني على انتفاء القصد الجنائي لدى الطبيب؛ لأن إرادة الطبيب لم تتجه إلى الأضرار بصحة المريض أو إيقاع الأذى به، وإنما اتجهت إلى شفائه أو تخفيف آلامه[٣].

الثالث: أن الإباحة تستند إلى ترخيص القانون، وهو الأقوى مدركا، فالمشرع يعترف بمهنة الطب، وينظم كيفية مباشرتها، وهو يسمح بكل الأعمال الضرورية أو الملائمة لمباشرتها، فمرجع الإباحة هو إرادة الشارع للأطباء بالتعرض لأجسام الغير أو إجراء عمليات جراحية عليه، مهما بلغت جسامتها [٤].

وينبغي الانتباه هنا إلى أن قانون العقوبات الصومالي لم يتطرق إلى الأساس القانوني لإباحة الأعمال الطبية مطلقا، سواء كان في الحكم أو في الشرط أو غير ذلك.

---

(١) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م:٤٤٥، ف (١).

(٢) المرجع السابق، م:٤٤٦. ف (١).

(٣) شرح قانون العقوبات اليمني، مرجع سابق، ص: ٢٤٧-٢٤٨.

(٤) شرح قانون العقوبات، الألفي، مرجع سابق، ص: ١٨٦.

فما مدى موافقة القانون على الفقه الإسلامي في استعمال حق الأعمال الطبية

لا يظهر للباحث في ممارسة حق الأعمال الطبية مخالفة القانون للفقه الإسلامي، فإنه لا مخالفة بينهما فيما تقدم من ممارسة حق الأعمال الطبية.

المطلب الثالث: شروط ممارسة حق الأعمال الطبية في الفقه الإسلامي

فالإنسان له ذات تقبل الأعراض، ومن تلك الأعراض الصحة والمرض، فإذا مرض يحتاج إلى علاج، فما دام أن الله عز وجل كرم الإنسان، وجعل محل حماية ينبغي التداوي، فهنا يأتي دور الطبيب، فإنه قد لا يمكن للمريض في كثير من الأحوال أن يعالج نفسه، فلهذا يكون للطبيب حق في مباشرة جسم الإنسان بعلاج لا يعرفه غيره، فإنه لا بد في هذا الجانب من الوقاية مما يمكن أن يفسد مصلحة الصحة، فإن الوقاية أولى من العلاج، ولذلك لو استعمل حقه المخول له، من حيث أن الفقه الإسلامي أباح للطبيب ممارسة حق الأعمال الطبية سواء كانت جراحية أو غيرها فهذا الحق مقيد بشروط، حتى لا تحصل جرءة على الإنسان الكريم الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ﴾ (١)، وكذلك قد حصل ذلك بالفعل في عصر النبوة، ومما يدل على ذلك:

١. أن عليّاً –رضي الله عنه– خطب على الناس، فقال «يا معشر الأطباء البياطرة(٢)، والمتطببين من عالج منكم إنسانا، أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة، فإن كان عالج شيئا، ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن» (٣).

ويفهم من هذا الأثر أن خطاب علي –رضي الله عنه– يدل على وجود أطباء يمارسون الأعمال الطبية، فهو مشروع، وكذلك توصيته ببعض من آداب الطبيب منها: أخذ البراءة من المريض التي تدل على المشروعية أيضا، وإلا لما سكت عن باطل.

---

(١) سورة الإسراء، الآية: ٧٠.

(٢) وهو جمع بيطار، ويجمع أيضا على بياطر وبياطير، وهو مشتق من بيطر الدابة: إذا عالجها. معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ج ١، ص: ٢٧٢.

(٣) أخرجه عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الحميري اليماني الصنعاني، في المصنف، كتاب العقول، باب الطبيب، برقم: (٢٢٠٧)، عن الضحاك بن مزاحم تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، ط٢، ت: ١٤٠٣هـ– الهند، ج ٩، ص: ٤٧٠، وهذا الأثر ضعيف بهذا الإسناد؛ لأن رجاله منهم من اتفق على ضعفه، وهما: يحيى بن العلاء، وجويبر بن سعيد، ومنهم من اختلف فيه، وهو: الضحاك بن مزاحم، ولكن قال يحيى بن سعيد القطان: تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث، ثم ذكر ليث بن السائب، وقال: هؤلاء لا يحمد حديثهم: أبي سليم، وجويبر، والضحاك، ومحمد، ويكتب التفسير عنهم، ينظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد بن أحمد بين عثمان أبو عبد الله شمس الدين الذهبي، تحقيق: محمد رضوان عرقسوسي، وعمار ريحاوي، وغياث الحاج أحمد، وفادي المغربي، الرسالة العالمية، ط ١، ت: ١٤٣٠ هـ – ٢٠٠٩ م، دمشق – سورية، ج ١، ص: ٣٩١ –٣٩٢، ج ٢، ص: ٢٩٢، ج ٥، ص: ١٣٤.

وأكثر من ذلك أنه علّم وجه براءتهم من الضمان، وأخبر أن أخذ البراءة من المريض لاسيما عند العلاجات الدقيقة والعمليات الجراحية، التي لا مفر منها، والتي يحتمل فيها تعرض المريض لخطر الموت، أو خطر الإصابات البالغة يحمي الطبيب من التفاعلات التي تحصل لو حدث فيما بعد أي أمر غير محمود كتعرض المريض للموت أو للإعاقة –لا سمح الله– إلى غير ذلك.

٢. الأحاديث السابقة في مشروعية التطبيب.

وبناء على ذلك فإن الفقه الإسلامي استنبط شروطا في رفع المسئولية الجنائية من هذه الأدلة وغيرها، ويمكن إجمالها فيما يلي:

١. أن يكون الفاعل طبيباً.
٢. أن يأتي الفعل بقصد العلاج وبحسن نية.
٣. أن يعمل طبقاً للأصول الطبية.
٤. أن يأذن له المريض أو من يقوم مقامه كالولي.

وتفصيل هذه الشروط كالتالي:

الشرط الأول: كون الفاعل معروفا بعلم الطب، فيشترط في انتفاء المسئولية الجنائية عن الطبيب أن يكون عارفا بأصول وقواعد علم الطب المتعارف عليها، فإذا مارس مهنة الطب ولم يكن عارفا، فهو ضامن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من تطبب، ولا يعلم منه طب، فهو ضامن»(١).

هذا الحديث يدل بلفظه وفحواه على: أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو لا يحسنها، سواء كان طبا أو غيره، وأن من تجرأ على ذلك، فهو آثم، وما ترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهما، فهو ضامن له، وما أخذه من المال في مقابلة تلك الصناعة التي لا يحسنها يجب رده على من أعطاه؛ لأنه لم يبذله إلا بما ظهر من الطبيب من تغريره وإيهامه أنه يحسن، وهو لا يحسن، فيدخل في الغش(٢)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « ومن غشنا فليس منا» (٣).

---

(١) أخرجه أبو داود، في سننه، كتاب الديات، باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت، رقم الحديث: (٤٥٨٦)، عن عبد الله بن عمرو، ج ٦، ص: ٦٤٣، وقال محمد بن مفلح: وهو حديث حسن، ينظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي، عالم الكتب، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر، ج ٢، ص: ٤٥٢.

(٢) بهجة قلوب الأبرار، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله أبو عبد الله، آل سعدي، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط ٤، ت: ١٤٢٣ هـ، المملكة العربية السعودية، ص: ١١٧.

(٣) أخرجه مسلم،في صحيحه، كتاب الإيمان، رقم الحديث: (١٠١)، عن أبي هريرة –رضي الله عنه–، ج ١، ص: ٩٩.

فيشترط كون الأطباء ذوي حذق في صناعتهم، ولهم بها بَصَارةٌ، ومعرفة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحلّ له مباشرة القطع، وإذا قطع مع هَذَا كَانَ فعلاً محرمًا، فيضمن سرايته، كالقطع ابتداء [١].

الشرط الثاني: أن يأتي الفعل بقصد العلاج وبحسن نية،لأن المطلوب منه قصده نفع العليل أو رجاء ذلك، لا أن يقصد ضرراء وأما لو قصد ضرره، فإنه يقتص منه، والأصل: عدم العداء إن ادعى عليه ذلك [٢].

الشرط الثالث: أن يعمل طبقاً للأصول الطبية، فإن تجاوز بغير اختياره الحد المعلوم في الطب عند أهل المعرفة كأن زلت يد طبيب أو سقى عليلًا دواء غير مناسب للداء معتقدًا أنه يناسبه، وقد أخطأ في اعتقاده فيضمن ما ذكر في ماله؛ لأنه عمد، ولا قصاص فيه [٣].

الشرط الرابع: أن يأذن له المريض أو من يقوم مقامه كالولي، ولو كان بلا إذن أصلا أو بإذن غير معتبر شرعا كأن داوى صبيا بإذنه فإنه يضمن [٤].

ثم إنه نقل الخطابي(*) اتفق الفقهاء على أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه معتد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقله [٥].

---

(١) ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلّوي، دار آل بروم، ط.١، ت: ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٣ م، بدون مكان النشر، ج ٣٦، ص: ٢٥٢، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج ٤، ص: ٣٥٥.

(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤، ص: ٣٥٥.

(٣) معالم القربة في طلب الحسبة، مرجع سابق، ص: ١٦٦.

(٤) مختصر العلامة خليل، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري، تحقيق: أحمد جاد، دار الحديث، ط.١، ت: ١٤٢٦ هـ – ٢٠٠٥ م، القاهرة–مصر، ص: ٢٤٦.

(*) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب أبو سليمان البستيّ: فقيه محدّث، من أهل بست (من بلاد كابل) من نسل زيد بن الخطاب (أخي عمر بن الخطاب)، معالم السنن، في شرح سنن أبي داود، و بيان إعجاز القرآن، وغيرهما، توفي في بست (في رباط على شاطئ هيرمند)، بنظر: الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، دار العلم للملايين، ط ١٥، ت: أيار / مايو ٢٠٠٢ م، بدون مكان النشر، ج ٢، ص: ٢٧٣–

(٥) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، دار الحديث – القاهرة، بدون الطبعة، ت: ١٤٢٥هـ – ٢٠٠٤ م، وبدون مكان النشر، ج ٤، ص: ٢٠٠، والعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، مرجع سابق، ج ١١، ص: ٣٠١، و حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، مرجع سابق، ج ٥، ص: ٣٣٩، و الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، عمر بن إسحق بن أحمد أبو حفص سراج الدين، الهندي الغزنوي، الحنفي، مؤسسة الكتب الثقافية، ط ١، ت: ١٤٠٦هـ–١٩٨٦ مـ، بدون مكان النشر، ص: ١٠٠.

وخلاصة القول:

إن الطبيب هو العارف بتركيب البدن ومزاج الأعضاء والأمراض الحادثة فيها وأسبابها وأعراضها وعلامتها والأدوية النافعة فيها والاعتياض عما لم يوجد منها والوجه في استخراجها وطريق مداواتها بالتساوي بين الأمراض والأدوية في كمياتها ويخالف بينها وبين كيفياتها، فمن لم يكن كذلك فلا يجعل له مداواة المرضا، ولا يجوز له الإقدام على علاج يخاطر فيه، ولا يتعرض لما لا علم له فيه [١].

المطلب الرابع: شروط ممارسة حق الأعمال الطبية في القانون

لم يتطرق قانون العقوبات الصومالي إلى ما يتعلق بشروط ممارسة الأعمال الطبية، ولم يجد الباحث نصا من نصوص قانون العقوبات الصومالي فيما يخص بشروط ممارسة الأعمال الطبية، ولذلك ينبغي للمشرع الصومالي أن يقوم بوضع مواد تخص بهذا الموضوع؛ لما فيه من أهمية اجتماعية، ولكن أشار إلى تلك الشروط معظم قوانين العقوبات في الدول الإسلامية ، ويمكن الاقتباس منها على ما يلي:

وقد استقر الفقه والقضاء على أساس أن القانون يرخص بمباشرة مهنة الطب، ويلتزم من ذلك حتما الاعتراف بحق كل من رخص له بمزاولتها بإتيان مختلف صور السلوك الملائم والضروري للقيام بها [٢].

فيشترط لإباحة ممارسة الأعمال الطبية شروط يمكن إجمالها في خمسة:

الشرط الأول: صفة الطبيب، تعني: كون من قام بالتطبيب طبيبا، أي معروفا له بممارسة الأعمال الطبية، وصفة الطبيب تتوافر إذا كان الشخص يحمل شهادة من جهة معترف بها بأنه طبيب، كالشهادة التي يحملها المتخرجون من الكليات الطبية، كما أن صفة الطبيب تتوافر إذا كان الشخص لا يحمل مثل تلك الشهادة، ولكنه معروف بمقدرته على ممارسة أعمال الطب، وهذا ينطبق على الأشخاص الذين يقومون بأعمال المداواة دون أن يدرسوا دراسة علمية حديثة، وذلك كالختانين والمجبرين والموسمين والمداوين بالأعشاب وأمثالهم، وهؤلاء كلهم في حكم الأطباء [٣].

الشرط الثاني: الترخيص القانوني

يشترط لعدم المسئولية الجنائية عن الطبيب أن يكون له ترخيص بالعلاج، فلا تنتفي المسئولية الجنائية عنه إلا إذا كان مرخصا له بمزاولة مهنة الطب [٤].

---

(١) معالم القربة في طلب الحسبة، مرجع سابق، ص: ١٦٦.

(٢) شرح قانون العقوبات، الألفي، مرجع سابق، ص: ١٨٧.

(٣) شرح قانون الجرائم والعقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص: ١٨٩.

(٤) شرح قانون العقوبات، الألفي، مرجع سابق، ص: ١٨٨.

فالترخيص هو الإذن الرسمي من السلطة المختصة (وزارة الصحة)، وهذا الإذن شرط لازم لكل طبيب، سواء كانت عنده شهادة علمية، أو كان عند الطبيب شهرة بهذه الممارسة الطبية عن طريق الخبرة [١].

ثم ينبغي الانتباه إلى أن الترخيص نوعان: ترخيص عام، وترخيص خاص.

فأما الترخيص العام هو الترخيص بمباشرة جميع الأعمال الطبية، وأما الترخيص الخاص هو عكس الترخيص العام فهو يقتصر على بعض صور الممارسات الطبية [٢].

الشرط الثالث: رضا المريض

فرضا المريض هو أحد الشروط الخاصة لممارسة الأعمال الطبية، فممارسة الأعمال الطبية حق للطبيب، بشرط أن يكون المريض راضيا بها [٣].

قد يكون صريحا، وقد يكون ضمنا، والرضاء أمر لا يمكن التخطي عنه؛ لأن الأعمال الطبية متنوعة، قد يرضا المريض ببعضها، ولا يرضا بالبعض الآخر، ولذلك لا بد من الحصول على موافقته؛ لأن بعض أنواع العلاج يترتب عليه نتائج خطيرة [٤].

وأيضا قد يصدر الرضا من المريض نفسه، أو من ينصبه القانون ممثلا له أو وليا عليه، وقد يكون ممثل المريض هو ولي النفس إذا كان صغيرا أو كانت إرادته غير معتبرة قانونا، وقد يكون الممثل وكيله (صراحة أو ضمنا)، وفي حالة ما إذا لم يمكنه التعبير عن إرادته ولم يكن له من يمثله يفترض الرضا في هذه الحالة، وأساس هذا الافتراض هو: أن التخلص من المرض أو إنقاذ الحياة أمر طبيعي عند كل شخص[٥].

فإذا لم يوجد إذن معتبر، بأن رفض المريض العلاج فليس للطبيب أن يقوم به، وإلا كان مسئولا وفقا للقواعد العامة، وبالرغم من تخلف شرط الرضا يكون عمل الطبيب مشروعا مع تلك الحالة، بشرط إذا توفرت شروط حالة الضرورة، بأن كان خطر جسيم حال يهدد المريض، ويقتضي السرعة في العلاج، ولم يمكن للمريض أن يعبر عن رضاه وإرادته، ولم يكن هناك من يرضى أن يكون بدلا عنه [٦].

---

(١) قانون الجرائم والعقوبات، ص: ١٨٩.

(٢) المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية، والقوانين الوضعية، مرجع سابق، ص:١٩٩.

(٣) شرح قانون العقوبات اليمني، مرجع سابق، ص: ٢٥٠.

(٤) شرح قانون العقوبات، الألفي، مرجع سابق، ص: ١٩١.

(٥) شرح قانون العقوبات اليمني، مرجع سابق، ص: ٢٥١.

(٦) شرح قانون العقوبات، الألفي، مرجع سابق، ص: ١٩١ –١٩٢.

الشرط الرابع: قصد العلاج

فالقصد هو شيء خفي لا يمكن إدراكه إلا عن طريق تتبع الملابسات مثلا، فهو معنوي، ومعلوم أن الأصل في الطبيب أنه حسن النية، فمن يدعي عكس ذلك فعليه دليل يثبت ذلك [١].

يجب أن يهدف الطبيب من عمله شفاء الأمراض أو تخفيف حدتها، فإذا سعى الطبيب إلى غاية أخرى كأن يقصد كشف العورات أو مجرد تجربة فإن الطبيب لا يكون في حالة إباحة، فبهذا تتحقق الحكمة من إباحة عمليات التطبيب والجراحة [٢].

الشرط الخامس: اتباع الأصول الطبية:

لكل مهنة أصول وقواعد يلتزم لها العاملون بهذه المهنة من حيث مراعاة تلك القواعد والأصول، وإلا اعتبروا مرتكبين خطأ مهنيا.

وعلى ذلك يشترط في إباحة ممارسة حق العمل الطبية اتباع الطبيب الأصول الطبية وقواعدها، فهذا الشرط هو أشد الشروط المتقدمة، وأكثرها إثارة للمشاكل؛ لأن الطبيب إنسان، والإنسان يخطئ أو يقصر في اتباع أساليب الحذر، وعندئذ لا بد أن يسأل مسئولية جنائية طبية إذا حصلت للمريض نتائج ضارة، وإلا فلا مسئولية عليه؛ لأنه لا يجب عليه إلا بذل العناية [٣].

فما مدى موافقة القانون للفقه الإسلامي في شروط ممارسة الأعمال الطبية

يبدو أنه لا مخالفة بين القانون والفقه الإسلامي في شروط ممارسة الأعمال الطبية، من حيث توفر شروط المسئولية الجنائية وعدمها إجمالا، وقد يكون اختلاف بسيط في بعض الأماكن.

---

(١) قانون الجرائم والعقوبات، مرجع سابق، ص: ١٩٠.

(٢) شرح قانون العقوبات، الألفي، مرجع سابق، ص: ١٨٦.

(٣) قانون الجرائم والعقوبات، مرجع سابق، ص: ١٩١.

المبحث الثالث: الدفاع الشرعي الخاص (دفع الصائل) وشروطه في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي:

تمهيد: هذا الموضوع بحث عنه الفقهاء قديما وحديثا، مطلقا، أي: سواء كان في داخل موضوعات أخرى أو مستقلا، ولكن الفقهاء اختلفوا فيما يعبر عنه، فالقدماء كانوا يعبرون عن هذا الموضوع بدفع الصائل، والمتأخرون يعبرون عنه بالدفاع الشرعي الخاص، فأيا كانت العبارة عنه فإن المضمون واحد، والدفاع الشرعي الخاص هو: عبارة عن: واجب للإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء.

والدفاع الشرعي الخاص أو ما يسميه الفقهاء قديما بدفع الصائل مشروع للحماية، باتفاق فقهاء الفقه الإسلامي الغراء، وبين فقهاء القانون.

ففيما يلي سيأتي الكلام على معنى الدفاع الشرعي الخاص (دفع الصائل)، والكلام أيضا على الدفاع الشرعي من حيث أحكامه وشروطه وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على المطالب الآتية إن شاء الله:

المطلب الأول: معنى الدفاع الشرعي الخاص(دفع الصائل) في الفقه الإسلامي.

اصطلاح الدفاع الشرعي اصطلاح حادث يستخدمها أصحاب القانون والمتأخرون من فقهاء الإسلام، ويسميه المتقدمون من فقهاء الفقه الإسلامي بدفع الصائل.

وبناء على ذلك ينبغي أولا البحث عن تعريف مصطلح دفع الصائل، ومصطلح الدفاع الشرعي الخاص، وثانيا المعنى العام لكلا المصطلحين:

أولا: تعريف مصطلح دفع الصائل، ومصطلح الدفاع الشرعي الخاص:

تعريف مصطلح "دفع الصائل"

الدفع في اللغة هو: الإزالة بقوة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ﴾[١]، ومن كلامهم: ادفع الشر ولو إصبعا [٢]، فالصائل اسم فاعل من الصيال والصيالة ومعناه: الوثوب[٣]، والمصاولة المواثبة، إذا فالصائل هو: القاصد الوثوب عليه، يقال: صال عليه: وثب [٤].

---

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٥١.

(٢) تاج العروس من جواهر القاموس، مرجع سابق، ج٢٠، ص: ٥٥٣.

(٣) معجم لغة الفقهاء، مرجع سابق، ص: ٢٦٩.

(٤) المطلع على ألفاظ المقنع، مرجع سابق، ص: ٢١١.

وأما معنى دفع الصائل اصطلاحا فهو: الاستطالة، والوثوب على الغير، وهذا التعريف لغوي وشرعي[١]، يعني: أنه لا فرق بين المعنيين، أي: معنى دفع الصائل في اللغة، ومعنى دفع الصائل اصطلاحا في الفقه الإسلامي.

تعريف مصطلح الدفاع الشرعي الخاص.

تعريف مصطلح الدفاع الشرعي الخاص يتكون هذا المصطلح من ثلاث كلمات من حيث اللغة:

١. الدفاع، هو والدفع معنى واحد، هو: الإزالة بقوة [٢].

٢. الشرعي: وهو منسوب إلى الشرع، وهو مصدر شرع شرعًا وشروعًا [٣]، والشريعة: المواضع التي يُنْحَدر إلى الماء منها [٤].وبها سمي ما شرع الله للعباد شريعة من الصوم والصلاة والحج والنكاح وغيره[٥].

٣. الخاص، أما معناه لغة فهو من خصه بالشيء يخصه خصا وخصوصية إذا فضله به وخصه بالود كذلك، وخصان الرجل: من يختصه من إخوانه [٦].

وأما اصطلاحا فهو: الذي لا يتصف بالعموم، فيتناول واحدا فحسب [٧].

ويفيد تقييد الدفاع الشرعي بكونه خاصا احترازا عن الدفاع الشرعي العام، الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه ليس محل بحث لهذا الموضوع، فهلا تمسكوا بعبارة الفقهاء الآباء؛ لأنهم أدق عبارة، وأقصر مما أحدثوه

ثانيا المعنى العام لكلا المصطلحين:

رغم اختلاف العبارات لا فرق بين المعنيين من حيث المضمون، كما أنه لا فرق بين معنى دفع الصائل في اللغة، ومعنى دفع الصائل اصطلاحا في الفقه الإسلامي، فعلى كلا المصطلحين

---

(١) مختار الصحاح، مرجع سابق، ص: ١٨٠.

(٢) تاج العروس من جواهر القاموس، مرجع سابق، ج٢٠، ص: ٥٥٣.

(٣) لسان العرب، مرجع سابق،ج٨، ص: ١٧٥.

(٤) المحكم والمحيط الأعظم، مرجع سابق، ج١، ص: ٣٦٩.

(٥) لسان العرب، مرجع سابق، ج٨، ص: ١٧٥.

(٦) جمهرة اللغة، محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر الأزدي، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، ط١، ت:١٩٨٧م بيروت، ج١، ص: ١٠٥.

(٧) البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد أبو المعالي، ركن الدين، الجويني، الملقب بإمام الحرمين، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، ط١، ت: ١٤١٨ هـ – ١٩٩٧ م، بيروت – لبنان، ج ١، ص: ١٤٥.

يمكن وضع تعريف شامل لهما، وهو أن دفع الصائل أو الدفاع الشرعي الخاص هو: عبارة عن رد اعتداء الغير على دين الآخرين وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم وغيرها من الكليات الخمسة[١].

أثر الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي

يترتب على توافر حالة الدفاع الشرعي أمور، فمن أهمها:

١. إباحة الفعل وعدم الضمان، فإذا صال على معصوم فدافع المصول عليه على اعتداء الصائل، فلا ضمان عليه [٢].

٢. أن هذا الحق مع الإباحة وعدم الضمان يستعمله غير المدافع من كل من ساعده وساهمه في رد اعتداء الصائل الظالم [٣].

المطلب الثاني: معنى الدفاع الشرعي الخاص في القانون

ليس هناك فارق كبير بين تعريف الدفاع الشرعي الخاص في القانون وتعريف الدفاع الشرعي الخاص (دفع الصائل) في الفقه الإسلامي، ولكن ينبغي استعراض بعض التعريفات للدفاع الشرعي الخاص في القانون الوضعي، ويعرف الدفاع الشرعي بأنه:

حق تخوله المبادئ القانونية العامة للمدافع لاستعمال القوة اللازمة لدرء اعتداء غير مشروع يوشك أن يقع أو للحيلولة دون استمراره [٤]، أو هو: استعمال القوة اللازمة لصد خطر حال غير مشروع يهدد بالإيذاء حقا يحميه القانون [٥].

ثم إنه من المبادئ التي استقر عليها القانون عدم جواز أن يقتص الشخص لنفسه بنفسه، فأجمع علماء القانون على أنه لا يجوز للشخص الانتقام، وعللوا بذلك بأنه إذا أبيح لكل من يعتدى عليه أن يقتص لنفسه يسود في المجتمع الفوضى، ويترتب عليه عدم الأمن والاستقرار، ولذلك يوجب القانون التقاضي أمام القضاء والسلطة المختصة.

---

(١) الدفاع الشرعي الخاص (دفع الصائل)، مسفر رزق الله محمد الزحامي، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، المعهد العالي للعلوم الأمنية، بدون الطبعة، ت:١٤١٦هـ-١٩٩٦م، بدون مكان النشر، ص: ٢٧-٢٨.

(٢) الذخيرة، مرجع سابق، ج ١٢، ص: ٢٦٢، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج، مرجع سابق، ج٩، ص: ١٨٢.

(٣) روضة الطالبين وعمدة المفتين، مرجع سابق، ج١٠، ص: ١٨٦.

(٤) شرح قانون العقوبات، الألفي، مرجع سابق، ص:٢٠٤.

(٥) المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ٢١٣.

ولكن يستثنى من هذا الأصل العام ما يسمى بالدفاع الشرعي، فيجوز لكل من يعتدى عليه أن يعتدي على المعتدي مثل ما اعتدى عليه، دون رفع الدعوى أمام السلطة المختصة لها(١).

ونص قانون العقوبات الصومالي على أنه:

"لا عقوبة على كل من ارتكب فعلا وهو مجبر عليه بحكم ضرورة الدفاع عن حق شرعي أو حق غيره أمام خطر واقعي ناجم عن ضرر غير مشروع إذا كان ذلك الدفاع متناسبا مع الضرر(٢).

أثر الدفاع الشرعي

يترتب أثر قانوني على استعمال الدفاع الشرعي بالمعنى السابق، وهو إباحة الأفعال التي صدرت من المعتدى عليه دفاعا عن نفسه أو ماله أو غيره مما سبق، فتنتفي الصفة غير المشروعية عن الفعل، وبالتالي ترتفع صفة الجريمة مع مطابقتها للنموذج التشريعي لجريمة من الجرائم (٣)، ومن ثم يكون المدافع غير مسئول جنائيا.

ويترتب أيضا على كون المدافع حال إباحة فيما يصدر منه من سلوك هو جريمة بذاته بغض النظر عن كونه استعمل حق الدفاع الشرعي، وأنه لا يسأل مسئولية جنائية، وأن المساعد والمساهم للمدافع في حكم المدافع؛ لأنه أعان صاحبه على سلوك مباح (٤).

ونلخص ذلك في القاعدة التي تقول:

"أن من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسئول؛ لأنه يمارس حقا من حقوقه" (٥).

ويتضح مما سبق أن استعمال حق الدفاع الشرعي مشروع في قانون العقوبات الصومالي؛ أخذا من المبادئ العامة في الفقه الإسلامي، وبالتالي يترتب من استعمال هذا الحق عدم المسئولية الجنائية عن المدافع نفسه، وعن المعاون أيضا، ولكن هذا ليس مطلقا عن القيود والشروط، بل هناك شروط ستأتي في المطلب الثالث والرابع.

فما مدى موافقة القانون للفقه الإسلامي في معنى الدفاع الشرعي

يبدو أنه لا مخالفة بين القانون والفقه الإسلامي في معنى الدفاع الشرعي الخاص سواء كان في التعريفات لهذه المصطلح أو أحكامه.

---

(١) أسباب الإباحة في القانون الدولي الجنائي، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون العام، إعداد الطالبة: مزيان راضية، جامعة قسنطينة، بدون الطبعة، ت: ٢٠٠٦م، الجزائر، ص: ١٣.

(٢) قانون العقوبات الصومالي، مرجع سابق، م: ٣٤.

(٣) شرح قانون العقوبات اليمني، مرجع سابق، ص:٢٩٨-٢٩٩.

(٤) شرح قانون العقوبات، الألفي، مرجع سابق، ص: ٢٤٠.

(٥) المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ٢٣٥.

المطلب الثالث: شروط الدفاع الشرعي الخاص(دفع الصائل)، في الفقه الإسلامي

بعد ما سبق الكلام على تعريف الدفاع الشرعي الخاص (دفع الصائل)، وما يترتب على استعمال حق الدفاع الشرعي من أن الدفاع الشرعي هو رد اعتداء غير مشروع حالّ على معصوم، وأن استعمال هذا الحق مباح، وأنه يكون الشخص غير مسئول جنائيا، فيأتي دور الكلام على الشروط التي ينبغي توافرها في استعمال هذا الحق حتى يكون سببا من أسباب الإباحة، وهذه الشروط في مجموعها تكون كالتالي:

الشرط الأول: أن يكون الدفاع لازما لرد الاعتداء ودفعه:

ومعنى هذا الشرط أن يدفع الصائل المعصوم بالأخف فالأخف وجوبا إن أمكن كهرب فزجر بكلام فاستغاثة أو تحصن بحصانة فضرب بيده فبسوط فبعصا فقطع فقتل لأن ذلك جوّز للضرورة ولا ضرورة للأثقل مع إمكان الأخف فمتى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بدونها ضمن بالقود وغيره [١].

الشرط الثاني: أن يكون منع الاعتداء بالقدر اللازم والقوة المناسبة لرده (التناسب):

يشترط في توافر قيام حالة الدفاع الشرعي الخاص (دفع الصائل) أن يكون بالقدر اللازم لدفع الاعتداء، فهو غير مسئول جنائيا، وما زاد على ذلك فلا يجوز له استعمال هذا الحق، وبمعنى آخر: يشترط في استعمال حق الدفاع التناسب والتوازن بين الاعتداء وبين الدفاع، فمن أمكن له الدفع بالصراخ فلا يجوز له الدفاع بالضرب[٢].

الشرط الثالث: عدم مشروعية الاعتداء:

يشترط في جواز الدفاع الشرعي أن يكون الفعل المراد دفعه الموصوف بالاعتداء غير مشروع، بأن لا يكون الاعتداء مستندا إلى أداء واجب أو استعمال حق، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز الدفع، كقيام الجلاد بتنفيذ الأحكام، أو قيام الزوج بتأديب الزوجة في حدود ما أباح له الفقه الإسلامي، وكقيام الأب بتأديب ولده وكذلك المعلم، وكقيام الطبيب بممارسة الأعمال الطبية كقطعه الجزء الفاسد من أجزاء أعضاء المريض، ففي هذه الأحوال وما يشبهها لا تجوز المقاومة والدفاع عنه على أساس استعمال حق الدفاع الشرعي الخاص (دفع الصائل) [٣].

---

(١) فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد زين الدين المعبري المليباري الهندي، دار بن حزم، ط ١، بدون التاريخ، ومكان النشر، ص: ٥٩٠.

(٢) الوسيط في المذهب، محمد بن محمد أبو حامد الغزالي الطوسي، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ، محمد محمد تامر، دار السلام، ط١، ت: ١٤١٧هـ، القاهرة، ج ٦، ص: ٥٣١.

(٣) التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، مرجع سابق، ج ٨، ص: ٣٤٢.

المطلب الرابع: شروط الدفاع الشرعي الخاص في القانون

بعد الحديث عن معنى الدفاع الشرعي الخاص في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي سيأتي هنا الكلام على شروط الدفاع الشرعي الخاص أو ما يسمى في الفقه الإسلامي بـــ(ـــدفع الصائل)، وهذا ما ذكر عليه قانون العقوبات الصومالي، حيث نص على أنه: "لا عقوبة على كل من ارتكب فعلا وهو مجبر عليه بحكم الدفاع عن حق شرعي أو حق غيره أمام خطر واقعي ناجم عن ضرر غير مشروع إذا كان ذلك الدفاع متناسبا مع الضرر" [١].

شروط الدفاع الشرعي الخاص

تبين مما سبق أن الدفاع الشرعي يكون من أسباب الإباحة، وكل من استعمله يكون في محل إباحة، وهذا ليس على الإطلاق، بل هنا شروط، بعضها للخطر المدفوع عنه، وبعضها لرد ذلك الخطر:

أولا: يشترط للخطر المدفوع عنه الشروط الآتية:

١. وجود خطر بارتكاب الجريمة، لا يجوز لأي شخص استعمال حق الدفاع إلا لرد اعتداء متوجه له ويهدده بخطر يعد جريمة، سواء كان في الخطر إضرار بالمدافع نفسه أو بغيره [٢].

٢. كون ذلك يعد جريمة واعتداء، بمعنى: أنه يجب أن يكون الخطر الحال ناجما عن فعل غير مشروع، تقوم به جريمة، وهذا الفعل هو الذي يوصف بأنه عدوان، وتعتمد هذه الصفة، أي: صفة العدوان المبدأ العام الذي هو مبدأ المشروعية [٣].

٣. كون الضرر والاعتداء حالا، فلا يكفي أن يكون الخطر غير مشروع لقيام الدفاع الشرعي، وإنما ينبغي أن يكون هذا الخطر حالا، أي: اعتداء حال أو وشيك الحدوث[٤].

ثانيا: الشروط اللازمة لرد الخطر، فشرطان:

١. اللزوم، فإذا كان خطر الاعتداء يبيح ارتكاب أفعال الدفاع فمن الطبيعي أن تكون هذه الأفعال لازمة لتحقيق هذا العرض، فإذا لم تكن ضرورية أو لازمة لذلك انتفت مبررات الإباحة؛ إذ أن الدفاع يختلف عن مجرد الانتقام أو الثأر [٥].

٢. التناسب، ومقتضى هذا الشرط أن فعل الدفاع يجب أن تكون متناسبا مع الخطر، أي: أن يكون بالقدر الضروري لصده [١].

---

(١) قانون العقوبات الصومالي مرجع سابق، م:٣٤.

(٢) شرح قانون العقوبات، الألفي، مرجع سابق، ص: ٢١٦.

(٣) قانون الجرائم والعقوبات، ص:٢١٧.

(٤) شرح قانون العقوبات اليمني، مرجع سابق، ص: ٢٦١.

(٥) شرح قانون العقوبات، الألفي، مرجع سابق، ص: ٢١٦.

(١) شرح قانون الجرائم والعقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص:٢١٧.

فما مدى موافقة القانون للفقه الإسلامي في شروط الدفاع الشرعي الخاص

تبين أنه ليس هناك فارق كبير في خصوص ما تقدم في شروط الدفاع الشرعي الخاص بين الفقه الإسلامي، وقانون العقوبات الصومالي والقوانين الوضعية الأخرى.

الخلاصة:

يستخلص مما سبق أن التأديب قد يكون للزوج على الزوجة، وقد يكون للولي على الصغير، وأما تأديب الزوج على الزوجة فهو وإن كان حقا للزوج تجاه زوجته فهو ليس استعماله بواجب، بل الزوج مخير، بين التأديب والعفو عن استعماله، ولكن الأولى له العفو عنها، فهو مشروع في الفقه الإسلامي والقانون، وأما ضرب الزوج زوجته على ترك العبادات فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين، والراجح منهما جواز ضرب الزوجة على ترك الفرائض.

وأن ممارسة الأعمال الطبية تعتبر مشروعا ومباحا، وسبب من أسباب الإباحة للجريمة في الفقه الإسلامي، والقانون الوضعي، ولم يجد الباحث نصا صريحا في بيان حكم ممارسة الأعمال الطبية في قانون العقوبات الصومالي، ولكنه يتضمنه باعتباره صورة من صور استعمال الحق في المواد المتقدمة.

ثم إنه يكون هناك شروط لممارسة الأعمال الطبية، فيمكن إجمالها فيما يلي:

١. أن يكون الفاعل طبيباً.
٢. أن يأتي الفعل بقصد العلاج وبحسن نية.
٣. أن يعمل طبقاً للأصول الطبية.
٤. أن يأذن له المريض أو من يقوم مقامه كالولي.
٥. أن يكون مرخصا من قبل الدولة.

وأن الدفاع الشرعي أو ما يسميه الفقهاء قديما بدفع الصائل مشروع للحماية، باتفاق فقهاء الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، وأن معناه بشكل عام هو: عبارة عن رد اعتداء الغير على دين الآخرين وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم وغيرها من الكليات الخمسة، وأن هناك شروط ينبغي توافرها في استعمال هذا الحق حتى يكون سببا من أسباب الإباحة، وهذه الشروط في مجموعها تكون كالتالي:

الشرط الأول: أن يكون الدفاع لازما لرد الاعتداء ودفعه.

الشرط الثاني: أن يكون منع الاعتداء بالقدر اللازم والقوة المناسبة لرده (التناسب).

الشرط الثالث: عدم مشروعية الاعتداء، وعلى هذا سلك القانون، إلا أن بعض هذه الشروط تكون للخطر المدفوع عنه، وبعضها لرد ذلك الخطر:

أما شروط الخطر المدفوع عنه تنحصر في: وجود خطر بارتكاب الجريمة، وكون ذلك يعد جريمة واعتداء، وكون الضرر والاعتداء حالا.

وأما الشروط اللازمة لرد الخطر، فشرطان: اللزوم، والتناسب.

الخاتمة

الخاتمة

توصل الباحث من خلال كتابة هذا البحث التكميلي إلى نتائج، وفي نفس الوقت تلى هذه النتائج توصيات أيضا، وفيما يلي أهم هذه النتائج وذلك على النحو التالي:

أولا: النتائج

١- أن معنى المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي نصا وفي القانون مفهوما هو: أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختاراً وهو مدرك لمعانيها ونتائجها.

٢- أن الفقهاء من المتقدمين لم يستعملوا كلمة المسئولية الجنائية بلفظها، بل بمرادفها، مثل: الضمان، وأنه لم يخضع الفقه الإسلامي الجنائي الإسلامي في قواعده وأسسه إلى التطور والتغيير إلا ما كان منه في مسائل اجتهادية معروفة ترك الشارع الحكيم أمره لأولي الأمر عبر الأزمان، وهي المسائل التي من شأنها أن تبرهن على صلاحية هذا النظام وفعاليته في مواجهة كل تغيير.

٣- أن تطور المسئولية الجنائية في قانون العقوبات الصومالي لا يوجد له تاريخ وتطور مدون، ولعل السبب الرئيسي يرجع إلى عدم إعطاء اهتمام لشرح قانون العقوبات الصومالي جنائيا أو مدنيا، وأما في القوانين الأخرى فهي قبل اليوم لم تمثل إلا مزيجا أو خليطا من المفاهيم، فإذا أطلقت المسئولية الجنائية في الفكر القانوني القديم تنصرف إلى المسئولية المدنية.

٤- أن المسئولية الجنائية مبنية على الإدراك والإرادة في الفقه الإسلامي والقانون.

٥- أن محل المسؤولية الجنائية هو الإنسان الجي لا غير، فلا مخالفة بين الفقه الإسلامي والقانون الصومالي في ذلك.

٦- أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا يسأل عن الجرم إلا فاعله ولا يؤخذ امرؤ بجريرة غيره مهما كانت درجة القرابة أو الصداقة بينهما ولا خلاف في ذلك بين الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.

٧- أن سبب المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي مخالفة حكم الله، وقانون العقوبات الصومالي هو ارتكاب الجرائم .

٨- أن درجات المسؤولية الجنائية ثلاثة في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الصومالي العمد وشبه العمد والخطأ.

٩- أن موانع المسئولية الجنائية هي: صغر السن والجنون والإكراه والضرورة والرضا والجهل.

١٠- أن أسباب الإباحة في المسؤولية الجنائية حق التأديب والدافاع والأعمال الطبية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي.

١١- أن قانون العقوبات الصومالي يخالف الفقه الإسلامي في بعض أحكام المسؤولية الجنائية من عقوبات، سواء كانت تلك العقوبة لجرح أو قتل.

ثانيا: التوصيات:

يوصي الباحث في ختام هذا البحث إلى الآتي:

١. ضرورة مراعاة مبنى المسؤولية الجنائية من قِبَلِ القضاة.

٢. التأكد من عدم توفر موانع المسؤولية الجنائية وأسباب الإباحة عند إصدار القاضي الأحكام الجنائية على المتهمين.

٣. ضرورة كشف معنى المسؤولية الجنائية للمجتمع.

٤. يوصي الباحث مجلس التشريع إلى أن يراجع جميع القوانين الصومالية وأسلمتها؛ لتهذيبها، تعديلا، أو إلغاء لما لا يقبل تعديلا؛ لما فيها من مخالفة للفقه الإسلامي بشكل عام.

٥. يوصي الباحث أيضا طلاب القانون إلى اهتمام شرح القوانين الصومالية عموما، وقانون العقوبات الصومالي خاصا.

الفهارس

وتشمل ما يلي:

- فهرس الآيات.
- فهرس الأحاديث.
- فهرس الأعلام.
- فهرس المصادر والمراجع.
- فهرس الموضوعات.

أولا: فهرس الأيات:

رقم	طرف الآية:	السورة:	الآية:	الصفحة:
١.	﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾	البقرة	١٧٣	٢١
٢.	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ﴾	البقرة	١٧٨	٥٤
٣.	﴿ وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ ﴾	البقرة	١٧٩	٥٤
٤.	﴿ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾	البقرة	٢١٩	١٦
٥.	﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ﴾	البقرة	٢٥١	١٣٦
٦.	﴿ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ﴾	النساء	٦	٢٩
٧.	﴿ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ	النساء	٣٤	١١١
٨.	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ ﴾	النساء	٤٣	٨٠
٩.	﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾	النساء	٨٠	٤٥
١٠.	﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْ ﴾	النساء	٩٢	٦٧
١١.	﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا ﴾	النساء	٩٣	٥٤
١٢.	وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ ﴾	النساء	٣٥	١١٧
١٣.	﴿ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ ﴾	النساء	١٢٣	٤٦

١٤.	﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى ﴾	المائدة	٣	٩٩
١٥.	﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾	المائدة	٣٢	١٢٨
١٦.	﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾	المائدة	٤٥	٥٤
١٧.	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾	المائدة	١٠١	١٤
١٨.	﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَٰبِ مِن شَىْءٍ ﴾	الأنعام	٣٨	٦٢
١٩.	﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ ﴾	الأنعام	١٦٠	٤٦
٢٠.	﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾	الأنعام	١٦٤	٢١
٢١.	﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ ﴾	الحجر	٩٣–٩٤	١٥
٢٢.	﴿ تَٱللَّهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴾	النحل	٥٦	١٥
٢٣.	﴿ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾	النحل	٩٣	١٥
٢٤.	﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾	النحل	١٠٦	٢١
٢٥.	وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا	الإسراء	٣٤	١٥
٢٦.	﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ	الإسراء	٣٦	١٥
٢٧.	﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾	طه	٥٠	٣٨
٢٨.	﴿ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟	النور	٥٩	٢١
٢٩.	﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَٰلِدِينَ ۚ ﴾	الفرقان	١٦	١٥

٣٠.	﴿ فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا ﴾	الفرقان	٥٩	١٤
٣١.	﴿ وَقِفُوهُمْۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ ﴾	الصافات	٢٤	١٥
٣٢.	﴿ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقْتَدُونَ ﴾	الزخرف	٣٢	٢٢
٣٣.	﴿ مَّنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ﴾	فصلت	٤٦	٤١
٣٤.	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا	الحجرات	١٣	١
٣٥.	﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَن ذَنۢبِهِۦٓ إِنسٌ وَلَا جَآنٌّ ﴾	الرحمن	٣٩	١٦
٣٦.	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ ﴾	التحريم	٦	١١١

ثانيا: فهرس الأحاديث

الرقم	طرف الحديث	الراوي	المخرج	الصفحة
١.	أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي	أبو رمثة	أبو داود	٤١
٢.	أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه عنده كأنما على رءوسهم الطير	أسامة بن شريك	أحمد	١٢٦
٣.	اجتنبوا السبع الموبقات	أبو هريرة	البخاري	٩٩
٤.	إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار	عن أبي بكرة	البخاري ومسلم	٥٥
٥.	أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار	واثلة بن الأسقع	أبو دلود	٥٧
٦.	ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟	ابن عباس	البخاري	١٢٧
٧.	ألا إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط، والعصا، مائة من الإبل	عبد الله بن عمرو	أحمد	٦٢
٨.	أما علمت: أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق	علي بن أبي طالب	البخاري	٢١
٩.	أن «رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله	زيد بن أسلم	مالك	١٢١
١٠.	إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان	ابن عباس	ابن ماجه	٢١
١١.	إن الميت ليعذب ببكاء أهله	ابن عمر	البخاري	٢٢
١٢.	أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق السوط في البيت	ابن عباس	البخاري والطبراني	١١٢

١٣.	أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل	عبد الله بن عمرو	أحمد	٦٧
١٤.	أن النبي صلى الله عليه وسلم، لقي ركبا بالروحاء، فقال: «من القوم؟» قالوا: المسلمون	ابن عباس	مسلم	٧٥
١٥.	أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى	جابر بن عبد الله	أبو داود	٤٢
١٦.	أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة	ابن عمر	البخاري ومسلم	٣٠
١٧.	أن عليًا -رضي الله عنه- خطب على الناس	الضحاك بن مزاحم	عبد الرزاق	١٣٠
١٨.	بعث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى أبي بن كعب طبيبًا	جابر	مسلم	١٢٨
١٩.	رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر	عائشة	أبو داود	٧٦
٢٠.	رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ	عائشة	النسائي وابن ماجه	٧٦
٢١.	رفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم: «المجنون حتى يفيق»	عائشة	الحاكم	٢١
٢٢.	عَقْلُ شبه العمدِ مُغلَّظٌ مثلُ عقلِ العمدِ،	عبدالله بن عمرو	أبو داود	٦١
٢٣.	فاتقوا الله في النساء	جابر بن عبد الله	مسلم	١١٦
٢٤.	فقضى على العاقلة الدية	ابن عباس	أبو داود	٤٢

٢٥.	فيه غرة، عبد أو أمة	المغيرة بن شعبة	البخاري ومسلم	٤٢
٢٦.	كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم	عمرو بن أوس	تفسير الإمام الشافعي	٤١
٢٧.	كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته	ابن عمر	البخاري وسلم	٤٦
٢٨.	لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها	عبد الله بن مسعود	البخاري ومسلم	٥٥
٢٩.	لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه	أنس بن مالك	البخاري	٩٩
٣٠.	لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث:	عبد الله بن مسعود	البخاري	٥٤
٣١.	لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام	أبو هريرة	البخاري ومسلم	١١٦
٣٢.	لكل داء دواءٌ	جابر	مسلم	١٢٦
٣٣.	اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك	عائشة	مسلم	٩٥
٣٤.	ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً	أبو هريرة	البخاري	١٢٦
٣٥.	مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين	سَبْرَةَ	أبو داود	١٢٠
٣٦.	من تطبب، ولا يعلم منه طب، فهو ضامن	عبد الله بن عمرو	أبو دلود	١٣١
٣٧.	من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل	عبد الله بن عمرو	أحمد	٦١
٣٨.	من لا يشكر الناس لا يشكر الله	أبو هريرة، وأبو سعيد الخدري	أحمد، الترمذي	و

٣٩.	ولا يضرب الوجه	معاوية القشيري	الحاكم	١١٧
٤٠.	ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه	عبد الله بن مسعود	النسائي	٤١
٤١.	ومن غشنا فليس منا	أبو هريرة	مسلم	١٣١
٤٢.	يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت	عائشة	البخاري	١٠٤
٤٣.	يا رسول الله، نتداوى؟ قال: ((نعم، تداووا	أسامة بن شريك	أحمد	١٢٦
٤٤.	يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب	أبو هريرة	البخاري ومسلم	١٢٧

ثالثا: فهرس الأعلام

الرقم	الاسم الكامل	الصفحة
١–	حمد بن محمد أبو سليمان الخطابي	١٣٢
٢–	طاهر بن محمد أبو المظفر، الإسفراييني	٣٨
٣–	عبد الله بن وهب بن مسلم	٤٨
٤–	محمد بن أحمد بن محمد أبو القاسم الغرناطي	٥٩

رابعا: قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم

كتب التفسير:

١) أحكام القرآن، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي، تعليق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط ٢، ت: ١٤٢٤ هـ -٢٠٠٣ م، بيروت – لبنان.

٢) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، عبد الله بن عمر بن محمد أبو سعيد ناصر الدين الشيرازي البيضاوي، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، ط ١، ت: ١٤١٨ ه، بيروت.

٣) تفسير الإمام الشافعي، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف أبو عبد الله المطلبي القرشي المكي، تحقيق: أحمد بن مصطفى الفرّان، دار التدمرية، ط١، ت: ١٤٢٧ه – ٢٠٠٦م، المملكة العربية السعودية.

٤) تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر أبو محمد ابن أبي حاتم التميمي، الحنظلي، الرازي، دراسة وتحقيق، وتخريج: حكمت بن بشير بن ياسين، دار ابن الجوزي، ط١، ت: ١٤٣٩ ه، الدمام – المملكة العربية السعودية.

٥) جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الآملي، الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط ١، ت: ١٤٢٠ ه – ٢٠٠٠ م، بدون مكان النشر.

٦) الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد الله شمس الدين الأنصاري الخزرجي القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، ط/٢، ت:١٣٨٤هـ – ١٩٦٤ م، القاهرة.

٧) زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج جمال الدين الجوزي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، ط ١، ت: ١٤٢٢هـ بيروت–لبنان.

٨) زهرة التفاسير محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة، دار الفكر العربي، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.

٩) الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق، الثعلبي، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، ط ١، ت: ١٤٢٢، هـ -٢٠٠٢ م، بيروت – لبنان.

١٠) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية أبو محمد الأندلسي المحاربي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، ط ١، ت: ١٤٢٢ هـ، بيروت.

١١) معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب ط١، ت: ١٤٠٨ هـ – ١٩٨٨م، بيروت.

١٢) مفاتيح الغيب، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين أبو عبد الله التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، دار إحياء التراث العربي، ط/٣، ت:١٤٢٠ هـ، بيروت.

متون الحديث

١) الأدب المفرد بالتعليقات، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الله، البخاري، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المعارف، ط ١، ت: ١٤١٩ هـ – ١٩٩٨ م، الرياض – المملكة العربية السعودية.

٢) سنن ابن ماجه، ابن ماجه محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد – محمّد كامل قره بللي – عَبد اللّطيف حرز الله، دار الرسالة العالمية، ط١، ت: ١٤٣٠ هـ – ٢٠٠٩م، بدون مكان النشر.

٣) سنن أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو أبو داود الأزدي السِّجِسْتاني، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط – محَمَّد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط ١، ت: ١٤٣٠ هـ – ٢٠٠٩ م، بدون مكان النشر.

٤) سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط٢، ١٣٩٥ هـ – ١٩٧٥ م، مصر.

٥) السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر الخُسْرَوْجِردي الخراساني، البيهقي، محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط ٣/ ت: ١٤٢٤ هـ –٢٠٠٣ م، بيروت – لبنان.

٦) سنن النسائي الصغرى، أحمد بن شعيب بن علي أبو عبد الرحمن الخراساني، النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية ، ط ٢، ت: ١٤٠٦ه – ١٩٨٦م، حلب – سورية.

٧) صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط١، ت: ١٤٢٢ه، بدون مكان النشر.

٨) صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بدون الطبعة، والتاريخ، بيروت.
٩) المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم أبو عبد الله الحاكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع، ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط١، ت:١٤١١ه – ١٩٩٠م، بيروت.
١٠) مسند أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أبو عبد الله الشيباني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط ١، ت: ١٤٢١ هـ – ٢٠٠١ م، بدون مكان النشر.
١١) المصنف، عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الحميري اليماني الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، ط٢، ت: ١٤٠٣ه– الهند.
١٢) المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير أبو القاسم اللخمي الشامي، الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، ط ٢، بدون التاريخ، القاهرة.
١٣) الموطأ، الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، دار إحياء التراث العربي، بدون الطبعة، ت: ١٤٠٦ هـ – ١٩٨٥ م، بيروت – لبنان.

شروح الحديث

١) الآداب الشرعية والمنح المرعية، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي، عالم الكتب، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.
٢) بهجة قلوب الأبرار، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله أبو عبد الله، آل سعدي، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط ٤، ت: ١٤٢٣ ه، المملكة العربية السعودية.
٣) توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم أبو عبد الرحمن البسام التميمي، مكتبة الأسدي، ط ٥، ت ١٤٢٣ هـ– ٢٠٠٣م، مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية.
٤) التوضيح لشرح الجامع الصحيح، عمر بن علي بن أحمد سراج الدين أبو حفص الشافعي المصري، المعروف بابن الملقن)، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النوادر، ط ١، ت: ١٤٢٩ هـ – ٢٠٠٨ م، دمشق – سوريا.
٥) ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي، دار آل بروم، ط١، ت: ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٣ م، بدون مكان النشر.

٦) سبل السلام، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد أبو إبراهيم، عز الدين، الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، المعروف كأسلافه بالأمير، دار الحديث، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.
٧) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن)، الحسين بن عبد الله شرف الدين الطيبي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط ١، ت: ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م، الرياض- السعودية.
٨) شرح صحيح البخارى علي بن خلف بن عبد الملك المعروف بابن بطال أبو الحسن ، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، ط ٢، ت: ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م، الرياض – السعودية.
٩) فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة، بدون الطبعة، ت: ١٣٧٩ه، بيروت.
١٠) معالم السنن (شرح سنن أبي داود)، حمد بن محمد بن إبراهيم أبو سليمان المعروف بالخطابي، المطبعة العلمية، ط١، ت: ١٣٥١ هـ - ١٩٣٢ م، حلب.

كتب التخريج والزوائد

١) جامع الأصول في أحاديث الرسول، المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم أبو السعادات مجد الدين الشيباني الجزري ابن الأثير، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط – التتمة تحقيق بشير عيون، مكتبة الحلواني، ط١، بدون التاريخ، ومكان النشر.
٢) فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، تحقيق : مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران، دار عالم الفوائد، ط ١، ت: ١٤٢٧ ه، بدون مكان النشر.

كتب التراجم:

١) الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، دار العلم للملايين، ط ١٥، ت: أيار / مايو ٢٠٠٢ م، بدون مكان النشر.

٢) سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز أبو عبد الله شمس الدين الذهبي، دار الحديث، بدون الطبعة، ت: ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م، - القاهرة.
٣) فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، محمد عَبْد الحَيْ بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي، المعروف بعبد الحي الكتاني، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، ط ١، ت: ١٩٨٢ – بيروت.

٤) ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد بن أحمد بين عثمان أبو عبد الله شمس الدين الذهبي، تحقيق: محمد رضوان عرقسوسي، وعمار ريحاوي، وغياث الحاج أحمد، وفادي المغربي، الرسالة العالمية، ط ١، ت: ١٤٣٠ ه – ٢٠٠٩ م، دمشق – سورية.

كتب العقيدة

١) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، ابن الوزير، محمد بن إبراهيم بن علي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط٢، ت: ١٤١٥ هـ – ١٩٩٤ م، بيروت.

كتب أصول الفقه

١) الإبهاج في شرح المنهاج، علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي أبو الحسن تقي الدين السبكي وولده عبد الوهاب أبو نصر تاج الدين، دار الكتب العلمية بدون الطبعة، ت: ١٤١٦هـ – ١٩٩٥ م،–بيروت.

٢) الأحكام في أصول الأحكام، علي بن أبي علي بن محمد بن سالم أبو الحسن سف الدين الثعلبي الآمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بدون الطبعة، والتاريخ، بيروت– لبنان.

٣) أصول الفقه الذي لا يَسَعُ الفقيهِ جَهلَهُ، عياض بن نامي بن عوض السلمي، دار التدمرية، ط١، ت: ١٤٢٦ هـ –٢٠٠٥م، الرياض –المملكة العربية السعودية.

٤) أصول الفقه، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي، تحقيق: فهد بن محمد السَّدَحَان، مكتبة العبيكان، ط ١، ت:١٤٢٠ هـ – ١٩٩٩ م، بدون مكان النشر.

٥) البحر المحيط في أصول الفقه، محمد بن عبد الله بن بهادر أبو عبد الله بدر الدين الزركشي، دار الكتبي، ط/١، ت: ١٤١٤هـ – ١٩٩٤م، بدون مكان النشر.

٦) البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد أبو المعالي، ركن الدين، الجويني، الملقب بإمام الحرمين، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، ط١، ت: ١٤١٨ هـ – ١٩٩٧ م، بيروت – لبنان.

٧) التقرير والتحبير، محمد بن محمد بن محمد أبو عبد الله، شمس الدين المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي، دار الكتب العلمية، ط٢، ت: ١٤٠٣هـ – ١٩٨٣م، بدون مكان النشر.

٨) تقويم الأدلة في أصول الفقه، عبد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسيّ الحنفي، تحقيق: خليل محيي الدين الميس، دار الكتب العلمية، ط١، ت: ١٤٢١هـ -٢٠٠١م، بدون مكان النشر.

٩) التمهيد في أصول الفقه، محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكَلْوَذَاني الحنبلي، تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، ط١، ت: ١٤٠٦ هـ -١٩٨٥ م، بدون مكان النشر.

١٠) التمهيد، محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف أبو المنذر المنياوي، المكتبة الشاملة، ط١، ت: ١٤٣٢ هـ -٢٠١١ م، مصر.

١١) تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول «المختصر»، محمد بن محمد بن عبد الرحمن كمال الدين المعروف بـ «ابن إمام الكاملية» ، تحقيق: عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، دار الفاروق الحديثة، ط١، ت: ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م، القاهرة- مصر.

١٢) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي، دار الكتب العلمية، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.

١٣) دراسات أصولية في القرآن الكريم، محمد إبراهيم الحفناوي، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، بدون الطبعة، ت: ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م، القاهرة-مصر.

١٤) روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة أبو محمد موفق الدين الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، مؤسسة الريّان، ط/٢، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م، بدون مكان النشر.

١٥) شرح التلويح على التوضيح، مسعود بن عمر سعد الدين التفتازاني، مكتبة صبيح، بدون الطبعة، والتاريخ، مصر.

١٦) شرح تنقيح الفصول، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين المالكي الشهير بالقرافي، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط١، ت: ١٣٩٣ هـ -١٩٧٣ م، بدون مكان النشر.

١٧) شرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي بن الكريم أبو الربيع نجم الدين، الطوفي الصرصري، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط/١، ت: ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م، بدون مكان النشر.

١٨) غاية الوصول في شرح لب الأصول، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا أبو يحيى زين الدين السنيكي الأنصاري، دار الكتب العربية الكبرى، بدون الطبعة، والتاريخ، مصر.

١٩) الفصول في الأصول، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، وزارة الأوقاف الكويتية، ط ٢، ت:١٤١٤هـ -١٩٩٤ م، بدون مكان النشر.

٢٠) قواعد معرفة البدع، محمد بن حسين بن حسن الجيزاني، دار ابن الجوزي، ط١، ت: ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م، المملكة العربية السعودية.

٢١) القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية، علي بن محمد بن عباس المعروف بابن اللحام، أبو الحسن علاء الدين البعلي الدمشقي الحنبلي، تحقيق: عبد الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية، بدون الطبعة، ت: ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، بدون مكان النشر.

٢٢) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.

٢٣) مذكرة في أصول الفقه، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، مكتبة العلوم والحكم، ط٥، ت: ٢٠٠١ م، المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية.

٢٤) المسودة، آل تيمية [بدأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين عبد السلام بن تيمية، وأضاف إليها الأب، : عبد الحليم بن تيمية، ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، دون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.

٢٥) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمّد بنْ حسيْن بن حَسنْ الجيزاني، دار ابن الجوزي، ط/٥، ت:١٤٢٧ ه، بدون مكان النشر.

٢٦) مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بدون الطبعة، ت: ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م، قطر.

٢٧) المهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد، ط/١، ت: ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، الرياض- المملكة العربية السعودية.

٢٨) الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: مشهور بن حسن أبو عبيدة آل سلمان، دار ابن عفان، ط١، ت: ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م، بدون مكان النشر.

٢٩) نشر البنود على مراقي السعود، عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، مطبعة فضالة بالمغرب، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.

٣٠) نهاية السول شرح منهاج الوصول، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيْ، أبو محمد، جمال الدين، دار الكتب العلمية، ط ١، ت: ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م، بيروت- لبنان.

كتب القواعد الفقهية:

١) الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، ط١، ت: ١٤١١هـ -١٩٩٠م، بدون مكان النشر.

٢) الأشباه والنظائر، عبد الوهاب تاج الدين بن تقي الدين السبكي، دار الكتب العلمية، ط١، ت:١٤١١هـ-١٩٩١م، بدون مكان النشر.

٣) تقرير القواعد وتحرير الفوائد، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق: مشهور بن حسن أبو عبيدة آل سلمان، دار ابن عفان، ط ١، ت: ١٤١٩ هـ المملكة العربية السعودية.

٤) شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، تحقيق: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، ط ٢، ت: ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م، دمشق - سوريا.

٥) المنثور في القواعد الفقهية، محمد بن عبد الله بن بهادر أبو عبد الله بدر الدين الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، ط٢، ت: ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥ م، بدون مكان النشر.

كتب الفقه:

١) الأحكام السلطانية، علي بن محمد بن محمد بن حبيب أبو الحسن البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، دار الحديث، بدون الطبعة، والتاريخ، القاهرة - مصر.

٢) أحكام المسئولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، وهبة الزحيلي، دار الفكر، بدون الطبعة، ت ١٩٨م، دمشق _ سورية.

٣) الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود أبو الفضل مجد الدين الموصلي البلدحي، الحنفي، تحقيق: الشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي، بدون الطبعة، ت:١٣٥٦ هـ -١٩٣٧ م، القاهرة.

٤) أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا أبو يحيى زين الدين الأنصاري، السنيكي، دار الكتاب الإسلامي، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.

٥) الإشراف على مذاهب العلماء، محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري، تحقيق: صغير أحمد أبو حماد الأنصاري، مكتبة مكة الثقافية، ط١، ت:١٤٢٥هـ -٢٠٠٤ م، رأس الخيمة -الإمارات العربية المتحدة.

٦) الإشراف على نكت مسائل الخلاف، عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد البغدادي المالكي، تحقيق: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، ط١، ت: ١٤٢٠هـ -١٩٩٩م، بدون مكان النشر.

٧) الأصل المعروف بالمبسوط، محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، بدون الطبعة، والتاريخ، كراتشي- باكستان.

٨) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، عثمان بن محمد شطا أبو بكر الدمياطي الشافعي (المشهور بالبكري)، دار الفكر، ط١، ت: ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م، بدون مكان النشر.

٩) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم أبو النجا شرف الدين، الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بدون الطبعة، والتاريخ، بيروت - لبنان.

١٠) الأم: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف أبو عبد الله الشافعي المطلبي القرشي المكي، دار المعرفة بدون الطبعة، ت: ١٤١٠ هـ، ١٩٩٠ م- بيروت.

١١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان أبو الحسن علاء الدين المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، دار إحياء التراث العربي، بدون الطبعة ، والتاريخ، ومكان النشر.

١٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي، ط ٢، بدون التاريخ، ومكان النشر.

١٣) بحر المذهب، عبد الواحد بن إسماعيل أبو المحاسن الروياني، تحقيق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، ط ١، ت: ٢٠٠٩ م، بدون مكان النشر.

١٤) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، دار الحديث، بدون الطبعة، ت: ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤ م، القاهرة.

١٥) بداية المحتاج في شرح المنهاج، بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر الأسدي الشافعي ابن قاضي شهبة، تحقيق: أنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني، دار المنهاج، ط١، ت: ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م، بدون مكان النشر.

١٦) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين، الكاساني الحنفي، دار الكتب العلمية، ط.٢، ت. ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، بدون مكان النشر.

١٧) بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد بن محمد الخلوتي، أبو العباس الشهير بالصاوي المالكي، دار المعارف، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.

١٨) البناية شرح الهداية، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين أبو محمد بدر الدين الغيتابى الحنفى العينى، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م، بيروت - لبنان.

١٩) البيان في مذهب الإمام الشافعي، يحيى بن أبي الخير بن سالم أبو الحسين العمراني اليمني الشافعي، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، ط١، ت: ١٤٢١ هـ-٢٠٠٠ م، جدة.

٢٠) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد القرطبي، تحقيق: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، ط٢، ت: ١٤٠٨ هـ -١٩٨٨ م، بيروت - لبنان.

٢١) التبصرة، علي بن محمد أبو الحسن، الربعي، المعروف باللخمي، تحقيق: أحمد عبد الكريم نجيب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط١، ت: ١٤٣٢ هـ -٢٠١١ م، قطر.

٢٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، المطبعة الكبرى الأميرية بولاق، ، ط١، ت: ١٣١٣ هـ، القاهرة.

٢٣) التجريد، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري، تحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد، دار السلام، ط/٢، ت: ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦م، القاهرة.

٢٤) تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية، ط٢، ت: ١٤١٤ هـ -١٩٩٤ م، بيروت - لبنان.

٢٥) تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، عمر بن علي بن أحمد أبو حفص سراج الدين الشافعي المصري المعروف بابن الملقن، تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني، دار حراء، ط ١، ت: ١٤٠٦ه، مكة المكرمة.

٢٦) تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ، المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمد، بدون الطبعة، ت: ١٣٥٧ هـ ١٩٨٣- م، مصر.

٢٧) التوضيح في شرح المختصر الفرعي، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري، تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط١، ت: ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م، بدون مكان النشر.

٢٨) جامع الأمهات، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي، تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، اليمامة للطباعة، ط٢، ت: ١٤٢١هـ -٢٠٠٠م، بدون مكان النشر.

٢٩) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير، محمد بن الحسن أبو عبد الله الشيباني، عالم الكتب، ط ١، ت: ١٤٠٦ هـ، بيروت.

٣٠) الجوهرة النيرة، بن علي بن محمد أبو بكر الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي، المطبعة الخيرية، ط١، ١٣٢٢ه، بدون مكان النشر.

٣١) حاشية البجيرمي على شرح المنهج، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي، مطبعة الحلبي، بدون الطبعة، ت: ١٣٦٩ هـ - ١٩٥٠ م، بدون مكان النشر.

٣٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، دار الفكر، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.

٣٣) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني علي بن محمد بن محمد بن حبيب، أبو الحسن البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط١، ت:١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م، بيروت - لبنان.

٣٤) الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط.١، ت:١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م، بدون مكان النشر.

٣٥) درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو المولى - خسرو، دار إحياء الكتب العربية، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.

٣٦) دستور الأخلاق في القرآن، محمد بن عبد الله دراز، مؤسسة الرسالة، ط/١، ت:١٤١٨ه-١٩٩٨م، بدون مكان النشر.

٣٧) الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين البلباني الحنبلي، عبد العزيز بن عدنان العيدان، وأنس بن عادل اليتامى، دار الركائز، ط ١، ت: ١٤٣٩ هـ – ٢٠١٨ م، الكويت.

٣٨) الذخيرة، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين المالكي الشهير بالقرافي، تحقيق: محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، ط ١، ت: ١٩٩٤ م ، بيروت.

٣٩) رد المحتار على الدر المختار، محمد بن (محمد أمين المعروف بابن عابدين) بن عمر بن عبد العزيز عابدين علاء الدين الحسيني الدمشقي، دار الفكر، ط٢، ت: ١٤١٢هـ – ١٩٩٢م، –بيروت.

٤٠) روضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن شرف أبو زكريا محيي الدين النووي، تحقيق: زهير الشاوي، المكتب الإسلامي، ط ٣، ت:١٤١٢هـ / ١٩٩١م، بيروت.

٤١) الشامل في فقه الإمام مالك، بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، أبو البقاء، تاج الدين السلمي الدَّمِيريّ الدَّمْيَاطيّ المالكي، تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط١، ت: ١٤٢٩ ه – ٢٠٠٨ م، بدون مكان النشر.

٤٢) شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك، أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي، دار الفكر، ط٢، بدون التاريخ، بيروت – لبنان.

٤٣) شرح الزُّرقاني على مختصر خليل، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري، تحريج: عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية، ط/١، ١٤٢٢ هـ – ٢٠٠٢ م، بيروت–لبنان.

٤٤) شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، دار العبيكان، ط١، ت: ١٤١٣ هـ – ١٩٩٣ م، بدون مكان النشر.

٤٥) الشرح الكبير (المطبوع مع المقنع والإنصاف)، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة أبو الفرج شمس الدين المقدسي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، هجر، ط/١، ت:١٤١٥ هـ – ١٩٩٥م، القاهرة – جمهورية مصر العربية.

٤٦) شرح مختصر الطحاوي، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، تحقيق: عصمت الله عنايت الله محمد، سائد بكداش، محمد عبيد الله خان، زينب محمد حسن فلاتة، دار البشائر الإسلامية، ط١، ت: ١٤٣١ هـ – ٢٠١٠ م، بدون مكان النشر.

٤٧) شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الخرشي المالكي، دار الفكر، بدون الطبعة، والتاريخ، بيروت.

٤٨) صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة كمال بن السيد سالم، أبو مالك ، تحقيق: ناصر الدين الألباني، وعبد العزيز بن باز، محمد بن صالح العثيمين، المكتبة التوفيقية، بدون الطبعة، ت: ٢٠٠٣ م، القاهرة – مصر.

٤٩) العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، تحقيق: علي محمد عوض – عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط ١، ت: ١٤١٧ هـ – ١٩٩٧ م، بيروت – لبنان.

٥٠) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار أبو محمد جلال الدين الجذامي السعدي المالكي، تحقيق: حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، ط١، ت:١٤٢٣ هـ –٢٠٠٣م، بيروت – لبنان.

٥١) عمدة السالك وعدة الناسك، أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله أبو العباس، شهاب الدين الرومي، ابن النقيب الشافعي، الشؤون الدينية، ط١، ت: ١٩٨٢ م، قطر.

٥٢) العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أبو عبد الله أكمل الدين ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، دار الفكر، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.

٥٣) عُيُون الْمَسَائِل، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث السمرقندي، تحقيق: صلاح الدِّين الناهي، مطبعة أسعد، بدون الطبعة، ت: ١٣٨٦ه، بَغْدَاد.

٥٤) الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، عمر بن إسحق بن أحمد أبو حفص سراج الدين، الهندي الغزنوي، الحنفي، مؤسسة الكتب الثقافية، ط ١، ت: ١٤٠٦ه–١٩٨٦م، بدون مكان النشر.

٥٥) فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد زين الدين المعبري المليباري الهندي، دار بن حزم، ط ١، بدون التاريخ، ومكان النشر.

٥٦) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا أبو يحيى زين الدين الأنصاري، السنيكي، دار الفكر، بدون الطبعة، ت:١٤١٤هـ/١٩٩٤م، بدون مكان النشر.

٥٧) فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل، دار الفكر ، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.

٥٨) فقه العبادات على المذهب المالكي، الحاجّة كوكب عبيد، مطبعة الإنشاء، ط ١، ت: ١٤٠٦ هـ – ١٩٨٦ م، دمشق – سوريا.

٥٩) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي، دار الفكر، بدون الطبعة، ت: ١٤١٥هـ – ١٩٩٥م، بدون مكان النشر.

٦٠) القتل الرحيم بين الإباحة والتجريم، مجلة المفكر، العدد السادس، عتيقة بلجبل، بدون الطبعة، والتاريخ، الجزائر.

٦١) القوانين الفقهية، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي أبو القاسم، الكلبي الغرناطي، بدون الناشر، والطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.

٦٢) الكافي في فقه الإمام أحمد، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة أبو محمد موفق الدين الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، دار الكتب العلمية، بدون الطبعة، ت: ١٤١٤ هـ –١٩٩٤ م، بدون مكان النشر.

٦٣) الكافي في فقه أهل المدينة، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم أبو عمر النمري القرطبي، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، ط٢، ت: ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م، الرياض– المملكة العربية السعودية.

٦٤) كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط١، ت: ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٣ م، بدون مكان النشر.

٦٥) كنز الدقائق، عبد الله بن أحمد بن محمود أبو البركات حافظ الدين النسفي، تحقيق: سائد بكداش، دار البشائر الإسلامية، ط١، ت: ١٤٣٢هـ – ٢٠١١م، بدون مكان النشر.

٦٦) لسان الحكام في معرفة الأحكام، أحمد بن محمد بن محمد، أبو الوليد، لسان الدين ابن الشِّحْنَة الثقفي الحلبي، البابي الحلبي، ط٢، ت: ١٣٩٣ ه– ١٩٧٣م، القاهرة–مصر.

٦٧) المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين، دار الكتب العلمية، ط١، ت: ١٤١٨ هـ –١٩٩٧م، بيروت – لبنان.

٦٨) المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة، بدون الطبعة، ت: ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م، بيروت.

٦٩) مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية أبو العباس تقي الدين الحراني، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد، بدون الطبعة، ت:١٤١٦هـ/١٩٩٥م المدينة النبوية-المملكة العربية السعودية.

٧٠) المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))، يحيى بن شرف أبو زكريا محيي الدين النووي، دار الفكر، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.

٧١) المحلى بالآثار، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الأندلسي القرطبي الظاهري، دار الفكر، بدون الطبعة، والتاريخ، بيروت.

٧٢) المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة -رضي الله عنه-، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م، بيروت - لبنان.

٧٣) مختصر العلامة خليل، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري، تحقيق: أحمد جاد، دار الحديث، ط.١، ت: ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م، القاهرة - مصر.

٧٤) المدخل، محمد بن محمد بن محمد أبو عبد الله المالكي الشهير بابن الحاج، دار التراث، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.

٧٥) المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، دار الكتب العلمية، ط١، ت: ١٤١٥هـ -١٩٩٤م، بدون مكان النشر.

٧٦) المطلع على ألفاظ المقنع، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل أبو عبد الله، شمس الدين، البعلي، تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، مكتبة السوادي، ط١، ت. ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣ م، بدون مكان النشر.

٧٧) المطلع على دقائق زاد المستقنع، عبد الكريم بن محمد اللاحم، دار كنوز إشبيليا، ط ١، ت: ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م، الرياض - المملكة العربية السعودية.

٧٨) معالم القربة في طلب الحسبة، محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخوة، ضياء الدين، القرشي، دار الفنون «كمبردج»، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.

٧٩) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية، ط١، ت: ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م، بدون مكان النشر.

٨٠) المغني لابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة أبو محمد موفق الدين الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.

٨١) المقدمات الممهدات، محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد القرطبي، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ط ١، ت: ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م، بيروت - لبنان.

٨٢) منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي، ، دار الفكر، بدون الطبعة، ت: ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م، بيروت.

٨٣) منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين أبو محمد الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى، تحقيق: أحمد عبد الرزاق الكبيسي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط ١، ت: ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م، قطر.

٨٤) منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، يحيى بن شرف أبو زكريا محيي الدين النووي، تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، ط١، ت:١٤٢٥هـ/٢٠٠٥ م، بدون مكان النشر.

٨٥) المهذب في فقه الإمام الشافعي، إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الشيرازي، دار الكتب العلمية، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.

٨٦) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله شمس الدين الطرابلسي المغربي، الرُعيني المالكي المعروف بالحطاب، دار الفكر، ط٣، ت: ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، بدون مكان النشر.

٨٧) الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، دارالسلاسل، ط٢، بدون التاريخ، الكويت.

٨٨) النجم الوهاج في شرح المنهاج، محمد بن موسى بن عيسى بن علي أبو البقاء كمال الدين، الدَّميري الشافعي، تحقيق: لجنة علمية، دار المنهاج، ط ١، ت: ١٤٢٥ ه - ٢٠٠٤ م، جدة.

٨٩) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج محمد شمس الدين بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار الفكر، بدون الطبعة، ت: ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م، بيروت.

٩٠) نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد أبو المعالي ركن الدين ، الجويني، ، الملقب بإمام الحرمين، تحقيق: عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، ط١، ت: ١٤٢٨ ه ـــ ٢٠٠٧ م، بدون مكان النشر.

٩١) الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل أبو الحسن برهان الدين، الفرغاني المرغيناني، تحقيق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي، بدون الطبعة، والتاريخ، بيروت – لبنان.

٩٢) الوسيط في المذهب، محمد بن محمد أبو حامد الغزالي الطوسي، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم , محمد محمد تامر، دار السلام، ط١، ت: ١٤١٧ه، القاهرة.

كتب القانون

١) أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، مكتبة الصحابة، ط ٢، ت: ١٤١٥ هـ – ١٩٩٤ م، جدة – المملكة العربية السعودية.

٢) أساسيات علم النفس الجنائي ونظرياته، صالح حسن أحمد الداهري، درا الحامد، ط ١، ت: ٢٠١١، عمان – الأردن.

٣) أسباب الإباحة في القانون الدولي الجنائي، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون العام، إعداد الطالبة: مزيان راضية، جامعة قسنطينة، بدون الطبعة، ت: ٢٠٠٦م، الجزائر.

٤) التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، دار الكاتب العربي، بيروت، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.

٥) الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، حسن علي الشاذلي، دار الكتاب الجامعي، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.

٦) الدفاع الشرعي الخاص (دفع الصائل)، مسفر رزق الله محمد الزحامي، بدون الناشر، والطبعة، ت:١٤١٦ه–١٩٩٦م، بدون مكان النشر.

٧) الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون، منصور محمد منصور الحفناوي، مطبعة الأمانة، ط/١، ت: ١٤٠٦ هـ– ١٩٨٦ م، بدون مكان النشر.

٨) شرح قانون الجرائم والعقوبات، القسم العام، على حسن الشرفي، دار الثقافة، بدون الطبعة، والتاريخ، عمان.

٩) شرح قانون العقوبات الأردني، الجرائم الواقعة على الإنسان، كامل السعيد، مكتبة دار الثقافة، ط٢، ت:١٩٩١م، عمان – الأردن.

١٠) شرح قانون العقوبات اليمني، القسم العام، حسني الجنيدي، بدون الطبعة، ت١٤١١ه-١٩٩٠ م، بدون مكان النشر.

١١) شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، القسم الثاني، فتوح عبد الله الشاذلي، دار المطبوعات الجامعية، بدون الطبعة، ت:١٩٩٤م، بدون مكان النشر.

١٢) شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جاك يوسف الحكيم، بدون الناشر والطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.

١٣) شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ماهر عبد شويش الدرة، المكتبة القانونية، ط٢، بدون التاريخ، بغداد-العراق.

١٤) شرح قانون العقوبات، القسم العام، أحمد عبد العزيز الألفي، بدون الناشر، والطبعة، ت: ١٩٨٥م، بدون مكان النشر.

١٥) قانون الأحوال الشخصية الصومالي، لجمهورية الصومالي الديمقراطية، بدون الناشر، والطبعة، الصادر في ١١ يناير ١٩٧٥م، بدون مكان النشر.

١٦) قانون العقوبات الصومالي، لجمهورية الصومالي الديمقراطية، مؤسسة الحلبي، الصادر: ١٩٦٢م، بدون الطبعة، القاهرة – مصر.

١٧) قانون العقوبات، القسم العام، عبود السراج، دار المستقبل، بدون الطبعة، ت: ١٤٠١-١٤٠٣ه، ١٩٨٢-١٩٩١م، بدون مكان النشر.

١٨) القتل بدافع الشفقة، بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، تخصص القانون الخاص الشامل، الطلبة: سبايعي علي، وصايت فريد، جامعة عبد الرحمن ميرة، وبدون الطبعة، السنة الجامعية: ٢٠١٢ – ٢٠١٣م، بجاية – الجزائر.

١٩) المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي، القانون الجزائري نموذجا، إعداد أمينة زواوي، إشراف الدكتورة: دهينة نصـ□ـة، جامعة ا□زائر، بدون الطبعة، ت: ١٩٩٦م، الخروبة- الجزائر.

٢٠) المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، أحمد الأشهب، دار الكتب الوطنية، ط/١، ت:١٤٠٤ه، بنغازي- ليبيا.

٢١) النظرية العامة للقصد الجنائي، محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية، بدون الطبعة، ت: ١٩٩٨م، القاهرة – مصر.

٢٢) نظرية الغلط في قانون العقوبات المقارن، محمد خصر السبعاوي، الركز القومي للإصدرات القانونية، ط ١، ت: ٢٠١٣م، بدون مكان النشر.

كتب اللغة:

١) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي، تحقيق: يحيى حسن مراد، دار الكتب العلمية، ، بدون الطبعة، ت: ١٤٢٤ه- ٢٠٠٤م، بدون مكان النشر.

٢) تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق أبو الفيض، الحسيني، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.

٣) التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية، ط١، ت:١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، بدون مكان النشر.

٤) التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، دار الكتب العلمية، ط١، ت:١٤٠٣ه -١٩٨٣م، بيروت - لبنان.

٥) التَّلخيص في مَعرفَةِ أسمَاءِ الأشياء، الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران أبو هلال العسكري، تحقيق: عزة حسن، دار طلاس، ط٣، ت:١٩٩٦ م، دمشق.

٦) جمهرة اللغة، محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر الأزدي، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، ط١، ت:١٩٨٧م بيروت.

٧) دستور العلماء، عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، دار الكتب العلمية، ط/١، ت: ١٤٢١ه - ٢٠٠٠م، بيروت - لبنان.

٨) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد أبو نصر الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، ط ٤، ت: ١٤٠٧ هـ -١٩٨٧ م، بيروت-لبنان.

٩) القاموس المحيط، محمد بن يعقوب أبو طاهر مجد الدين الفيروزآبادى، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة، ط٨، ت: ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، بيروت - لبنان.

١٠) كتاب العين، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم أبو عبد الرحمن الفراهيدي البصري، تحقيق: مهدي المخزومي، و إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.

١١) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى أبو البقاء الحسيني القريمي الحنفي، الكفوي، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بدون الطبعة، والتاريخ، بيروت.

١٢) لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى، ط٣، ت: ١٤١٤ ه، دار صادر – بيروت

١٣) المحكم والمحيط الأعظم، علي بن إسماعيل بن سيده أبو الحسن المرسي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط١، ت: ١٤٢١ هـ – ٢٠٠٠ م، بيروت.

١٤) محيط المحيط قاموس عصري مطول للغة العربية، المعلم بطرس البستاني، تحقيق: محمد عثمان، دار الكتب، بدن الطبعة، والتاريخ، بيروت – لبنان.

١٥) مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر أبو عبد الله زين الدين الحنفي الرازي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ، المكتبة العصرية، ط/٥، ت: ١٤٢٠ه / ١٩٩٩م، بيروت.

١٦) المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، ط١، ت: ١٤١٨ ه ١٩٩٨ م، بيروت.

١٧) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي أبو العباس، الفيومي ثم الحموي، المكتبة العلمية، بدون الطبعة، والتاريخ، بيروت.

١٨) معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر، عالم الكتب، ط/١، ت:١٤٢٩ هـ – ٢٠٠٨ م، بدون مكان النشر.

١٩) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة،(إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)، دار الدعوة، بدون الطبعة، والتاريخ، ومكان النشر.

٢٠) معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبي، دار النفائس، ط/٢، ت:١٤٠٨ه–١٩٨٨م، بدون مكان النشر.

٢١) معجم متن اللغة، أحمد رضا، دار مكتبة الحياة، بدون الطبعة، ت: ١٣٧٧ هـ – ١٩٥٨ م، بيروت.

٢٢) معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين، القزويني الرازي، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بدون الطبعة، ت: ١٣٩٩هـ –١٩٧٩م، بدون مكان النشر.

خامسا: فهرس الموضوعات

الموضوع:.....الصفحة
البسملة .....أ
تقرير لجنة المناقشة وتوقيعات أعضائها .....ب
استهلال ..... **Error! Bookmark not defined.**
إهـــــــداء ..... د
شكر وتقدير..... ه
إقـــــــرار ..... و
مستخلص .....ز
ABSTRACT..... ح
مـقـدمـــة ١
أساسيات البحث:.....٢
سبب اختيار الموضوع: ٢
أهمية البحث: ٢
أهداف البحث: ٣
مشكلة البحث:.....٣
أسئلة البحث:.....٣
فروض البحث. ٤
حدود البحث:.....٤
الدراسات السابقة: ٤
منهجية البحث:.....٧
مصطلحات البحث:.....٧
الصعوبات: ٧
هيكل البحث:.....٨

الفصل الأول: مفهوم المسئولية الجنائية وتاريخها وشروطها في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي: ١٣
المبحث الأول: مفهوم المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي ١٤
المطلب الأول: تعريف المسئولية الجنائية في اللغة. ١٤
الفرع الأول: تعريف المسئولية في اللغة: ١٤
الفرع الثاني: تعريف الجنائية في اللغة: ١٧
المطلب الثاني: تعريف المسئولية الجنائية في الاصطلاح..... ١٧
الفرع الأول: تعريف المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي..... ١٧
الفرع الثاني: تعريف المسئولية الحنائية في القانون ١٩
المبحث الثاني: تاريخ وتطور المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون ٢٠
المطلب الأول: تاريخ وتطور المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي ٢٠
المطلب الثاني: تاريخ وتطور المسئولية الجنائية في القانون..... ٢٣
المبحث الثالث: شروط المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي: ٢٥
المطلب الأول: الإدراك والتمييز في الفقه الإسلامي ٢٥
الفرع الأول: الإدراك ٢٥
الفرع الثاني: التمييز: ٢٧
المطلب الثاني: الإدراك والتمييز في القانون..... ٣٠
المطلب الثالث: الاختيار في الفقه الإسلامي ٣٢
المطلب الرابع: الاختيار في القانون..... ٣٢

الفصل الثاني: محل المسئولية الجنائية وسببها وصور قصدها ودرجاتها في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي..... ٣٦
المبحث الأول: محل المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي ٣٧
المطلب الأول: الإنسان محلّ المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي. ٣٧
المطلب الثاني: الإنسان محلّ المسئولية الجنائية في القانون ٣٩
المطلب الثالث :المسئولية الجنائية شخصية في الفقه الإسلامي..... ٤٠
المطلب الرابع :المسئولية الجنائية شخصية في القانون. ٤٣
المبحث الثاني: سبب المسئولية الجنائية وصور قصدها في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي: .. ٤٦
المطلب الأول: سبب المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي..... ٤٦
المطلب الثاني: سبب المسئولية الجنائية في القانون ٤٧
المطلب الثالث: صور قصد المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي ٤٩
المطلب الرابع: صور قصد المسئولية الجنائية في القانون..... ٥١
المبحث الثالث: درجات المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي: ٥٣
المطلب الأول: درجة مسئولية العمد في الفقه الإسلامي. ٥٤
المطلب الثاني: درجة مسئولية العمد في القانون..... ٥٨
المطلب الثالث: درجة مسئولية شبه العمد في الفقه الإسلامي..... ٥٩
المطلب الرابع: درجة مسئولية شبه العمد (الضرب المفضي إلى الموت) في القانون. ... ٦٤
المطلب الخامس: درجة مسئولية الخطأ في الفقه الإسلامي..... ٦٧
المطلب السادس: درجة مسئولية الخطأ في القانون. ٦٩

الفصل الثالث: موانع المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي: ٧٢
المبحث الأول: موانع الإدراك في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي ٧٣
المطلب الأول: الصغر في الفقه الإسلامي. ٧٣
المطلب الثاني: الصغر في القانون ٧٦
المطلب الثالث: الجنون وما يلحق به في الفقه الإسلامي ٧٧
المطلب الرابع: الجنون وما يلحق به في القانون. ٨٠
المبحث الثاني: موانع الاختيار في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي: ٨٣
المطلب الأول: الإكراه في الفقه الإسلامي ٨٣
المطلب الثاني: الإكراه في القانون ٨٦
المطلب الثالث: الضرورة في الفقه الإسلامي. ٨٩
المطلب الرابع: الضرورة في القانون ٩١
المبحث الثالث: الرضا على المسئولية الجناية والجهل عنها في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي: . ٩٥
المطلب الأول: رضا المجنى عليه على القتل والجرح في الفقه الإسلامي ٩٥
المطلب الثاني: رضا المجنى عليه على القتل والجرح في القانون. ١٠٠
المطلب الثالث: الجهل بتحريم الفعل والحكم وأقسامه في الفقه الإسلامي. ١٠٢
المطلب الرابع: الجهل بتحريم الفعل والحكم وأقسامه في القانون ١٠٥
الفصل الرابع: الأسباب الإباحة في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي ١٠٩
المبحث الأول: استعمال حق التأديب في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي ١١٠
المطلب الأول: حق تأديب الزوجة في الفقه الإسلامي ١١٠
الفرع الأول:حكم تأديب الزوجة ومشروعيته وحكمته ١١٠
الفرع الثاني: مراتب تأديب الزوجة ١١٤

المطلب الثاني: حق تأديب الزوجة في القانون..... ١١٨
الفرع الأول: حكم تأديب الزوجة وحكمته ١١٨
الفرع الثاني: شروط استعمال حق تأديب الزوجة ١١٩
المطلب الثالث: حق تأديب الصغار في الفقه الإسلامي. ١٢٠
الفرع الأول: مشروعية تأديب الصغار وعلته..... ١٢٠
الفرع الثاني: شروط تأديب الصغار بالضرب ١٢١
المطلب الرابع: حق تأديب الصغار في القانون..... ١٢٢
الفرع الأول: حكم تأديب الصغار في القانون، وعلته ١٢٢
الفرع الثاني: شروط تأديب الصغار:..... ١٢٣
المبحث الثاني: استعمال حق الأعمال الطبية في الفقه الإسلامي والقانون الصومالي..... ١٢٥
المطلب الأول: ممارسة حق الأعمال الطبية في الفقه الإسلامي..... ١٢٥
الفرع الأول: الأعمال الطبية ومشروعية التداوي ١٢٥
الفرع الثاني: حكم ممارسة الأعمال الطبية ١٢٧
المطلب الثاني: ممارسة حق الأعمال الطبية في القانون ١٢٨
الفرع الأول: حكم ممارسة الأعمال الطبية ١٢٨
الفرع الثاني: الأساس القانوني لإباحة الأعمال الطبية: ١٢٩
المطلب الثالث: شروط ممارسة حق الأعمال الطبية في الفقه الإسلامي ١٣٠
المطلب الرابع: شروط ممارسة حق الأعمال الطبية في القانون ١٣٣
المبحث الثالث: الدفاع الشرعي الخاص (دفع الصائل) وشروطه..... ١٣٦
المطلب الأول: معنى الدفاع الشرعي الخاص(دفع الصائل) في الفقه الإسلامي. ١٣٦
المطلب الثاني: معنى الدفاع الشرعي الخاص في القانون ١٣٨
المطلب الثالث: شروط الدفاع الشرعي الخاص(دفع الصائل)، في الفقه الإسلامي ١٤٠
المطلب الرابع: شروط الدفاع الشرعي الخاص في القانون..... ١٤١

الخاتمة ١٤٤
أولا: النتائج ١٤٤
ثانيا: التوصيات: ١٤٥
أولا: فهرس الأيات: ١٤٧
ثانيا: فهرس الأحاديث ١٥٠
ثالثا: فهرس الأعلام ١٥٤
رابعا: قائمة المصادر والمراجع ١٥٥
خامسا: فهرس الموضوعات ١٧٥